



El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado



Diana Beatriz González Carvallo
(Coordinadora)



Suprema Corte
de Justicia de la Nación



Centro de Estudios
Constitucionales
SCJN

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS RESPONSABILIDADES DE CUIDADO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

*Catedrática de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Valencia*

ANA CAÑIZARES LASO

*Catedrática de Derecho Civil
de la Universidad de Málaga*

JORGE A. CERDIO HERRÁN

*Catedrático de Teoría y Filosofía del Derecho
Instituto Tecnológico Autónomo de México*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

*Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
y miembro de El Colegio Nacional*

MARÍA LUISA CUERDA ARNAU

*Catedrática de Derecho Penal
de la Universidad Jaume I de Castellón*

MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO

*Catedrática de Derecho Civil
de la Pontificia Universidad Católica de Chile*

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

*Juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM*

OWEN FISS

*Catedrático emérito de Teoría del Derecho
de la Universidad de Yale (EEUU)*

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC

*Catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Valencia*

LUIS LÓPEZ GUERRA

*Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Carlos III de Madrid*

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

*Catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de Sevilla*

MARTA LORENTE SARIÑENA

*Catedrática de Historia del Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid*

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

*Catedrático de Filosofía del Derecho
y Filosofía Política de la Universidad de Valencia*

VÍCTOR MORENO CATENA

*Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad Carlos III de Madrid*

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

*Catedrático de Derecho Penal
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla*

ANGELIKA NUSSBERGER

*Catedrática de Derecho Constitucional
e Internacional en la Universidad de Colonia
(Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia*

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

*Catedrático de Derecho Internacional
de la Universidad del Rosario (Colombia)
y Presidente del Instituto Ibero-Americano
de La Haya (Holanda)*

LUCIANO PAREJO ALFONSO

*Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Carlos III de Madrid*

CONSUELO RAMÓN CHORNET

*Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Valencia*

TOMÁS SALA FRANCO

*Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia*

IGNACIO SANCHO GARGALLO

*Magistrado de la Sala Primera (Civil)
del Tribunal Supremo de España*

ELISA SPECKMAN GUERRA

*Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM*

RUTH ZIMMERLING

*Catedrática de Ciencia Política
de la Universidad de Mainz (Alemania)*

Fueron miembros de este Comité:

Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS RESPONSABILIDADES DE CUIDADO

Diana Beatriz González Carvallo
Coordinadora



Suprema Corte
de Justicia de la Nación



Centro de Estudios
Constitucionales
SCJN

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2024

Copyright © 2024

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

© VV.AA.

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Avenida José María Pino Suárez núm. 2
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06060, Ciudad de México, México.

El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta obra estuvo a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La edición y el diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

© TIRANT LO BLANCH
DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502

Hipódromo, Cuauhtémoc

06100 Ciudad de México

Telf.: +52 1 55 65502317

infomex@tirant.com

www.tirant.com/mex/

www.tirant.es

ISBN: 978-84-1071-550-9

MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministra Norma Lucía Piña Hernández

Presidenta

Primera Sala

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

Presidente

Ministra Ana Margarita Ríos Farjat

Ministra Loretta Ortiz Ahlf

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Segunda Sala

Ministro Alberto Pérez Dayán

Presidente

Ministra Lenia Batres Guadarrama

Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Ministro Javier Laynez Potisek

Ministro Luis María Aguilar Morales

**Centro de Estudios Constitucionales
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Alejandra Martínez Verástegui

Directora General

Índice

Introducción	XI
Diana Beatriz González Carvallo	
Regresando al futuro. La interdependencia del derecho a la seguridad social y el derecho al cuidado	1
Laura C. Pautassi	
El derecho a la seguridad social y el derecho al cuidado: de la relación paradójica a la interdependencia de derechos	37
Lourdes Jiménez Brito	
Cuestiones de género en el derecho del trabajo y la seguridad social...	79
Patricia A. Rossi	
La maternidad frente a la seguridad social	103
Valeria González Ruiz	
La prestación de guarderías y las responsabilidades de cuidado en el contexto de la seguridad social.....	133
Silvia López Estrada	

Una perspectiva de la pensión de viudez a la luz del concubinato. Reconocimiento y protección en el derecho a la seguridad social	183
Lizbeth Berenice Montealegre Ramírez	
Gema Patricia Cortés Matus	
 El derecho a la seguridad social de las trabajadoras domésticas remuneradas	 207
Flavia Marco Navarro	
 ¿Tragedias privadas? El derecho familiar como seguro social.....	 253
Anne L. Alstott	
 De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina	 307
Magdalena Sepúlveda	

Introducción

Diana Beatriz González Carvallo*

* Investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sus líneas de investigación actuales son la relación entre el derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado y el derecho al trabajo en el contexto de la reforma laboral.

El derecho a la seguridad social tiene un estatus paradójico. Aunque los tratados internacionales de derechos humanos, las decisiones de tribunales regionales en la materia y buena parte de las constituciones latinoamericanas lo reconocen como un derecho fundamental autónomo, su desarrollo legislativo y la opinión común, jurídica o no, van en contravía de ese carácter. La línea de investigación del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia sobre el derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado se deriva, precisamente, de la necesidad de dilucidar en qué consiste ese estatus paradójico del derecho y de qué manera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de cierre en México ha contribuido a su configuración actual.

Esta línea de investigación, entonces, es producto de la reconstrucción de la jurisprudencias de la Suprema Corte en materia de seguridad social y, por la manera en que está institucionalizado el derecho, también de las decisiones del Tribunal sobre derechos del trabajo y familia.¹ Entre los hallazgos de este ejercicio hay dos cosas que, en buena medida, fueron el germen de este libro: aunque de manera casi unánime los instrumentos de derechos humanos reconocen el carácter universal y fundamental del derecho a la

¹ Los cuadernos de jurisprudencia se pueden consultar en: «<https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cuadernos-jurisprudencia>».

seguridad social, las normas e instituciones nacionales distinguen entre la seguridad social como derecho de los trabajadores y sus beneficiarios y las prestaciones no contributivas a las personas sin vinculación laboral formal. Éstas últimas de benefician de programas sociales, pero no serían titulares del derecho a la seguridad social.

La segunda cuestión es que el litigio en asuntos laborales y de seguridad social está claramente dividido en términos de género, según el objeto de las demandas. Es decir, nos dimos cuenta de que las disputas en materia de sustituciones pensionales por causa de muerte, guarderías y estabilidad laboral en el embarazo las demandantes eran mujeres. Pero, en los litigios sobre pensiones de vejez e invalidez, riesgos de trabajo y propiamente laborales los actores son mayoritariamente hombres.

Para entender, entonces, la manera en la que están relacionados estos dos hallazgos —el reconocimiento nacional del derecho a la seguridad social sólo a los trabajadores y a sus beneficiarios y las características de género en el litigio sobre la materia— es necesario incorporar en el análisis la categoría “cuidado”. Me explico, la hipótesis inicial para dar cuenta de estas características es que para entender cómo y por qué se distribuyen los riesgos sociales es indispensable revisar cómo se asignan las responsabilidades de cuidado en el entorno familiar. Y, dado que el derecho fundamental a la seguridad social sólo se reconoce respecto de un grupo minoritario de empleados y sus familiares, es preciso revisar el impacto de los mercados laborales en su titularidad.

Los riesgos sociales que debido a sus efectos eventualmente ruinosos están cubiertos por los regímenes de seguridad social son, entre otros, vejez, invalidez, muerte, riesgos laborales, maternidad y guarderías, aunque estos último no son exactamente riesgos. Debido a que las instituciones de aseguramiento social también son prestadoras de servicios de salud, el acceso a ese derecho para esta población está vinculado de manera necesaria con la titularidad del derecho a la seguridad social. Tenemos, entonces, un panorama complejo en este caso: aunque es derecho humano universal, sólo a algunas

personas se les reconoce su titularidad. Además de depender de vínculos laborales formales que pueden ser frágiles, muchos individuos acceden a esas prestaciones gracias a que clasifican como familia beneficiaria. Por eso, la posibilidad de perder el derecho es permanente: si se pierde el trabajo que garantiza aseguramiento social, si se es familiar beneficiario de un trabajador formal que deja de serlo y si se pierde el carácter de familiar del asegurado.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México la población económicamente activa (PEA) representa 60.3% de la población (60.2 millones de personas).² De esa PEA ocupada, alrededor de 35,000,000 son hombres y 24,000,000 son mujeres. El Instituto también estableció que, durante 2022, el valor del trabajo de cuidados no remunerado fue de 7,156,986 billones de peso y representó 24.3% del producto interno bruto (PIB).³

Pero ¿qué tienen que ver estas cifras con el derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado? Estos datos de población ocupada reportada por el INEGI son muy importantes, primero, porque muestran que hay alrededor de 11,000,000 más de hombres ocupados que de mujeres. Y esa configuración de género de los mercados laborales muy probablemente se traduce en la distribución por género de aseguramiento social directo, no como beneficiario derivado. También sabemos que las mujeres dedicaron alrededor de 2,207 horas al año a trabajos de cuidado no remunerados y los hombres 802,⁴ y esa diferencia de horas se refleja en el tipo de participación femenina en el mercado laboral y sus estatus de aseguramiento social.

En su libro *Carrera y familia*, Claudia Goldin⁵ estudia las brechas de género en términos de avance profesional de mujeres universitarias en Estados

² Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada en enero de 2023. Disponible en «www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen/enoen2023_03.pdf».

³ Datos de trabajo no remunerado en los hogares en México. Disponible en «<https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/>».

⁴ *Idem*.

⁵ Goldin, Claudia, *Career and family: women's century-long journey toward equity*, Princeton University Press, 2021.

Unidos durante el siglo pasado y lo que va de este. Una de las conclusiones que resalta respecto de este grupo es que la razón por la cual no ha ascendido profesionalmente como sus pares hombres es que la distribución de responsabilidades de cuidado sigue siendo inequitativa. Esto es, aunque este grupo relativamente privilegiado de mujeres ha logrado avanzar en términos profesionales y ha modificado radicalmente la integración de los mercados laborales, esos cambios no se han dado al mismo ritmo ni en la misma medida en la distribución de tareas del hogar. Las encuestas de uso de tiempo y otros datos estadísticos han permitido corroborar que las mujeres siguen dedicándole un número mucho mayor de horas a las labores de cuidado doméstico y eso impacta de manera directa en su posibilidad de dedicarle un número mayor de horas a su profesión.

En México, la encuesta de uso de tiempo realizada en 2019⁶ arrojó que mientras las mujeres dedican un promedio de 30.8 horas a trabajos de cuidado no remunerado, los hombres emplean 11.6 horas semanales. Esto quiere decir que la proporción de mujeres que se dedica al trabajo en el hogar no remunerado y la cantidad de horas que, en general, emplean en tareas de cuidado puede impactar de manera directa no sólo su posibilidad de estar ocupada con remuneración, sino que también condiciona el tipo de empleo que se logra. Y dado que el estatus laboral es la puerta de acceso al derecho humano a la seguridad social, al menos en el modelo contributivo, es posible que debido a las responsabilidades de cuidado y la cantidad de tiempo que las mujeres les dedican muchas se queden sin cobertura o con una precaria de los riesgos sociales más acuciantes.

Aunque la discusión sobre qué es y cuál es el alcance del derecho humano al cuidado en sus modalidades de derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado es muy importante, en este libro quisimos centrarnos en los impactos de las responsabilidades de cuidado en el acceso a la seguridad social y en la relación que hay entre estos dos derechos. La distribución de obligaciones

⁶ Disponible en www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf».

de cuidado y las consecuencias de desconocerlas ha sido objeto explícito del derecho familiar durante mucho tiempo. En esta obra nos ocupamos de los efectos de esa repartición genérica de las obligaciones de cuidado en la distribución de riesgos sociales. La obra está integrada por nueve artículos que estudian este vínculo.

En el primer texto del libro, Laura C. Pautassi explora la interdependencia entre los derechos a la seguridad social y al cuidado. La profesora Pautassi, una de las académicas más reconocidas y citadas en temas del derecho al cuidado, reflexiona sobre la inquietud por el futuro y el aseguramiento contra los riesgos como preocupaciones persistentes de la humanidad. La autora recuerda que los sistemas de aseguramiento social surgieron en el siglo XIX como respuesta colectiva a esa preocupación. Ante la actualización de la contingencia cubierta por la seguridad social, vejez, invalidez, embarazo, entre otras, los modelos entregan prestaciones a las personas que cumplen los requisitos establecidos por la ley para acceder a los beneficios, como titulares directos de la prestación o como familiares beneficiarios. De esa manera, los Estados le dan una solución colectiva que redistribuye los costos de una situación potencialmente ruinosa para los sujetos y las familias.

Pautassi recuerda que este esquema de cubrimiento de contingencias, al menos en buena parte de Latinoamérica, protege a los trabajadores que tienen empleo formal y a quienes califican como familia asegurable. Este sistema solidario en relación con el ingreso y con los deberes intergeneracionales se sostiene en los aportes que realizan trabajadores, empleadores y Estado. La manera, entonces, en la que se entiende el derecho a la seguridad social y en la que las instituciones lo garantizan apunta al cubrimiento de contingencias futuras que pueden tener consecuencias ruinosas.

Esta preocupación legítima por el futuro, asegura la autora, ha provocado el descuido de la manera en que se cubren las necesidades básicas en el presente. Las tareas que se realizan en los hogares y que procuran la sostenibilidad de la vida —lo que se conoce como trabajo reproductivo— han sido realizadas de manera mayoritaria por mujeres. El rasgo de género del trabajo reproduc-

tivo ha provocado una menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado y, en consecuencia, un acceso más precario al derecho a la seguridad social, precisamente, porque está condicionado a si se tiene una relación laboral formal.

Este capítulo desarrolla con enfoque de género las particularidades de los derechos humanos al cuidado y a la seguridad social, sus fuentes normativas y su carácter interdependiente. Resalta, también, la necesidad de adelantar una agenda que permita garantizar ambos derechos y llegar a acuerdos redistributivos más equitativos en términos de ingresos y de responsabilidades de cuidados.

En el segundo texto, Lourdes Jiménez Brito trata el tema del tránsito de una relación paradójica a una de interdependencia entre los derechos humanos a la seguridad social y al cuidado. Jiménez señala que, a diferencia del reconocimiento generalizado del derecho a la seguridad social como la garantía de acceso al cubrimiento de ciertos riesgos sociales, el derecho al cuidado, en cuanto trabajo, es mucho más reciente. Reconstruye los caminos diferenciados, pero ligados de manera estrecha, de estos derechos. Para esto presenta la evolución histórica de estas titulaciones y su incorporación al derecho mexicano: tanto de la seguridad social como del cuidado en cuanto trabajo.

Jiménez enfatiza, como también lo hace Pautassi, que es necesario posicionar la agenda de cuidados en el contexto de las decisiones públicas a través de, entre otras cosas, la ampliación y socialización del conocimiento sobre estos temas. Una de las maneras de avanzar en esta tarea es, a juicio de la autora, facilitando la comprensión de los aportes económicos y materiales de las tareas de cuidado y proteger a las personas que los realizan mediante, entre otras cosas, la titularidad del derecho a la seguridad social.

Por su parte, Patricia A. Rossi resalta algunas de las características de los mercados laborales y del derecho a la seguridad social en términos de género: el mayor desempleo femenino, la mayor segregación ocupacional, la brecha salarial y la desigualdad en remuneración. Señala que es necesario

enfatar cómo estas diferencias no se derivan de características de género naturales, sino de estereotipos y patrones culturales que ubican a las mujeres en situaciones estructurales de desventaja.

A partir de la exposición de las fuentes normativas de estos derechos, presenta la manera en la que el sistema de justicia argentino ha respondido a los desequilibrios de género, en especial en materia pensional, y cuáles son las tareas que siguen pendientes. Argumenta que cuando se trata de este tipo de desigualdades o no basta con interpretar el principio de igualdad como no discriminación, sino que debe hacerse en términos de desigualdad estructural.

Es su texto, Valeria González Ruiz afirma que en México se han hecho esfuerzos para avanzar en la protección del embarazo y la maternidad, en especial mediante las reformas de 2019 a Ley Federal del Trabajo. Pero, afirma González, estos esfuerzos han sido insuficientes porque no han estado acompañados por políticas públicas transversales que protejan los derechos en materia de seguridad social de esta población. La autora considera que, aunque uno de los objetivos de este derecho fundamental es procurar el desarrollo digno de las personas, debido a que no toma en cuenta las particularidades de sus titulares, termina por discriminarlas. Eso es, precisamente, lo que, a su juicio, ocurre en el caso del embarazo y la maternidad.

González se propone, en consecuencia, evidenciar que la regulación de la seguridad social invisibiliza los trabajos de cuidado, que la maternidad es un bien social que amerita una protección reforzada y que la paternidad responsable es básica para alcanzar las metas de igualdad de género. La autora enfatiza algunos de los asuntos más urgentes en este tema: la falta de reconocimiento de las labores de cuidado en términos de trabajo; los requisitos de cotización para acceder a la seguridad social; la situación precaria de las personas empleadas por honorarios o con contratos temporales, en términos generales, y la insuficiencia de los permisos de paternidad como están legislados en este momento. También resalta que las consecuencias de estas faltas de reconocimiento son que muchas personas embarazadas o con hijos no tienen cobertura en seguridad social, están expuestas a la discrimi-

nación laboral y tienen que enfrentar desde una posición de vulnerabilidad las inequidades de género en el mercado laboral. Finalmente, reitera que, debido a este acceso precario a la seguridad social, muchas mujeres terminan absorbiendo los costos de responsabilidades de cuidado que deberían estar distribuidos de otra manera.

Silvia López Estrada desarrolla el tema de la prestación de guarderías y las responsabilidades de cuidado en la seguridad social. Estrada recuerda cómo la normativa internacional en materia de derechos humanos le reconoce este estatus a la seguridad social y al cuidado. Es ese sentido, en su texto desarrolla la cuestión del derecho humano al cuidado de la primera infancia tal y como está dispuesto en la seguridad social.

A partir de la revisión de la literatura especializada, al igual que de la realización de entrevistas a mujeres beneficiarias de la prestación de guarderías y a asistentes educativas que trabajaron en estas instituciones, presenta las tendencias actuales en México en punto de esta prestación. Algunos de sus hallazgos son que los servicios de cuidado infantil están fragmentados y segmentados según el vínculo laboral de las personas. También, que hay diferencias importantes en cuanto a la cobertura y calidad de los servicios entre los modelos contributivo y no contributivo de aseguramiento social. Esto implica, a juicio de la autora, que, aunque el Estado se ha comprometido a garantizar los derechos de la infancia, buena parte de la responsabilidad en este tema se transfiere a las familias, precisamente, por esos déficits de cobertura y calidad de las guarderías. Enfatiza que ese traslado de responsabilidad a las familias se da de manera mayoritaria a las mujeres, lo que impacta de negativamente en sus posibilidades de acceder y mantenerse en el mercado laboral, en la distribución del cuidado por género en el hogar y en el desarrollo integral de la infancia. López resalta la necesidad de enfrentar este desafío mediante, entre otras cosas, la creación de un sistema integral de cuidados en el país.

En su texto sobre la pensión de viudez en el concubinato y el derecho a la seguridad social, Berenice Montealegre Ramírez y Gema Cortés Matus revisan algunas de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de México sobre

el punto. Señalan que una revisión histórica de la evolución de los derechos sociales en cuanto derechos humanos permite afirmar que su reconocimiento y protección son cada vez más amplios. Resaltan que esto también permite identificar las áreas en las que hay tareas pendientes, en particular, en la protección de los derechos fundamentales en el trabajo y a la seguridad social. El artículo se enfoca en la adjudicación del máximo tribunal constitucional cuando se trata de pensiones de viudez en el concubinato. Las autoras consideran que este caso permite detectar las intersecciones de estos derechos con los de familia y los efectos de unos respecto de los otros.

Montealegre y Cortés afirman que, precisamente, los cambios en la idea tradicional de familia han impactado la manera en la que el derecho a la seguridad social entiende esa institución. Resaltan que durante los últimos años la Corte ha reinterpretado el régimen de las pensiones por causa de muerte, en particular, las de viudez en el concubinato. Las autoras consideran que ha habido un cambio de paradigma jurisprudencial en esta materia y que este cambio se debe, además de al reconocimiento de diversos tipos de familia, a la aplicación de principio de realidad a cuestiones de seguridad social.

Flavia Marco Navarro estudia la situación del derecho a la seguridad social de un grupo de personas que realiza trabajos de cuidado remunerados y, muy posiblemente, no remunerados. La autora considera que el estudio de la titularidad de este derecho de las trabajadoras del hogar ofrece un campo privilegiado para revisar varias cosas. Entre estas, las fallas en la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y su relación con el desconocimiento del derecho a la igualdad. Es decir, una de las hipótesis del trabajo es que el déficit de protección del derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar se debe a la vulneración de su derecho a la igualdad, formal y material.

Marco Navarro se basa en un estudio comparativo sobre la situación del trabajo del hogar en 19 países de América Latina y llega a la conclusión de que, de manera generalizada, la exclusión masiva de estas trabajadoras de los beneficios de la seguridad social se debe a situaciones de discriminación

directa e indirecta. La autora estudia, en particular, el caso mexicano y los cambios impulsados por la jurisprudencia constitucional para contrarrestar esa discriminación. En específico, revisa la sentencia AD 9/2018, los cambios institucionales y legislativos que provocó y las demandas que quedan por atenderse en este punto.

El texto de Ann Alstott recuerda que el derecho de familia está plagado de tragedias privadas. Los casos suelen enfrentar a un familiar contra otro en la pelea por recursos, muchas veces escasos. En la versión tradicional, esas cuestiones familiares son objeto del derecho privado en tanto se trata de conflictos entre individuos. Alstott considera que esa división entre cuestiones públicas y privadas descansa en una distinción que es, cuando menos, exagerada.

La autora afirma que el derecho de familia no es sólo un mecanismo para resolver las disputas del orden privado. Más que eso, hace parte de un género mucho más amplio de derecho público, el de la seguridad social que distribuye riesgos cuando ocurren ciertas situaciones como la discapacidad, la disolución familiar, etc. La legislación de familia distribuye derechos de ayuda financiera y de cuidado y, en ese sentido, según lo entiende Alstott, la responsabilidad entre individuos es un complemento de los programas públicos de aseguramiento social. Por eso considera que aunque las dos ramas del derecho tienen diferencias y a algunas situaciones le asignan consecuencias diversas, usan categorías normativas que reconocen ciertas relaciones y no otras, que protegen contra ciertos riesgos y que distribuyen riesgos antes de que suceda la contingencia y no necesariamente después de que ocurren los conflictos.

Finalmente, Magdalena Sepúlveda expone en su texto varias aristas de la tensión entre la protección social como política pública y el enfoque de derechos en estos temas. Defiende tanto la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados en la materia como el aporte del enfoque de derechos.

El texto recoge los debates en torno a los conceptos de protección y aseguramiento social y sus efectos sobre la titularidad y disfrute de otros derechos

sociales como la alimentación, la educación y la vivienda. Enfatiza que para el pleno disfrute de este derecho no basta con su reconocimiento constitucional y legal, sino que debe ir acompañado de políticas adecuadas. Entre las condiciones que se deben garantizar están la implementación de marcos institucionales apropiados, la puesta en marcha de estrategias integrales y consistentes de protección social y el respeto del derecho a la igualdad y no discriminación.

Sepúlveda recalca que es necesario que los Estados hagan un esfuerzo mayor para garantizar que las mujeres sean titulares del derecho a la seguridad social en condiciones de igualdad. Por eso, afirma, es preciso que el diseño de los programas de protección social atienda las desigualdades estructurales debido al género. Los programas que implementen el derecho fundamental a la seguridad social deben tener en cuenta que las mujeres tienen una carga mayor de cuidados del hogar, pero sin repetir y reforzar los estereotipos de género. Por eso, un componente fundamental del respeto de este derecho es la ponderación del impacto de los trabajos de cuidado no remunerado en el acceso a múltiples derechos fundamentales por parte de las mujeres, entre estos, el derecho a la seguridad social y del trabajo.

Un punto en el que coinciden todos los artículos que integran este libro es que la pandemia por covid-19, que empezó en marzo de 2020, evidenció algo que ya era más o menos evidente. Las tareas y responsabilidades de cuidado absorben buena parte del tiempo del que disponen las mujeres, que son quienes, en su mayoría, las realizan. Esta distribución estereotipada e inequitativa implica, entre otras cosas, que o bien las mujeres limitan por esa razón su acceso y permanencia en el mercado laboral, tienen jornadas de trabajo remunerado y no remunerado que absorben prácticamente la mayoría de su tiempo o se dedican exclusivamente a tareas de cuidado no remunerado.

Ahora bien, dado que el mecanismo de acceso al derecho a la seguridad social es el trabajo formal, eso supone que muchas mujeres no están protegidas contra contingencias sociales ruinosas porque no cumplen los requisitos

legales. O que un buen número de estas acceden como beneficiarias de un afiliado principal, lo que las deja a merced de si la ley o un funcionario en específico considera que es familia o no.

En suma, los artículos reunidos en este libro resaltan la necesidad de entender las interrelaciones del derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado. Un enfoque de derechos humanos, de género y la claridad sobre cómo incide la distribución del trabajo no remunerado en el hogar en la posibilidad de tener cubiertas contingencias sociales graves y en la brecha laboral de género pueden ser un buen punto de partida. Tal vez de esa manera, y apoyados en los textos que integran este libro, las lecciones que dejó la pandemia en términos de responsabilidades de cuidado se traduzcan en agendas de derechos, políticas públicas y mecanismos de justicia.

**Regresando al futuro.
La interdependencia del derecho
a la seguridad social y el derecho
al cuidado**

Laura C. Pautassi*

* Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Social. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “A. Gioja”, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (www.dspp.com.ar). Socia fundadora y presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

SUMARIO: A. Introducción; B. Seguridad social y cuidado: bases conceptuales; C. La interdependencia en la norma; D. Conclusiones: el futuro regresa; E. Bibliografía.

A. Introducción

La preocupación por el futuro ha atravesado la historia de la humanidad, al igual que los cuidados. El temor por lo inesperado, por las situaciones futuras, eventuales que pueden poner en riesgo el presente ha impulsado, desde el siglo XIX en adelante, gran parte de los esfuerzos sociales e institucionales. De hecho, el concepto de seguridad surge como una respuesta que permite posicionarse ante lo inesperado, que brinda previsión a lo contingente, pero que trasciende la posibilidad de dinámicas resolutivas individuales para abrir paso a soluciones colectivas.

En efecto, la base de legislaciones, sistemas y prestaciones de seguridad social es el concepto de contingencia, que refiere a un acontecimiento o hecho futuro que, en caso de producirse, acarrea consecuencias riesgosas para la persona. Es, por lo tanto, un acontecimiento futuro e incierto —pero con un alto grado de probabilidad de que se produzca— que lleva a la necesidad de proteger a la persona o a un grupo de personas ante dicha eventualidad y darles precisamente seguridad. El eje central es que no se asuma de manera individual sino colectiva.

Por lo tanto, las prestaciones previstas en el sistema de seguridad social se efectivizan una vez configurada la contingencia, y siempre que estén dados los requisitos de acceso, lo cual produce, como efecto, que una persona o las y los integrantes de su familia, o uno y otros, resulten afectados en su nivel de vida, debido a un aumento en el consumo, una disminución o una supresión de los ingresos, o por procesos vitales vinculados al tiempo. Es decir, se busca proteger aquellas situaciones que en caso que no se lo haga van a generar una carencia en la persona o dejarla desprotegida.

Entre los elementos contingentes que se resguardan se encuentra la posibilidad de contraer una enfermedad y, por lo tanto, tener garantizado el acceso a un sistema de salud (contingencias patológicas), la pérdida temporaria o permanente de ingresos monetarios (contingencia socioeconómica) o la afectación del curso de vida y las garantías para personas mayores (contingencia biológica). Es decir, hay mecanismos establecidos que han posibilitado generar un reconocimiento de los riesgos y situaciones a los cuales nos vemos expuestas las personas y sobre la base de una relación laboral remunerada. En efecto, esta seguridad, con respecto al futuro y las posibles situaciones de riesgo, está cubierta en los trabajadores asalariados formales y se extiende a su núcleo familiar. Es decir, lo contingente se protege en función de un resguardo inicial, que es la relación asalariada formal.

Esta importante red de protección se organiza a partir de reconocer que una persona trabajadora remunerada requiere tomar recaudos para que ciertas eventualidades que puedan afectarle a lo largo de su vida laboral no le generen un perjuicio o aumenten el riesgo. De esta forma, cada persona trabajadora —que tenga una relación laboral formal regulada por un contrato de trabajo y que se le apliquen descuentos para la seguridad social— se encuentra protegida ante ciertas situaciones futuras riesgosas. Esto es, se va a minimizar el riesgo, se va a garantizar el bienestar y se va a colectivizar el sostenimiento del sistema. Por lo mismo, se protege al trabajador o trabajadora remunerada y a su grupo familiar asumiendo los costos entre el conjunto de involucrados en el proceso. Esto significa que los aportes que realiza cada persona trabajadora, junto con los que realiza su empleador y

el financiamiento general por parte del Estado, permiten asumir los costos y riesgos de los sistemas de seguridad social. Una ecuación relativamente sencilla que, a la vez, se fundamenta en un pacto intergeneracional solidario que ha perdurado desde hace más de un siglo.

Esta red de seguridad en el trabajo, si bien reconoce situaciones y momentos vitales de personas trabajadoras remuneradas, no se detiene en considerar cómo transitan cotidianamente las necesidades de las personas. En primer lugar, la genuina preocupación por el futuro ha invisibilizado el presente, o en todo caso, la forma en que se resuelven las actividades cotidianas que se realizan en los hogares para garantizar la sostenibilidad de la vida. Se trata precisamente del cuidado, inicialmente definido como trabajo reproductivo, que comprende las tareas imprescindibles para el desenvolvimiento de las personas que se prestan al interior de las familias. Este trabajo fue delegado y concentrado a lo largo de la historia en las mujeres, afectando su participación en el mercado de trabajo y el ejercicio pleno de su autonomía.

El cuidado refiere a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, para brindarles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad.¹ Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal), la provisión de las precondiciones en que se realiza (el trabajo doméstico) y su gestión (coordinar horarios, realizar traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisar el trabajo de la cuidadora remunerada entre otros). El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones/capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermas o con discapacidades), y también de las personas que pueden autoproveérselo.²

¹ Batthyány, Karina, *Cuidado infantil y trabajo: ¿un desafío exclusivamente femenino?* Montevideo: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR)/ Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2004.

² Rodríguez Enriquez, Corina y Pautassi, Laura, *La organización social del cuidado en niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina*, Buenos Aires, ELA-Ciepp y ADC editores, 2014.

El cuidado involucra trabajo, que se realiza al interior de los hogares (de manera remunerada o no) y también en las instituciones que lo proveen, que pueden ser públicas, de mercado o comunitarias.³ Es por ello que se asemeja pero se diferencia de la seguridad social, no sólo en términos de esa primera tensión entre futuro (contingencia) y presente (cuidados), sino en su propia lógica constitutiva. En efecto, ambas esferas —seguridad social y cuidados— se vinculan a las situaciones vitales que trascienden una posición —trabajador o trabajadora—, presentan necesidades concretas, trabajo —remunerado y no remunerado—, subjetividades, y han sido reconocidos como derechos humanos.

En tanto derechos humanos y específicamente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), comparten un fundamento común, principios y estándares. El derecho a la seguridad social cronológicamente fue reconocido como tal a mediados del siglo pasado; en cambio, el derecho al cuidado, si bien estaba integrado en los mismos instrumentos sin ser explícitamente denominado como tal, se consolida como una conquista del siglo XXI, por lo que resulta fundamental precisar el contenido de cada uno y su interdependencia. Y de esta relación trata este capítulo, que, con base en un enfoque de género y derechos humanos, presenta, en primer lugar, las diferencias conceptuales entre el derecho a la seguridad social y al cuidado, para luego desarrollar la recepción en Pactos y Tratados Internacionales y en las constituciones en América Latina, y, cuando corresponda, en el campo de las políticas públicas y en la jurisprudencia. Especial interés reviste identificar elementos comunes y diferenciales que dan cuenta de la interdependencia entre el derecho la seguridad social y al cuidado. Las conclusiones recuperan la agenda urgente —presente y futura— para garantizar ambos derechos, promover acuerdos distributivos y avanzar en una (re)distribución de los cuidados más justa y en condiciones de igualdad.

³ Durán, María-Ángeles, “Alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado”, en *El trabajo de cuidados: una cuestión de Derechos Humanos y políticas públicas*, México, ONU-MUJERES, 2018. Razavi, Shahra, “The Political and Social Economy of Care in a Development Context, Conceptual Issues”, en *Research Questions and Policy Options*, Gender and Development Programme Paper Núm. 3, Geneva, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), junio de 2007.

B. Seguridad social y cuidado: bases conceptuales

El concepto de seguridad social surge vinculado a una reestructuración de la relación entre el Estado y la economía en las sociedades capitalistas modernas y se tradujo en la conformación de los modernos regímenes de bienestar. Estos arreglos institucionales, que se desarrollaron desde mediados del siglo pasado en los países europeos pero también en América Latina, principalmente en los del cono sur, buscan por diferentes vías garantizar legalmente la seguridad o el bienestar de las personas a través de las políticas sociales.⁴ Para ello, incorporaron un conjunto de respuestas institucionales sectoriales, que incluyeron tanto regulaciones como prestaciones relacionadas con la salud, la educación, servicios sociales, vivienda, infraestructura básica, transferencias monetarias, seguros de desempleo, estableciendo asimismo regulaciones en torno a la economía, el mercado de trabajo, el rol del Estado, la distribución del poder y la organización del control social.

Tanto en términos de su conceptualización, como de la traducción normativa, se han caracterizado por un alto grado de androcentrismo, presuponiendo un patrón de inserción laboral masculina, a partir de la figura un “trabajador ideal varón” heterosexual, blanco, que conforma hogares nucleares y cuya dedicación al empleo remunerado es plena. Significa que el diseño institucional presupone que los trabajadores remunerados tienen toda la energía para dedicarse a su ocupación y que la reproducción de la vida cotidiana se asigna a la esposa, a quien se le delega no sólo esta función sino todas las tareas vinculadas a las hijas y los hijos de ese hogar.

Esta matriz fundante de las instituciones de política social, tanto en los países europeos como en América Latina, impregnó los principios organizadores del mercado de trabajo remunerado como de las instituciones de seguridad

⁴ El antecedente fueron los seguros sociales implementados a partir de 1881 por el canciller Otto von Bismarck, que se concentraban en seguros para la vejez, para enfermedades y una indemnización para trabajadores, con base en el reconocimiento de la condición de trabajadores y no con base en criterios de beneficencia (Isuani, 1991).

social. El supuesto del pleno empleo que caracterizó a los modelos keynesianos de la posguerra no fue neutro; por el contrario, presupuso el empleo remunerado de varones, y sólo de manera marginal y con jornadas reducidas o de medio tiempo, de las mujeres. La “mujer ideal” era la ama o dueña de casa, dedicada tiempo completo a las actividades del hogar, al cuidado de las y los hijos, principalmente garantizando la educación y la “armonía del hogar”, con fuertes improntas moralizantes de su función, cuando no influencias religiosas.⁵

Precisamente, la funcionalidad estaba dada por esa división de lo público y remunerado en los varones y lo privado y no remunerado en las mujeres. Trabajo remunerado y seguridad social para varones, trabajo de cuidados no remunerado para mujeres, y acceso a las prestaciones sociales, no por el reconocimiento de su aporte y de su trabajo de cuidado, sino por el vínculo con el trabajador varón titular. Es así que el titular pleno protegido por el derecho al trabajo y a la seguridad social fue el varón, y la mujer junto con hijos e hijas accedían a prestaciones por estar vinculados—marital o filialmente— con el titular. Paradojalmente, el derecho al trabajo surge precisamente para nivelar la desigualdad inicial de las partes contratantes, como lo son el capital y el trabajo, estableciendo la igualdad en la contratación, interviniendo directamente sobre el conflicto que esta relación genera y buscando revertir situaciones de desigualdad propias de los sistemas capitalistas industriales.⁶

Sin embargo, a las mujeres no se les reconocía por derecho propio el acceso a las prestaciones de seguridad social, sino como “esposa de”, que coincide con las iniciales regulaciones de los códigos civiles de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando no se les reconocía plena autonomía, sino que estaban sujetas a la autorización del padre o del marido para celebrar, entre otros, actos patrimoniales y trabajar remuneradamente. Aún más grave, se

⁵ Pautassi, L., “¿Primero... las damas? La situación de la mujer frente a la propuesta del ingreso ciudadano”, en Ruben Lo Vuolo (comp.), *Contra la exclusión*, Buenos Aires, Ciepp, 1995.

⁶ Sanguinetti, Wilfredo, “El Derecho del Trabajo como categoría histórica”, en *Revista Ius et Veritas*, Núm. 12, 1996, pp.143-157.

invisibilizaba su contribución directa y central a la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, a la generación de valor económico.⁷ De esta manera se fueron configurando regímenes de bienestar de tipo familiarista, atravesados por asimetrías de género y subordinando a las mujeres.⁸

La base de las regulaciones del derecho civil contemplaba los intereses del individuo sobre el de los familiares, y al individualizarse anula la identificación de las responsabilidades de cuidado asignadas a las mujeres injustamente.⁹ Tampoco se le concedía titularidad para tomar decisiones respecto a las/os hijas/os, ya que la patria potestad estaba concentrada en los padres varones, y es recientemente a finales del siglo pasado cuando se avanza en que sea compartida, gracias a las demandas feministas. En el siglo en curso, se produce en algunos países de la región una transformación hacia el derecho de las familias, infancias y adolescencias que ha permitido una incorporación del enfoque de género y de diversidades sexuales, pero en general circunscripto al ámbito privado sin incorporar su dimensión social.

Ahora bien, en el caso de las mujeres insertas en el mercado de trabajo a partir de un contrato de trabajo formal, y por lo tanto titulares del derecho a la seguridad social, las prestaciones vinculadas al embarazo, a licencias y a infraestructura de cuidado las reconocen como titulares exclusivas, es decir, la norma titulariza en ellas las obligaciones de cuidado.¹⁰ Por ejemplo, la obligatoriedad de dotar de guarderías a empleadores aplica a partir de un número establecido (entre 20 y 50 trabajadores mujeres), lo que significa

⁷ Pautassi, Laura, *El derecho al cuidado. De la conquista al ejercicio efectivo*. Serie Trabajo y Justicia Social, Ciudad de México, Friedrich Ebert Stiftung, 2023.

⁸ Martínez Franzoni, Juliana y Voorend, Koen, “Desigualdades de género en los regímenes de bienestar latinoamericanos: mercado, política social y organización familiar de los cuidados”, en Pautassi, Laura y Zibecchi, Carla (comps.), *Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura*, ELA, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013, pp. 59-98.

⁹ Marco Navarro, Flavia, *Legislación comparada en material de familias. Los casos de cinco países de América Latina*, Serie Políticas Sociales No. 149, Santiago de Chile, CEPAL, 2009. LC/L.3102.

¹⁰ Pautassi, Laura; Faur Eleonor y Gherardi, Natalia, “Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para una mayor equidad”, Serie Mujer y Desarrollo Núm. 56, CEPAL, Santiago de Chile, 2004.

que la norma presupone que las únicas que tienen que resolver el cuidado de sus hijos e hijas pequeños durante la jornada laboral son las mujeres. En tal caso, la regulación debería considerar a trabajadores varones y mujeres con responsabilidades familiares y romper con la naturalización de las tareas de cuidados en las mujeres. Y este tipo de ejemplos se reiteran en los códigos de trabajo y leyes laborales de los países de la región, que si bien en muchos casos se han producido reformas, el núcleo duro regulatorio permanece refractario a la incorporación de un enfoque de género. Otro ejemplo claro son las licencias por nacimiento de hija o hijo para los varones, que en los casos en que están reconocidas oscilan en promedio entre 2 y 5 días, resultando claramente insuficientes para establecer un vínculo con el niño o niña recién nacido, como tampoco para asumir responsabilidades de cuidado.¹¹

Pero no solamente se concentran las responsabilidades de cuidados en las mujeres, sino que, en general, a las mujeres se las asocia siempre en función de una posición —madre, trabajadora, esposa, pobre— y no como personas titulares de derechos, lo cual ha determinado las formas de organización y de desarrollo de los sistemas de políticas sociales en América Latina. Y en el caso de la seguridad social, no sólo ha cristalizado esta consideración sino que al proteger a trabajadores asalariados formales, es selectivo y deja por fuera a un importante número de personas de esta protección.

El aspecto constante es la falta de reconocimiento del cuidado no remunerado, ya que las disposiciones existentes —sean regulaciones laborales, la doctrina jurídica del trabajo y de la seguridad social— no consideran el cuidado. En el caso del derecho al trabajo, no reconoce el trabajo de cuidado directamente —solo de manera implícita— y establece mecanismos o políticas de “conciliación” del trabajo remunerado con responsabilidades familiares. Es decir, incorpora mecanismos que articulan estas dos instancias, ya que, como lo ha definido de manera reiterada el feminismo, no es posible conciliar dos

¹¹ Inclusive en el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá directamente no contemplan licencias por paternidad (OIT, 2022).

esferas (trabajo remunerado y no remunerado).¹² Por lo tanto, la tradición regulatoria de la región fue a partir de establecer “títulos especiales” para el trabajo de las mujeres y en muchos casos con el trabajo de “los menores”.¹³

Sin embargo, lo cuestionable es que se perpetúe este orden y que la doctrina laboral y de la seguridad social se encuentren refractarias a los procesos de transformación de las relaciones sociales de género, que incluyen al cuidado como uno de sus elementos centrales. Si bien el campo de las políticas de empleo tampoco se ha producido un proceso de cambio profundo, se han realizado algunos avances que impactan directamente sobre los sistemas de seguridad social. El caso más concreto se sitúa en procesos de reformas legislativas en materia de licencias, centralmente por nacimiento de hijas e hijos, algunas disposiciones respecto a infraestructura como espacios de lactancia infantil y en el campo de la protección social, con los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTCI) para trabajadores informales o en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, aunque prácticamente sin dispositivos de cuidados.

La interpretación judicial viene rezagada al respecto; sin embargo, se visualiza una tendencia interesante de transformación. Sirva como ejemplo una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que reconoció el cuidado como un derecho autónomo y desarrolló el contenido de este derecho.¹⁴ Para este Tribunal, las relaciones sociales de género reproducen el estereotipo de la mujer cuidadora y el varón proveedor, señalando que la pandemia del covid-19 agravó el problema, al punto de dejar en clara desventaja a las mujeres por las tareas de cuidado que debieron realizar. Además de reconocer

¹² Véase el capítulo de Flavia Marco Navarro en esta obra.

¹³ Este concepto de minoridad, asociada a la tradición de los sistemas tutelares, fue superado por la Convención Internacional de los derechos del Niño, que establece que niños, niñas y adolescentes (NNA) dejan de ser sujetos de tutela para ser considerados personas titulares de derechos.

¹⁴ Se trata de un caso de trabajadoras del sector público con un embarazo en curso o en período de lactancia que vieron afectados sus derechos laborales por actos discriminatorios. *Corte Constitucional del Ecuador, Caso 3-19-JP y acumulados. Revisión de garantías (JP). Derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia*, Quito, 5 de agosto de 2020. Disponible en «www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/sentencia%20CC%203-19-JP%20y%20acumulados.pdf».

el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, introduce elementos para una interpretación interseccional, al considerar la noción de “buen vivir” (sumak kawsay) como instituto de la cosmovisión indígena, incorporado en la Constitución de Ecuador, que incluye, por un lado, el principio de relacionalidad (que implica “la vinculación entre todos los componentes de la realidad permite la vida como un tejido” [párr. 106]), y, por otro, el de reciprocidad (por el que “una persona tiene correspondencia mutua con otra y debe dar o recibir según sea la situación” [párr. 107]). Estos principios se encuentran estrechamente relacionados con el derecho al cuidado, toda vez que “requiere el cuidado de una persona frente a otra” (párr. 108) y define el principio de corresponsabilidad en el cuidado.¹⁵ Y más reciente aún, la Suprema Corte de México ha reconocido el derecho al cuidado en una sentencia vinculada a derechos de personas con discapacidad, personas mayores y con enfermedades crónicas, reconociendo que los cuidados son un bien común, reconociendo que el derecho al cuidado es de todas las personas.¹⁶

En esta línea, y para aportar algunas interpretaciones a la dificultad para incorporar una mirada transformadora del derecho del trabajo y de la seguridad social, resulta importante recuperar lo señalado por Fraser,¹⁷ quien sostiene que los problemas en el cuidado no son accidentales, sino que tienen raíces sistémicas profundas en la estructura de nuestro actual orden social, el capitalismo financiero. Significa que cada forma de sociedad capitalista aloja una tendencia a la crisis de su reproducción: aunque la reproducción sostiene y perpetúa la acumulación del capital, esta acumulación tiene consecuencias desestabilizadoras en los propios procesos de reproducción en los que se asienta.

¹⁵ El tribunal la define como: “la responsabilidad que tiene cada uno de los sujetos con relación al cuidado. En primer lugar, está cada una de las personas con el cuidado a sí mismo (autocuidado). En segundo lugar, están quienes tienen obligaciones (por el principio de reciprocidad), como el padre y madre con relación a sus hijas e hijos, la mujer o el hombre en relación con su cónyuge o pareja. Un tercer lugar corresponde a los miembros del espacio en el que se desenvuelven cotidianamente las personas, como la familia, el lugar de trabajo o de educación. Un cuarto lugar es la sociedad o comunidad, el barrio, el condominio, la familia ampliada, las organizaciones sociales. En quinto lugar, está el Estado”. Corte Constitucional, *ibidem*, párr. 130.

¹⁶ Amparo directo 6/23, resuelto el 18 de octubre de 2023, por unanimidad de cinco votos.

¹⁷ Fraser, Nancy, “Contradictions of Capital and Care”, en *New Left Review*, N. 100, 2016, p. 100.

Continúa la autora señalando que las formas actuales del capitalismo configuran una suerte de “neoliberalismo progresista”, que celebra la diversidad, la meritocracia y la emancipación mientras desmantela las protecciones sociales, afectando a la reproducción social y —agrego— la sostenibilidad de la vida. El resultado es no sólo el abandono de importantes núcleos de población a la depredación del capital, sino con igual intensidad, la redefinición de la idea de emancipación que fue bandera principalmente del feminismo y de las diversidades sexuales, pero que en la actualidad adopta los términos del mercado.¹⁸ Para este nuevo capitalismo, el imaginario dominante es la igualdad de género en la esfera de la producción. La reproducción, en contraste, aparece como un residuo, un obstáculo que debe ser descartado con fines de la liberación. De esta manera, el capitalismo financiero no sólo ha disminuido la provisión pública de cuidado necesaria para la sostenibilidad de la vida, y con ello ha reclutado a las mujeres en el mundo asalariado, sino que además ha reducido los salarios reales, elevando así la cantidad de horas de trabajo remunerado necesarias para mantenerlo, dando lugar a una crisis en la provisión de cuidado en el interior de los hogares.¹⁹

En forma gráfica, los efectos del actual sistema económico capitalista, con sus vetas de neoliberalismo financiero, está provocando una crisis de la reproducción social, en sentido amplio, que se manifiesta en presiones desde diferentes direcciones que están “exprimiendo” una serie de capacidades sociales clave, entre ellas, la capacidad de tener y criar niños y niñas, cuidar a amigos o familiares, sostener hogares, comunidades y conformar redes.²⁰

Reiteradamente, la pandemia de covid-19, que tuvo características de una *sindemia*,²¹ conjugó en América Latina una crisis sanitaria, de cuidados con un entramado de desigualdades estructurales que dejaron al descubierto la

¹⁸ *Ibidem*, p. 113.

¹⁹ *Ibidem*, p. 114.

²⁰ *Ibidem*, p. 99.

²¹ El neologismo de *sindemia* surge por una integración de *sinergia* y *pandemia*, que permite visibilizar que la crisis acontecida no afecta sólo en el terreno epidemiológico y de la salud, sino adquiere un carácter multidimensional donde confluyen la crisis ecológica global, la crisis de reproducción social

debilidad de los sistemas de políticas sociales y la institucionalidad en su conjunto. No solamente los sistemas de salud no pudieron responder ágil y adecuadamente a tamaña crisis, sino la seguridad social tampoco pudo adaptarse, salvo contadas excepciones, para garantizar las prestaciones necesarias y garantizar el bienestar de las personas.

Nuevamente, el futuro regresó y presentó una nueva estructura de riesgos, que lejos de movilizar y promover procesos de reformas a los sistemas de seguridad social mostró los déficits ocasionados por la resistencia a incorporar las relaciones sociales actuales. En especial, no se consideró la advertencia desarrollada por Tronto,²² quien contrapone una sociedad del riesgo respecto a una sociedad del cuidado, ya que en esta última el riesgo se transforma si la estructura social se organiza en torno al cuidado. A pesar de que la pandemia permitió visibilizar y considerar al cuidado como un bien público indispensable, no se avanzó en promover un equilibrio entre necesidades y las obligaciones contenidas en los derechos como parte central de la discusión política. En otras palabras, la oportunidad para sacar al cuidado de la oscuridad y a la seguridad social del aletargamiento histórico no fue el eje central durante la pandemia, lo cual alerta sobre la urgencia de retomarlo en este escenario pospandémico, pero no sólo a partir de las consecuencias negativas vivenciadas, sino desde un enfoque de género y derechos humanos, de modo de imprimir una mirada dinámica y relacional a las desigualdades estructurales y generar respuestas efectivamente interdependientes.

C. La interdependencia en la norma

Resulta interesante verificar que tanto el derecho a la seguridad social como el derecho al cuidado han sido incorporados en los Pactos y Tratados internacionales desde sus inicios. En el caso del derecho a la seguridad social, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 lo reconoce

(material y simbólica) y de los cuidados, de manera simultánea con la crisis sanitaria provocada por el covid-19. (Rico y Pautassi, 2023).

²² Tronto, Joan, *¿Riesgo o cuidado?*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Medife Edita, 2020.

como derecho en el artículo 22, cuando establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, a partir del antecedente directo de la Declaración de Filadelfia de 1944, que recomendaba a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los Estados también a “extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa”.²³ En la DUDH, complementa las disposiciones en el artículo 25, parr. 1, que establece que toda persona tiene “derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Estos mandatos quedaron reflejados en el Convenio 102 sobre seguridad social de la OIT (1952) y subsiguientes.

Sin embargo, pasó desapercibido el reconocimiento del derecho al cuidado, ya que, al no ser denominado como tal, otra vez fue invisibilizado. En particular, en este primer instrumento, la consideración del cuidado y la seguridad se acercan y alejan al mismo tiempo. En efecto, la DUDH parte por reconocer la libertad para casarse y formar una familia, considerando que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (artículo 16, inciso 3, DUDH), agregando que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (artículo 25, inciso 2, DUDH).²⁴

²³ OIT, *Derecho a la seguridad social en las constituciones del mundo: Ampliando el espacio moral y legal para la justicia social*, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2023, p. 3.

²⁴ En los artículos 22 a 27 de la DUDH se establecen derechos y obligaciones interdependientes con otros derechos, pero vinculados al concepto de vida digna. En todo el texto se incluyen destacados que son propios. Este apartado sigue y complementa los desarrollos de Pautassi, Laura, *El derecho al cuidado. De la conquista al ejercicio efectivo*. Serie Trabajo y Justicia Social, Ciudad de México, Friedrich Ebert Stiftung, 2023 y Rico, María Nieves y Pautassi, Laura, “The Right to Care at Stake: The Syndemic Emergency in Latin America”, en Mignon Duffy, Amy Armenia y Kim Price-Glynn (editoras), *From Crisis to Catastrophe. Care, COVID, and Pathways to Change*, Rutgers University Press, 2023.

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) de 1948 también reconoce el derecho a la seguridad y protección social en el artículo 16, al consagrar que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. Nuevamente, estableció disposiciones respecto al cuidado, como fundar una familia, y agrega en el artículo 7 que “toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayudas especiales”, y en el capítulo de deberes establece que “toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten” (artículo 25). Agrega que “toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias” (artículo 35).

Es decir, desde el inicio del sistema de derechos humanos las responsabilidades y derechos en torno al cuidado están incluidos y se diferenciaban del derecho a la seguridad social.

En 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce estos principios y establece, en el artículo 17, el derecho a la protección integral de la familia, creando la obligación de los Estados de adoptar “medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de los cónyuges” que incluye los derechos de niños y niñas nacidos dentro y fuera del matrimonio, con base en el respeto por la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna. Estas y otras acciones deben ser adoptadas por los Estados, tanto a nivel interno como internacional. Es decir, los Estados tienen, respecto de este derecho como de todos los otros, las obligaciones de respetar y de garantizar (artículo 1.1 CADH), de prohibición de discriminación (artículo 1.1) como de garantizar igualdad ante la ley (artículo 24 CADH) y de adoptar medidas de orden interno para garantizar el derecho (artículo 2 CADH). Asimismo, dado el carácter de derecho social del derecho al cuidado,

los Estados tienen las obligaciones de cumplimiento inmediato como las de desarrollo progresivo “para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia y cultura” (artículo 26, CADH) utilizando todos los recursos disponibles, tanto por vía legislativa u otros medios apropiados.

En relación con los instrumentos de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas, aprobado en 1966, que cuenta con un alto grado de ratificación por parte de los países de la región, reconoce en el artículo 9 el derecho a la seguridad, y en el siguiente artículo establece la obligación de los Estados de “conceder a las familias, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución para que sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo” (artículo 10, inciso 1).

Nótese que el artículo 11.1 reconoce, de manera interdependiente, los distintos derechos que deben ser reconocidos para garantizar “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. En consonancia, por ejemplo, la Observación General No. 16 del Comité DESC²⁵ aborda el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, reconociendo la importancia del trabajo de cuidado para el logro de la salud y destacando la necesidad de abordar las desigualdades de género en la distribución del trabajo de cuidado.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en 1988, se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador, PSS), que establece que los Estados se encuentran obligados a “ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada

²⁵ E/C.12/2005/4.

atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo” (artículo 6, inciso 2) y a tomar medidas para la protección y atención de la familia (artículo 15, PSS), a la niñez (artículo 16, PSS), incluyendo a las personas mayores y con discapacidades (artículo 17 y 18, PSS).

Adicionalmente, tres instrumentos específicos de Naciones Unidas y sus respectivos protocolos facultativos consignan obligaciones estatales respecto al cuidado y a la seguridad social. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención de Derechos del Niño (CDN, 1980) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006). La CEDAW establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para “garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos” (artículo 5, inciso b). Con respecto al trabajo remunerado de las mujeres, deben prohibir el “despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad”, a la vez que deben implementar “licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables” y alentar “el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación de la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños” (artículo 11, incisos 2, 2.b y c).

En el caso del artículo 14 referido a los derechos de las mujeres que viven en zonas rurales, reconoce su importante contribución a la supervivencia económica de su familia, “incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía” (artículo 14, inciso 1, CEDAW) y agrega que deben adoptarse, entre otras, medidas para que puedan beneficiarse directamente de los programas de seguridad social.

Respecto a hijas e hijos, el artículo 16, inciso d, establece que los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación de la mujer en el

matrimonio y relaciones familiares, garantizando “los mismos derechos y obligaciones como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materia relacionadas con sus hijos” (artículo 16, inciso d).

En la Recomendación General Núm. 17²⁶ del Comité CEDAW, titulada “Medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto” se insta a los Estados que alienten y apoyen las investigaciones y los estudios destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado, que adopten medidas encaminadas a cuantificar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer e incluirlo en el producto nacional bruto, que incluyan en sus informes presentados los estudios experimentales realizados, así como sobre los progresos logrados en la incorporación de dicho trabajo en las cuentas nacionales.

Posteriormente, la Recomendación General Núm. 21²⁷ del Comité CEDAW sobre “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares” reconoció que algunos países no respetan el principio de igualdad de madres y padres de familia, especialmente cuando no están casados. Sus hijos e hijas no siempre gozan de la misma condición jurídica que los nacidos dentro del matrimonio y, cuando las madres están divorciadas o viven separadas, muchas veces los padres no comparten las obligaciones del cuidado, la protección y el sostén económico. Con base en este diagnóstico, encomendó a los Estados velar para que, conforme a sus leyes, madre y padre, independientemente de su estado civil o si viven con sus hijos e hijas, compartan los derechos y las obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad.

La CDN transformó la concepción de los niños, niñas y adolescentes (NNA), antes considerados destinatarios de tutela, para pasar a ser personas titulares de derechos. Bajo el precepto de autonomía progresiva y la figura del interés superior de las infancias, se produce una transformación tanto en términos

²⁶ CEDAW/RG/17, 1991.

²⁷ CEDAW/RG/21, 1994.

del ejercicio de derechos como de los vínculos entre todo el grupo familiar y la sociedad. En el artículo 3, inciso 2, se establece que

los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y **el cuidado** que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

En el siguiente inciso reafirma que

los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o de la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de la supervivencia adecuada (artículo 3, inciso 3, CDN).

El artículo 18 de la CDN establece las obligaciones de ambos progenitores al afirmar que

los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño [...] [inciso 1], [agregando que] a los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados parte prestarán asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños (3). Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

En los siguientes artículos refiere a las obligaciones que asumen los Estados de garantizar para aquellos niños, niñas y adolescentes privados temporal o

permanentemente de su medio familiar “otros tipos de cuidados para esos niños”, que incluye diversas figuras como los hogares de guarda, siempre que respeten la continuidad en la educación y su origen étnico, religioso, lingüístico (artículo 20, inciso 2 y 3, CDN). La obligación de cuidar se extiende a la figura de la adopción, que se habilita que sea internacional en el entendido que puede ser considerada como “otro medio de cuidar al niño” (artículo 21, inciso b).

Esta consideración del vínculo entre interés superior del niño y cuidado refuerza respecto a niños con situaciones especiales (denominados en ese entonces como niño impedido) su

derecho a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación del niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él (artículo 23, inciso 2).

Se constata un uso amplio del concepto de cuidado, inclusive en el artículo 24, cuando establece el deber de garantizar el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, ejemplificando en el inciso e: “asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños conozcan los principios básicos de salud”. Por otra parte, y siguiendo con el principio de interdependencia de derechos, el art. 26 señala que los Estados parte “reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social”.

En el siguiente artículo reafirma que

- i) Los Estados reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social,
- ii) A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias

para el desarrollo del niño, iii) Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda, iv) Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que este último resida, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados (artículo 28, CDN).

En efecto, se establece una vinculación interdependiente entre obligaciones civiles a ambos progenitores como societales y estatales, de manera interseccionada y bajo un principio de igualdad y no discriminación.

En el caso de las dos Convenciones de Protección de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas (CDPD, 2006), y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (CIDPD, 1999), establecen el reconocimiento de igualdad de todas las personas con discapacidad. En el caso de la CDPD, exige asegurar que

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta (artículo 19, inciso b, CDPD).

En el artículo 23, este mismo instrumento define las obligaciones que le competen a los Estados para garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación en el matrimonio, con las relaciones personales, a tener hijos, a la

adopción, guarda y tutela conforme a las legislaciones nacionales. El Estado deberá prestar

la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias [...] 5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar (artículo 23, CDPD).

La CDPD establece con claridad la obligación de los Estados parte a adoptar medidas para promover la integración de las personas con discapacidad en el acceso y cobertura de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, sumada a la obligación de garantizar esfuerzos para la detección, tratamiento, rehabilitación y suministro de servicios que posibiliten asegurar un “nivel óptimo de independencia y de calidad de vida de las personas con discapacidad” (artículo III).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció en el Convenio Núm. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) el compromiso para que

con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales (artículo 3).

Posteriormente, en el año 2000 se aprueba el Convenio No. 183 sobre la protección de la maternidad, que insta a los Estados a crear medidas para prohibir a empleadores exigirle a una mujer que aplica a un empleo la presentación de una prueba de embarazo, o despedir a una mujer embarazada que se encuentre en licencia de maternidad o luego de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo a determinarse en la legislación nacional, y garantizar a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.²⁸

En 2011 se aprueba el Convenio No. 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que establece derechos laborales de este sector, define qué se considera trabajo doméstico y establece regulaciones con respecto a la jornada laboral, periodos de descanso, la remuneración y salario mínimo, horas extra de trabajo, seguridad social y otros derechos laborales,²⁹ así como la protección y prevención sobre medidas de discriminación en función del sexo, particularmente con respecto a la remuneración.³⁰

Por su parte el Convenio No. 156 ya citado sobre los trabajadores con responsabilidades familiares busca conciliar las obligaciones familiares y laborales, destacando la importancia de ejercer el derecho sin ser objeto de discriminación,³¹ estableciendo que “la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo” (artículo 8). La Conferencia Interamericana de Seguridad Social también reivindica sistemas de seguridad social universales en su Declaración 115, en el Marco de su 80 aniversario (2023). Afirma que el origen del derecho a la seguridad social debe ser la condición de persona y no la vinculación laboral.

²⁸ Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la protección de la maternidad, núm. 183, art. 8, 2000.

²⁹ OIT, Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, núm. 189, art. 7, 2011.

³⁰ *Ibidem*, art. 11.

³¹ OIT, Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, núm. 156, art. 3, 1981.

En suma, los instrumentos internacionales de derechos humanos han reconocido en amplitud el derecho a la seguridad social, como también el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, con las consiguientes obligaciones. Además, su reconocimiento surge de manera interdependiente con otros derechos.

Finalmente, el último tratado aprobado en la región es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CPDHPM, 2015), en el que se refleja con claridad el reconocimiento de ambos derechos de manera interdependiente, al señalar que

los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (artículo 6).

En el siguiente artículo se reconoce la autonomía de la persona mayor y el autocuidado, asegurando para ello que dispongan de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos, propiciando su autorrealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos sociales y relaciones afectivas. En el artículo 12 la Convención reconoce de manera extensa el tipo de cuidados, considerando que

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda;

promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión. Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor. Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:

- a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.
- b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente.
- c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
 - i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.
 - ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
 - iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
 - iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona mayor.
 - v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.
- d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacio-

nales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona mayor, según corresponda. e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.

Nótese que a pesar de que las personas mayores demandan una consideración específica de medidas de cuidados, la mirada transversal de la Convención se sitúa en el reconocimiento de las personas a ser cuidadas, a cuidar y al autocuidado, incluyendo nuevamente una perspectiva transformadora.

En esa dirección, los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como Principios de Yogyakarta (2006), parten por definir como primer principio que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos” (artículo 1), para establecer garantías de ejercicio de derechos de manera interdependiente, a la seguridad social —reconociendo el derecho a prestaciones y a tiempo para cuidado (licencias por maternidad o paternidad), a la vivienda, trabajo remunerado, educación, salud, contraer matrimonio, fundar familias, en el marco de la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado—.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó en 2017 la Opinión Consultiva Núm. 24 sobre identidades sexuales, reafirmando los anteriores principios y señalando

los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales,

licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte (Corte IDH, OC 24/2017, párr. 196).

Agrega en el siguiente párrafo un listado en “expansión de derechos, beneficios y responsabilidades de las cuales las parejas del mismo sexo podrían ser titulares” incluyendo entre otros, compensaciones laborales, seguros de salud y responsabilidad parental de hijas, hijos e hijes, entre otros.

A su vez, resulta muy importante el reflejo constitucional de ambos derechos. En el caso del derecho a la seguridad social fue temprano su reconocimiento como derecho y de manera adelantada en los países de la región: Argentina (1949), Bolivia (1938), Brasil (1934), Chile (1925), Costa Rica (1943), El Salvador (1886), a través de una enmienda constitucional realizada en 1945, Guatemala (1945), Nicaragua (1948), República Dominicana (1955) y Venezuela (1947), con el caso pionero de la Constitución de México de 1917 por su título especial dedicado a los derechos laborales y el bienestar social (OIT, 2023). A pesar que estas constituciones han sufrido procesos de reformas o de enmiendas, cabe destacar que todas mantienen o amplían el reconocimiento del derecho a la seguridad social.

Nuevamente el derecho al cuidado se presenta rezagado respecto a su reconocimiento. En el caso de Bolivia y Ecuador, en el marco de procesos de conformación de Estados plurinacionales, reconocieron el cuidado no remunerado en sus textos constitucionales. Bolivia lo definió en el artículo 338 de la Constitución sancionada en 2009, que reconoce “el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”, al tiempo que establece también la obligatoriedad de ambos cónyuges sobre el cuidado de las y los hijos y del hogar (artículo 64). Ecuador incorpora en 2008 en su Constitución el artículo 333, que “reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuida-

do humano que se realiza en los hogares” y se compromete en un régimen laboral que promueva la conciliación de responsabilidades laborales con las familiares, así como la provisión de servicios e infraestructura de cuidados.

El derecho al cuidado cobró relevancia en Ciudad de México, en ocasión de aprobar la Constitución en 2017. En el artículo 9, inciso B, reconoce y define el “Derecho al cuidado”. Sostiene que

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

En noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de México aprobó el proyecto de reforma para elevar a rango constitucional el “derecho al cuidado digno” y a cuidar, a partir de la reforma de los artículos 4 y 73 de la Constitución federal mexicana, que establece la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad entre mujeres y varones en las actividades de cuidado. Dicha reforma requiere todavía de la aprobación del Senado de la República para su entrada en vigor.

En síntesis, tanto el reconocimiento histórico de la seguridad social, en primer lugar, y, de manera más reciente, del derecho al cuidado remiten a obligaciones de hacer (obligaciones positivas) y de no hacer (obligaciones negativas) para los Estados. Todas estas normas identifican a los sujetos titulares de cada derecho y, a su vez, a quienes se encuentran obligados a respetar y garantizarlos.

Sin embargo, en el caso de la seguridad social, se establece un esquema de protección de cada persona—en su condición de trabajador formal que incluye

al núcleo familiar— que debe ser garantizado. En este caso, la corresponsabilidad entre la persona protegida y quien se encuentra obligado a proteger y satisfacer el derecho se vincula con esquemas de aportes contributivos.

En cambio, la relación se invierte en el cuidado, ya que el reconocimiento como derecho establece la titularidad de la persona independientemente de su condición laboral o de su estado de necesidad. Pero, a su vez, al involucrar elementos de las relaciones del derecho civil y de familias, hay obligaciones de provisión de cuidado de mujeres y varones como progenitores en general o como integrantes de una pareja para con sus hijos e hijas, o de los hijos varones e hijas mujeres para con sus progenitores para facilitar el ejercicio de su autonomía. Pero el Estado es un sujeto obligado a respetar, garantizar y satisfacer el derecho al cuidado. La obligación positiva del Estado implica la obligación de provisión, al mismo tiempo de imposición a terceros de ciertas y determinadas obligaciones y conductas, como por ejemplo la obligatoriedad de los empleadores privados de que efectivamente provean la infraestructura necesaria o transferencias y asignaciones monetarias.

En estos casos, el derecho al cuidado opera de manera interdependiente con el derecho a la seguridad social, ya que se debe garantizar el derecho al cuidado, en tanto derecho universal y propio de cada persona —y no sujeto a alguna condición o posición— ampliando la esfera de exigibilidad individual pero también colectiva hacia los distintos ámbitos (estatales, privados y comunitarios) y posibilita un cambio en la dinámica de los cuidados, incluyendo a todas las personas.

Tal como pudo apreciarse, desde los inicios de la conformación de los sistemas de protección de derechos humanos, la inclusión del cuidado se hizo de manera autónoma (más allá de las palabras con que haya sido aludido), así como también interdependiente considerando al cuidado en tanto derecho, estableciendo las obligaciones de hacer y de abstención, reflejando correctamente el carácter transversal que tiene el cuidado a lo largo del ciclo de vida y respecto del cual confluyen responsabilidades públicas y privadas.

En concordancia, tanto la garantía de su cumplimiento como de su provisión es obligación del Estado, que no debe reducirse a fiscalizar el ámbito productivo (por medio del contralor de la implementación de políticas tradicionalmente llamadas de conciliación trabajo-familia), sino que la complejidad se encuentra en transversalizar la noción misma del derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse de manera interdependiente con el derecho al trabajo y a la seguridad social.

D. CONCLUSIONES: EL FUTURO REGRESA

Tal como fue analizado, el desarrollo de los sistemas de seguridad social se asentó sobre la base del empleo remunerado y de la fiscalidad, sin reconocer el aporte del trabajo de cuidados en sostener la red (en el empleo remunerado y en la seguridad social).

Por otra parte, la histórica relación asalariada lejos está de ser la regla en América Latina, habiendo crecido la informalidad laboral, pero también un abanico de nuevas situaciones en relación con el trabajo remunerado, a la heterogeneidad de los sectores productivos y de los servicios, donde el cuidado ha crecido de manera importante al compás del aumento de las demandas familiares y sociales. Estas situaciones conviven con problemas de larga data en los sistemas de políticas sociales, en una reconfiguración de las estructuras económicas productivas y los límites presupuestarios y fiscales. La anhelada fiscalización e inspección del trabajo como herramienta de verificación del cumplimiento de obligaciones ha sido claramente ineficaz.

A ello se suma la diversificación del trabajo, la informalidad laboral como principal forma de inserción de las mujeres y, en paralelo, procesos inflacionarios que van configurando la presencia de “trabajadores pobres”, que en muchos casos son asalariados formales pero su nivel de vida de encuentra por debajo de la línea de pobreza y sus salarios se licúan al compás inflacionario. La lista podía seguir extendiéndose, a lo cual se suma el teletrabajo, procesos de movilidades humanas junto con relaciones de trabajo informales y las pocas perspectivas que la región aborde, procesos de reforma tributaria que

permitan nuevos pactos fiscales y una discusión en torno al gasto público, la inversión y la urgencia distributiva. A su vez, el cuidado se resuelve de manera estratificada de acuerdo con la disponibilidad de ingresos y cada vez más sucede lo mismo con la seguridad social ante la caída de la provisión pública.

En contextos como los actuales, de crecimiento de opciones políticas ultra-conservadoras, que argumentan desde la “ideología de género”, el escenario es cada vez más complejo y las bases de la red de seguridad en el trabajo y en la seguridad social presentan límites claros para garantizar el acceso a bienes y servicios.

América Latina está atravesando un proceso de transición demográfica acelerada, donde los cuidados presionan a las familias ante la ausencia de respuestas públicas. No sólo el bono demográfico se venció sino que pronto va a vencer la moratoria social que están dando las mujeres a las políticas sociales de la región.³²

Pero también los Estados se comprometen en los diversos instrumentos analizados a promover niveles más altos de protección, sea por vía contributiva o por ampliación de los esquemas de protección social. A pesar de los esfuerzos notables de muchos Estados por ampliar el gasto público o la implementación de sistemas nacionales de cuidados, éstos están siendo insuficientes. En otros casos, la vía de acceso es el reclamo judicial, con un fuerte activismo judicial sin que impacte en transformaciones en las políticas públicas.

El trabajo remunerado y no remunerado, productivo y de cuidados, como también comunitario requieren una importante revisión en América Latina. Tal como fue desarrollado, se debe dejar definitivamente atrás la hegemonía del trabajo remunerado y su normativa con profundos sesgos androcéntricos,

³² Marco Navarro, Flavia, Giacometti, Claudia, Huertas, Tebelia y Pautassi, Laura, *Medidas compensatorias de los cuidados no remunerados en los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica*, Madrid, España, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2019. Disponible en «<https://oiss.org/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en-iberoamerica>».

sumados a los principios de la seguridad social anclados a las contingencias, para considerar como trabajo a todas las actividades que contribuyen a la sostenibilidad de la vida.

Esta recomendación no ignora el hecho que la disponibilidad de empleo y de ingresos en las sociedades actuales regidas por la regulación de mercado es un elemento esencial para el desempeño y las elecciones de cada persona, sino que precisamente identifica que bajo las actuales condiciones sólo contribuye a reproducir las desigualdades estructurales vigentes en el mercado de trabajo y en la organización de los cuidados.³³

Claro está que este proceso debe partir por asumir las desigualdades estructurales existentes, que en el caso del trabajo y de los cuidados son múltiples e intersectan de acuerdo con diversos factores y operan en desmedro del ejercicio de la autonomía de las mujeres e identidades sexuales diversas. En la misma dirección, la seguridad social debe romper su esquema rígido atado a las prestaciones contributivas y revisar todo su andamiaje. Ampliar los márgenes interpretativos del alcance de la seguridad social asumiendo nuevas prestaciones de protección social no promueve la necesaria mirada transformadora.

Si no avanzamos por el cambio transformador, con base en un enfoque de género y derechos humanos, reconociendo la interdependencia de cada derecho, regresaremos una vez más al futuro, dejando de lado un presente que demanda respuestas urgentes. Todos y todas tenemos obligaciones con el presente y con el futuro, pero la única forma de comenzar a cumplirlas es si se distribuyen obligaciones y se avanza así una organización social del trabajo y de los cuidados más justa.

³³ Rico, María Nieves y Pautassi, Laura, “The Right to Care at Stake: The Syndemic Emergency in Latin America”, en Mignon Duffy, Amy Armenia y Kim Price-Glynn (editoras), *From Crisis to Catastrophe. Care, COVID, and Pathways to Change*, Rutgers University Press, 2023.

E. Bibliografía

- Batthyány, Karina, *Cuidado infantil y trabajo: ¿un desafío exclusivamente femenino?* Montevideo: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR)/Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2004.
- Batthyany, Karina (coord.), *Miradas latinoamericanas a los cuidados*. México, Siglo XXI, 2020. Disponible en «<https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/Miradas-latinoamericana.pdf>».
- Durán, María-Ángeles, “Alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado”, en *El trabajo de cuidados: una cuestión de Derechos Humanos y políticas públicas*, México, ONU-MUJERES, 2018.
- Fraser, Nancy, “Contradictions of Capital and Care”, en *New Left Review*, N. 100, 2016, pp. 99-117.
- Isuani, Aldo, “Bismarck o Keynes ¿Quién es el culpable?”, en Isuani, Aldo; Lo Vuolo, Rubén y Tenti, Emilio (comp.), *El Estado de Bienestar: un Paradigma en Crisis*, Buenos Aires, CIEPP, Miño y Dávila, 1991, 9-26.
- Marco Navarro, Flavia, *Legislación comparada en material de familias. Los casos de cinco países de América Latina*, Serie Políticas Sociales No. 149, Santiago de Chile, CEPAL, 2009. LC/L.3102.
- Marco Navarro, Flavia, Giacometti, Claudia, Huertas, Tebelia y Pautassi, Laura, *Medidas compensatorias de los cuidados no remunerados en los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica*, Madrid, España, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 2019. Disponible en «<https://oiss.org/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en-iberoamerica>».
- Martínez Franzoni, Juliana y Voorend, Koen, “Desigualdades de género en los regímenes de bienestar latinoamericanos: mercado, política social y organización familiar de los cuidados”, en Pautassi, Laura y Zibecchi, Carla (comps.), *Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura*, ELA, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013, pp. 59-98.
- OIT, *Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para*

- una mayor igualdad en el mundo del trabajo*. Organización Internacional del Trabajo, 2022.
- OIT, *Derecho a la seguridad social en las constituciones del mundo: Ampliando el espacio moral y legal para la justicia social*, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2023.
- Pautassi, L., “¿Primero... las damas? La situación de la mujer frente a la propuesta del ingreso ciudadano”, en Ruben Lo Vuolo (comp.), *Contra la exclusión*, Buenos Aires, Ciepp, 1995.
- Pautassi, Laura, *El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos*, Serie Mujer y Desarrollo Núm. 57, Santiago de Chile, CEPAL, 2007, p. 18.
- Pautassi, Laura, “El tiempo y su distribución. Claves para su incorporación en las regulaciones laborales en Argentina”, *Revista Derecho Social*, 2022.
- Pautassi, Laura, *El derecho al cuidado. De la conquista al ejercicio efectivo*. Serie Trabajo y Justicia Social, Ciudad de México, Friedrich Ebert Stiftung, 2023.
- Pautassi, Laura; Faur Eleonor y Gherardi, Natalia, “Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para una mayor equidad”, Serie Mujer y Desarrollo Núm. 56, CEPAL, Santiago de Chile, 2004.
- Razavi, Shahra, “The Political and Social Economy of Care in a Development Context, Conceptual Issues”, en *Research Questions and Policy Options*, Gender and Development Programme Paper Núm. 3, Geneva, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), junio de 2007.
- Rico, María Nieves y Marco, Flavia, “La agenda pública de los cuidados en América Latina. Recorrido e interrogantes para una nueva estrategia”, en Elaine Acosta (Ed.), *Crisis de cuidados y políticas de bienestar en Cuba*, Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2021.
- Rico, María Nieves y Pautassi, Laura, “The Right to Care at Stake: The Syndemic Emergency in Latin America”, en Mignon Duffy, Amy Armenia y Kim Price-Glynn (editoras), *From Crisis to Catastrophe. Care*, CO-

VID, and Pathways to Change, Rutgers University Press, 2023.

Rodríguez Enríquez, Corina y Pautassi, Laura, *La organización social del cuidado en niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina*, Buenos Aires, ELA-Ciepp y ADC editores, 2014.

Sanguinetti, Wilfredo, “El Derecho del Trabajo como categoría histórica”, en *Revista Ius et Veritas*, Núm. 12, 1996, pp.143-157.

Tronto, Joan, *¿Riesgo o cuidado?*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Medife Edita, 2020.

El derecho a la seguridad social y el derecho al cuidado: de la relación paradójica a la interdependencia de derechos

Lourdes Jiménez Brito*

* Especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

SUMARIO: A. Introducción; B. La seguridad social: del paradigma laboralista al reconocimiento como derecho humano; I. La seguridad social en el derecho mexicano; C. El cuidado como trabajo y como derecho; D. El enfoque de derechos aplicado al cuidado; E. El reconocimiento del derecho al cuidado en instrumentos internacionales; F. Cuidados y seguridad social: de la paradoja a la interdependencia; G. Avances normativos y buenas prácticas en América Latina y el Caribe; H. El proceso de opinión consultiva sobre el derecho al cuidado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; I. Conclusiones y llamado a la acción; J. Bibliografía.

A. Introducción

Hablar de cuidados y de seguridad social hubiera sido difícil (incluso impensado para muchas personas e instituciones) hace apenas un par de décadas. Si bien la seguridad social presenta un amplio y robusto camino de reconocimiento como una forma de protección frente a una serie de riesgos sociales, el cuidado, como trabajo y derecho, irrumpe en el espacio público en forma reciente buscando posicionarse en la agenda política de los países de América Latina y del mundo.

En el 2022, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), organismo internacional técnico especializado en promover la seguridad social en el continente, cumplió 80 años de existencia. En ese marco, se celebró el panel de alto nivel “Retos de la seguridad social. El trabajo de cuidados”. Por primera vez en 80 años de vida institucional de la CISS se abordó en forma central la relación del cuidado con la seguridad social. Esto constituyó un verdadero hito en el quehacer institucional de la CISS, marcando con ello

un camino contundente hacia el reconocimiento de la interdependencia de derechos, característica clave de la relación entre cuidados y seguridad social.

En este capítulo se realiza un análisis sobre la relación existente entre el derecho a la seguridad social y el derecho al cuidado. El objetivo es trazar el recorrido diferenciado, pero estrechamente relacionado entre ambos derechos. Con ello se procura informar a las personas lectoras sobre la relación que existe entre la seguridad social y los cuidados. Los objetivos específicos de este capítulo son ofrecer un recorrido histórico sobre la evolución del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano, su incorporación al derecho mexicano y su traducción institucional actual. Por otra parte, se presenta al cuidado como un trabajo y como un derecho. En particular, se enfatiza en la aplicación del enfoque de derechos humanos al cuidado y la forma en la cual la región de América Latina contribuyó a este reconocimiento a través de diferentes instrumentos normativos regionales y acciones específicas.

El documento se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, se presenta el recorrido normativo de la seguridad social a nivel convencional, nacional y su actual traducción institucional para el caso de México. En dicha sección se aprecia cómo de la concepción inicial “laboralista” se avanzó hacia la seguridad social reconocida como un derecho humano y desvinculada de la situación laboral de las personas; sin embargo, aún hoy en México y gran parte de la región su traducción institucional sigue vinculando fuertemente el acceso a sus prestaciones sólo a las personas trabajadoras asalariadas formales. En segundo lugar, se aborda el reconocimiento del cuidado como un trabajo y como un derecho. Asimismo, se da cuenta de lo que la literatura ha denominado como “relación paradójica” entre cuidados y seguridad social. A partir de los contenidos de esta sección, las personas lectoras podrán comprender la tensión existente entre el actual diseño de la seguridad social y su incapacidad de poder ofrecer protección a quienes brindan cuidados en forma no remunerada dentro del espacio doméstico. En tercer lugar, se presenta una serie de avances normativos y buenas prácticas de políticas a nivel comparado en materia de cuidados y seguridad social que sirven de orientación e información sobre las formas en las cuales se puede empezar a transformar la relación entre ambos derechos.

Finalmente se presentan unas conclusiones que buscan guiar e informar sobre los aspectos críticos y urgentes en este tema con un específico llamado a la acción dirigido a las personas funcionarias públicas e instituciones políticas.

Para la elaboración de este documento se aplicó una metodología cualitativa que incluyó revisión de fuentes documentales primarias y secundarias, de literatura especializada, de encuestas y datos de fuentes oficiales y la aplicación de la técnica de análisis comparado. Con este documento de trabajo se busca ampliar la base de conocimiento general sobre la urgencia de poner la agenda de cuidados en el centro de las decisiones públicas. Sólo a través de una comprensión más amplia de los aportes materiales y económicos que supone el trabajo de cuidados y de la necesidad de proteger a quienes lo realizan podremos empujar la frontera del conocimiento sobre la relación entre seguridad social y cuidados.

B. La seguridad social: del paradigma laboralista al reconocimiento como derecho humano

Hablar de seguridad social a menudo implica entrar en debates teóricos y conceptuales de gran relevancia. Desde su origen hace ya más de un siglo e incluso hasta la actualidad, sigue despertando diferentes dudas y cuestionamientos vinculados especialmente a su alcance, prestaciones incluidas, financiamiento y hasta asuntos relativos a la diversidad de formas que adopta su recepción normativa en cada uno de los estados nacionales. A pesar de que el largo camino recorrido por la seguridad social es amplio y robusto, presenta todavía decisivas aristas que son necesarias de analizar. En particular, las vinculadas a su diseño, que no recoge la perspectiva de género y de cuidados, y su relación interdependiente con el derecho a cuidar, recibir cuidados y autocuidarse.

La conexión entre la seguridad social y el mercado laboral ha existido desde sus inicios. Resulta difícil separar completamente la seguridad social del ámbito laboral. No obstante, es crucial reconocer que el acceso a la seguridad social

no debería depender exclusivamente del trabajo.¹ Este “paradigma laboralista” ha marcado a la seguridad social a lo largo de su desarrollo teniendo esto una gran cantidad de implicaciones críticas para lograr su universalización. Ciertamente el paradigma laboralista ha limitado el alcance de las prestaciones de la seguridad social.² Para una gran parte de la doctrina —y de las políticas públicas— la seguridad social sigue estando sujeta a la condición laboral de las personas, pudiendo acceder al disfrute de sus prestaciones (y, por lo tanto, a la protección ofrecidas por éstas) sólo quienes se desempeñan bajo condiciones de empleo formal y asalariado. Esto es un motivo de tensión entre el enfoque de derechos humanos y la actual traducción institucional de las condiciones de acceso a la seguridad social.

El origen de la seguridad social se encuentra en la respuesta a las necesidades sociales y económicas de diferentes épocas. Para algunos autores, la seguridad social “es el resultado de un largo proceso histórico derivado del estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad”.³ Aunque las formas específicas y los enfoques varían, los sistemas de seguridad social surgieron para abordar ciertos desafíos comunes, como la pobreza, la enfermedad, la vejez y otros riesgos sociales.

El concepto moderno de seguridad social comenzó a tomar forma en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial en Europa. A medida que las condiciones laborales cambiaron y surgieron problemas sociales relacionados con la industrialización, como la explotación laboral, las lesiones en el trabajo y la pobreza generalizada, surgió la necesidad de crear mecanismos para proteger a las personas trabajadoras y a la sociedad en general. Karl

¹ Sánchez-Belmont, M., Ramírez, M. Á. y Romero, F., *Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS*, Conferencia Interamericana de Seguridad Social. México, CISS (Cuadernos de historia, teoría y bienestar, 2), 2019.

² Carpenter, S. *et al.*, “Sistemas previsionales con enfoque de género en América Latina y el Caribe: una cuestión de igualdad”, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 2022.

³ Nugent, R., “Capítulo 33 La Seguridad Social: su Historia y sus Fuentes”, en *Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social*, México, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

Polanyi, sociólogo y economista, propuso la idea de que la mercantilización del trabajo humano, que tuvo lugar durante la era industrial y la expansión del capitalismo, generó una reacción contraria. De acuerdo con él, la búsqueda de beneficios económicos y la creciente comercialización de la fuerza laboral llevaron a una serie de consecuencias perjudiciales para las personas y la sociedad en general.⁴ Esta mercantilización, según Polanyi, condujo a la explotación laboral, la inseguridad en el empleo y condiciones de trabajo precarias. En respuesta a estos desafíos, surgieron movimientos y políticas que buscaban proteger a los individuos y a la sociedad de los impactos negativos de la economía de mercado. Este proceso de “contramovimiento” incluía la promulgación de leyes laborales, regulaciones y la creación de sistemas de seguridad social.

Y es que las personas nos enfrentamos a diferentes circunstancias a lo largo del ciclo de vida que pueden afectarnos negativamente y frente a las cuales no es posible una respuesta individual. La seguridad social emerge, entonces, como un mecanismo que procura ofrecer cierta protección a dichas circunstancias adversas. Esto es lo que la literatura ha denominado “contingencias” o “riesgos sociales”. Ruezga Barba identifica a los riesgos sociales como ciertas contingencias que afectan la salud, la vida, la capacidad laboral y los ingresos económicos necesarios para llevar una existencia digna.⁵ Con el propósito de resguardar a las personas frente a estos riesgos, reducir su vulnerabilidad, fortalecer sus capacidades de respuesta y compensar los daños sufridos, se establecen sistemas de seguridad social.⁶

Esping-Andersen señala tres constantes que definen lo que constituye un riesgo social: cuando el destino de un individuo repercute en consecuencias

⁴ Polanyi, K., *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, 2ª. ed., Boston, Mass., Beacon Press, 2001.

⁵ Ruezga Barba, A., *Seguridad social: una visión latinoamericana*, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 2009.

⁶ Sánchez-Belmont, M., Ramírez, M. Á. y Romero, F., *Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS*, Conferencia Interamericana de Seguridad Social. México, CISS (Cuadernos de historia, teoría y bienestar, 2), 2019.

colectivas; cuando la sociedad reconoce la necesidad de abordar colectivamente ciertos riesgos y cuando la complejidad social propicia la aparición de riesgos que surgen más allá del control individual.⁷ Ahora bien, lo que en cierta época se definió socialmente como riesgo no es algo intransigente e inamovible; al contrario, es una conceptualización dinámica que implica procesos sociales complejos vinculados a intereses y preferencias de la sociedad que avanza y evoluciona con el paso del tiempo. En este sentido, en la literatura se mencionan los “nuevos riesgos sociales”. Los nuevos riesgos sociales son conceptos que han surgido o evolucionado en respuesta a cambios en la sociedad, la economía y la tecnología. Estos riesgos reflejan las complejidades y desafíos emergentes que enfrentan las personas y las comunidades en la actualidad. Suelen identificarse como nuevos riesgos sociales el cambio climático, los desastres naturales, las crisis ambientales o las crisis migratorias, entre otros. Por ello, es crucial incorporar de manera explícita a los esquemas de seguridad social, aquellos riesgos que previamente no se tomaban en consideración.⁸

Uno de los hitos fundamentales en la historia de la seguridad social a nivel mundial fue la creación del sistema de seguridad social en Alemania por parte de Otto von Bismarck en la década de 1880. Este sistema proporcionaba beneficios a los trabajadores en caso de enfermedad, accidentes y vejez. Otros países europeos adoptaron sistemas similares en las décadas siguientes. Cabe enfatizar que estos beneficios alcanzaban, justamente, sólo a quienes estaban en una relación laboral, de empleo, es decir, a “trabajadores”. Esto excluía a todas las otras personas de la protección de dichas prestaciones. Dicha exclusión también alcanzaba a las mujeres que en aquella época no formaban parte, al menos no masivamente, del mercado laboral. Esta situación hizo que, tanto en América como en el resto de los continentes, la seguridad social

⁷ Esping-Andersen, G., *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Oxford, New York, Oxford University Press, 1999.

⁸ Sánchez-Belmont, M., Ramírez, M. Á. y Romero, F., *Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS*, Conferencia Interamericana de Seguridad Social. México, CISS (Cuadernos de historia, teoría y bienestar, 2), 2019.

haya tenido una traducción institucional como parte del derecho laboral⁹ con todas las implicaciones negativas que tal enfoque supone.

Es de vital importancia reconocer que el empleo formal no puede constituir la única vía para acceder a las prestaciones de seguridad social. Esta consideración cobra gran relevancia en América Latina y el Caribe, donde una considerable proporción de personas trabajadoras se desempeña en el ámbito informal.¹⁰ Además, es imperativo prestar una atención especial a la inclusión de grupos que históricamente han sido excluidos o discriminados por diversas razones.¹¹ De hecho, Sánchez-Belmont *et al.* invitan a considerar una arista central de este debate: “reflexionar qué se considera trabajo, más allá del empleo formal, que es sólo una de sus variantes”.¹²

Y es así como el desarrollo del paradigma laboralista acompañó, desde sus inicios, a la seguridad social. Un verdadero hito en este recorrido fue, sin lugar a duda, el reconocimiento expreso de la seguridad social como un derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, en su artículo 22, establece lo siguiente:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales

⁹ Townsend, P. (ed.), *Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development*, New York, Geneva Switzerland, Palgrave Macmillan, 2009.

¹⁰ De acuerdo con el Informe Panorama Laboral 2022 de América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de informalidad regional (promedio de 11 países) es de casi 50 por ciento. OIT, Panorama Laboral 2022 de América Latina y el Caribe, OIT, Perú, 2022. Disponible en «https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/documents/publication/wcms_867497.pdf». [Consultado el 22 de enero de 2024].

¹¹ Sánchez-Belmont, M., Ramírez, M. Á. y Romero, F., *Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS*, Conferencia Interamericana de Seguridad Social. México, CISS (Cuadernos de historia, teoría y bienestar, 2), 2019. p. 10.

¹² *Ibidem*, p. 11

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.¹³

Este artículo enfatiza el derecho a la seguridad social como un componente esencial de los derechos económicos, sociales y culturales. Destaca la responsabilidad tanto en los ámbitos nacional como internacional para garantizar la satisfacción de estos derechos, considerándolos indispensables para preservar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. La cooperación internacional es subrayada como un medio para lograr estos objetivos, reconociendo la interconexión de los derechos humanos en un contexto global.

Por su parte, en 1952 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el Convenio 102, conocido como la Norma Mínima de Seguridad Social. Fue adoptado el 28 de junio de 1952 durante la 35ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Este convenio establece estándares mínimos internacionales para los sistemas de seguridad social. Reconoce las siguientes nueve prestaciones: asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, maternidad, invalidez y discapacidad, y sobrevivientes.¹⁴

Otro de los acontecimientos significativos en esta etapa de reconocimiento fue la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por las Naciones Unidas. El PIDESC fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor en 1976. La seguridad social se encuentra explícitamente

¹³ Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, United Nations, 1948. Disponible en «<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

¹⁴ Organización Internacional del Trabajo, “Convention C102–Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)”, 1958. Disponible en: «https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312247,es». [Consultado el 19 de octubre de 2023].

reconocida en el artículo 9 del PIDESC. Dicho artículo establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.¹⁵

Este reconocimiento significa que los Estados que son parte en el Pacto tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción tengan acceso a la seguridad social. Según este tratado, la seguridad social abarca medidas que garanticen la protección contra la falta de ingresos debido a enfermedad, discapacidad, desempleo, vejez u otras circunstancias que resulten en la pérdida de medios de subsistencia por razones ajenas a la voluntad de la persona.

Además de la DUDH y el PIDESC, otros documentos y declaraciones internacionales también respaldan el reconocimiento de la seguridad social como un derecho humano. En el ámbito interamericano, se cuenta con el denominado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como el “Protocolo de San Salvador”. Este protocolo fue adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Es un complemento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como la “Convención de San José”), que es un tratado internacional que establece los derechos civiles y políticos en la región de las Américas.

El Protocolo de San Salvador incluye disposiciones específicas relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. En el ámbito de la seguridad social, el Protocolo establece en su artículo 9 que

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o

¹⁵ Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Disponible en: «<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.¹⁶

Este reconocimiento fortalece la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito americano y subraya la importancia de garantizar condiciones de vida dignas y el bienestar de las personas. Sin lugar a duda, fortalece los mecanismos de protección y garantías dentro del sistema interamericano de derechos humanos.

La particularidad de los instrumentos internacionales de reconocimiento de la seguridad social como derecho humano es que establecen claramente que es un derecho de las personas, es decir, no dice trabajador o trabajadora sino persona. Esto implica una superación del paradigma laboralista —al menos en el aspecto normativo— dejando de lado el estatus laboral de las personas como condición para acceder a las prestaciones de seguridad social. Se trata de un gran avance en la construcción de un paradigma basado en el enfoque de derechos; sin embargo, hasta la actualidad los diferentes Estados de la región siguen condicionando el acceso a la seguridad social a la situación laboral de las personas.

En la publicación “Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS”, las personas autoras mencionan que una característica de los artículos de estos instrumentos internacionales es la falta de precisión con la que fueron redactados. En particular exponen que “no se establece con claridad qué prestaciones debería incluir la seguridad social”.¹⁷ Sobre este punto aluden a las diferentes posibles razones de esta llamativa imprecisión: tensiones entre diferentes posturas sobre el alcance de la seguridad social, limitaciones estructurales de los Estados para poder garantizar adecuadamente universalidad o incluso la realidad cambiante y dinámica de la definición de los riesgos sociales

¹⁶ Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1988.

¹⁷ Sánchez-Belmont, Ramírez y Romero, *op. cit.*, p. 51.

protegidos. Por todo ello, la CISS propone una definición de seguridad social en los siguientes términos:

Un derecho humano que tiene como objetivo contribuir al bienestar personal y social, y que comprende un conjunto de transferencias y servicios de carácter solidario y público, cuya responsabilidad fundamental recae en el Estado, y que buscan proteger a los individuos y las colectividades ante riesgos sociales, que reducen la vulnerabilidad social y promueven la recuperación ante las consecuencias de un riesgo social materializado, dignificando así las distintas etapas de la vida, y promoviendo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad social.¹⁸

Tal como se puede apreciar en esta propuesta conceptual, la seguridad social no está vinculada a la situación laboral de las personas y su protección alcanza ante cualquier riesgo social materializado. Sin duda, en el aspecto teórico supone un avance sustancial y funciona como una guía de utilidad en los debates regionales sobre la conceptualización y alcances de la seguridad social.

I. La seguridad social en el derecho mexicano

En el contexto de México, el reconocimiento de la seguridad social se encuentra, mayormente, consagrado como un derecho laboral en el artículo 123 de su Constitución. Este artículo establece que la Ley del Seguro Social se considera de utilidad pública y tiene como objetivo establecer seguros destinados a promover el bienestar y protección de los trabajadores. Además, se menciona que la seguridad social debe abarcar aspectos como la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte, entre otros, asegurando una cobertura amplia y brindando protección integral a los trabajadores en diversas etapas de sus vidas laborales y personales.¹⁹

¹⁸ *Ibidem*, p. 74.

¹⁹ García Guzmán, M., "Derecho a la seguridad social", *Estudios Políticos*, (32), 2014 pp. 83-113. Disponible en: «[https://doi.org/10.1016/S0185-1616\(14\)70582-7](https://doi.org/10.1016/S0185-1616(14)70582-7)».

De un rápido análisis del texto constitucional, es posible identificar la vigencia del paradigma laboralista en su texto. Por ejemplo:

Artículo 4º: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. [...] La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.²⁰

Este artículo, si bien versa centralmente sobre el derecho a la salud y dado que ésta es una de las prestaciones de un sistema de seguridad social, expresa que para las personas que no cuenten con acceso a dicha protección se definirá un sistema de salud “para el bienestar”. Esta enunciación pone de manifiesto que no todas las personas son alcanzadas por la protección de la seguridad social de acuerdo con este artículo. Además, la misma configuración de los alcances y contenidos del artículo 123, donde vienen regulados todos los derechos laborales de “los trabajadores”, deja entrever la estrecha vinculación entre el acceso y disfrute de prestaciones de seguridad social y el estatus laboral de las personas.

De hecho, es conocido que la seguridad social en México está gestionada principalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas instituciones proporcionan servicios de salud, pensiones y otros beneficios y prestaciones a los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Bajo esta configuración, no todas las personas tienen acceso a ella. Existen también programas específicos para ciertos grupos, como el Programa IMSS-Bienestar, que atiende a población sin acceso a prestaciones de seguridad social, en particular, al servicio de salud.

Sin embargo y dado que México ha firmado tratados y pactos internacionales que, sí reconocen el derecho humano a la seguridad social, es importante

²⁰ Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023.

dejar en claro que, por la vigencia del control de convencionalidad, el país no puede abstraerse de sus responsabilidades de garantizar dicho derecho para todas las personas. En este sentido se expresan Morales Ramírez y Apáez Pineda cuando manifiestan que

[...] el bloque de constitucionalidad se integra por las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos y se complementa con aquellas que son resultado de su interpretación nacional e internacional, con lo que se genera un núcleo de normas de derechos humanos integradas a partir de sedes y fuentes diversas.²¹

La consideración del bloque de constitucionalidad como herramienta crítica para poder ofrecer la más amplia y completa protección a las todas las personas es central a la hora de abordar el derecho a la seguridad social. De la misma forma lo es la aplicación de la metodología del enfoque de derechos humanos, como base para la exigibilidad y justiciabilidad directa del derecho a la seguridad social. Estos mismos criterios y herramientas serán claves para el abordaje del derecho al cuidado y la interrelación entre ambos.

Antes de cerrar esta sección es importante dar cuenta de un interesante —y reciente— debate que se está dando en la región respecto a la seguridad social y los cuidados.

Dicha discusión está relacionada con el hecho de que el trabajo de cuidados debería considerarse un nuevo riesgo social (o no) y, por lo tanto, debe ser alcanzado por la protección de las prestaciones de seguridad social. Tal como se explicó previamente, el término “riesgo social” se ha asociado con situaciones o condiciones que pueden tener consecuencias negativas para el bienestar de los individuos o la sociedad en general. En este sentido, el cuidado podría ser considerado un riesgo social en situaciones donde la

²¹ Morales Ramírez, M. A. y Apáez Pineda, Ó. J., *El impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social de México*, Ciudad de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018, p. 38.

falta de acceso o la insuficiencia de servicios de cuidado pueda tener efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, en sociedades donde no hay suficientes servicios de cuidado infantil, el cuidado de las infancias puede convertirse en un riesgo social para los padres y madres que enfrentan dificultades para equilibrar el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares. Del mismo modo, la falta de servicios de cuidado para personas mayores o con discapacidades podría considerarse un riesgo social para quienes deben cuidar de ellos.

Es importante señalar que la perspectiva sobre si el cuidado es un riesgo social puede variar y dependerá de cómo se aborden los aspectos relacionados con la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de cuidado en una determinada sociedad. Además, no existen suficientes acuerdos para conceptualizar al cuidado sólo como riesgo social. De hecho, hay una parte de la academia que identifica al cuidado como el cuarto pilar del Estado de Bienestar (junto con la salud, la educación y la seguridad social), argumentando que la noción de contingencia o riesgo es bastante limitada para las implicaciones reales del cuidado. Se han expresado en este último sentido importantes académicas de América Latina, tales como Karina Batthyány, Laura Pautassi y Patricia Cossani, entre otras.²²

C. El cuidado como trabajo y como derecho

La academia feminista ha sido el lugar desde donde se han producido las mayores contribuciones al estudio de los cuidados en los últimos 30 años. Si bien el tema de los cuidados podría ser para algunas personas un “tema novedoso”, lo cierto es que desde hace décadas tanto la academia feminista anglosajona como la de América Latina viene produciendo en forma ininte-

²² La Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en conjunto con la Alianza Global por los Cuidados, organizó a lo largo del 2023 un ciclo de conversatorios denominado “Cuidados ¿Nuevo riesgo social o cuarto pilar del Estado de Bienestar? Un debate regional necesario”. El ciclo tuvo tres rondas de conversaciones con personas expertas tanto de la agenda de cuidados como de seguridad social. Se pueden ver las grabaciones en el canal de YouTube de la CISS.

rrumpida teoría, conceptos y evidencia a nivel agregado sobre el problema público de los cuidados. Los estudios de género han sido pioneros en destacar la desigualdad de género en la distribución del trabajo de cuidado. Investigadoras como Nancy Folbre, Diane Elson o incluso la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin, han abordado la economía del cuidado y han argumentado que el trabajo de cuidado no remunerado es esencial para el funcionamiento de la economía.

Batthyány y Genta²³ sostienen que la academia latinoamericana, en particular la vinculada a la producción del cono sur (Uruguay y Argentina), ha promovido fuertemente la identificación del cuidado como un “trabajo”. En primer lugar, es importante destacar que la identificación del cuidado como un trabajo implica la superación del ideal “maternalista y familista” que identifica que se trata de tareas que generalmente hacen las mujeres en forma voluntaria y “por amor”. Pero el acto de cuidar involucra una inversión de tiempo con oportunidades alternativas de uso, implica la asignación de tareas entre aquellas de naturaleza manual e intelectual, y el resultado final no está vinculado directamente a la persona que realiza dichas tareas.²⁴ Todas estas características, de acuerdo con Genta, lo asimilan a un trabajo. La crítica subyacente a este posicionamiento es que no se recibe una remuneración por esta actividad. Sin embargo, es sabido que el cuidado puede o no ser remunerado sin que ello invalide su característica de trabajo. En todo caso el trabajo de cuidados remunerado podría identificarse como empleo, adonde media una relación laboral entre quien paga por el servicio de cuidados y quien lo brinda a cambio de un salario.

Uno de los hitos en el reconocimiento del cuidado como trabajo ha sido el posicionamiento de la OIT sobre este tema. Sobre todo, teniendo en cuenta

²³ Batthyány, K. y Genta, N., “Sociología de género y cuidados en Uruguay: el camino recorrido”, en *Políticas públicas para la equidad social*, vol. 1, 2018, pp. 127-136. Disponible en: «<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7689555>». (Consultado el 14 de abril de 2022).

²⁴ Genta, N., “Clase 7: Recorridos de los cuidados en Latinoamérica”. Curso Debates conceptuales y metodológicos sobre el cuidado. Especialización en políticas de cuidados con enfoque de género, CLACSO, 2021.

que es una de las organizaciones internacionales de mayor peso en la agenda global del trabajo y el empleo. La OIT se expresa en los siguientes términos:

El trabajo de cuidados comprende dos tipos de actividades superpuestas: las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El trabajo de cuidados no remunerado consiste en la prestación de cuidados por parte de cuidadoras y cuidadores no remunerados sin recibir una retribución económica a cambio. La prestación de cuidados no remunerada se considera un trabajo, por lo que es una dimensión fundamental del mundo del trabajo. El trabajo de cuidados remunerado es realizado por trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de trabajadores de los servicios personales, como el personal de enfermería, el personal médico, y los trabajadores y trabajadoras del cuidado personal. Las trabajadoras y trabajadores domésticos, que prestan cuidados tanto directos como indirectos en los hogares, también integran la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados.²⁵

Tal como se puede ver, la complejidad del trabajo de cuidados exige la necesidad de establecer criterios, tipos y definiciones en relación con las personas que se dedican a él. Se puede observar una división en dos categorías superpuestas: el cuidado directo indirecto; a su vez, el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Y finalmente la decisión de sólo llamarle “trabajadoras y trabajadores del cuidado” a quienes lo hacen en forma remunerada. De hecho, este último aspecto no está libre de controversias.

Ahora bien, identificar al cuidado como un trabajo —y demostrar sus implicaciones materiales para quienes cuidan— no implica desconocer su conceptualización como derecho humano. Al contrario, se trata de dos as-

²⁵ Organización Internacional del Trabajo, El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, OIT, 2019. Disponible en: «http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang-es/index.htm». [Consultado el 23 de octubre de 2023].p. 27.

pectos relacionados. No son incompatibles ni muchos menos antagónicos. Lo cierto es que el recorrido de su conceptualización como derecho humano es relativamente reciente; a pesar de su corto camino recorrido, ha ganado un importante terreno en el ámbito normativo tanto internacional como en muchos países de América Latina y el Caribe, en particular en la última década.

La referencia obligada en este recorrido es el trabajo de Laura Pautassi, académica feminista, quien en 2007 presentó, en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer²⁶ en Quito, uno de los documentos antecedentes clave del derecho al cuidado: *El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos*. En este documento de trabajo, editado y publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pautassi expone, por primera vez, la fundamentación teórica que reconoce la existencia de un “derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse”. Al respecto, expresa:

El derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse [...] implica un conjunto de obligaciones negativas, características de los derechos económicos sociales y culturales, como no entorpecer los servicios de guarderías infantiles, no impedir el acceso de un adulto mayor al sistema de salud; pero principalmente incluye obligaciones positivas, que se enrolan en proveer los medios para poder cuidar, en garantizar que el cuidado se lleve adelante en condiciones de igualdad y sin discriminación y que no solo se concedan para un grupo reducido —por caso vinculado al empleo asalariado formal— sino que sean garantizados a todas las ciudadanas y los ciudadanos.²⁷

²⁶ La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe “es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Es organizada por la CEPAL, como Secretaría de la Conferencia y, desde 2020, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)” (CEPAL, s. f.). Es importante destacar que en este órgano se reúnen los Estados miembros de la CEPAL y aprueban compromisos que constituyen la llamada “Agenda Regional de Género”, una hoja de ruta para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sus reuniones son bianuales o trianuales.

²⁷ Pautassi, L. C., *El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos*, CEPAL, 2007. Disponible en: «<https://hdl.handle.net/11362/5809>». [Consultado el 23 de octubre de 2023].

Este extracto enfatiza tanto en las obligaciones negativas (abstenerse de hacer) como las positivas en el ámbito del cuidado. Estas últimas se centran en proporcionar los medios necesarios para llevar a cabo el cuidado, garantizando que éste se realice en condiciones de igualdad y sin discriminación. Un aspecto clave es la insistencia en que estas obligaciones no deben limitarse a un grupo específico, como aquellos vinculados al empleo asalariado formal, sino que deben ser garantizadas para todas las personas. En conjunto, el texto aboga por un enfoque integral que no solo reconozca los derechos inherentes al cuidado, sino que también establezca las responsabilidades asociadas para asegurar una sociedad justa e igualitaria.

Pautassi reconoce que aquel “momento fundacional” abrió una nueva etapa en la interpretación normativa al constatar el alcance del cuidado como un derecho humano. Agrega que a partir de ese momento “ya no solo el cuidado es un problema, es un trabajo —remunerado y no remunerado— y es un derecho humano que, denominado o no como tal, es de cumplimiento obligatorio para los Estados”.²⁸ Al respecto manifiesta:

Este reconocimiento incorpora no sólo una definición poderosa asociada a su carácter de derecho humano, sino que establece responsabilidades, garantías y satisfactores; otorga un papel central al Estado, pero también establece obligaciones para el sector privado, para los mercados y en los ámbitos comunitarios. Además, ubica a los varones como prestadores directos de sus obligaciones en torno al cuidado y como activos partícipes del bienestar.²⁹

De esta forma se establece claramente la responsabilidad pública en la provisión de los cuidados como así también el principio de la corresponsabilidad de género en la producción y distribución de todo el cuidado que requiere la sociedad.

²⁸ Pautassi, L., *El derecho al cuidado. De la conquista a su ejercicio efectivo*, México, Friedrich Ebert Stiftung (FES) 2023, p. 7.

²⁹ *Ibidem*, p. 5.

D. El enfoque de derechos aplicado al cuidado

Para poder llegar a estas conclusiones, se aplicó lo que se conoce como la “metodología de enfoque de derechos humanos”; que a su vez está estrechamente relacionado con el enfoque de derechos en las estrategias del desarrollo. Abramovich lo define en los siguientes términos:

El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento.³⁰

Introduciendo este concepto, se busca transformar la lógica de la formulación de políticas, alejándose de la noción de asistir a personas con necesidades para reconocer a individuos como sujetos con el derecho a exigir prestaciones y conductas específicas. Las acciones propuestas en este ámbito se considerarán como la vía para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles establecidas por los tratados de derechos humanos. Y es que el reconocimiento de derechos demanda la existencia de mecanismos efectivos para hacer exigibles y cumplir esas obligaciones. En esencia, este enfoque aboga por un cambio de paradigma hacia un modelo más proactivo y legalmente vinculante en la promoción y protección de los derechos humanos.

³⁰ Abramovich, V., *Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo*, CEPAL, 2006. Disponible en: «<https://hdl.handle.net/11362/11102>». [Consultado el 24 de octubre de 2023].

Ahora bien, el enfoque de derechos humanos aplicado al cuidado, según Pautassi, se fundamenta en un conjunto de principios y estándares legales que incluyen:

- Universalidad.
- Obligación de asegurar el contenido mínimo de los derechos.
- Obligación de los Estados de implementar acciones y medidas que reconozcan la progresividad en sus acciones y prohíban medidas o acciones regresivas.
- Deber de garantizar la participación ciudadana.
- Principio de igualdad y no discriminación.
- Acceso a la justicia.
- Acceso a la información pública.
- Participación social y empoderamiento de las personas titulares de derechos.³¹

A su vez, menciona que cada uno de estos estándares ha sido desarrollado por diversos mecanismos de monitoreo internacional, como los Comités de los Pactos, o el trabajo de relatoras y relatores, así como expertas y expertos de Naciones Unidas para cada derecho. Ahora bien, una idea esencial en el enfoque de derechos es su interdependencia e indivisibilidad. Esto significa que no es factible separar el goce de las diversas formas de garantías, ya sean civiles, políticas, económicas, sociales o culturales.³²

³¹ Pautassi, *op. cit.*, 2007; Pautassi, *op. cit.*, 2023.

³² Sánchez-Belmont, Ramírez y Romero, Pautassi, *op. cit.*, 2019.

Este aspecto es central para poder comprender las formas en la cual se relacionan el derecho a la seguridad social y el derecho al cuidado.

E. El reconocimiento del derecho al cuidado en instrumentos internacionales

De acuerdo con Pautassi,³³ diferentes instrumentos de derechos humanos fueron sentando las bases para la inclusión del cuidado como un derecho humano y trazando un robusto camino interpretativo respecto a su alcance y contenidos. A continuación, algunos de los mismos, presentes en instrumentos internacionales.

Artículo 3, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados parte se comprometen a: asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él [...]”.³⁴

Artículo 28, inciso 2 C, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.³⁵

Artículos 12 y 7 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores:

³³ Pautassi, *op. cit.*, 2023.

³⁴ Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Disponible en: «<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

³⁵ Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 2007.

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados [...]. Los Estados Parte [...] en especial, asegurarán: [...] c) que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad [...].³⁶

Tal como se mencionó previamente, otro de los mecanismos utilizados fueron las conferencias regionales de la mujer, que son un instrumento del sistema de Naciones Unidas para el adelanto de la agenda de género en América Latina y el Caribe. Estas instancias han sido claves para promover el derecho al cuidado en el marco de acuerdos intergubernamentales a nivel regional. De la ya mencionada Conferencia de Quito en 2007 en adelante se profundizaron los compromisos alcanzados en la agenda de cuidados hasta la más reciente, celebrada en Buenos Aires en 2022.

Por ejemplo, los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, reunidos en Brasilia (Brasil), firmaron el denominado Consenso de Brasilia, que establece lo siguiente:

Reconociendo que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar el carácter indivisible e integral de los derechos humanos, incluido el derecho al cuidado [...] Señalando que el derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el sector privado.³⁷

Por su parte, el tema principal de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en 2022 en Buenos Aires (Argentina), fue “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación

³⁶ *Idem*.

³⁷ Consenso de Brasilia, 2010.

sostenible con igualdad de género”. Ya desde el título se preveía un fuerte posicionamiento político sobre la agenda de cuidados. Y en efecto, los Estados miembros de la CEPAL participantes de la Conferencia firmaron el Compromiso de Buenos Aires, que “propone un camino para avanzar hacia la sociedad del cuidado, con acuerdos en áreas novedosas para una recuperación transformadora con igualdad de género y sostenibilidad”.³⁸ En particular el punto 8 del documento manifiesta:

Reconocer el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado.³⁹

Con este sintético recorrido se cubrió gran parte de la evidencia normativa a nivel regional que demuestra la existencia del derecho al cuidado en los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En la sección siguiente se presentan, además, casos específicos de avances normativos a nivel país y avances en políticas públicas que reconocen la interdependencia de este derecho con la seguridad social. Cabe mencionar que en este recorrido no se han incluido otras fuentes interpretativas como, por ejemplo, las numerosas observaciones y recomendaciones provenientes de los mecanismos de monitoreo de cada uno de los Pactos, por caso el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) o la misma CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), en donde también es posible identificar el reconocimiento del derecho al cuidado.

³⁸ CEPAL, Compromiso de Buenos Aires, 2022.

³⁹ *Idem*.

F. Cuidados y seguridad social: de la paradoja a la interdependencia

La agenda de cuidado presenta una particularidad muy peculiar frente a otros problemas públicos: su complejidad y múltiples manifestaciones y aristas exigen una respuesta pública-estatal de gran alcance y a nivel interinstitucional. Es por lo que la principal demanda de los movimientos sociales que tiene como bandera a los cuidados, es que piden respuestas integrales a este asunto (y no sólo soluciones parciales y atomizadas). A pesar de que la sensación generalizada pueda ser que el cuidado no haya estado presente en la política pública a lo largo de la historia, es posible identificar las regulaciones de cuidados en espacios “tradicionales” tales como la legislación civil, de familia y, sobre todo, en la materia de seguridad social.

Existen diversas formas de clasificar las políticas públicas de cuidado, y una de ellas distingue entre políticas de tiempo para cuidar, políticas de dinero por cuidar y servicios de cuidados.⁴⁰ El tiempo remunerado para cuidar con las licencias de cuidado (maternidad, paternidad o parentales) ha estado tradicionalmente dentro de los esquemas de seguridad social. Por su parte, en algunos esquemas de aseguramiento, ciertos servicios de cuidados forman parte también de las prestaciones previstas de la seguridad social (por ejemplo, estancias infantiles o casas de día para personas mayores). Finalmente, en el caso de las políticas de dinero para cuidar (transferencias), cuando existen, han estado históricamente incluidas dentro de prestaciones de seguridad social.

Ahora bien, si se analiza la situación de los países de la región, es claro identificar cómo el diseño de la seguridad social (a través de la normativa vigente) divide entre quienes pueden contar con licencias y/o servicios de cuidados a partir de si cuentan o no con seguridad social, lo que a su vez significa, en la mayoría de los casos, que son una persona trabajadora asalariada for-

⁴⁰ Batthyány, *op. cit.*

mal. Quienes no cumplen con estas condiciones, no pueden acceder a estas prestaciones de cuidados. Se observa una falta de cumplimiento tanto del derecho a la seguridad social como del derecho al cuidado.

En la publicación *De beneficiarias a ciudadanas: acceso y tratamiento de las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina*, se señala que la aparente gratuidad del cuidado que se produce y distribuye dentro de las familias no es tal. Se explica que, aunque este cuidado no genera costos directos para los Estados ni para quienes reciben el cuidado, impone un costo significativo y permanente a las mujeres en términos de tiempo, calidad de vida y salud. Este costo se manifiesta principalmente como un costo de oportunidad para las mujeres, quienes ven afectada su libertad de emplear su tiempo en otras actividades por dedicarse al cuidado no remunerado. De aquí la expresión de que “las mujeres subsidian los sistemas de seguridad social”. Esto es lo que la literatura ha señalado como “relación paradójica entre los cuidados y la seguridad social”, donde la contribución significativa de las mujeres con su trabajo de cuidado no remunerado no ha sido reconocida y abordada en el diseño de políticas y sistemas de seguridad social.⁴¹

En la publicación *Políticas de cuidados y seguridad social. Sistematización de buenas prácticas de políticas que reconozcan el trabajo de cuidado como vía de acceso a prestaciones de seguridad social*, la CISS desarrolla y fundamenta una contundente crítica al diseño de los sistemas de seguridad social “que funcionan bajo el supuesto de un hombre proveedor sin responsabilidades de cuidado familiar y una mujer que asume todo el trabajo de cuidados en forma no remunerada”.⁴² Al basarse en estereotipos de género, el diseño de la seguridad social no puede ofrecer una protección adecuada, justa y completa

⁴¹ Pautassi, *op. cit.*, 2002; Marco Navarro, F., *La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género en América Latina*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Serie Asuntos de Género, 139), 2016; Pautassi, L. y Marco Navarro, F., “La compensación del cuidado en los sistemas de pensiones en América Latina”, *Revue internationale des études du développement*, 242(2), 2020, pp. 143-165. Disponible en: «<https://doi.org/10.3917/ried.242.0143>».

⁴² Jiménez Brito, L., *Políticas de cuidados y seguridad social. Sistematización de buenas prácticas de políticas que reconozcan el trabajo de cuidado como vía de acceso a prestaciones de seguridad social*, CISS, 2023.

a todas las personas. Una de las dimensiones más críticas de este problema de diseño es justamente el señalado por la literatura respecto a que la seguridad social nunca consideró el aporte del trabajo de cuidados no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres. En vista de esto, resulta crítico que los sistemas de seguridad social reconozcan y compensen adecuadamente el valor del cuidado no remunerado, hasta tanto no se cuenten con prestaciones diseñadas bajo un esquema de estricta igualdad. Por lo tanto, y tal cual se expresa en la nota técnica editada por la CISS, “Sistemas previsionales con enfoque de género en América Latina y el Caribe: una cuestión de igualdad”,

es hora de promover un esquema de seguridad social [...] que no sólo busque compensar a las mujeres por el trabajo de cuidados que realizan en forma no remunerada sino más bien que reconozca, desde su diseño, las trayectorias diferenciadas de hombres y mujeres hasta lograr la igualdad.⁴³

Un punto a destacar en este recorrido es la adopción de la Declaración de la CISS, número 115 de 2023, en el Marco de su aniversario 80, que establece en el punto I, inciso “b”: “La ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social debe considerar [...] todas las formas de trabajo, remunerado y no remunerado, a lo largo de todo el ciclo vital”.⁴⁴ Con ello, los Estados miembros reconocieron que la seguridad social debe considerar también al trabajo no remunerado (y no sólo limitarse al asalariado, es decir, al empleo). En este mismo instrumento, en el punto 3, inciso “a” se manifestó respecto al cuidado lo siguiente:

Debemos promover el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y su incorporación como prestación de la seguridad social.

Disponible en: «<https://ciss-bienestar.org/2023/02/27/politicas-de-cuidados-y-seguridad-social/>». [Consultado el 23 de octubre de 2023].

⁴³ Carpenter, S. *et al.*, “Sistemas previsionales con enfoque de género en América Latina y el Caribe: una cuestión de igualdad”, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 2022, p. 25.

⁴⁴ Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Declaración 115 Sobre el acceso universal del ejercicio pleno al derecho a la seguridad social, 2023.

Por consiguiente, alentamos el establecimiento y consolidación de sistemas integrales de cuidado a lo largo de todo el ciclo vital. Esto último implica la provisión de cuidados mediante servicios públicos y la valorización e incorporación a los sistemas de seguridad social de las personas que se dedican a esta forma de trabajo remunerado o no.⁴⁵

La relación entre cuidado y seguridad social es la de interdependencia de derechos, es decir, “no puede ejercerse plenamente uno de ellos sin que esté materializado el otro”.⁴⁶ En dicho documento, inédito al momento de la escritura de este capítulo, se señala que la seguridad social debe posibilitar que las personas cuiden o reciban cuidados, sin que esto signifique un conflicto con su empleo e ingresos, y debe hacer factible también que quienes se dedican a cuidar tengan una cobertura de estos sistemas. En definitiva el acceso a prestaciones de seguridad social contribuye al reconocimiento y redistribución de los cuidados, así como al disfrute de los derechos de las mujeres y de las personas que reciben cuidados y apoyo.

G. Avances normativos y buenas prácticas en américa latina y el caribe

En esta sección se presenta, en forma resumida, una serie de avances normativos específicos sobre el reconocimiento del cuidado como derecho y, además, algunas buenas prácticas de políticas que reconocen el trabajo de cuidado no remunerado como vía de acceso a prestaciones de seguridad social. El objetivo de esta sección es poner de manifiesto cómo se ha dinamizado el tema en toda la región y cómo los Estados han avanzado en forma decisiva hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. Asimismo, también las agencias de cooperación internacional e interamericanas ha contribuido

⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ Conferencia Interamericana de Seguridad Social and Alianza Global por los Cuidados (Manuscrito inédito), “*Amicus Curiae* para la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho al cuidado”.

con este proceso aportando importantes insumos y herramientas para avanzar en la construcción de una sociedad que ponga al cuidado en el centro.

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó en el año 2022 una propuesta normativa marco sobre cuidados. Se trata de la Ley Modelo Interamericana de Cuidados.⁴⁷ Con ella, la OEA, a través de la CIM, busca poner a disposición de los Estados miembros un insumo de utilidad para contribuir al debate legislativo sobre los cuidados en todo el continente. Dicha propuesta normativa marco fue diseñada con base en estándares de derechos humanos y enfoque de género. Además, tiene como objetivo reconocer, redistribuir, regular, promocionar y generar nuevas formas de atención del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, así como visibilizar y reconocer la contribución histórica de las mujeres en esta materia.⁴⁸

Por su parte, recientemente Naciones Unidas también ha sumado acciones contundentes para avanzar en el reconocimiento y la visibilización del cuidado. En el mes de julio del 2023, la Asamblea General decidió proclamar el 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. En la sesión plenaria 93, la Asamblea invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales, así como a otras partes interesadas pertinentes a que celebren anualmente el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo de manera adecuada, a fin de concienciar sobre la importancia de los cuidados y el apoyo y su contribución clave a la consecución de la igualdad de género y la sostenibilidad de sociedades y economías.⁴⁹

Además, en octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó la resolución titulada “Importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos”, en donde reconoce la importancia de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de

⁴⁷ Disponible para su consulta en <https://www.oas.org/es/cim/docs/LeyModeloCuidados-ES.pdf>

⁴⁸ Comisión Interamericana de Mujeres, 2022, p. 5.

⁴⁹ Asamblea General de las Naciones Unidas, 2023.

las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas y de las personas que reciben cuidados y apoyo, al tiempo que insta a los Estados a que apliquen todas las medidas necesarias para reconocer el trabajo de cuidados de tal modo que se promueva la igualdad de género y el disfrute de los derechos humanos por todas las personas.⁵⁰

Ahora bien, existen también algunas conquistas normativas a nivel de los Estados en la región en materia de reconocimiento del cuidado como trabajo, como derecho en diferentes dimensiones. Tempranamente fue la Constitución de Ecuador en el 2008 una de las constituciones pioneras en establecer que el cuidado es un trabajo y, además, productivo. Lo hizo en los siguientes términos:

Art. 333.— Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.⁵¹

Ecuador también presenta el único régimen vigente que permite que las personas que se dedican en forma exclusiva a cuidar no remuneradamente puedan acceder a prestaciones de seguridad social. Se trata del régimen de acceso a prestaciones de seguridad social bajo la órbita del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.

⁵⁰ Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023.

⁵¹ Asamblea General Constituyente del Ecuador, 2008.

Además, y en forma reciente, en el mes de mayo de 2023, se publicó en Ecuador la denominada Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano,⁵² con el objetivo de:

[...] tutelar, proteger y regular el derecho al cuidado de personas trabajadoras respecto de sus hijos e hijas, dependientes directos, otros miembros de su familia directa que componen los diferentes tipos de familia, que de manera evidente necesiten su cuidado o protección, a fin de garantizar su ejercicio pleno, en cumplimiento a la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en la materia.⁵³

En esta legislación se modifica, entre otras cosas, el régimen de licencias de cuidados, extendiéndose, por ejemplo, la de paternidad. Se trata de un avance sustancial en la medida que reconoce al cuidado como un derecho y establece su marco normativo para su ejercicio. Sin embargo, resultado de un rápido análisis de su contenido, es posible advertir que sus disposiciones sólo alcanzan a personas que cuentan con un empleo (trabajo formal asalariado), lo cual representa una limitación para el disfrute y la garantía del derecho al cuidado, que por definición debería ser de carácter universal.

Al comparar, sólo existe una constitución que reconoce expresamente el derecho al cuidado. En la Constitución Política de la Ciudad de México, sancionada en 2017, en el artículo 9, inciso B, se reconoció el derecho al cuidado y se mandató el establecimiento de un sistema de cuidados. Dicha normativa manifiesta:

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles,

⁵² Disponible en: «<https://procuraduria.utpl.edu.ec/NormativaExterna/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DEL%20DERECHO%20AL%20CUIDADO%20HUMANO-2-26.pdf>».

⁵³ Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2023.

pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.⁵⁴

En forma reciente —octubre de 2023— el gobierno de la Ciudad de México publicó el acuerdo por el cual se crea la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados para el Bienestar de la Ciudad de México. Casi en forma inmediata, se celebró la sesión de instalación de dicha comisión, cuyo principal mandato es elaborar la Estrategia de Cuidados para el Bienestar de la Ciudad de México.

En el ámbito federal también hay avances significativos. Actualmente hay una iniciativa de ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, como así también la incorporación del derecho al cuidado al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de haber sido votada favorablemente por la Cámara de Diputados, dicha iniciativa de reforma sigue esperando su tratamiento en el Senado. Por otra parte, el pasado 18 de octubre, el máximo tribunal de justicia federal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, reconoció por primera vez el derecho humano al cuidado. La Primera Sala reconoció que “todas las personas tienen el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado”.⁵⁵ Además, determinó que el derecho al cuidado no debe ejercerse a costa de la salud, el bienestar o el plan de vida de quienes cuidan, especialmente de aquellas personas que, por razones de género, han estado histórica y culturalmente vinculadas a estas labores. Esto, sin dudas, constituye un antes y un después en la defensa del cuidado como un derecho humano.

Finalmente, antes de cerrar esta sección, hay que hacer una mención expresa a las denominadas “medidas compensatorias” ampliamente vigentes en la

⁵⁴ Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2017.

⁵⁵ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2023.

región. Dichas medidas son compensatorias, en el sentido de que “se trata de políticas que buscan retribuir en alguna dimensión a las mujeres por su dedicación al trabajo de cuidados no remunerado, significando aquello el acceso a algunas de las prestaciones de seguridad social”.⁵⁶ Algunos ejemplos de estas medidas son aquellos programas que reconocen años de aportes o cotizaciones previsionales a mujeres que fueron madres o cuidaron a lo largo de su ciclo de vida.

Tal como quedó de manifiesto, existen varios avances normativos de interés que dan cuenta de cómo la agenda de cuidados va tomando posicionamiento en la agenda política a nivel global y regional. Dicho posicionamiento se traduce en estas conquistas legislativas, pero también en programas específicos de política pública que evidencian la corresponsabilidad del Estado frente al problema público de los cuidados.

H. El proceso de opinión consultiva sobre el derecho al cuidado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

A inicios de 2023, el gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre “*El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos*”.⁵⁷ Esta solicitud se realizó en el marco de los esfuerzos del país para sacar adelante una serie de reformas legislativas relativas al Sistema Nacional de Cuidados de Argentina (SINCA).

De acuerdo con el texto presentado por el gobierno argentino, se le solicita a la Corte “determinar con mayor precisión los alcances del cuidado como derecho humano, así como las obligaciones que, al respecto, son exigibles a

⁵⁶ Jimenez Brito, *op. cit.*, p. 23.

⁵⁷ Solicitud completa disponible en: «https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_2_2023_es.pdf».

los Estados”. A lo largo de 25 páginas, la solicitud incluye una serie de preguntas específicas que van desde las obligaciones positivas—y negativas—de los Estados para con el derecho al cuidado, como así también la forma en la cual se establece la interrelación entre este derecho y otros como el derecho a la vida, la salud, la educación e incluso con la seguridad social. Se trata de una solicitud sumamente amplia que abarca una multiplicidad de temas y dimensiones del derecho al cuidado, abriendo una oportunidad histórica para que las personas miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidan sobre los alcances de este derecho. Teniendo en cuenta el actual sistema de protección interamericano de derechos humanos vigente en la región, lo que resuelva la actual Corte puede ser decisivo para el avance normativo favorable al derecho al cuidado.

En general podría decirse que este proceso de opinión consultiva ha movilizado a Estados, sociedad civil, y academia, quienes —al momento de la escritura de este documento— planean participar del proceso bajo la figura de *amicus curiae*. El objetivo es que todas estas instituciones puedan acercar a la Corte elementos que le permitan contribuir en la resolución de la opinión consultiva en cuestión. Es una gran oportunidad para visibilizar las décadas de producción académica feminista, además de los importantes avances normativos conseguidos por los Estados en esta agenda.

I. Conclusiones y llamado a la acción

A lo largo de este capítulo se abordaron, centralmente, dos temas: por un lado, el derecho a la seguridad social, y, por otro, el derecho al cuidado. El repaso y recorrido diferenciado de cada derecho no impidió mostrar y establecer cómo ambos son interdependientes. La seguridad social desde su diseño no consideró los aportes del trabajo de cuidados ni mucho menos a las personas que lo proveen como parte de su alcance en la protección.

Tal como quedó evidenciado, la seguridad social funciona, mayoritariamente, bajo un supuesto basado en estereotipos de géneros que asume que todo el trabajo de cuidados necesario para la supervivencia de la sociedad lo realizará

la familia (en realidad, las mujeres de las familias) en forma no remunerada. El gran problema con esta organización de la provisión y distribución del cuidado es que afecta la igualdad, libertad y dignidad de las mujeres; son ellas quienes sufren las incontables consecuencias de asumir la desproporcionada carga de trabajo de cuidado que les impide usar su tiempo en otras actividades libremente. Las mujeres cuidadoras no sólo no pueden participar de la misma forma que los hombres en el mercado laboral formal, educativo, tiempo libre, etc., sino que tampoco son alcanzadas por las prestaciones de seguridad social.

Las prestaciones, bajo el paradigma laboralista de la seguridad social, sólo alcanzan a las personas trabajadoras formales asalariadas, que en su gran mayoría son hombres. Históricamente las mujeres han accedido a la protección de la seguridad social, en el mejor de los casos, en forma indirecta, a través de su situación conyugal con una persona titular de prestaciones. El cuidado, al no ser reconocido como trabajo y como derecho, excluye a las mujeres del acceso, por propio derecho, a la seguridad social.

Y es por todas estas razones que la crítica central que se elabora desde la CISS es que hay que rediseñar los sistemas de seguridad social para que puedan, en su justa medida, reconocer el aporte del trabajo de cuidados al Bienestar social y extender la protección y alcance de las prestaciones a todas las personas, independientemente de su situación laboral o su forma de trabajo (remunerada o no remunerada).

La relación entre cuidados y seguridad social es la de la interdependencia. El acceso universal a las prestaciones de seguridad social contribuye al reconocimiento y redistribución de los cuidados, así como al disfrute de los derechos de las mujeres y de las personas que reciben cuidados y apoyo.

Finalmente, antes de concluir, es necesario tomar conciencia de que nos toca vivir un momento histórico. Nunca en la historia de la humanidad, la agenda de cuidados había tenido tanto alcance y posicionamiento en la esfera política. Durante décadas permaneció casi exclusivamente en los claustros

universitarios de la mano de la academia feminista; en los últimos años, y sobre todo en la etapa postpandemia por covid-19, la demanda por el reconocimiento del derecho al cuidado y por una organización social del cuidado más justa está más fuerte y presente que nunca. El llamado es a la acción; en particular, a promover en todos los ámbitos que nos toca desempeñarnos el principio de la corresponsabilidad de los cuidados, bajo el cual el trabajo de cuidados debe ser una tarea compartida tanto por hombres como mujeres, como así también reconocer el papel central del Estado en la garantía del derecho a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado.

J. Bibliografía

- Abramovich, V., *Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo*, CEPAL, 2006. Disponible en: «<https://hdl.handle.net/11362/11102>». [Consultado el 24 de octubre de 2023].
- Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad de México, 2017.
- Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Declaración 115 Sobre el acceso universal del ejercicio pleno al derecho a la seguridad social, 2023.
- Asamblea General Constituyente del Ecuador, Constitución Política del Ecuador, 2008.
- Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1988.
- Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2007.
- Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, *Cuaderno Jurídico y Político*, 2(7), 2017, pp. 65-89. Disponible en: «<https://doi.org/10.5377/cuadernojurypol.v2i7.11040>».

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, United Nations, 1948. Disponible en «<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Disponible en: «<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Disponible en: «<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 77/317, 2023.

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, 2023.

Batthyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales*, 2015. Disponible en: «<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/37726>». [Consultado el 18 de octubre de 2023].

Batthyány, K. y Genta, N., “Sociología de género y cuidados en Uruguay: el camino recorrido”, en *Políticas públicas para la equidad social*, vol. 1, 2018, pp. 127-136. Disponible en: «<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7689555>». (Consultado el 14 de abril de 2022).

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023.

Carpenter, S. *et al.*, “Sistemas previsionales con enfoque de género en América Latina y el Caribe: una cuestión de igualdad”, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 2022.

CEPAL, Compromiso de Buenos Aires, 2022.

Comisión Interamericana de Mujeres, Ley Modelo Interamericana de Cuidados, 2022.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social and Alianza Global por los Cuidados (Manuscrito inédito), “Amicus Curiae para la Opinión

- Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho al cuidado”.
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “A/HRC/54/L.6/Rev.1 Importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos”, 2023.
- Consenso de Brasilia, 2010.
- Esping-Andersen, G., *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Oxford, New York, Oxford University Press, 1999.
- García Guzmán, M., “Derecho a la seguridad social”, *Estudios Políticos*, (32), 2014 pp. 83-113. Disponible en: «[https://doi.org/10.1016/S0185-1616\(14\)70582-7](https://doi.org/10.1016/S0185-1616(14)70582-7)».
- Genta, N., “Clase 7: Recorridos de los cuidados en Latinoamérica”. Curso Debates conceptuales y metodológicos sobre el cuidado. Especialización en políticas de cuidados con enfoque de género, CLACSO, 2021.
- Jiménez Brito, L., *Políticas de cuidados y seguridad social. Sistematización de buenas prácticas de políticas que reconozcan el trabajo de cuidado como vía de acceso a prestaciones de seguridad social*, CISS, 2023. Disponible en: «<https://ciss-bienestar.org/2023/02/27/politicas-de-cuidados-y-seguridad-social/>». [Consultado el 23 de octubre de 2023].
- Marco Navarro, F., *La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género en América Latina*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Serie Asuntos de Género,139), 2016.
- Morales Ramírez, M.A. and Apáez Pineda, Ó. J., *El impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social de México*, Ciudad de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018.
- Nugent, R., “Capítulo 33 La Seguridad Social: su Historia y sus Fuentes”, en *Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social*, México, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
- Organización Internacional del Trabajo, “Convention C102–Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)”, 1958. Dispo-

- nible en: «https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312247,es». [Consultado el 19 de octubre de 2023].
- Organización Internacional del Trabajo, El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, OIT, 2019. Disponible en: «http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang-es/index.htm». [Consultado el 23 de octubre de 2023].
- Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2022 de América Latina y el Caribe, OIT, 2022. Disponible en «https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/--ro-lima/documents/publication/wcms_867497.pdf». [Consultado el 22 de enero de 2024].
- Pautassi, L., *Legislación previsional y equidad de género en América Latina*, CEPAL, 2002. Disponible en: «<https://www.cepal.org/es/publicaciones/5898-legislacion-previsional-equidad-genero-america-latina>». [Consultado el 17 de febrero de 2022].
- Pautassi, L., *El derecho al cuidado. De la conquista a su ejercicio efectivo*, México, Friedrich Ebert Stiftung (FES) 2023.
- Pautassi, L. y Marco Navarro, F., “La compensación del cuidado en los sistemas de pensiones en América Latina”, *Revue internationale des études du développement*, 242(2), 2020, pp. 143-165. Disponible en: «<https://doi.org/10.3917/ried.242.0143>».
- Pautassi, L. C., *El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos*, CEPAL, 2007. Disponible en: «<https://hdl.handle.net/11362/5809>». [Consultado el 23 de octubre de 2023].
- Polanyi, K., *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, 2ª. ed., Boston, Mass., Beacon Press, 2001.
- Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicado de prensa No. 378/2023, 2023.
- Ruezga Barba, A., *Seguridad social: una visión latinoamericana*, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 2009.
- Sánchez-Belmont, M., Ramírez, M. Á. y Romero, F., *Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS*, Conferencia Inter-

americana de Seguridad Social. México, CISS (Cuadernos de historia, teoría y bienestar, 2), 2019.

Townsend, P. (ed.), *Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development*, New York , Geneva Switzerland, Palgrave Macmillan, 2009.

Cuestiones de género en el derecho del trabajo y la seguridad social

Patricia A. Rossi*

* Secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social del P.J.N. de Argentina, abogada UBA, profesora y publicista.

SUMARIO: A. A modo de introducción; B. Algo de estadísticas y algunos conceptos básicos; C. Qué es la “economía del cuidado” y cómo afecta el acceso al trabajo y a las prestaciones de la seguridad social; D. ¿Qué hacer cómo operadores del sistema judicial?; E. Conclusiones; F. Bibliografía.

A. A modo de introducción

Hablar de cuestiones de género en el derecho del trabajo y de la seguridad social es hablar del mayor grado de desempleo, de la mayor segregación ocupacional y de la mayor informalidad que afecta principalmente a las mujeres, así como de la brecha salarial en el trabajo remunerado y de la división desigual del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres. Es visibilizar cómo juegan los estereotipos y patrones culturales en la consolidación de estos fenómenos que afectan a las mujeres estadísticamente en mayor medida, colocándolas en una situación de desventaja y desigualdad.

Diversos autores —como Diana Maffía,¹ Dora Barrancos² y el historiador israelí Yuval Harari, en su libro *Sapiens*—³ atribuyen las diferencias entre hombres

¹ Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maffía, Diana, “Contra las dicotomías: Feminismo y epistemología crítica”, *Seminario de epistemología feminista*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008; Maffía, Diana, *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*, Buenos Aires, Feminaria Ediciones, 2003; Maffía, Diana, “Género y ciudadanía”, *Encrucijadas*, no. 40, febrero de 2007. Disponible en: «http://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsdll/collect/encruci/index/assoc/HWA_376.dir/376.PDF».

² Investigadora principal del CONICET. Barrancos, Dora, *Inclusión/exclusión. Historia con mujeres*, 1ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

³ Harari, Yuval Noah, *De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*, 21ª. ed., Buenos Aires, Debate, 2020.

y mujeres a las relaciones de jerarquía y poder entre los sexos construida sobre la base de estereotipos y mandatos culturales. Afirman que la sociedad les asigna a unos y otras atributos y roles propios según su sexo al nacer. Hasta entrada la edad moderna, los conceptos de diferencia y jerarquía iban de la mano, ya que se pensaba que existían entre las personas relaciones y diferencias “naturales” y que éstas explicaban la organización social.

A través de la historia, la mayoría de las sociedades han sido y son patriarcales, en las que la división de las tareas se realiza según el género. En el caso de las mujeres, desde la revolución agrícola, siempre han sido relegadas a un segundo plano, negándoles derechos, educación, acceso a la vida pública y recursos. A partir de la Revolución industrial y de la Revolución francesa, aparecen el concepto de “familia nuclear” (padre, madre, hijos) y la división sexual del trabajo, que le asignan a cada miembro de la familia roles y tareas propias correspondientes a su género conforme la construcción social. Y así al hombre se le va a pedir que salga al ámbito “público”, a efectos de realizar las tareas “productivas”, mientras que a la mujer se le van a asignar las tareas “reproductivas” y “de cuidado” dentro del ámbito “privado del hogar”.

Sin embargo, las conductas sociales no tienen que ver con la “naturaleza”. Son una construcción cultural y en la medida en que las naturalizamos, no las cuestionamos.⁴

Por tal motivo, el análisis de estas cuestiones de género permite realizar un examen crítico de cómo los roles asignados a las personas según su sexo las afectan de modo tal que determinan, limitan o restringen su acceso y control de los recursos, y cómo, al valorar en forma diferenciada sus tareas, se reproducen las relaciones jerárquicas de poder y, por lo tanto, de desigualdad entre hombres y mujeres.

⁴ Marquez, Josef-Vincent, *No es natural. Para una sociología de la vida cotidiana*, Barcelona, Anagrama, 1982.

B. Algo de estadísticas y algunos conceptos básicos

En Argentina la Constitución nacional consagra la igualdad de derechos en su artículo 16, al establecer que todos los habitantes son iguales ante la ley y, más aún a partir de la reforma constitucional de 1994, en la que quedó plasmada la igualdad de derecho entre hombres y mujeres con la incorporación al texto de la Constitución nacional de los tratados internacionales de derechos humanos, ésta es una igualdad “formal” y no absolutamente real o “material”. No es suficiente tener consagrada normativamente la igualdad formal si en la práctica no lo somos. En lo hechos, la brecha existente entre la igualdad formal y la igualdad material da cuenta de la necesidad imperiosa de un “enfoque con perspectiva de género” que atraviese toda la institucionalidad y todas las materias.

En un trabajo publicado hace unos años,⁵ comenté cómo la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) realizaba estudios de perspectiva de género en los sistemas de seguridad social de la región, y había llegado a la conclusión de que dichos sistemas reflejaban todas las diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres y perpetuaban las desigualdades de hecho y de derecho en torno al género.

En efecto, en 2014, la OISS puso en marcha el “Programa sobre Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social”, cuyo objetivo, precisamente, es promover la inclusión de la perspectiva de género en los sistemas de seguridad social para sensibilizar y formar al personal de las instituciones de seguridad social acerca de su importancia y cómo aplicar la perspectiva de género en sus actuaciones, entre otros objetivos específicos.

En dicho marco, elaboró estudios —que se encuentran publicados en la página web de la OISS— y promovió encuentros para el debate de esta temática, los

⁵ Rossi, Patricia A., “Seguridad social y género”, *Revista Argentina de Derecho de la Seguridad Social*, número 1, julio 2018, IJ-DXXXV-528.

que dieron como resultado la firma de un “Acuerdo final”⁶ en el que se establecieron diversas líneas de acción, tales como: promover la corresponsabilidad equitativa de hombres y mujeres en las tareas de cuidado; promover que los sistemas de seguridad social reconozcan las tareas de cuidado que las mujeres realizan de manera frecuentemente invisibilizada, a través de medidas compensación; fomentar el desarrollo de sistemas públicos de cuidados infantiles y de personas en situación de dependencia; impulsar medidas como los permisos parentales iguales e intransferibles, licencias para adopción, para cuidado de hijos/as prematuros/as, reducciones de jornada para lactancia, etc.; fomentar el empleo formal y la afiliación a sistemas de protección social de las trabajadoras domésticas; promover la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad en los países iberoamericanos que aún no lo hayan hecho, entre otras medidas.

Ahora bien, conforme estos estudios realizados por la OISS, así como con los datos y estadísticas de la OIT, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y otros organismos especializados, las mujeres tenemos una menor tasa de participación en el mercado laboral, menores ingresos, peores condiciones de trabajo y menos tiempo de cotización en los Sistemas de Previsión Social.

En una publicación⁷ del 6 de marzo de 2023, la OIT ha señalado que, conforme nuevos indicadores —que incluyen para el cálculo de la “brecha de empleo” a todas las personas desempleadas pero interesadas en encontrar trabajo—, el acceso de las mujeres al empleo, sus condiciones de trabajo y la diferencia de ingresos no han mejorado en las dos últimas décadas. En la actualidad, en el ámbito global, hay 15% de mujeres que desearía trabajar y no encuentra empleo, frente a 10.5% de hombres en la misma situación. Indica, además, que

⁶ Disponible en: «https://www.oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/ACUERDO_FINAL_II_Encuentro_Iberoamericano_sobre_Genero_y_Seguridad_Social-2.pdf».

⁷ “Las diferencias de género en el empleo son mayores de lo que se pensaba, según un informe de la OIT”. Disponible en: «https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_869932/lang-es/index.htm».

[esta] brecha laboral es especialmente grave en los países en desarrollo, donde la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo alcanza el 24.9% en los países de renta baja. La tasa correspondiente a los hombres en la misma categoría es del 16.6%, un nivel preocupantemente alto, pero significativamente inferior al de las mujeres.

Tal como lo comentaba en el trabajo al que hice referencia, estas diferencias, en general, obedecen a las “tareas de cuidado”, dato al que hace especial mención el artículo de la OIT. Destaca que “las responsabilidades personales y familiares, incluido el trabajo de cuidados no remunerado, afectan desproporcionadamente a las mujeres. Estas actividades pueden impedirles no sólo tener un empleo, sino también buscarlo activamente o limitar su disponibilidad para trabajar con poca antelación”. Es decir que, cinco años después de aquella publicación, esta situación no sólo no ha mejorado, sino que, pandemia mediante, ha empeorado significativamente.

Según datos recabados sobre la tasa de actividad de la población en Argentina, 70.1% de varones trabaja, frente a 51.7% de mujeres,⁸ con un salario promedio —para los primeros— que rondaba, hasta septiembre de 2021, 31% por arriba del que percibían las trabajadoras.⁹ En México, por ejemplo, en el último trimestre de 2022, la participación laboral de los hombres alcanzaba 76.5%, frente a 46.2% de las mujeres económicamente activas.¹⁰ La brecha salarial oscilaba en 14%.¹¹

Huelga decir que en ambos países la población total femenina es superior a la de los hombres. En México, hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzaba 52% de la población total (*conf.* la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-

⁸ Véase “La participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción”. Disponible en: «https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/informe-desigualdad_en_el_trabajo-igualar-segundo_trimestre_2022.pdf».

⁹ Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informe de Evolución de Distribución del Ingreso (EPH) correspondiente al segundo trimestre de 2021, publicado el 28 de septiembre de 2021.

¹⁰ Véase: «<https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/>».

¹¹ Véase: «<https://imco.org.mx/brecha-salarial-de-genero/>».

pleo, Nueva Edición [ENOE]) y en Argentina la población de mujeres llega a 51.45%, conforme datos del último Censo 2022. En ambas naciones, al igual que en la mayoría de las regiones del mundo, las mujeres superan en cantidad a los hombres que ingresan y se gradúan en las universidades. Esto nos habla de una mejor preparación formal para el desempeño de tareas calificadas, que luego no se refleja al evaluar las estadísticas que dan cuenta de que en el sector privado los puestos de decisión son ocupados en 72% por varones, mientras que en la administración pública, si bien la presencia de mujeres en los cargos ejecutivos creció significativamente en los últimos dos años, lo cierto es que aún no se ha alcanzado una paridad.¹² Los datos estadísticos muestran que cuanto más grande es la empresa, menos probabilidades hay de que la mujer acceda a un cargo de liderazgo gerencial. Asimismo, la brecha salarial tiende a ser mayor en los puestos directivos.¹³ Estas desigualdades en los puestos de decisión es lo que se conoce como “techo de cristal”.

Si bien hombres y mujeres sufren por igual las consecuencias del desempleo, las estadísticas demuestran que siempre son las mujeres las que lo padecen en mayor proporción. Cabe aquí destacar la importancia de contar con datos estadísticos, pues éstos son la evidencia empírica de la veracidad del planteo.

C. Qué es la “economía del cuidado” y cómo afecta el acceso al trabajo y a las prestaciones de la seguridad social

Ante estas estadísticas, que muestran que con el correr de los años las diferencias de género no han desaparecido y su disminución no ha alcanzado aún los niveles esperados a la luz de todos los esfuerzos realizados en pos de la tan anhelada equidad, cabe entonces preguntarse el por qué.

¹² Véase: «<https://www.argentina.gob.ar/noticias/importante-crecimiento-de-la-participacion-de-las-mujeres-en-los-cargos-de-alta-direccion#:~:text=Mientras%20tanto%2C%20en%20las%20Autoridades,%2Fas%2C%20secretarios%2Fas%20y>».

¹³ Véase: «<https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#footer>».

Durante el “VIII Congreso internacional de derecho constitucional. Precedente judicial, entre la teoría y la práctica”, que se llevó a cabo en Ciudad de México en octubre de 2022 —y en el que tuve el gusto de participar junto con las distinguidísimas colegas Laura Pautassi y Flavia Marco, en la mesa dedicada al Derecho de la Seguridad Social—, la doctora Pautassi nos recordaba la famosa frase de la escritora, profesora y activista feminista Silvia Federici: “eso que llaman amor es trabajo, no pago”, que hace referencia a cómo el sistema económico de los países se sostiene gracias a la red de cuidados y tareas domésticas que realizan, principalmente, las mujeres día a día sin que esa tarea sea remunerada.¹⁴

En septiembre de 2020, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género de Argentina presentó el informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al producto interno bruto”, en el que se estimaba que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al sistema productivo —en el contexto de la pandemia en el que se presentó el documento— representaba 16% del PBI.

Por otra parte, conforme análisis de los organismos internacionales, como CEPAL, Pan American Health Organization (PAHO), ONU Mujeres, los quehaceres domésticos y las tareas de cuidado no remuneradas, si se conta-

¹⁴ Federici, en su libro *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y lucas femeninas*, sostiene que “La diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que este no solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración, proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres. El trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como trabajo ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital tenía que convencernos de que es natural, inevitable e incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un salario. A su vez, la condición no remunerada del trabajo doméstico ha sido el arma más poderosa en el fortalecimiento de la extendida asunción de que el trabajo doméstico no es un trabajo, anticipándose al negarle este carácter a que las mujeres se rebelen contra él, excepto en el ámbito privado del dormitorio-cocina que toda la sociedad acuerda ridiculizar, minimizando de esta manera aún más a las protagonistas de la lucha. Se nos ve como brujas gruñonas, no como trabajadoras en lucha”. Federici, Silvia, *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y lucas femeninas*, 2a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tinta Limón, 2018.

bilizaran en cada país, representarían entre 10 y 39% del producto interno bruto, llegando incluso a pesar más en la economía que la industria manufacturera, el comercio o el transporte, por ejemplo.¹⁵

Las tareas domésticas y el cuidado de menores y adultos dependientes que realizan las mujeres dentro de sus hogares posibilitan que los otros miembros de la familia salgan a trabajar para generar el ingreso “en dinero”, que de otro modo sería imposible, y suplen, así, las carencias en materia de servicios sociales que debería asumir el Estado.

Son estas tareas, que las mujeres realizan “por amor” y en las que invierten más del doble de horas semanales que sus compañeros varones, las que imposibilitan o dificultan su acceso a un empleo remunerado o que le dediquen menos tiempo, impactando ello directamente sobre su capacidad de generar ingresos propios —y por lo tanto, en su autonomía— y, como consecuencia, en el acceso a futuras prestaciones previsionales.

Conforme las estadísticas de cuidado de la CEPAL, en América Latina las mujeres dedican un promedio de 36 horas semanales a las tareas de cuidado, mientras que los varones no alcanzan 15 horas semanales. En algunos países llega a duplicarse e incluso triplicarse esa diferencia.

En Argentina, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó en 2013 —mediante la Encuesta Anual de Hogares Urbanos— un relevamiento a fin de obtener información respecto de la participación y el tiempo destinado por las personas mayores de 18 años a las tareas domésticas y al cuidado de miembros del hogar, lo que arrojó como resultado que las mujeres realizan más de 75% de las tareas domésticas no remuneradas; 88.9% de las mujeres que participan de estas tareas dedica, en promedio, 6.4

¹⁵ Véase: «<https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work>» y «<https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/valorizacion-economica-trabajo-no-remunerado-hogares-cepal-2021.pdf>».

horas diarias. Mientras tanto, sólo 57.9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3.4 horas diarias.

En México, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado un promedio semanal de 47.9 horas, frente a las 16.5 horas que le dedican los varones.

Resulta necesario hacer hincapié en estas estadísticas porque ponen en evidencia que la distribución asimétrica de las tareas dentro del hogar es una de las principales causas por las que las mujeres no logran obtener un empleo formal remunerado, acepten trabajos precarizados a fin de poder flexibilizar horarios o deban afrontar una doble jornada laboral. Estas tareas de cuidado, que limitan la cantidad de horas que la mujer puede trabajar en actividades remuneradas formales, es lo que se conoce también como piso pegajoso o *sticky floor*.

Hagamos una pequeña pausa aquí para recordar que si bien a partir de las dos grandes guerras mundiales las mujeres salieron en forma masiva al mercado de trabajo —pues era necesario cubrir los puestos que habían quedado descubiertos por tener los hombres que marchar a la guerra—,¹⁶ lo cierto es que siempre se consideró a estas tareas como “de segunda” o “de reemplazo”, ante la ausencia eventual del trabajo del varón, lo que justificaba menores salarios, mayor inestabilidad, peores condiciones y trabajos a tiempo parcial. Pero el principal rol de la mujer seguía estando dentro del hogar, ejerciendo las tareas de cuidado y de reproducción que, desde el patriarcado, se consideraban propias a su género. El hecho de realizar tareas remuneradas fuera del hogar nunca las liberó de sus “obligaciones familiares” Surgió así, en primer lugar, el concepto de “doble jornada laboral”, porque aun cuando los hombres compartan algunas responsabilidades y tareas dentro del hogar, no es habitual que esto se realice en igual proporción, tal como lo demuestran

¹⁶ Moreno Balaguer, Rebeca (coord.), *Feminismos. La historia*, Madrid, Ed. Akal, 2019.

las estadísticas señaladas *ut supra*. La responsabilidad principal de las tareas de cuidado recae en las mujeres.

Desde los talleres de la Oficina de la Mujer que replicamos en el fuero de la Seguridad Social, a los que me referiré más adelante, hemos podido corroborar año tras año —al realizar un trabajo práctico llamado “Las Horas”,¹⁷ que busca precisamente revelar la cantidad de horas que los y las participantes dedican a las tareas domésticas y de cuidado— que estas circunstancias y las estadísticas arriba señaladas se siguen reproduciendo, y no se ha alcanzado aún la paridad en la distribución de tareas entre hombres y mujeres dentro del hogar. Si bien es cierto que las diferencias tienden a achicarse cuanto más jóvenes son los entrevistados y/o menos responsabilidades y cargas de familia tienen.

En definitiva, el término “economía de cuidado” o “tareas de cuidado” alude a la salida de la mujer del mercado laboral (o la imposibilidad o dificultad de acceder a él) para dedicarse al trabajo no remunerado de las tareas domésticas y al cuidado de hijos, hijas menores de edad y adultos mayores dependientes dentro de sus hogares.

Es precisamente la precarización del trabajo la responsable directa de la falta de cotización o de cotizaciones insuficientes de las mujeres en los sistemas de seguridad social y, si bien el trabajo no registrado afecta a todos por igual, la tasa de informalidad laboral afecta nuevamente en mayor medida a las mujeres más que a los varones.¹⁸

¹⁷ El trabajo práctico consiste en que las y los participantes deben indicar cuántas horas dedican en un día promedio (de lunes a viernes) a trabajos arancelados, al trabajo doméstico y al tiempo libre. Luego, se calcula el promedio de distribución horaria según el sexo de las/los participantes, lo que muestra generalmente que las mujeres dedican mayor cantidad de horas en actividades no aranceladas que los hombres.

¹⁸ En Argentina, la informalidad las penaliza a ellas en mayor medida: la tasa de empleo no registrado es de 37% en el caso de las mujeres, comparada con 32% de los varones. 1 de octubre de 2019. Véase, Sesión especial: Mujeres y mercados de trabajo informales-ILO. Disponible en: «https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_718195/lang-es/index.htm». En México, la situación al inicio de la pandemia indicaba que para el primer trimestre de 2020 la Tasa de Informalidad Laboral de las

En efecto, el trabajo no registrado o informal perjudica en forma directa a las personas trabajadoras que, ante la falta de aportes y contribuciones a la seguridad social, ven imposibilitado su acceso a los beneficios previsionales y demás coberturas que brinda la seguridad social, tales como seguros de salud u obras sociales, asignaciones familiares, seguro de desempleo, etcétera.

Si a esta distribución asimétrica de las tareas de cuidado —producto de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres sustentadas en patrones culturales patriarcales— le sumamos el hecho de que la mayoría de los sistemas de previsión vigentes (basados en el modelo de seguro social de Bismark) tienden a proteger solamente a los trabajadores asalariados formales —de determinados riesgos y contingencias—, premiando la trayectoria laboral y dejando sin cobertura a aquellos que, por distintas causas, quedaron fuera del sistema, todo ello da cuenta de cómo el sistema jubilatorio reproduce las diferencias y brechas de género que venimos señalando. Estas afectan a las mujeres en el acceso al mercado laboral y la permanencia en él, por lo cual es urgente tomar medidas tendientes a revertir estos contrastes distributivos entre los sexos.

Combatir y erradicar el flagelo del trabajo no registrado resulta imprescindible a fin de mantener la sustentabilidad de los sistemas previsionales. No obstante, los sistemas de seguridad social no deben ser evaluados únicamente desde una visión economicista, debe también tenerse en cuenta su sentido de protección social. Recordemos que uno de los objetivos primarios del Estado es (o debería ser) garantizar un piso mínimo de protección social con carácter universal para los habitantes ciudadanos.

A fin de paliar estas deficiencias, los Estados de Iberoamérica han implementado diversas medidas compensatorias, con menor o mayor éxito, para procurar reparar, en alguna medida, estas inequidades de género e incluir a las mujeres cuidadoras en los sistemas de seguridad social, a los que, de otro

mujeres era de 56.7%, frente a 49,6% de los hombres. Véase: «https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_8M2023.pdf».

modo, en su gran mayoría, sólo acceden mediante pensiones no contributivas o mediante pensiones de viudez.

España, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile y, más recientemente, Argentina, entre otros países de la región, han dictado normas tendientes a compensar el tiempo dedicado al cuidado, pero generalmente con un alcance puntual y limitado y dentro de las particularidades de cada sistema.

En el caso de Argentina, el Estado nacional reconoció la situación de quienes tienen a su cargo cuidado de menores de edad que complejiza su acceso al mercado laboral. En consecuencia, a estas personas les resulta más complicado completar los requisitos que exige la Ley 24.241 para obtener las prestaciones previsionales. Consideró que, conforme lo establece nuestra Constitución nacional, el Estado debe garantizar a la ciudadanía las prestaciones de la seguridad social, priorizando la inclusión y atención de los grupos y personas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Reconoció, asimismo, las evidentes dificultades estructurales y honró los compromisos asumidos con la suscripción de tratados internacionales mediante el dictado del Decreto 475/2021, en el que dictó medidas de justicia social orientadas a reparar parte de dichas desigualdades estructurales que sufren las mujeres.

Este decreto reconoce a las mujeres en edad de jubilarse (60 años) que hayan sido madres y no cuenten con los años de aportes necesarios (30 años), ni posean una jubilación ya otorgada o en trámite, un año de aportes por hija(o), dos años de aportes por hija(o) adoptada(o) y además se le reconoce, de forma adicional, un año por hija(o) con discapacidad y dos años en caso de que haya sido beneficiaria(o) de la Asignación Universal por Hija(o)¹⁹ por al menos 12 meses. Además, reconocen también los plazos de licencia por

¹⁹ La ley 24.714 de Asignaciones Familiares prevé una “asignación universal por hijo para Protección Social” que consiste en una suma mensual que se paga por cada hijo o hija menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite para cobrarlo si el hijo o hija tiene discapacidad.

maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

En muchos casos esta medida resulta insuficiente para alcanzar los 30 años de servicios con aportes que requiere la Ley 24.241 para acceder a la prestación. Se establece, entonces, la compatibilidad de aplicación de esta norma con la posibilidad de complementar los años faltantes mediante el acogimiento a la moratoria y planes de pagos de deuda vigentes.

En este sentido, cabe destacar que las moratorias previsionales constituyen una herramienta para que los/as trabajadores/as que hayan alcanzado la edad mínima, pero no cuenten con el tiempo de aportes necesarios puedan acceder a la jubilación mediante la cancelación de su deuda previsional en cuotas.

La experiencia en Argentina de la implementación de estos mecanismos da cuenta de que 87% de las personas favorecidas con las moratorias fueron mujeres. Estas mujeres, en su mayoría, no contaban con los aportes necesarios para acceder a una jubilación dentro del SIPA (ex SIJP) debido a las entradas y salidas del mercado laboral formal por haberse dedicado a las tareas de cuidado o haber tenido empleos informales o precarizados. Estas prestaciones no suelen superar el haber mínimo que a septiembre del año 2023 ascendía a \$87,459.76 en bruto.

Pero todos estos esfuerzos tendrán un resultado limitado si no se resuelve el problema de la informalidad laboral, situación que quedó evidenciada aún más por la crisis de la pandemia generada por el covid-19. La pandemia provocó que miles de trabajadores no pudieran hacer uso de las prestaciones de la seguridad social por tener trabajos precarizados y por la pérdida de los empleos, especialmente por parte de las mujeres.²⁰

²⁰ Los datos estadísticos en Argentina, a marzo de 2023, de tasas de desempleo, subocupación y de trabajo no registrado demuestran que son las mujeres quienes sufren esta situación en mayor medida que los hombres. Disponible en: «https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_estadisticas_laborales_según_sexo_marzo-2023_-_actualizado.xlsx».

D. ¿Qué hacer cómo operadores del sistema judicial?

México y Argentina son signatarios de las Declaraciones y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben cualquier tipo de discriminación basada en el sexo (entre otros criterios de distinción entre las personas) y consagran el derecho a la seguridad social para toda persona, como parte de la sociedad en su dimensión más amplia.

A partir del momento en que los Estados suscriben los tratados internacionales de derechos humanos y los incorporan a su legislación —que, en el caso de Argentina, además, integran el bloque constitucional— han asumido el compromiso de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de los distintos poderes del Estado.

En dicho sentido, cabe recordar que tanto México como Argentina han suscripto y ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará). Estos instrumentos imponen a los Estados parte el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra las mujeres.

Mediante la ratificación de estas convenciones se comprometieron a detectar las prácticas jurídicas o consuetudinarias y las leyes que perpetúan la desigualdad o que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Al mismo tiempo, se comprometieron a garantizar, a través de los tribunales competentes, los derechos de las mujeres.

La CEDAW incluye la noción de responsabilidades familiares y señala que debe estimularse la provisión de servicios sociales para permitir que ambos progenitores combinen sus obligaciones familiares con las responsabilidades de trabajo y la participación en la vida pública.

Por su parte, la Convención de “Belem do Pará” también impone, expresamente, a los Estados la obligación de capacitar en perspectiva de género a todo el personal de la administración de justicia y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

En el marco de estos compromisos asumidos por el Estado argentino, con la ratificación de las mencionadas convenciones, se crearon en 2006, dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD). Estas oficinas tiene el fin de remover las dificultades que las personas en especial estado de vulnerabilidad, por encontrarse afectadas por violencia doméstica, puedan tener en el acceso a la justicia. Posteriormente, el 23 de abril de 2009, la Oficina de la Mujer (OM), con el objetivo de impulsar en el Poder Judicial un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos. La OM busca alcanzar la equidad de género tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes trabajan en ese ámbito.²¹

La OM produjo un protocolo de trabajo en talleres a fin de incorporar la perspectiva de género en la justicia. Primero, personas de todas las jurisdicciones del país fuimos instruidas en el uso del material elaborado por la OM y validado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina) —y declarado como una de las “buenas prácticas” de la región por la Organización de Estados Americanos— para luego empezar a replicar los talleres en sus propios lugares de trabajo. Estos talleres tienen por objeto que quienes desempeñan tareas en la Justicia, desde el primero al último cargo, obtengan herramientas conceptuales que les posibiliten dar respuestas

²¹ Con la designación en junio de 2004 y en febrero de 2005 de las doctoras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, respectivamente, llegan por primera vez dos mujeres al cargo de Ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina. Ellas crearon la Oficinas de Violencia Doméstica, para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia doméstica, lo que significó una profunda transformación en la forma de encarar la atención de las víctimas de manera integral y con perspectiva de género, y la Oficina de la Mujer, con el fin de capacitar en género a magistrados, funcionarios y empleados, siendo pionera, tanto a nivel mundial como en lo que respecta a los otros poderes del estado nacional, en establecer una estructura con ese objetivo específico.

a casos vinculados a cuestiones de género acordes a la Constitución y los tratados internacionales.

A partir de 2019, estos talleres de perspectiva de género son utilizados también para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Micaela,²² que ordena que todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado cumplan con la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia de género. Capacitarse en perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género y entender que cada acción de gobierno debe tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y en la colectividad LGBTI+. Es obligación y responsabilidad del Estado, en todos sus estamentos y poderes, formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas que no reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas.

Otra herramienta que utiliza la OM para cumplir con los objetivos impuestos por la CEDAW y Belem do Pará es la sistematización de las decisiones judiciales vinculadas a los derechos de las mujeres, que se recopilan en una base de datos diseñada a tal fin.

No obstante los cambios legislativos que apuntan a establecer la igualdad entre las personas, la práctica judicial demuestra que esta meta no ha sido alcanzada, pues perduran relaciones de subordinación de la mujer hacia el hombre. La justicia debe luchar contra los estereotipos a fin de evitar pronunciarse conforme a viejos modelos sociales que terminan reafirmando la desigualdad de reparto de poder entre los géneros.

Los y las juezas deben brindarles a las mujeres la oportunidad de acceder a la justicia en igualdad de condiciones y —de ser necesario— remover los obstáculos que se lo impidan. Corresponde, asimismo, que se cuestionen cómo estructurar un sistema que no juzgue sobre la base de estereotipos de

²² Ley 27.499 sancionada el 19 de diciembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial Nacional el 10 de enero de 2019. Se llama así en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años víctima de feminicidio.

género, a fin de no reproducir y perpetuar las desigualdades. A la hora de sentenciar debe ponerse— especial atención no sólo en a la valoración de la prueba sino también a este enfoque que obliga tener en cuenta las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y gozar de recursos económicos y derechos patrimoniales.

Consecuentemente, una de las herramientas con las que los jueces y las juezas cuentan es el control de constitucionalidad y de convencionalidad que deben ejercer a fin de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Cabe aquí recordar nuevamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin...”²³

Los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos actúan, entonces, como directrices e imponen a los Estados parte la obligación de adoptar medidas adecuadas que permitan erradicar las diferencias entre hombres y mujeres. Este deber de adoptar medidas tendientes a erradicar estas diferencias incluye la obligación de tomar las acciones positivas necesarias para eliminar patrones socioculturales que perpetúan relaciones de jerarquía entre hombres y mujeres y ponen en cabeza de la mujer las obligaciones domésticas y de cuidado.

En el ámbito de la seguridad social las leyes previsionales tienden a proteger al individuo frente a las contingencias de vejez, enfermedad y muerte y a su grupo familiar del desamparo que supone el fallecimiento del sostén de la

²³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

familia. Ante los cambios socioeconómicos y culturales de la sociedad moderna, el “concepto tradicional de familia” contemplado por las leyes se ha visto alterado, obligando a legisladores e intérpretes del derecho a adecuar las normas vigentes a la nueva realidad.

En este aspecto, cabe destacar que la seguridad social es una rama del derecho que se ha adelantado muchas veces a otras, reconociendo y contemplando situaciones que eran ignoradas por las leyes. Así, por ejemplo, la jurisprudencia argentina, en su momento, evolucionó en pos de reconocerles derechos a las personas que habían optado por hacer vida marital de hecho, cuando en una primera etapa y siguiendo la legislación y prejuicios imperante de la época no se reconocía el derecho de la concubina a obtener el beneficio de pensión. Con el tiempo, el legislador recogió estos criterios plasmándolos normativamente. Incluso, jurisprudencialmente, se le reconoció el derecho a pensión a una pareja de igual sexo, mucho antes de que el congreso nacional sancionara el matrimonio igualitario²⁴ en el país. El organismo administrador del sistema de seguridad social, la AN. SeS., recogió los criterios sentados por numerosos fallos en la materia²⁵ —que le reconocieron el derecho a pensión a convivientes del mismo sexo y dejó sin efecto resoluciones administrativas que se lo habían denegado. Afirmó que las uniones de hecho comprendían tanto a las heterosexuales como a las homosexuales. Esto porque la unión de hecho es la unidad de convivencia alternativa al matrimonio, dentro de lo que se puede distinguir la unión heterosexual y la homosexual, que tienen caracteres comunes como la estabilidad, la publicidad, la comunidad de vida o cohabitación y la singularidad. En consecuencia, no es admisible excluir de la caracterización de convivientes que se procuran ostensible trato familiar a las parejas homosexuales. Cualquier diferenciación originada en la igualdad de sexo de los convivientes significaría una discriminación prohibida respecto de

²⁴ Con la sanción de la Ley 26.618, el 15 de junio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

²⁵ “Y.E.A. c. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires”, sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, de fecha 9 de marzo de 2005; “D., J. A c V. V.E y otro”, Sala I de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, sent. del 8/6/1999 publ. en LLBA, 1999-1071, en E.D, 184-555; “A. A. s/información sumaria”, del Juzgado Civil y Comercial y Minas N° 10 de Mendoza, fallo del 20 de octubre de 1998, entre otros.

parejas heterosexuales—. La Resolución 671/2008 de la ANSES (publicada en el Boletín Oficial el 27 de agosto de 2008) declaró a los convivientes del mismo sexo incluidos en los alcances del art. 53 de la Ley 24.241 (es decir, en la norma previsional que enumera quiénes son las personas con derecho a pensión y su grado de prelación) como parientes con derecho a la pensión por fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad del régimen previsional.

La ley por sí sola no elimina las desigualdades estructurales a las que están sometidas las mujeres, las minorías y los grupos desventajados en general. — Resulta necesaria la implementación de diverso tipo de medidas que aseguren un cambio de paradigma sobre el sistema de valores a fin de erradicar todo resabio sexista, fundamentalmente en los organismos e instituciones que tienen a su cargo la delicada misión de reconocer derechos y prestaciones.

En dicho sentido, las cortes supremas de México y Argentina han dado claros ejemplos de pronunciamientos tendientes a revertir los mencionados estereotipos y patrones culturales. Tal es el fallo dictado en el Amparo Directo 18/2021, en el que una madre que había estado unida en concubinato con el padre de su hijo promovió un juicio de amparo a fin de que se los reconociera, a ella y al menor, como beneficiarios de derechos laborales del trabajador fallecido, que le habían sido denegados porque el causante no estaba libre de matrimonio. La Segunda Sala de la SCJN resolvió conceder el amparo solicitado en virtud de que esta situación reafirmaba estereotipos de género y prejuicios sociales que históricamente han vulnerado el derecho de igualdad de la mujer y de igual forma le han impedido el acceso a sus derechos. La Corte, al igual que lo ha hecho en otros casos, sostuvo que la protección constitucional de la familia no debe obedecer a un solo modelo y agregó que en la actualidad la estructura de la familia se ha transformado y ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por vínculos diferentes al matrimonio, de tal forma que la restricción del derecho a la protección de la familia, con base en el estado civil, es una medida que no está vinculada a los objetivos ni a los fines de la Constitución federal.

Por su parte, el tribunal cimero de Argentina revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que había rechazado la demanda tendiente a que se reconozca el derecho de la actora a percibir las asignaciones familiares por hijo, ayuda escolar y familia numerosa porque su cónyuge percibía un salario superior al tope previsto en el art. 3 de la Ley Nacional 24.714 de Asignaciones Familiares. La Corte dejó sin efecto dicho pronunciamiento y señaló que era arbitrario ya que había omitido considerar el cuestionamiento formulado por la peticionaria referente a la inconstitucionalidad del decreto provincial 1599/89 bis por resultar discriminatorio hacia las mujeres. En efecto, dicha norma establecía una distinción de trato discriminatoria en razón del sexo al excluir del cobro de las asignaciones familiares únicamente a las empleadas mujeres cuyos cónyuges excedían el tope salarial establecido en el artículo 3 de la ley 24.714 y habilitar el cobro de tales prestaciones a los agentes varones en idéntica situación. De igual modo, sostuvo que no había analizado la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación y no había ponderado que la tacha de inconstitucionalidad presentada por la actora comprometía una distinción basada en una de las categorías sospechosas como es el sexo, sujeta a la aplicación del test de escrutinio estricto.

E. Conclusiones

Para concluir, quiero destacar, por un lado, que conforme lo tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de seguridad social corresponde siempre realizar una interpretación situada, coherente y que no pierda de vista los objetivos centrales de los mandatos constitucionales, y en la cual las normas deben ser tratadas otorgando prevalencia a los fines tuitivos que procuran y esto requiere de la máxima prudencia, toda vez que la inteligencia que se les asigna puede llevar a la pérdida de un derecho de carácter alimentario o de su retaceo.

Por otro, en lo que respecta a las cuestiones de género en particular, y a la luz de todo lo hasta aquí desarrollado, el principio de igualdad debe ser interpretado no sólo como igualdad de no discriminación, sino además como

de no exclusión o desigualdad estructural donde se considera relevante la situación de la persona individualmente considerada pero integrante de un grupo sistemáticamente excluido.

F. Bibliografía

- Barrancos, Dora, *Inclusión/exclusión. Historia con mujeres*, 1ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Federici, Silvia, *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y lucas femeninas*, 2ª. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tinta Limón, 2018).
- Harari, Yuval Noah, *De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*, 21a ed., Buenos Aires, Debate, 2020.
- Maffia, Diana, “Contra las dicotomías: Feminismo y epistemología crítica”, *Seminario de epistemología feminista*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008.
- Maffia, Diana, “Género y ciudadanía”, *Encrucijadas*, no. 40, febrero de 2007. Disponible en: «http://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsdll/collect/encrucijadas/index/assoc/HWA_376.dir/376.PDF».
- Maffia, Diana, *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*, Buenos Aires, Feminaria Ediciones, 2003.
- Marquez, Josef-Vincent, *No es natural. Para una sociología de la vida cotidiana*, Barcelona, Anagrama, 1982.
- Moreno Balaguer, Rebeca (coord.), *Feminismos. La historia*, Madrid, Ed. Akal, 2019.
- Rossi, Patricia A., “Seguridad Social y Género”, *Revista Argentina de Derecho de la Seguridad Social*, número 1, julio de 2018, IJ-DXXXV-528.

La maternidad frente a la seguridad social

Valeria González Ruiz*

* Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Ha trabajado en la Dirección General de Igualdad de Género de la Secretaría de la Función Pública y en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. En la academia se ha desempeñado como profesora adjunta de las cátedras de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana.

SUMARIO: A. Introducción; B. La seguridad social; I. Invisibiliza las labores de cuidado; III. Invisibiliza la maternidad como un bien social; III. Invisibiliza la paternidad como un factor esencial para el desarrollo infantil y familiar y como factor esencial para la igualdad entre hombres y mujeres; C. Preceptos de regulación social que impactan de forma negativa a la maternidad; I. Días de cotización mínimos; II. Madres trabajadoras contratadas por honorarios profesionales y contratos temporales no están protegidas por la seguridad social; III. Ausencia de permisos de paternidad en la regulación de la seguridad social; D. Consecuencias; I. Madres y mujeres embarazadas sin acceso a la seguridad social; II. Incentiva la violencia laboral por razón de maternidad; III. Desigualdad laboral; E. Propuesta; F. Conclusión; G. Bibliografía.

A. Introducción

Se han hecho esfuerzos para sancionar las vulneraciones al embarazo y la maternidad, como en las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo (2019). Sin embargo, aún estamos frente a una falta de políticas públicas transversales que tengan por objeto brindar una protección reforzada a la maternidad, especialmente en el espacio laboral y que incentiven espacios libres de violencia y amigables para la maternidad.

La regulación en torno a la seguridad social es un ejemplo perfecto para mostrar esta situación, pues en lugar de reconocer la maternidad como un bien social que requiere la máxima protección la inhibe e incluso la violenta.

Si bien la finalidad de la seguridad social es apoyar el desarrollo digno de las personas, al no distinguir entre sus necesidades particulares, discrimina y perjudica, especialmente a las mujeres y la maternidad como condición

vinculada a ellas. El objetivo de este ejercicio de análisis es mostrar que su regulación invisibiliza las labores de cuidado como un trabajo digno de ser remunerado y garantizado por la seguridad social, que la maternidad es un bien social merecedor de protección reforzada y que la paternidad responsable es un elemento esencial en el desarrollo y salud de las hijas e hijos, pero también en el proceso de alcanzar la igualdad de género.

En este texto se desarrollan los efectos de ciertos preceptos normativos que, en la práctica, han dejado desprotegidas a cientos de mujeres: la falta de seguridad y reconocimiento como un trabajo a las labores de cuidado; los días de cotización mínimos como requisito indispensable para acceder a la seguridad social; la falta de protección a las mujeres contratadas por honorarios o contratos temporales y la total ausencia de permisos de paternidad reconocidos por la seguridad social son ejemplos que se proyectan como obstáculos para las trabajadoras —especialmente aquellas que son madres— en el acceso a condiciones reales de igualdad y seguridad.

Con estas premisas, se exponen las consecuencias de este escenario desolador: madres y mujeres embarazadas que actualmente se encuentran sin acceso a la seguridad social; otras, expuestas a sufrir discriminación laboral por embarazo y todas frente a una evidente desigualdad de género en el mercado laboral.

Finalmente, en este ejercicio se plantean principios a tomar en cuenta para implementar un modelo de seguridad social que pueda cumplir con su finalidad y sea más justo con las mujeres, que históricamente absorben los gastos de la seguridad social al asumir las labores de cuidado de las infancias, las personas mayores, las que están enfermas y las personas con discapacidad.

B. La seguridad social

“A finales del siglo XIX, surgen los seguros sociales como mecanismo de protección frente a determinadas necesidades sociales, que se recono-

rían solo a los *trabajadores*”.¹ La finalidad de la seguridad social es que las personas dispongan por derecho de las condiciones sociales mínimas para su independencia. Ésta ha sido diseñada bajo la “teoría de la sociedad del riesgo”, que parte de que una sociedad no puede permanecer siempre en la incertidumbre y debe convertirse en una sociedad de seguridad; ha sido creada por el Estado para proteger a sus ciudadanos de contingencias como la vejez, la discapacidad o la pérdida de la salud. En otras palabras, es la forma a través de la cual las personas aseguran la acción estatal de los servicios públicos sin obedecer a la lógica del mercado.²

La pensión de jubilación o de vejez, por ejemplo, constituye una solución a la inseguridad social que enfrenta una persona mayor trabajadora sin la posibilidad de trabajar. “De esta manera, se consolida como ‘un derecho constituido a partir del trabajo’, amparando al trabajador cuando ya no trabaja”.³

Así pues, toda legislación que regula la seguridad social es una “derivación directa de la pretensión más amplia del sistema de derechos humanos: el respeto de la igual dignidad de las personas”.⁴ En ese sentido, debe apuntar hacia la solidaridad, de manera que el interés común de una sociedad sea generar prestaciones para toda la sociedad.⁵

Sin embargo, “no hay Estado social (ni habrá, materialmente, Estado constitucional) sin la plena efectividad y exigibilidad de los derechos sociales”.⁶ Por el contrario, cuando el sistema de seguridad social falla, se generan

¹ Vargas Sandoval, Yaneth, “Un acercamiento teórico sobre la mujer en la seguridad social”, *Revista IUSTA*, núm. 52, 2020, p. 90. Disponible en: «<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/5484/5240>».

² *Ibidem*, p. 81.

³ *Ibidem*, p. 82.

⁴ Urquilla Bonilla, Carlos Rafael, “El derecho a la seguridad social: Una aproximación desde la perspectiva de género”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 253. Disponible en: «<https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22094.pdf>».

⁵ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “¿Discrimina la seguridad social a las mujeres?”, *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, núm. 4, enero-junio de 2007, p. 135.

⁶ Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.*, p. 83.

contextos de inseguridad e incertidumbre para la sociedad, especialmente para las personas más vulnerables.

El problema se manifiesta cuando no se distinguen las particularidades de los distintos grupos que integran a la sociedad, se invisibiliza su reconocimiento y las prestaciones que requieren son ignoradas. Es en este punto cuando, “a pesar de que la seguridad social tiene la obligación —como rama del derecho social— de redistribuir las cargas sociales, no cumple su cometido en la práctica”.⁷

Si bien la seguridad social tiene como finalidad subsidiar y apoyar el desarrollo digno de las personas, cuando no distingue entre las necesidades particulares de sus beneficiarios discrimina y perjudica, especialmente a las mujeres y a la maternidad como condición vinculada a ellas, quienes reciben un tratamiento injusto en las prestaciones de los seguros sociales.

El sistema de seguridad social mexicano no está exento de esta situación. En él, las mujeres también están en desventaja, tienen que afrontar una realidad dada por su condición de ser mujer en el mundo del trabajo⁸ sin las herramientas necesarias que podrían proveer la regulación y las instituciones de la seguridad social.

Como se verá a lo largo de las siguientes páginas, desafortunadamente la seguridad social aún carece de perspectiva de género y se ha mantenido neutra ante los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres.

I. Invisibiliza los labores de cuidado

Históricamente, el planteamiento del hombre proveedor se construye en torno al trabajo asalariado, masculino y público. Esto no es otra cosa que

⁷ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, *op. cit.*, p. 115.

⁸ Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.*, p. 89.

parte de la división sexual del trabajo, que deja a las mujeres en actividades propias del hogar, tareas de cuidado y en el plano privado.⁹

Actualmente, esta división sexual del trabajo ha impuesto a las mujeres como las responsables exclusivas de las labores domésticas y de cuidado, actividades que, como la investigación “Un acercamiento teórico sobre la mujer en la seguridad social” de Yaneth Vargas Sandoval concluye, “muchas veces no son remuneradas, lo que genera una gran desventaja en las relaciones sociales y laborales”.¹⁰

Los cuidados se definen como las actividades específicas que realizan las personas para atender, asistir, acompañar, vigilar y brindar apoyo a las y los integrantes del hogar o a otras personas, con la finalidad de buscar su bienestar físico y la satisfacción de sus necesidades básicas.¹¹ Precisamente por lo anterior, las labores de cuidado están vinculadas directamente a la seguridad social porque existe una responsabilidad compartida entre la sociedad, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el acceso libre y universal a los servicios de cuidado. Esto, para asegurar que las personas cuidadoras desarrollen sus actividades de forma profesional y bajo la completa protección de sus derechos laborales; sin embargo, en México eso no sucede, las mujeres asumen esta responsabilidad sin reconocimiento, remuneración ni seguridad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022,¹² publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

⁹ *Ibidem*, p. 90.

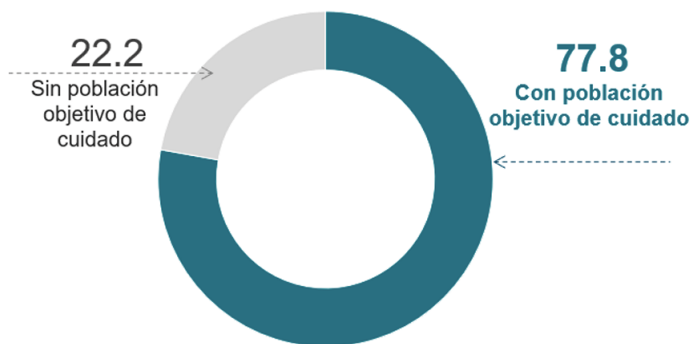
¹⁰ *Ibidem*, p. 98.

¹¹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC). Nota técnica”, 2022, p. 7. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_tecnica.pdf.

¹² Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha hecho el levantamiento de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 con la que busca conocer la demanda y cobertura para la población objetivo de cuidados, así como las repercusiones en la vida de las personas que cuidan, en específico, en la de las mujeres y el impacto en su incorporación al

(INEGI), 77.8% (30.2 millones) del total de hogares en el país tenía al menos una persona que pertenecía a la población objetivo de cuidados.

Figura 1. Hogares con población objetivo de cuidados



Incluye hogares donde se requieren cuidados para al menos una persona con discapacidad y/ o dependencia, y/ o para alguno de los siguientes grupos: de 0 a 5 años, de 6 a 17 años o de 60 años y más.

Fuente: INEGI, ENASIC, 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para efectos de este texto, destaca que de 58.3 millones de personas que representan la población objetivo de cuidados,¹³ 35.7 millones son niñas, niños y adolescentes (10.3 millones, personas de 0 a 5 años; 25.4 millones, personas de 6 a 17 años) y del total de personas responsables del cuidado de la población infantil, 96.0% correspondió a mujeres; como ejemplo, las personas cuidadoras principales de las y los infantes de 0 a 5 años fueron la madre, con 86.3%, y la abuela, con 7.6%. En general, la composición por sexo de las personas cuidadoras en el país es mayoritariamente femenina.

Ahora bien, no basta con reconocer que el cuidado es *predominantemente* responsabilidad de las mujeres, sino que realmente implica un trabajo. De

mercado laboral. Así mismo, la ENASIC identifica las redes de apoyo y la percepción de la población acerca de la corresponsabilidad de los cuidados, entre otros aspectos.

¹³ La ENASIC considera como población objetivo de cuidados a las personas con alguna discapacidad o dependencia, a las infancias de 0 a 5 años, a las niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años y a la población adulta mayor (60 años y más).

acuerdo con los resultados, las mujeres dedican a las labores de cuidados 38 horas a la semana, 12 horas más que los hombres.

Figura 2. Tasa de participación y tiempo promedio semanal de las personas de 15 años y más cuidadoras del hogar y de otros hogares, según sexo (porcentaje y horas)

	Mujeres que brindan cuidados	Hombres que brindan cuidados
Tasa de participación	45.1 (23.8)	17.0 (7.9)
Tiempo promedio	37.9	25.6

Nota: entre paréntesis se indican los millones de personas.
Fuente: INEGI, ENASIC, 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Pero no sólo es el tiempo, sino también el tipo de actividades que las mujeres desempeñan al ejercer cuidados: de acuerdo con la encuesta, mujeres participaron con porcentajes más altos en actividades como “dar de comer o ayudar a hacerlo” con 63.8%, y “ayudar o apoyar en bañar, asear, peinar o ir al baño”, con 58.7%. Con respecto a la población infantil de 0 a 5 años, las actividades en las que más participaron las mujeres cuidadoras fueron: bañar, asear, visitar, arreglar, cargar, acostar, platicar, jugar, realizar actividades de esparcimiento, hacer compañía y estar al pendiente. A diferencia de los hombres cuidadores, que participaron en mayor medida en jugar, realizar actividades de esparcimiento, hacer compañía y estar al pendiente.

En ese sentido, 15.5% de las mujeres cuidadoras reconoció que necesita apoyo o ayuda para poder realizar el trabajo de cuidados; sin embargo, lejos de obtener apoyo, este tipo de trabajo sigue sin recibir el reconocimiento que merece, la remuneración y el acceso a la seguridad social.

II. Invisibiliza la maternidad como un bien social

En ese sentido, se muestra necesario analizar cómo entonces es percibida la maternidad, condición que está íntimamente ligada con las labores de cuidado.

De entrada, el sistema de seguridad social mexicano no trata la maternidad como un *bien social* o como un derecho, sino como una incapacidad. Tanto La Ley del Seguro Social como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas dan tratamiento a la maternidad como una “incapacidad temporal” en la cual las mujeres se enfrentan a ciertas limitaciones que les impiden llevar a cabo sus actividades. Es decir, “la maternidad es comparable a una enfermedad sufrida por la mujer como consecuencia de su embarazo y posterior alumbramiento”.¹⁴ Las prestaciones a madres trabajadoras otorgadas por la regulación del sistema de seguridad social tienen gran similitud con las prestaciones por incapacidad laboral.¹⁵

Si bien la precisión puede parecer una cuestión de mera terminología no lo es; por el contrario, es importante porque —como se verá más adelante— genera consecuencias en el acceso a la seguridad social. No es lo mismo tratarla como una prestación de carácter laboral que se otorga bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, que como una condición que representa un pilar fundamental de la sociedad, una condición que requiere protección reforzada y universal.

En palabras de Lourdes Jiménez Brito, la maternidad es “una de las tareas fundamentales de la reproducción social” que deben ser una preocupación central del Estado, ya que por medio de ellas se garantiza la supervivencia

¹⁴ Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México*, México, 2022, p. 23.

¹⁵ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo de las prestaciones de seguridad social por maternidad”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XXXIX, núm. 116, mayo-agosto de 2006, p. 456.

misma de la sociedad. Sin embargo, las actividades que involucra —como el cuidado, alimentación, protección y educación de las hijas e hijos— son subvaloradas y —en su gran mayoría— se encuentran desprotegidas.¹⁶

Adicionalmente, abona a la percepción de que se trata de un inconveniente para el empleador. Diversos estudios identifican que la maternidad es vista como una “desventaja” en el trabajo que representa un costo para la mujer y el empleador.

Comúnmente los empleadores comparten la idea de que las madres son más inestables, menos comprometidas y competentes en el trabajo. Esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del “trabajador ideal”, a diferencia de los hombres que son mayormente asociados con la idea de que son más comprometidos si están casados y son padres.¹⁷

Por tal situación, las mujeres han sido posicionadas —como se verá más adelante— en desventaja y desigualdad laboral frente a los hombres.

III. Invisibiliza la paternidad como un factor esencial para el desarrollo infantil y familiar y como factor esencial para la igualdad entre hombres y mujeres

La paternidad tiene un papel accesorio en el sistema jurídico mexicano, me atrevería a decir que incluso decorativo. La regulación del sistema de seguridad social no es la excepción pues, como se verá más adelante, no la visibiliza como un factor que deba ser considerado para otorgar prestaciones similares a las de la maternidad, pese a ser un pilar fundamental para la primera infancia mejorar el bienestar infantil y familiar y como factor esencial para la igualdad entre hombres y mujeres.

¹⁶ Jimenez Brito, Lourdes, “Maternidad y seguridad social”, *Cuadernos de Políticas para el Bienestar*, México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, p. 116.

¹⁷ Early Institute, *La discriminación laboral por embarazo*. Serie: Prácticas que vulneran la maternidad en México, México, 2021, p. 13.

Los hallazgos a nivel mundial son claros: los padres importan y su presencia comprometida hace una diferencia. Las investigaciones sugieren que: 1) los padres son importantes para el desarrollo emocional, social e intelectual de las/os niñas/os; 2) los padres son importantes durante todo el desarrollo de las/os niñas/os, no sólo en los primeros años de vida; 3) la paternidad ausente tiene costos tanto para las familias como para el Estado; 4) la paternidad participativa es importante para la igualdad de género puesto que los padres cumplen un rol esencial en el cuidado y el desarrollo de sus hijos/as, como “co-cuidadores” junto con las madres y otros/as cuidadores/as, y 5) la experiencia tanto de la crianza como el cuidado transforma a los hombres psicológica e incluso biológicamente. En resumen, los padres influyen en el desarrollo de sus hijos/as y esta experiencia tiene consecuencias tanto en sus propias vidas como en el entorno familiar.¹⁸

De fondo, la consecuencia es mucho más profunda pues vulnera el derecho que tiene la niñez a ser cuidada y el derecho de los padres a cuidar de ellos. Y como un círculo vicioso, invisibilizar su papel genera que las labores de cuidado sigan irremediamente absorbidas por la maternidad y que exista baja participación paterna en el cuidado de la niñez, la crianza y las tareas domésticas”.¹⁹ Sin embargo, son numerosas las investigaciones en la materia que evidencian que tanto padres y madres como otros/as cuidadores/as pueden asumir estos roles indistintamente.²⁰

Implementar mecanismos que permitan y fomenten ejercer la paternidad, como los permisos de paternidad, es fundamental para generar que madres y padres tengan “oportunidades equitativas que aumenten sus capacidades como proveedores y cuidadores”.²¹

¹⁸ International Planned Parenthood Federation/WHR y Promundo, “Capítulo 2. ¿Cómo impacta una paternidad participativa y comprometida con el desarrollo infantil?”, *Estado de la paternidad: América Latina y el Caribe*, 2017, p. 37.

¹⁹ Early Institute, *Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México*, México, 1a. ed., 2019, p. 13.

²⁰ International Planned Parenthood Federation/WHR y Promundo, *op. cit.*, p. 37.

²¹ Early Institute, “Recomendaciones para implementar...”, *op. cit.*, p. 11.

Lo que es importante señalar con los ejemplos anteriores es que la protección limitada que ofrecen las prestaciones por maternidad —y la nula por paternidad— dentro del seguro social se conservan sin mejora notable en favor de los derechos de igualdad de la mujer, es decir, no constituyen una base regulatoria que permita lograr una redistribución social de las cargas familiares.²² Todo lo contrario, como se profundizará más adelante, las mujeres embarazadas y madres trabajadoras se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad pues su labor de cuidado no es reconocida como trabajo, retribuido ni protegido por la seguridad social, dejándolas en evidente desventaja frente a los hombres. Además, aquellas que adicionalmente tienen un empleo formal sufren las consecuencias de la doble jornada, desigualdad laboral y vulnerabilidad frente a posibles casos de violencia laboral por razón de maternidad.

C. Preceptos de la regulación social que impactan de forma negativa a la maternidad

Ahora bien, como ejemplo de la falta de una protección integral a la maternidad y una regulación de seguridad social que considera las necesidades particulares de las mujeres, en las siguientes páginas se desarrollan preceptos de la regulación social que impactan de forma negativa a las mujeres y, consecuentemente, a la maternidad.

I. Días de cotización mínimos

Ley del Seguro Social

Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;

²² Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “¿Discrimina la seguridad social...?”, *op. cit.*, p. 124.

II. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha probable del parto, y

III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los períodos anteriores y posteriores al parto. Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad.

Artículo 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro a que se refiere la fracción V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta Ley. Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción I del artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional: “Artículo 28.— Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo”.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge, concubina o la mujer con quien la o el Trabajador o la o el Pensionado haya suscrito una unión civil, así como la hija menor de dieciocho años y soltera, según sea el caso, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los de la o el Trabajador o la o el Pensionado del que se deriven estas prestaciones. En el caso de que la Trabajadora no cumpla con el requisito de seis meses de antigüedad, la Dependencia o Entidad de su adscripción, cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la Junta Directiva.

De acuerdo con estos preceptos, la trabajadora asegurada tiene derecho a gozar de un subsidio en dinero durante el embarazo y el puerperio si cumple con el requisito de cotizar un mínimo de semanas en el caso de la Ley del Seguro Social; y de tres meses de “descanso” si se mantuvieron vigentes los

derechos laborales seis meses previos al parto según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En caso de no cumplir con esta condición, el patrón o empleador tendría que asumir el costo de los días de licencia de maternidad.

Sin embargo, diversos trabajos académicos afirman que el mejor escenario para la equidad socioeconómica y de género es aquel en que los permisos no representen un costo directo para los empleadores.²³ Si bien bajo la lógica del legislador las mujeres embarazadas “no quedan desamparadas” al incumplir este requisito, pues la carga del pago del salario completo se traslada al patrón, lo cierto es que las mujeres trabajadoras (sin hijos, embarazos y madres) también se ven afectadas.

Bajo estos criterios de acceso a la protección de la seguridad social se maneja un doble discurso: por un lado, que la seguridad social protege a la maternidad, pero, por otro lado, ante el incumplimiento de un requisito de carácter matemático y circunstancial se deslinda de esa responsabilidad, imponiéndosela a los empleadores.

Se olvidan de que el control de cuándo embarazarse no está completamente en manos de las mujeres ni mucho menos de sus patrones. Desafortunada y precisamente por lo anterior, en la práctica muchos de ellos recurren a medidas ilegales para evitar caer en ese supuesto, como se verá más adelante.

II. Madres trabajadoras contratadas por honorarios profesionales y contratos temporales no están protegidas por la seguridad social

Las mujeres trabajadoras que no cuentan con seguridad social, ya sea porque laboran en el sector informal o porque sus empleos no las aseguran, están en una situación más alta de vulnerabilidad al trabajar doble jornada (labores

²³ Early Institute, “Recomendaciones para implementar...”, *op. cit.*, p. 37.

de cuidado de sus hijas e hijos y fuera de casa) y carecer de protección de los servicios de salud, teniendo que buscar otras alternativas para resolver su atención médica.²⁴

Si bien las mujeres contratadas por honorarios y bajo nombramientos temporales no aportan a la seguridad social, en muchas ocasiones no es por voluntad propia, sino por conveniencia del patrón. En el fondo, aquí también hay un doble estándar, pues la regulación de la seguridad social dice proteger a la maternidad, pero ante casos de mujeres contratadas por honorarios y bajo nombramientos temporales se deslinda de esta responsabilidad, volviéndose omiso en garantizar la atención obstétrica y de maternidad a todas las mujeres mexicanas y dándole un trato diferenciado en la práctica a las madres trabajadoras, unas de primera y otras de segunda categoría.

Al final —como se verá más adelante— esta situación genera el efecto contrario a lo que aspira la seguridad social en la teoría, que las personas dispongan por derecho de las condiciones sociales mínimas para su independencia: inhibir el embarazo y la maternidad en el espacio laboral.

Por lo tanto, el embarazo debe ser una excepción a la regla de que los trabajadores contratados por honorarios no tengan seguridad social, pues la maternidad es un bien social que debe ser protegido en cualquier circunstancia.

III. Ausencia de permisos de paternidad en la regulación de la seguridad social

Así como el caso anterior y pese a los inconmensurables esfuerzos por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y de visibilizar su importancia para el cuidado de la niñez, la paternidad no se encuentra garantizada por la seguridad social en México; por el contrario, mientras que la licencia de maternidad tiene una duración en promedio de 12 semanas, el permiso de

²⁴ Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *op. cit.*, p. 26.

paternidad sólo tiene una duración máxima de cinco días laborables con goce de sueldo y —conforme a la Ley Federal del Trabajo—²⁵ éstos deberán ser cubiertos por el empleador; es decir, la licencia de maternidad en México “se financia con las contribuciones a la seguridad social, mientras que el permiso por paternidad se financia por los empleadores”.²⁶

En ese sentido, esta regulación “implica una doble discriminación: la significativamente menor duración de la licencia de paternidad y la ausencia de subsidios públicos para la misma”.²⁷ Sin embargo, la licencia de maternidad y el permiso de paternidad deberían ser asegurados en conjunto como “una prestación familiar”, pues se trata de labores esenciales que abonan al mismo fin.²⁸

De acuerdo con la ENASIC 2022, 86.6% de los hombres de 15 a 60 años con hijas o hijos menores de 18 años informó que apoyó para darles de comer o beber a sus en el primer mes de vida y 75.8% en tareas de bañar, asear, vestir o arreglar.²⁹ Como se puede observar, los padres también realizan labores de cuidado que tienen que ser garantizadas por la seguridad social para que, a su vez, las asuman en corresponsabilidad con las madres.

Así pues, la paternidad también debe pertenecer a la seguridad social universal por dos factores: el primero y más importante, porque las niñas y niños tienen derecho a ser cuidados por su papá, los necesitan cerca para su sano desarrollo; el Estado debe impulsarlo y garantizarlo; el segundo factor, para no perpetuar los estereotipos de que las labores de cuidado infantil son responsabilidad principal o exclusiva de las mujeres. “De aquí que las reivin-

²⁵ Artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo.

²⁶ Early Institute, “La discriminación laboral por embarazo...”, *op. cit.*, p. 36.

²⁷ Ramos Duarte, Rebeca y Murrieta Ramírez, Rebeca, “Los cuidados y el trabajo”, en Vela Barba, Estefanía (comp.), *Manual para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Laboral*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, p. 321.

²⁸ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 455.

²⁹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados...”, *op. cit.*, p.33.

dicaciones de equidad e igualdad de las mujeres respecto a los hombres y de la sociedad en general deben ser impulsadas dentro de la seguridad social”.³⁰

D. Consecuencias

Ahora bien, estos preceptos y omisiones de la seguridad social generan consecuencias graves para las mujeres trabajadoras, como las que se desarrollan a continuación.

I. Madres y mujeres embarazadas sin acceso a la seguridad social

Como se mencionó, México aún se mantiene en su totalidad bajo el esquema de aseguramiento social con prestaciones dependientes de la vinculación laboral, es decir, para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social, se requiere contar con un empleo formal. Esta situación deja a las mujeres —quienes son las “más propensas a realizar trabajo no remunerado”—³¹ que se encuentran laborando en el sector informal o en empleos donde no las aseguran en una situación más alta de vulnerabilidad al carecer de protección de los servicios de salud y al tener que buscar otras alternativas para resolver su atención médica.³²

Un indicador de esta realidad lo arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI, que reportó que 54% de las mujeres trabajadoras entre 15 y 49 años requirió atención por un embarazo o parto en 2017 no obtuvo licencia por maternidad,³³ esto es más de la mitad. En esa lógica, las mujeres carecen de un mínimo básico para el funcionamiento como seres humanos.³⁴

³⁰ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 455.

³¹ Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.* p. 87.

³² Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 455.

³³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS). Presentación de resultados”, 2017, p. 26, Véase en: «<https://www.inegi.org.mx/programas/eness/2017/default.html>».

³⁴ Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.* p. 87.

Es precisamente en el nexo de aseguramiento con las instituciones de seguridad social nacionales que los problemas que aún enfrenta el derecho laboral para las mujeres se amplifican. Dicho en otras palabras, factores como el subempleo, desempleo y el aumento del empleo informal se tornan dramáticos al darles el enfoque de género, puesto que no sólo constituyen una problemática aún no resuelta para el derecho laboral, sino que además excluyen a las mujeres de la cobertura de los seguros sociales, ocasionándoles la desprotección social, el empobrecimiento y la dependencia a las instituciones de asistencia social.³⁵

Si bien no se debe menospreciar la creación de algunas modalidades de aseguramiento que permiten a trabajadoras y trabajadores no formales tener acceso a prestaciones de índole médico como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), lo cierto es que la situación de vulnerabilidad persiste aún ante este tipo de alternativas pues el acceso a la salud no es el único factor en juego.

Por un lado, las mujeres trabajadoras (dentro o fuera de casa) que no tienen acceso a la seguridad social tampoco se pensionarán; por ejemplo, la falta de reconocimiento de las labores de cuidado y del hogar afecta de manera directa las pensiones de las mujeres cuidadoras no remuneradas.³⁶ La seguridad social delega las labores de cuidado pero no las retribuye; al contrario, vulnera a quien las ejerce. Pero no sólo eso, este contexto tiene una consecuencia mucho más profunda y es que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación. Un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

Ahora bien, concretamente con respecto a las labores de cuidado, la falta de reconocimiento, pago y acceso a la seguridad social no es la única desventaja

³⁵ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, "Análisis comparativo", *op. cit.*, p. 455.

³⁶ Vargas Sandoval, Yaneth, *op.cit.* p. 93.

a la que se enfrenan las mujeres como únicas responsables, sino que también implica la dificultad enorme de acceder al empleo formal. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC 2022), 68.4 % de las mujeres no económicamente activas reconoció que deseaban trabajar por un ingreso, pero no lo hacían por “no tener quien les cuide a sus hijas(os)”.³⁷ Es decir, se trata de un trabajo que es muy difícil de realizar, sin apoyo, a la par de otro fuera del hogar. Esta situación genera que no exista un salario o ingreso constante de dinero, e inevitablemente una dependencia económica de alguien más —generalmente un hombre—, lo que mantiene las condiciones de desigualdad de género a las que nos enfrentamos actualmente.³⁸

Así pues, si la maternidad no es vista como un bien social que tiene que ser protegido, las labores de cuidado no son remuneradas ni reconocidas como un trabajo formal y tampoco están protegidas por la seguridad social de forma universal, el Estado será omiso frente a todas las mujeres mexicanas.³⁹

II. Incentiva la violencia laboral por razón de maternidad

Ahora bien, la forma en la que está regulada la seguridad social en México también perjudica a las mujeres que tienen un empleo formal a pesar de tener garantizado su acceso a la seguridad social en ley. Es decir, por no considerar las necesidades particulares de las mujeres trabajadoras y la forma en la que requieren desenvolverse, la regulación de la seguridad social las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los hombres.

El requisito de cotizar un número determinado de semanas para que la asegurada tenga derecho a la licencia de maternidad y, a su vez, la imposición al empleador de pagar el salario completo ocasiona —en la práctica— que

³⁷ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados...”, *op. cit.*, p. 28.

³⁸ Urquilla Bonilla, Carlos Rafael, *op. cit.*, p. 244.

³⁹ Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *op. cit.*, p. 26.

se incumpla la obligación de garantizar plenamente los derechos de las trabajadoras embarazadas.⁴⁰

Si bien se podría creer que “las mujeres no quedan desamparadas” pues se traslada la responsabilidad —de la seguridad social— al patrón, lo cierto es que —inevitablemente y por mero sentido común— él lo percibe como una “carga”. Esto, por un lado, desincentiva el trabajo que se tiene que hacer para que la maternidad sea percibida —en todos los ámbitos, incluido el laboral— como un bien social, no como una desventaja, pero también genera un trato laboral violento y discriminatorio hacia las trabajadoras.

En ese sentido, algunos patrones recurren a métodos ilegales para cerciorarse del estado de no gravidez; por ejemplo, en para evitar contratar a mujeres embarazadas o que se embarazarán pronto, solicitan certificados de no gravidez expedidos por laboratorios clínicos como requisitos para las aspirantes a una vacante,⁴¹ o preguntan directamente en las entrevistas de trabajo si planean embarazarse pronto. También sucede que simplemente deciden no cumplir con su obligación y condicionan el trabajo de las mujeres a que no exijan su licencia de maternidad.

Para bien o para mal, la voluntad patronal juega un papel determinante para que la madre trabajadora o trabajadora embarazada ejerza sus derechos pues, además de los ejemplos anteriores, existen casos documentados de que cuando no las quieren inscribir en el seguro social simplemente no les dicen y ellas, que en muchas ocasiones desconocen los procesos, no se enteran. En los registros administrativos con los que cuenta el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se aprecia cómo sólo 37.5% de las mujeres que acudieron a presentar una queja o a pedir información cuentan con seguridad social, el resto no (15.3%) y la mayoría —casi la

⁴⁰ *Idem.*

⁴¹ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 465; Ramos Duarte, Rebeca y Murrieta Ramírez, Rebeca, *op. cit.*, p. 345.

mitad— no lo sabe (47.2%). Destaca el hecho de que no estuvieran dadas de alta cuando ellas asumían que lo estaban.⁴²

Tampoco es posible ignorar que los empleadores también recurren a las contrataciones temporales y por honorarios para eludir las responsabilidades de contratarlas formalmente, las mujeres aceptan las condiciones con tal de obtener el trabajo y la seguridad social queda exenta de sus obligaciones, supuesto bajo el que se esquiva la finalidad propia de la seguridad social.

En el mismo sentido, si la propia regulación de la seguridad social da al embarazo un trato de incapacidad, es lógico que empleadoras y empleadores harán lo mismo y lo verán como una desventaja frente a los hombres que, tristemente, no cuentan con permisos de paternidad homologados (del mismo tiempo ni garantizados por la seguridad social). Esto ha llevado a que “la discriminación laboral por embarazo sea un problema de gran escala, mucho más frecuente y común de lo que se piensa, incluso en países donde se tiene una regulación específica para erradicarla”.⁴³

En México, a pesar de que aparentemente existen leyes y mecanismos institucionales que protegen a las mujeres embarazadas, el embarazo es una de las principales razones de discriminación. De acuerdo con el informe “La discriminación laboral por embarazo”, publicado por Early Institute en 2022, entre 2012 y 2021, esta problemática representó la principal causa de presuntas conductas discriminatorias denunciadas ante el COPRED⁴⁴ y 69% del total de las denuncias por discriminación presentadas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona (FEVIMTRA).⁴⁵

Generalmente se ha asociado con conductas como el despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación o el ascenso. Sin embargo, abarca

⁴² Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *op. cit.*, p. 146.

⁴³ Early Institute, “La discriminación laboral por embarazo...”, *op. cit.*, p. 13.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 46.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 49.

otras, como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la reducción de salario, el cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, la prohibición de ir al baño o sentarse, así como ordenar la realización de labores que pongan en riesgo la salud de la mujer embarazada y de su hijo o hija.⁴⁶

Como se observa, no se trata de casos aislados ni de carácter exclusivamente laboral, existe un clima adverso para el embarazo y la maternidad en el espacio público, todo lo contrario a lo que debería de ser.

Sin embargo, como lo documenta el informe de Early Institute, las mujeres embarazadas prefieren no denunciar por temor a ser despedidas o a ser revictimizadas en un procedimiento de denuncia que no cuenta con los elementos necesarios para brindarle acceso a la justicia ni a medidas de protección. Soportan malos tratos, humillaciones y hostigamiento con tal de conservar su trabajo y tener acceso a la seguridad social al momento del parto, así como estabilidad económica para que sus bebés estén bien. Así que la falta de una regulación de seguridad social con perspectiva de género puede generar que, incluso, las madres trabajadoras toleren violencias ejercidas contra ellas.

Finalmente, pero no menos importante, se tiene que visibilizar que este tipo de violencia en el embarazo puede provocar en el bebé bajo o muy bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés y un parto pretérmino.⁴⁷ Así pues, se observa la falta de un enfoque con perspectiva de niñez que visibilice el impacto que la discriminación deja no sólo en la mujer, sino también en la vida, salud, integridad y desarrollo de las niñas y niños.

III. Desigualdad laboral

Diversos estudios muestran que la incorporación de las mujeres en contextos laborales no ha estado acompañada de igualdad ni equidad laboral. A raíz de la participación cada vez más activa de las mujeres en el empleo se

⁴⁶ *Ibidem*, p. 19.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 14.

empezó a observar el fenómeno de la discriminación en razón del género y su consecuente desigualdad laboral.⁴⁸

En ese sentido y derivado de todo lo anterior, se hace evidente que las madres “tienen mayores dificultades de encontrar un empleo, permanecer o continuar en él”.⁴⁹ Por tal motivo, han nacido conceptos como el de *maternal wall*, que se refiere a la barrera que representa ser madre para obtener ciertos puestos y ascender en el ámbito laboral.⁵⁰

Así lo confirma la ENASIC 2022, cuyos hallazgos mostraron que del total de las mujeres cuidadoras de integrantes de su hogar o de otros hogares 56.3% son económicamente activas y su incorporación presenta una amplia brecha en comparación con la de los hombres.⁵¹

E. Propuesta

Como se pudo observar, estamos lejos de contar con una regulación de la seguridad social que contemple las prestaciones de maternidad como un mecanismo que permita repartir las obligaciones entre padres y madres para con los hijos, posibilitando la no desvinculación laboral de las madres⁵² y el involucramiento de los padres.

En ese sentido, se requiere brindar una protección al embarazo y la maternidad que vaya más allá de la licencia de maternidad como la conocemos actualmente; debe ser una protección reforzada, integral y transversal.

Mecanismos de esta naturaleza ya existen en ámbitos como el jurisdiccional, tal es el caso del *fuero maternal*, que exige una mayor protección del Estado

⁴⁸ Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *op. cit.*, p. 70.

⁴⁹ *Idem.*

⁵⁰ Early Institute, “La discriminación laboral por embarazo...”, *op. cit.*, p. 13.

⁵¹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados...”, *op. cit.*, p. 25.

⁵² Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “¿Discrimina la seguridad social...”, *op. cit.*, p. 117.

durante los periodos de embarazo y licencia posnatal pues, a consideración del máximo tribunal,

durante esos periodos tienen condiciones físicas especiales y necesidades que las hacen merecedoras de conservar el empleo en mayor énfasis. Se trata de lograr una garantía real y efectiva en su favor, de modo que cualquier decisión que se tome desconociendo esta protección indebidamente, constituirá un caso de discriminación por razón de sexo.⁵³

El desarrollo de este criterio fue necesario y consecuencia de algunos casos en que empleadores, ante la falta de información y para evadir la ley, esperan a que las mujeres embarazadas lleguen a término para despedirlas sin incurrir en una conducta ilegal, pues —bajo su lógica— “ya no están embarazadas”, pero lo hacen porque en el fondo están motivados por prejuicios y estereotipos alrededor de la maternidad. Por otra parte, se trata de una protección especial debido a que exige —de quienes están encargados de investigar e impartir justicia— eliminar las barreras y obstáculos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de, por ejemplo, gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del bebé. Así pues, se trata de un ejemplo de que es posible implementar políticas reforzadas encaminadas a cumplir con ese objetivo.

En resumen, se requiere un cambio profundo en el sistema de seguridad social mexicano que no esté basado en la condición laboral de las personas y elimine las barreras de acceso efectivo a los servicios y prestaciones sociales; para ello, la propuesta de reforma debe ser diseñada desde un enfoque de derechos sociales, para evitar que ésta se limite a ser un derecho laboral del asalariado.⁵⁴ En ese sentido y frente a la maternidad el derecho a la seguridad social debe ser releído y reposicionado a partir de una lectura desde la perspectiva de género, que implica, por un lado, comprender las necesida-

⁵³ SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 5139/2018, 14 de noviembre de 2018, pág. 22, párr. 2.

⁵⁴ Early Institute, “Recomendaciones para implementar...”, *op. cit.*, p. 37.

des específicas y diferenciadas de hombres y mujeres frente a cada derecho, pero igualmente, abrir el ejercicio y goce del derecho a las opciones que se derivan de las diferentes formas de construcción-ejercicio de la feminidad y la masculinidad.⁵⁵

La respuesta está en apostar por una seguridad social universal en la que se supere el modelo de división sexual del trabajo donde las mujeres son relegadas a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y se incluya no sólo a las y los trabajadores que cotizan sino también a quienes realizan las labores de cuidado.⁵⁶

Reconocer el trabajo doméstico y las labores de cuidado dentro de las leyes relacionadas con la seguridad social, incluso aunque sólo se trate de la modificación a los preceptos que se han señalado previamente, sería un gran paso para reivindicar el trabajo que las mujeres han hecho por años sin recibir la justa compensación. Llevaría a que se reconozca que el trabajo de reproducción, crianza de las hijas e hijos, cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores es una “responsabilidad social”.⁵⁷

Ahora bien, lo anterior forzosamente requiere incluir los permisos de paternidad como una prestación de la seguridad social, pues ya se ha demostrado su potencial para promover la participación de los hombres en el cuidado y la educación de sus hijas e hijos, incrementar la colaboración en el trabajo doméstico e incidir favorablemente en el crecimiento laboral de las madres.⁵⁸

Basta recordar que la seguridad social se construye alrededor de la manera en la que una sociedad reparte las responsabilidades de cuidado, por lo que en México es necesaria una repartición equitativa de la responsabilidad familiar al interior del núcleo familiar entre trabajadores y trabajadoras, inclusive

⁵⁵ Urquilla Bonilla, Carlos Rafael, *op. cit.*, p. 253.

⁵⁶ Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.*, p. 97.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 93.

⁵⁸ Early Institute, “Recomendaciones para implementar...”, *op. cit.*, p. 13.

con la intención de favorecer la posibilidad del desarrollo profesional de las mujeres.⁵⁹

Si bien “una de las principales dificultades que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la seguridad social”,⁶⁰ lo cierto es que los beneficios que estos cambios podrían lograr son mucho más redituables. No se debe olvidar que la intervención protectora y asistencial hacia la maternidad, la infancia y la familia representan en el ordenamiento jurídico nacional un valor prioritario que debería ser superior inclusive al tratamiento de igualdad.⁶¹

F. Conclusión

“En América Latina, la seguridad social se ha implementado con instituciones y leyes hasta hace muy poco tiempo, por lo que aún son estructuras frágiles, que no garantizan adecuadamente los derechos a sus ciudadanos”.⁶² El sistema de seguridad social mexicano no es la excepción, ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de justicia social de las mujeres trabajadoras, dentro y fuera del hogar, y de sus hijas e hijos.

Como se desarrolló en este texto, la seguridad social en México le ha dado la espalda a las mujeres que día a día dedican su vida a cuidar a quienes lo requieren en este país, ha invisibilizado su labor y las ha dejado desprotegidas; pero también le ha fallado a las que salen a buscar un empleo remunerado y que forman parte de la economía del país, las ha condicionado, dejado al arbitrio de sus empleadores y en desventaja frente a sus colegas varones.

La reivindicación de los servicios sociales tendrá lugar sólo en la medida que se reconozca la maternidad y las labores de cuidado, no sólo como un bien social, sino también como un trabajo digno de ser remunerado y garantizado

⁵⁹ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 477.

⁶⁰ Early Institute, “Recomendaciones para implementar...”, *op. cit.*, p. 31.

⁶¹ Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo”, *op. cit.*, p. 478.

⁶² Vargas Sandoval, Yaneth, *op. cit.*, p. 85.

por la seguridad social. Mientras se releguen como una condición de carácter privado, las mujeres seguirán estando en desigualdad frente a los hombres y en situación de vulnerabilidad.

G. Bibliografía

Artículos de revistas especializadas

International Planned Parenthood Federation/WHR y Promundo, “Capítulo 2, ¿Cómo impacta una paternidad participativa y comprometida con el desarrollo infantil?”, *Estado de la paternidad: América Latina y el Caribe*, 2017, p. 37.

Jiménez Brito, Lourdes, “Maternidad y seguridad social”, *Cuadernos de Políticas para el Bienestar*, México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, p. 116.

Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “¿Discrimina la seguridad social a las mujeres?”, *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, Núm. 4, enero-junio de 2007, p. 135.

Mendizábal Bermúdez, Gabriela, “Análisis comparativo de las prestaciones de seguridad social por maternidad”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XXXIX, núm. 116, mayo-agosto de 2006, p. 456.

Ramos Duarte, Rebeca y Murrieta Ramírez, Rebeca, “Los cuidados y el trabajo”, en Vela Barba, Estefanía (comp.), *Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021.

Urquilla Bonilla, Carlos Rafael, “El derecho a la seguridad social: Una aproximación desde la perspectiva de género”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 253. Disponible en: «<https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22094.pdf>»

Vargas Sandoval, Yaneth, “Un acercamiento teórico sobre la mujer en la seguridad social”, *Revista IUSTA*, Núm. 52, 2020, p. 90. Disponible en: «<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/5484/5240>».

Libros y obras consultadas

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, *Discriminación por embarazo, Un estudio sobre la Ciudad de México*, México, 2022, p. 23.

Early Institute, *La discriminación laboral por embarazo, Serie: Prácticas que vulneran la maternidad en México*, México, 2021, p. 13.

Early Institute, *Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México*, México, 1a. ed., 2019, p. 13.

Sitios web consultados

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS). Presentación de resultados”, 2017, p. 26. Disponible en: «<https://www.inegi.org.mx/programas/eness/2017/default.html>».

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC). Nota técnica” 2022, p. 7. Disponible en: «https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_tecnica.pdf».

Legislación nacional

Ley del Seguro Social.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Precedentes judiciales

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 5139/2018, 14 de noviembre de 2018, pág. 22, párr. 2.

La prestación de guarderías y las responsabilidades de cuidado en el contexto de la seguridad social

Silvia López Estrada*

* Departamento de Estudios de Población. El Colegio de la Frontera Norte.

SUMARIO: A. Introducción; B. El cuidado infantil y la seguridad social; I. Regímenes de bienestar y la protección social para la infancia; II. Protección social para la infancia; III. El derecho al cuidado infantil y la seguridad social; C. Marco normativo de los derechos de la infancia; I. Características de la población infantil de 0 a 6 años en México; II. Políticas para la protección social de la infancia; D. La prestación de guardería en México; E. Conclusiones; F. Bibliografía.

En el contexto de las normativas internacionales que establecen que la seguridad social es un derecho, así como también el derecho al cuidado a lo largo de la vida, ya que todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidados, en este trabajo analizo la prestación de guarderías y estancias infantiles en México como un derecho de la primera infancia.

Con base en la revisión de la literatura especializada sobre el tema de cuidados, los derechos de la infancia y la prestación de guarderías como parte de la seguridad social, este trabajo intenta promover la reflexión sobre las tendencias que se presentan en México con relación a la prestación de guarderías. Para ello me apoyo también en información de entrevistas realizadas con mujeres que fueron beneficiarias de las Estancias Infantiles Sedesol y con asistentes educativas que laboraban en estos centros de atención a la infancia.

Se argumenta que en México prevalece un conjunto de provisión de servicios de cuidado infantil segmentado y fragmentado en función del acceso de las personas al empleo, de tal forma que coexisten distintos tipos de prestación de guarderías, que forman parte de sistemas contributivos y no contributivos y que se caracterizan por diferente amplitud de su cobertura y por su calidad,

pues, a pesar de los esfuerzos por expandir los servicios de cuidado infantil, persiste la fragmentación. Además, no obstante el carácter garantista del Estado frente a los derechos de la infancia, que asume su corresponsabilidad en el cuidado de la infancia, y que está presente en el marco normativo, las familias siguen cargando con la responsabilidad primaria del cuidado infantil, con consecuencias para el desarrollo integral de la infancia, así como para la inserción laboral femenina y el reparto del cuidado entre mujeres y varones. De ahí que se enfatice la necesidad de avanzar en la propuesta de crear un Sistema Integral de Cuidados en el país.

A. INTRODUCCIÓN

En el contexto de los aportes conceptuales sobre el concepto de cuidado y los regímenes de bienestar, así como de los derechos para la infancia, en este capítulo se analiza la prestación de guarderías como parte de la seguridad social, a través de programas y políticas que se han implementado en México, así como los impactos y las limitaciones que estas acciones públicas han tenido para la primera infancia, para la inserción laboral de las mujeres y el balance en el reparto de cuidados al interior de las familias. La intención es establecer los aportes, así como también definir las áreas de oportunidad para la ampliación de los derechos de la infancia.

De esta forma, el capítulo inicia con una breve revisión de los aportes conceptuales sobre los cuidados y los regímenes de bienestar, y en particular los regímenes de cuidados, que nos permite ubicar la prestación de guarderías como parte de la seguridad social. Considerando que el enfoque de derechos es una de las principales perspectivas de los cuidados, un segundo apartado está dedicado al marco normativo de los derechos de la infancia. En el marco de las políticas de cuidado infantil, enseguida abordó la prestación de guarderías, en donde se exponen las instituciones y programas que forman parte de los sistemas contributivo y no contributivo, señalando sus bondades, en tanto ampliación de derechos ciudadanos para la infancia, y sus limitaciones e impactos en las desigualdades de género y clase.

Por último, en el contexto de los desafíos que presenta la prestación de guarderías en México, se elaboran algunas conclusiones tendientes a la creación de un sistema integral de cuidados que permita la disminución en el acceso a la provisión de servicios de cuidado infantil a través de su ampliación.

B. El cuidado infantil y la seguridad social

En el análisis de la prestación de guarderías, que consiste en una externalización del cuidado infantil fuera del ámbito de la familia, en primer lugar, es necesario referirnos al concepto más amplio de cuidados.

Recupero aquí la definición de cuidados de Joan Tronto: “actividades de la especie que incluyen todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar el mundo en que vivimos, haciéndolo lo mejor posible”,¹ en tanto que Daly y Lewis especifican las personas y las normas que regulan los cuidados, y refieren, además, sus relaciones: “Actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como los marcos normativos económicos y sociales dentro de los cuales éstas son asignadas y llevadas a cabo”.²

Para la CEPAL, los cuidados son actividades que se desempeñan para el bienestar de las personas, ya que todos y todas somos vulnerables y requerimos de cuidar y ser cuidados a lo largo de la vida, por lo cual el curso de vida es un elemento central en el análisis. La idea de los cuidados como derecho es también fundamental, según la acepción de Pautassi.³ En el caso particular de la infancia, se sostiene en los convenios internacionales, así como en la legislación y normatividad nacionales.

¹ Tronto, J., *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, 1993, p. 103.

² Daly, Mary y Lewis, Jane, “El concepto de ‘Social Care’ y el análisis de los Estados de Bienestar contemporáneos”, en Borderías, Cristina, Carrasco, Cristina y Torns, Teresa (eds.), *El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas*, 2a. ed., Madrid, Catarata, 2019, p. 285.

³ Pautassi, L., “El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos”. *Serie Mujer y Desarrollo* 87, Santiago de Chile, Cepal, 2007.

Además, entre las acepciones más importantes del concepto de cuidado se destaca que es un trabajo no remunerado pero también remunerado que llevan a cabo las mujeres en forma predominante. La naturaleza de la actividad varía considerando los ámbitos y la remuneración, ya que este trabajo puede llevarse a cabo tanto dentro como fuera de los hogares, y puede realizarse de manera honoraria o con remuneración.⁴

Los cuidados se caracterizan por dos dimensiones, que son la material y la afectiva/emocional, aunque autoras como Aguirre⁵ también incluyen una dimensión física. Además, es importante considerar las prácticas de cuidados, así como las valoraciones y significados de estas actividades.

En este contexto, considero el cuidado infantil como la acción de ayudar a un niño a desarrollarse y a facilitarle bienestar en su vida cotidiana, casi siempre llevada a cabo por mujeres, se compone de distintas dimensiones: el cuidado físico, que implica una serie de actividades; el cuidado material, que implica costos económicos, y el cuidado afectivo, que implica el desarrollo de un vínculo emotivo y sentimental.⁶

Además, los cuidados se caracterizan por una dimensión relacional entre quienes reciben cuidado y quienes lo proporcionan, y tiene al centro relaciones de poder que desde una mirada interseccional: consideran el género, la edad, la etnicidad, la clase social, etc. En el caso de la infancia, se suele considerar a las niñas o niños en relaciones de dependencia;⁷ sin embargo, tienen derechos por sí mismos y no son “menores” bajo intervención, protección y vigilancia. De esta forma, sus interacciones con las personas adultas

⁴ Aguirre, R., “La necesaria redefinición del trabajo. Consideraciones conceptuales y metodológicas [ponencia]”, en V Congreso Latinoamericano de Sociología, Montevideo, Uruguay, 2007.

⁵ Aguirre, R., “La política de cuidados en Uruguay: ¿un avance para la igualdad de género?”, *Estudios Feministas*, vol. 22, núm. 3, 2014.

⁶ Batthyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales*. Santiago de Chile, CEPAL-AECID, serie Asuntos de Género, 2015; Aguirre, “La política de cuidados en Uruguay: ¿un avance para la igualdad de género?”, *op. cit.*

⁷ Comas, D., “Cuidados y derechos. El avance hacia la democratización de los cuidados”, *Cuadernos de Antropología Social*, núm. 49, 2019.

que cuidan no son unilaterales, ya que si bien las hijas o hijos dependen de sus padres para llegar al jardín infantil, estas acciones también impactan las actividades productivas y reproductivas de los padres.⁸

Las decisiones que se llevan a cabo acerca del cuidado infantil casi nunca son individuales, sino que están condicionadas por decisiones y negociaciones que se llevan a cabo en los contextos familiares y que deben tomar en cuenta las necesidades y, en lo posible, la opinión de las niñas o niños. Debido a lo anterior, en materia de cuidados, se considera que es más pertinente hablar de interdependencia que de in/dependencia.⁹

I. Regímenes de bienestar y la protección social para la infancia

Los regímenes de bienestar expresan las formas en que se produce y asigna el bienestar de sus integrantes por la familia, el Estado, el mercado y la sociedad.¹⁰ En los estados de bienestar, el objetivo es la satisfacción de las necesidades básicas de la población, a través de sus pilares fundamentales, que son la gratuidad de los servicios públicos de salud y educación, así como también la alimentación.

En América Latina, los sistemas de bienestar tienen como base los pilares de la educación, la salud y seguridad social, aunque son heterogéneos en sus características, grados de desarrollo, cobertura y calidad de las prestaciones.¹¹ Scuro, Alemany y Coello consideran que, además de estos tres elementos, los cuidados constituyen un elemento esencial para el bienestar y el desarrollo individual y colectivo, así como para la sostenibilidad de la vida y la

⁸ Murray, L. y Cortes-Morales, S., *Children's Mobilities*, Palgrave MacMillan, 2019.

⁹ Mikkelsen, M. y Christensen, P., "Is Children's Independent Mobility Really Independent? A Study of Children's Mobility Combining Ethnography and GPS/Mobile Phone Technologies", *Mobilities*, vol. 4, núm 1, 2009.

¹⁰ Espig-Andersen, C., *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge/Princeton, Polity Press and Princeton University Press, 1999.

¹¹ ONU-Mujeres y CEPAL, citado por Scuro, L., C. Alemany y Coello, R., *Financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe. Aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género*, Santiago de Chile, Cepal, División de Asuntos de Género, 2022.

reproducción del sistema en su conjunto.¹² Por su parte, dada la creciente importancia de los cuidados, su visibilidad y posicionamiento en la agenda de las políticas públicas, Sonia Montaña señala que los cuidados constituyen el cuarto pilar del bienestar.¹³

En el modelo tradicional de familia, mujeres y niños acceden a la seguridad social a través del empleo del varón. De acuerdo con Espig-Andersen,¹⁴ mientras que en la familia el bienestar se consigue a través de la reciprocidad, los mercados lo asignan a través del dinero y el Estado lo redistribuye a través de un sistema de transferencias.

Espig-Andersen distingue tres distintos modelos de bienestar en las sociedades capitalistas: el liberal, que promueve la provisión de mercado con un rol marginal del Estado y la familia (Canadá y Estados Unidos como ejemplos); el conservador, representado por Alemania y Francia, y que se caracteriza por provisión social, rol central de la familia, carácter marginal del mercado y acción subsidiaria del Estado. Por último, el régimen socialdemócrata implica una política social universal e igualitaria en términos de clase, con rol central del Estado y marginal del mercado y la familia.

Desde el feminismo, las especialistas han argumentado que estos distintos ámbitos se caracterizan por relaciones de poder, y, por tanto, se producen desigualdades de género, así como de clase y etnicidad, entre otras. Razavi propuso el concepto del diamante del cuidado para reflejar estas injustas relaciones desiguales de poder en la organización social del cuidado que se constituyen por diferentes actores sociales: la familia, el estado, el mercado y la sociedad.¹⁵

¹² Scurio, L., C. Alemany y Coello, R., *Financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe. Aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género*, Santiago de Chile, CEPAL, División de Asuntos de Género, 2022.

¹³ Montaña, S. y Calderón C. (coords.), "El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo", *Cuadernos de la CEPAL*, 94, 2010.

¹⁴ Espig-Andersen, *op. cit.*

¹⁵ Razavi, S., "The Political and Social Economy of Care in the Development Context. Conceptual Issue, Research Questions and Policy Options", *Gender and Development*, núm. 3, 2007.

II. Protección social para la infancia

Los distintos modelos de bienestar incluyen, a su vez, un marco para la protección social que se constituye de prestaciones laborales para garantizar el trabajo digno y calidad de vida de las personas, así como distintas políticas y programas de carácter público. Debido a que el marco más amplio de la protección se dirige a los derechos de las personas que tienen un empleo formal, para garantizar los derechos de la infancia a la protección social universal, sobre todo de las niñas y niños de familias pobres y vulnerables, la UNICEF define la protección social como “un conjunto de políticas y programas destinados a prevenir o proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida, con especial atención a los grupos vulnerables”.¹⁶

Este enfoque se guía por cuatro principios clave: el interés superior del niño, el logro progresivo de la cobertura universal, sistemas y dirección nacionales, así como la protección social inclusiva que responda a necesidades de niñas y niños y que tome en cuenta rasgos identitarios tales como que puedan incrementar su vulnerabilidad, como el género, la etnia, la discapacidad y la ubicación geográfica, entre otros.¹⁷

No obstante la importancia de los programas de protección social para la infancia, la UNICEF advierte que por sí solos estos programas no pueden hacer frente a las necesidades de niñas y niños y sus familias, ni resolver la falta de disponibilidad de servicios de calidad.¹⁸ Es decir, si bien la protección social es vital para la atención de la infancia, no es suficiente para hacer efectivos los derechos de las niñas y los niños.

¹⁶ UNICEF, Marco programático mundial de protección social para la infancia de la UNICEF, 2019, p. 2.

¹⁷ *Ibidem*, p. 3.

¹⁸ *Ibid.*, p. 4.

III. El derecho al cuidado infantil y la seguridad social

El derecho al cuidado infantil puede abordarse desde distintas perspectivas, aquí distinguimos por lo menos tres. En primer lugar, se trata del derecho de las niñas y los niños al cuidado con garantía para su desarrollo y bienestar social; en segundo lugar, se trata del derecho de las mujeres trabajadoras en particular, pero también de los varones, a que sus niñas o niños tengan acceso a servicios de provisión de cuidado infantil, para que puedan acceder al trabajo remunerado y atender sus actividades productivas con la seguridad de que sus niñas y niños están bien atendidos. Se trata también de los derechos de las personas que proporcionan los servicios remunerados y no remunerados de cuidado infantil. Por último, también es importante considerar la corresponsabilidad en las tareas de cuidados entre mujeres y hombres, así como entre las familias y el Estado.

Estas tensiones se reflejan en los debates sobre el cuidado infantil y se vinculan a las discusiones sobre la matriz de la protección que se desea implementar en cada país. Sin embargo, los cuidados no pueden verse desde una perspectiva aislada, ya que hay que considerar los derechos de todas las personas, así como las políticas de educación, salud y seguridad social, y el acceso a los cuidados con garantía de universalidad; además de evitar los sesgos de género que han caracterizado a la mayoría de las políticas sociales en América Latina.¹⁹

En América Latina, algunos países han llevado a cabo programas y políticas con el papel activo del Estado en el reconocimiento de la protección de la infancia o el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres o la promoción de la inserción laboral femenina. Sin embargo, el objetivo de los programas se ha establecido dependiendo de la forma en que cada país define el problema.

Por ejemplo, en el caso de los programas de cuidado infantil, mientras que en Chile el Programa Chile Crece Contigo está orientado a resolver el desarrollo integral de la primera infancia, así como la inserción laboral de

¹⁹ Scuro *et al.*, *op. cit.*, p. 26.

las mujeres, en México el programa de provisión de servicios de cuidado consideraba como problema la inserción laboral de las mujeres, y, por tanto, tenía como objetivo facilitar la participación económica femenina. Uruguay contaba con una política integral de cuidado infantil, que hacía parte de un Sistema Integral de Cuidados, al considerar entre sus objetivos el desarrollo integral de la infancia, la inserción laboral femenina, así como también un reparto equitativo del trabajo de cuidados tanto entre mujeres y hombres, como entre las familias y el estado.²⁰

C. Marco normativo de los derechos de la infancia

Desde una perspectiva de derechos que considera que todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidados a lo largo de la vida.²¹ En los tratados internacionales, el derecho al cuidado forma parte de los derechos reconocidos de los que gozan las personas, sin importar su situación de vulnerabilidad, fragilidad o dependencia. Estos derechos hacen posible la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta, atendiendo a principios de universalidad, corresponsabilidad y género.²²

Además de garantizar el acceso al cuidado de las personas, el derecho al cuidado reconoce el valor del trabajo de cuidados, garantiza también los derechos de las personas que los proveen, y también implica deconstruir la noción de la responsabilidad exclusiva de las mujeres en estas tareas.

A continuación reviso el marco jurídico internacional y nacional que ampara los derechos de las niñas y niños al cuidado y la protección social y que se muestra de manera resumida en el cuadro 1.

²⁰ Batthyány, K. N. Genta y Perrota, V., “Las representaciones sociales del cuidado infantil desde una perspectiva de género. Principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Representaciones sociales del cuidado”, *Papers*, 99/3, 2014; López Estrada, S., “Políticas de cuidado infantil en América Latina: Análisis comparado de Chile, Costa Rica, Uruguay y México”, *Frontera Norte*, vol. 29, núm. 58, julio-diciembre, 2017.

²¹ Pautassi, L., “El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos”, *Mujer y Desarrollo* Santiago de Chile, Cepal, 87, 2007.

²² Scuro et al., *op. cit.*

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²³ establece en su artículo 9 el derecho a la seguridad social, el cual consiste en el derecho que tienen a la seguridad todas las personas a la provisión de bienestar social, garantizando en particular la protección de las personas más vulnerables, como es el caso de las niñas y los niños entre cero y seis años. Los Estados deben garantizar en forma progresiva este derecho a través de medidas de protección, ya sea en dinero o en especie, que permita a las personas acceder a la atención sanitaria esencial, abrigo y vivienda básicos, agua, saneamiento, alimentación y formas básicas de educación como es la educación inicial. Se establece que por su carácter redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor fundamental de inclusión y cohesión social, así como para la reducción de la pobreza.

En la Observación general 19, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la ONU establece las obligaciones de los Estados en cuanto a respetar, proteger y garantizar el derecho a la seguridad social. Entre las características principales se establecen las siguientes: Disponibilidad, Riegos e imprevistos sociales, Nivel suficiente y Accesibilidad.

Los marcos internacionales establecen los derechos de niñas y niños, así como también favorecen las condiciones propicias para garantizar su cuidado. Sin embargo, fue hasta 1989 que se aprobó como tratado internacional la Convención de los Derechos de los Niños,²⁴ donde se reconoce la necesidad de que los padres reciban asistencia en el cumplimiento de sus responsabilidades de cuidado infantil, considerando que las niñas y los niños pequeños dependen de las capacidades y recursos de sus cuidadores principales.²⁵

²³ Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), *Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales*, México, 2012.

²⁴ Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Convención de los Derechos del Niño*, 1989.

²⁵ Hein, C. y Cassirer, N., *Soluciones para el trabajo infantil en el lugar de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2010.

Con anterioridad, en 1981 la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio núm. 156, impulsó políticas para reducir el conflicto entre el trabajo y la familia, así como para combatir la discriminación laboral asociada a las responsabilidades familiares. Entre dichas políticas se consideraba la participación de instancias públicas y privadas, así como la importancia de la participación estatal en la resolución de las demandas de cuidado.²⁶

Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,²⁷ la Iniciativa para el desarrollo de la Primera Infancia y el impulso del empoderamiento económico de las mujeres recomiendan a los gobiernos el garantizar el acceso universal a los servicios de cuidado infantil temprano y de calidad para todos los niños.²⁸

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño²⁹ adoptando en consecuencia las medidas administrativas y legislativas para hacer efectivo el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas y los niños.

En el ámbito nacional, el artículo 4 constitucional incorpora el derecho de la infancia a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Para ello, en la reforma constitucional del 2000 se establece la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de las niñas y niños y el ejercicio pleno de sus derechos. Como consecuencia de esta reforma, este mismo año fue promulgado un ordenamiento reglamentario del artículo 4. que establece la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,³⁰ con el fin de asegurar su desarrollo pleno e integral. Esta ley establece los derechos mínimos reconocidos a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, norma los cuidados y asistencia para niños y adolescentes y su

²⁶ *Idem.*

²⁷ Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Agenda 230 para el Desarrollo Sostenible*, 2015.

²⁸ Samman, E. y Lombardi, J. *Childcare and Working Families: New Opportunity of Missing Link? An Evidence Brief*, UNICEF, 2019.

²⁹ Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Convención de los Derechos del Niño*, 1989.

³⁰ Cámara de Diputados, *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*, *Diario Oficial de la Federación*, 4 de diciembre de 2014. Última reforma publicada DOF 26-05-2023.

protección contra toda forma de maltrato, abuso y explotación, tanto en el entorno familiar, como en el comunitario y la escuela. Considera también la necesidad de proporcionar asistencia a madres, padres y tutores, en particular a aquellos que tengan hijos con alguna discapacidad, y establece las bases para la participación de los sectores privados y social para garantizar la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNA).

Con relación a la educación inicial, las recientes modificaciones a la Ley General de Educación establecen, en el artículo 38, que

en educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio. Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez.³¹

Por su parte, en el capítulo II, artículo 9, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece que “niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respecto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez”.³²

Cuando esta Ley fue publicada en 2011, Mateo Díaz, Rodríguez Chamussy y Greco consideraron que esta norma era una oportunidad para lograr una

³¹ Cámara de Diputados, *Ley General de Educación* (LGE), última reforma publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2022.

³² Cámara de Diputados, *Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil*, publicada el 24 de octubre de 2011. Última reforma publicada DOF 25-06-2018.

política nacional congruente que tomara en cuenta el alcance de los programas y políticas públicas, tanto para facilitar la inserción laboral de las mujeres, como para lograr efectos positivos en los niños.³³ Sin embargo, se ha dado continuidad a la política sectorial, que por una parte, promueve el trabajo femenino, y, por otra, la educación inicial.

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)³⁴ regula las prestaciones sociales de sus trabajadores afiliados. En el capítulo VII destina un apartado para establecer los beneficios relacionados con el servicio de guarderías para infantes entre 43 días de nacidos y hasta cuatro años. Brinda beneficios a madres trabajadoras, padres viudos o divorciados —siempre y cuando no contraigan nuevamente matrimonio— o aquel que tenga la custodia de los hijos.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)³⁵ establece, en el artículo 3, que son sujetos de protección por el ramo de guarderías las trabajadoras aseguradas del régimen obligatorio, así como aquellos trabajadores asegurados viudos o divorciados a quienes judicialmente se les hubiera confiado la guarda y custodia de sus hijos, mientras no contraigan matrimonio o entren en concubinato.

Podemos observar que tanto la Ley del IMSS como la del ISSSTE establecen restricciones de accesibilidad a la prestación por parte de los varones, en función de su estado civil. A pesar de lo anterior, al parecer, en la práctica estas instituciones han flexibilizado sus criterios para que las y los trabajadores sin distinción accedan a la prestación. Por lo menos así se observa en la página gubernamental del ISSSTE, que ofrece el servicio tanto para hombres y mujeres sin distinción de estado civil.

³³ Mateo Díaz, M., Rodríguez Chamussy L. y Grafe, F., *Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo*, BID, 2014.

³⁴ Cámara de Diputados, *Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 21 de diciembre de 1995. Última reforma publicada DOF 25-04-2023.

³⁵ Cámara de Diputados, *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 31 de marzo de 2007. Última reforma publicada, DOF 08-05-2023.

Por último, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes³⁶ dispone que las autoridades deberán garantizar un enfoque integral en el diseño e implementación de las políticas y programas dirigidos a esta población.

En paralelo a este marco normativo y jurídico, y con el objetivo de garantizar el pleno desarrollo de la infancia, el Estado mexicano ha creado también una Estrategia Nacional para la Protección de la Infancia (ENAPI).³⁷ De acuerdo con Alaniz,³⁸ esta estrategia surge de la reforma al artículo 30 constitucional, que establece la obligatoriedad de la educación inicial en mayo de 2019.

Los objetivos de la ENAPI son los siguientes:

- Garantizar a niñas y niños menores de seis años, el ejercicio de sus derechos al desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, vida libre de violencia, atendiendo brechas de desigualdad sociales y regionales.
- Atención al desarrollo físico, afectivo, intelectual y social de las niñas y los niños respecto a derechos de la infancia y bienestar.
- Se atienden cuatro componentes interrelacionados del desarrollo integral de NN: a) salud y nutrición, b) educación y cuidados, c) protección y d) bienestar.³⁹

Se destaca que la ENAPI reconoce la importancia de los cuidados, ya que establece un eje rector de Educación y Cuidados, cuyo objetivo es:

³⁶ Cámara de Diputados, *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 4 de diciembre de 2014. Última reforma publicada DOF 26-05-2023.

³⁷ Secretaría de Gobernación, *Estrategia Nacional para la Infancia*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, 23 de marzo de 2020.

³⁸ Alaniz-Hernández, C., “Atención y cuidado para la primera infancia en México. Un reto para la equidad de género”, *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, vol. 9, Núm. 2, Educación, democracia y justicia social: Miradas desde América Latina, 2020.

³⁹ Secretaría de Gobernación, *Estrategia Nacional para la Infancia*, *op. cit.*, p. 61.

Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación (inicial y preescolar) y al cuidado cariñoso y sensible de NN en primera infancia, atendiendo a las brechas de desigualdad existentes en los estratos sociales, regiones geográficas, géneros y a la diversidad inherente a cada persona.⁴⁰

Y que contempla los siguientes objetivos para la educación inicial:

- Fortalecer la cobertura y la calidad de servicios públicos sociales y privados de educación inicial en todas las modalidades, con enfoque de derechos, inclusión y pertenencia cultural y equidad de género.
- Fortalecer programas de educación inicial en zonas rurales.
- Fortalecer infraestructura física, equipamiento y materiales en los servicios de educación inicial.
- Focalización de infancias con mayor vulnerabilidad.

Para cumplir con el mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ENAPI, a su vez, crea el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el fin de instrumentar políticas que faculden a la niñez al ejercicio de sus derechos, bajo la consideración de que no son objeto de protección, sino personas responsables de opinar y decidir lo que consideran mejor para ellas.

Si bien este modelo pretende articular las políticas para la infancia en sus tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de la infancia, se reconoce la existencia de desigualdades que limitan su ejercicio.

Sobre este programa estratégico dirigido a la protección de la infancia, se puede decir que en su diseño contempla un enfoque intercultural e inclu-

⁴⁰ *Ibidem*, p. 64.

sivo, así como también una mirada progresista sobre los derechos de la infancia que se aleja de discursos adulto-céntricos y reconoce su capacidad decidir y opinar. Además, a decir de Myers y Uresti,⁴¹ también se muestra la intención por parte del Estado de asumir la corresponsabilidad para apoyar a las familias en sus tareas de cuidado y facilitar la protección y el desarrollo integral y de “cuidado cariñoso y sensible” de niñas y niños.

Cuadro 1. Normatividad internacional y nacional y políticas de cuidado dirigidas a la infancia en México

Convenios internacionales	Legislación nacional	Programas y prestaciones sociales
– Convención Internacional de los Derechos del Niño – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – OIT Convenio 156 – OIT Convenio 183, extensión de licencias de maternidad, licencias de paternidad – OIT Servicios de cuidado infantil para madres trabajadoras – Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	– Artículo 4 constitucional – Artículo 23 constitucional – Ley del IMSS – Ley del ISSSTE – Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes⁴ – Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil – Ley General de Educación	– Licencias de maternidad – Derecho a sala cuna – Derecho de lactancia – Prestación de guardería: IMSS, ISSSTE, DIF – Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras – Programa de Apoyo al Bienestar para los hijos e hijas de Madres Trabajadoras – Estrategia Nacional para la Protección de la Infancia

⁴¹ Myers, R. y Uresti, D., “Atención a niñas y niños menores de 4 años en México durante el gobierno de Amlo: Análisis de un cambio de estrategia”, *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (México), vol. LIII, núm. 1, 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de convenios internacionales, legislación nacional y programas de cuidado infantil.

Sin embargo, a dos años de la publicación de la ENAPI, que fue creada con la participación de las sociedad civil y agencias de gobierno, no es posible ver todavía cuáles han sido sus resultados, sobre todo cuando no fue definido un presupuesto para llevarla a cabo. Tampoco se sabe cómo se vincula a los programas y políticas que ya existían sobre la protección a la infancia, como es el caso de la provisión de servicios de cuidado infantil.

I. Características de la población infantil de 0 a 6 años en México

En México hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad (49% mujeres y 51% hombres); esto representa 30% de la población total del país. De ellos, 26% tienen entre 0 y 4 años de edad.⁴²

En México, todavía la gran mayoría de las niñas y los niños entre 0 y 6 años son cuidados en las familias. De acuerdo con el Censo 2020, 3.5 millones de niños y niñas de 0 a 6 años eran cuidados en una guardería, estancia infantil o por terceras personas, cifra equivalente a 25% de la población infantil en dicho rango de edad. De éstos, 16.3% fueron atendidos en una guardería y 83.7% estuvo al cuidado de terceras personas dentro del hogar, de la familia, en la comunidad o personas externas, destacando la abuela como la principal cuidadora (65.6%).

Información de la Encuesta Elcos (2012) informaba que 73% de las personas que realizaban cuidados en los hogares eran mujeres y 27% eran varones.⁴³ Los recién publicados datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de

⁴² INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.

⁴³ Jácome, T., “¿Quién cuida a quién? Diferencias entre mujeres y hombres que realizan trabajo de cuidado en el hogar”, en Edith Pacheco (coord.), *Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012*, México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2013, pp. 32-71.

Cuidados confirman que las mujeres siguen siendo las cuidadoras primarias dentro de las familias. Además, como responsables primarias de la crianza, se destaca su participación en el cuidado de menores.⁴⁴

En México se estima que hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares. La población infantil de 0 a 5 años, que constituye 10.3 millones, es el grupo que recibe la mayor cobertura de cuidados, con 99%. De esta población se respondió que 6.3% requería más tiempo de cuidados o atención, y la estimulación temprana fue la actividad más mencionada, con 70.4%.⁴⁵

De las personas de 0 a 2 años, 91.5% no asistía a educación inicial. La razón principal que se reportó fue “porque no tenía necesidad de asistir o era pequeña”. Para 9.1% de este grupo se indicó que no había centros de educación inicial, guarderías o estancias infantiles o quedaban lejos.

Con relación a las personas que cuidan, datos de la misma fuente revelan que en 2022, 31.7 millones de personas de 15 años y más brindaron cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares. De esta población, 75.1% correspondió a mujeres y 24.9%, a hombres. Las personas cuidadoras principales de la población infantil y del grupo de NNA fueron mujeres, con 96.0 y 90.3%, respectivamente.

De acuerdo con Coneval-Unicef (2023), entre 2018 y 2020 se incrementó la pobreza en la población infantil y adolescente 2.3 puntos porcentuales, pasando de 50.3% a 52.6%. Lo anterior se debió en gran parte a la crisis económica de las familias causada por la pandemia por covid-19. El principal componente que afectó la pobreza infantil fue el aumento de la pobreza extrema. De 2018 a 2020 la pobreza extrema pasó de 8.7% a 10.6% en la población de 0 a 17 años.

⁴⁴ INEGI, Comunicado de prensa número 578/23; Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), Comunicación Social, 3 de octubre 2023.

⁴⁵ *Ibidem*.

En el país, los NNA son quienes padecen más la pobreza comparados con otros grupos etarios. En NNA, la pobreza oscila en 52.6% y para el resto de la población es de 43.9%. Para 2020, más de la mitad de todos los NNA del país estaba en condiciones de pobreza multidimensional (19.5 millones) y 6 de cada 10 NNA contaban con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos. De acuerdo con la fuente, la carencia social más grande para NNA fue la de acceso a la seguridad social, ya que en 2020 58% de esa población no tenía acceso.

La pandemia covid-19 tuvo efectos en la pobreza de las familias en México; sin embargo, a diferencia de otros países de América Latina que implementaron medidas emergentes de política social para atender las consecuencias de la pandemia,⁴⁶ en materia de atención a la infancia, nuestro país solo dio continuidad al Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Además, en virtud de la suspensión de actividades en todos los niveles educativos, a nivel federal no se contemplaron otros apoyos para el cuidado infantil, con excepción de las personas trabajadoras de la salud. Por ejemplo, el ISSSTE abrió guarderías para trabajadores esenciales con cupo de 30% y protocolo sanitario. En su caso, el IMSS reabrió el servicio de guarderías infantiles el 8 de julio de 2020 para brindar apoyo a las trabajadoras esenciales, considerando el semáforo epidemiológico de cada lugar e implementando el protocolo sanitario.

II. Políticas para la protección social de la infancia

Las políticas públicas de cuidados pueden clasificarse de distintas maneras si están basadas en apoyos a madres y niñas y niños, licencias parentales y servicios de cuidado.⁴⁷ Atendiendo a estos criterios, Batthyány, Genta y

⁴⁶ Blofield, M., Lustig, N. y Trasnberg, M., “La protección social durante la pandemia: Casos de Argentina, Brasil, Colombia y México”, CEQ Institute, Tulane University, Working paper 104, 2021.

⁴⁷ Bahle, Thomas, “Family Policy Patterns in the Enlarged EU”, en Alber, Jens, Fahey, Tony y Saraceno, Chiara (eds.), *Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union*, London y Nueva York, Routledge, 2008, pp. 100-126.

Scavino establece diferencias entre las políticas de tiempo para cuidar, las políticas de dinero por cuidar y los servicios de cuidados.⁴⁸ A continuación analizaremos cada uno de estos tipos de políticas.

Políticas de tiempo

Las políticas de tiempo se popularizaron a partir de la Conferencia de Beijing, que puso énfasis en las diferencias en los tiempos de trabajo entre mujeres y hombres, con base en encuestas de usos del tiempo, que hicieron visibles las desigualdades enormes entre mujeres y varones en los tiempos de trabajo dedicados a la producción y la reproducción.

Las políticas de tiempo están orientadas a liberar tiempo para que el trabajo y el cuidado familiar se articulen en forma equilibrada. En este caso particular, para el cuidado de niñas y niños entre 0 y 3 años. Entre estas políticas están las licencias de maternidad y paternidad, las licencias parentales, así como las reducciones horarias para los cuidados.

En la mayoría de los países de América Latina al principio surgieron las licencias laborales por motivos de maternidad y crianza. México fue uno de los primeros países en implementar esta política; sin embargo, a diferencia de países como Chile, Argentina y Brasil, no cumple todavía con el estándar de 14 semanas establecido por la OIT, tal como se puede observar en el cuadro 2.

Más adelante, y como un indicador de que el Estado reconoce la corresponsabilidad de los padres varones en el cuidado de sus hijas e hijos, se establecieron también las licencias paternas, aunque con tiempos limitados, que varios países como Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México han puesto en marcha al contar con permisos por paternidad en el caso de nacimiento y adopciones, aunque con variaciones en los días de licencia que

⁴⁸ Batthyány, K., Genta, N. y Scavino, S., “Análisis de género de las estrategias de cuidado infantil en Uruguay”, *Cadernos de Pesquisa*, vol. 46, núm. 162.

se conceden, que van entre dos días en Argentina y hasta 13 días en Uruguay, según se muestra en el cuadro 2. En México, la licencia de paternidad se incluyó en la Ley Federal del Trabajo en 2012.

Las licencias de paternidad también tienen relación con el principio de interés superior del niño, al promover un vínculo afectivo entre padres varones y sus niñas o niños desde los primeros meses de vida. Además, contribuyen a modificar prácticas culturales basadas en estereotipos de género, que, como sugieren Guezmes y Baeza, resultan en la “irresponsabilidad privilegiada”,⁴⁹ que excusa a algunas personas de dedicarse a las actividades de cuidado.

En algunos países estos permisos no son remunerados 100 por ciento, suelen ser poco flexibles o pueden tener consecuencias laborales. Por esta razón tienen poco uso. Por ejemplo, en Chile sólo 20% de los trabajadores hace uso de este derecho.⁵⁰

Por otra parte, este tipo de licencias laborales para el cuidado infantil están restringidas en su alcance porque están ligadas a la participación en el empleo formal y, como sabemos, la división sexual del trabajo limita la participación femenina en los mercados de trabajo. Por otra parte, las altas tasas de informalidad excluyen a los trabajadores de estos beneficios.⁵¹

Ligadas a las políticas de tiempo también existen políticas relacionadas con el derecho a la lactancia. Sobre este tema, los convenios internacionales establecen que todas las mujeres deberían tener derecho a tiempo para la lactancia materna dentro de la jornada laboral. El Convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad y su Recomendación 191 del año 2000

⁴⁹ Tronto, citado por Guezmes, A. y Baeza, M. N. (coords.), *Avances de la normativa sobre el cuidado en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, Cepal, División de Asuntos de Género, 2023, p. 23.

⁵⁰ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), *Y si hablamos de igualdad. Licencias de paternidad en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2023. Disponible en «<https://blogs.iadb.org/igualdad/es/licencias-paternidad-testimonio-colombia/>».

⁵¹ Scuro et al., *op. cit.*; Guezmes, A. y Baeza M. N. (coords.), *op. cit.*

sugieren que estas interrupciones puedan ser agrupadas en un solo tiempo, ya sea al comienzo o final de la jornada.

En el cuadro 2 se puede observar que se concede una hora de lactancia en los países considerados, aunque hay variaciones en los límites de edad, que va de los seis meses hasta los dos años. Además, la OIT también establece la existencia de instalaciones para la lactancia o lactarios en el lugar de trabajo, centro de estudios o centros de formación, como medio para propiciar y mantener la práctica de la lactancia materna, pero deja esta regulación a las legislaciones nacionales (cuadro 2). Por ejemplo, mientras que en Argentina la norma establece esta obligación para empresas de 100 trabajadoras/es con niños de 45 días de nacidos hasta tres años de edad, en México esta prestación es un derecho con rango constitucional, y desde 1970 se estableció la obligación de la empresa de asignar un lugar adecuado e higiénico.⁵²

Estas diferentes políticas son un indicativo de los avances del amplio desarrollo normativo sobre licencias de maternidad y crianza que existe en la región, pero, como concluyen Guezmes y Baeza,⁵³ esta normatividad requiere un enfoque que integre los derechos de la niñez, la igualdad de género y la inclusión social de las familias.

⁵² Guezmes y Baeza, *op. cit.*, p. 22.

⁵³ *Ibidem*, p. 20.

**Cuadro 2. Legislación de protección al cuidado infantil
y su financiamiento en algunos países de América Latina**

	Argentina	Brasil	Chile	México	Uruguay	OIT
Licencias de maternidad	14 semanas	18 semanas y más	18 semanas y más	12 semanas	Más de 14 semanas y menos de 18	14 semanas
Licencias de paternidad	2 días	5 días	5 días	5 días	13 días	
Derecho a sala cuna y centro de cuidados	Empresas con 100 trabajadoras/es Con niños de 45 días de nacidos hasta tres años de edad	Empresas con 30 trabajadores mayores de 16 años con hijos menores de 5	Empresas con 20 trabajadoras	Derecho con rango constitucional		Las leyes regularán la obligación de patrones para instalar y mantener salas cuna
Horario de Lactancia 1 hora diaria	Hasta 1 año	Hasta 6 meses de edad	Hasta 2 años de edad	Hasta 1 año de edad	Hasta 1 año de edad	Un solo tiempo al comienzo o final de la jornada laboral
Financiamiento	Patrones	Patrones	Patrones	Patrones, trabajadores y Estado		

Fuente: Elaboración propia con información de Todaro, R. y Yañez, S. (eds.), *El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género* y Guezmes, A. y Baeza M. N, *op. cit.*

Políticas monetarias y de provisión de cuidado infantil

Las políticas monetarias y de provisión de cuidado infantil son de los principales instrumentos de protección social para la primera infancia y forman

parte de las transferencias condicionadas. A decir de Rossel, Rico y Filgueira,⁵⁴ estos programas permitieron reorientar la protección social hacia la infancia, ya que al estar dirigidos hacia las familias con niñez y adolescencia en situación de pobreza constituyeron un elemento clave. Por su parte Cecchini y Madariaga⁵⁵ consideran que a pesar de su baja inversión, los impactos de las transferencias condicionadas han sido notorios con relación a los derechos de la infancia.

Para distintas autoras,⁵⁶ el fin último de los subsidios al cuidado infantil era reducir la pobreza y aumentar el capital humano con la corresponsabilidad de las familias para evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Estos programas usaron, como criterios de focalización, la empleabilidad y la vulnerabilidad, en tanto que la ausencia de la perspectiva de género reprodujo los roles tradicionales de género.

Entre los principales debates sobre las transferencias condicionadas, la literatura sobre el tema distingue los siguientes: su carácter condicional, el reparto de la carga de cuidados en los hogares y la toma decisiones por parte de las madres. Sobre el primer tema, especialistas como Mateo-Berganza y Rodríguez Chamussy, en México,⁵⁷ y Rodríguez,⁵⁸ en Argentina y Uruguay, argumentan

⁵⁴ Rossel, C., Rico, N. y Filgueira, F., "Protección social para la infancia", en Cecchine, S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (editores), *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*, Santiago de Chile, CEPAL, 2015.

⁵⁵ Cecchini, S. y Madariaga, A., *Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la Experiencia Reciente en América Latina*. Santiago de Chile: Cepal/ASDI, 2011.

⁵⁶ Zibecchi, 2014:93; Faur, Esquivel y Jelin 2012; Araujo y López-Boo, 2015; Bathyány, 2015.

⁵⁷ Zibecchi, C., "Mujeres cuidadoras en contextos de pobreza. El caso de los Programas de Transferencias Condicionadas en Argentina", *Estudios Feministas, Florianópolis*, vol. 22, núm. 1, enero-abril, 2014 p. 416; Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E., "Hacia la conceptualización del cuidado: familia, mercado y Estado", en Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E. (eds.), *Las lógicas del cuidado infantil: entre las familias, el Estado y el mercado*, Buenos Aires, IDES, UNFPA, Unicef, 2012, pp. 1143; Araujo, M. C. y López-Boo, F., "Los servicios de cuidado infantil en América Latina y el Caribe", *El Trimestre Económico*, vol. LXXXII (2), núm. 326, abril-junio de 2015; Bathyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales*. Santiago de Chile, CEPAL-AECID. Serie Asuntos de Género, 2015.

⁵⁸ Bathyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales*, Santiago de Chile, CEPAL-AECID, serie Asuntos de Género, 2015.

que las transferencias condicionadas han contribuido a incrementar la carga de cuidados de las mujeres, ya que como corresponsabilidad se les exige que asistan a prácticas sobre diversos temas como nutrición y desarrollo infantil.

Las transferencias monetarias directas brindan dinero como contraprestación a la dedicación al cuidado de alguna persona de la familia.⁵⁹ De acuerdo con Batthyány,⁶⁰ estas prestaciones reconocen que hay personas, generalmente mujeres, que no están en el mercado laboral porque se dedican a cuidar y que esa tarea debe darles acceso a una remuneración o a derechos sociales.

Además, se supone que el dinero es para pagar servicios de cuidado infantil; sin embargo, el bajo nivel de las transferencias y la precaria economía de la población beneficiaria no parecen hacerlo posible.⁶¹ Con relación a este punto, se argumenta que la entrega de transferencias monetarias asume que las familias tienen libre albedrío y toma de conciencia para decidir en qué invierten los recursos. Sin embargo, en condiciones de alta precariedad, más bien parece que las transferencias monetarias se usan para cubrir gasto de contingencia de alimentación y salud. Estas circunstancias disminuyen la posibilidad de que las mujeres usen el dinero en la provisión de servicios de cuidado infantil mercantiles. Resultado de un estudio reciente sobre el cierre de las Estancias Infantiles de Sedesol así lo documentan también, ya que cuando algunas de las beneficiarias fueron transferidas al nuevo programa, que consiste en transferencias monetarias, las mujeres decidieron invertir el dinero en gastos familiares contingentes no siempre asociados a los infantes.

En este sentido, como sugiere Bathyány⁶² las políticas de transferencias monetarias son ambiguas ya que, por un lado, reconocen la desigualdad de género al considerar el valor del cuidado que se proporciona en los hogares, pero el bajo monto de las transferencias puede contribuir a reproducirla.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² *Ibidem*, p. 17.

Además, si bien el Estado puede asumir parte de los costos del cuidado infantil, también se puede favorecer que estas actividades se queden en el ámbito doméstico y familiar. En nuestra opinión, esto es precisamente lo que sucede con el cambio en el programa de cuidado infantil en México, ya que mientras el Programa de Estancias infantiles desfamiliarizaba el cuidado, el actual programa, que está basado en transferencias monetarias, ha tenido como consecuencia la privatización del cuidado infantil en las familias.⁶³ Además, de acuerdo con Batthyány, Genta y Scavino,⁶⁴ este tipo de programas no abonan a un reparto más igualitario del cuidado infantil, ya que no cuentan con mecanismos definidos para la participación de los varones.

Además de las transferencias monetarias, existen distintos tipos de intervenciones y subsidios gubernamentales asociados al cuidado infantil, como servicios y la transferencia de bienes y apoyos en especie.⁶⁵ En este ámbito de las transferencias indirectas, se destaca la importancia de las políticas de provisión de servicios de cuidado infantil, ya que sin ellas ninguna política integral está completa. Al revisar los programas de cuidado infantil en América Latina,⁶⁶ se observa que la mayoría contempla una política de este tipo, ya sea a través de servicios que son subvencionados por el Estado, o bien con servicios que proporciona el Estado en forma directa.⁶⁷

⁶³ López Estrada, S., “Hacia la (re)privatización del cuidado infantil en México. Las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles Sedesol”, *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, vol. 6, 2020.

⁶⁴ Batthyány, K. Genta, N. y Scavino, S., “Análisis de género de las estrategias de cuidado infantil en Uruguay”, *Cadernos de Pesquisa*, vol. 46, núm. 162, 2017, p. 298.

⁶⁵ Rodríguez, C., *Programas de Transferencias condicionadas. ¿Por dónde anda América Latina?*, Santiago, CEPAL, 2011.

⁶⁶ Batthyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina*, op. cit.; López Estrada, S., “Políticas de Cuidado Infantil en América Latina: Análisis comparado de Chile, Costa Rica, Uruguay y México”, *Frontera Norte*, vol. 29, núm. 58, julio-diciembre, 2017.

⁶⁷ Araujo, M. C. y López-Boo, F., “Los servicios de cuidado infantil en América Latina y el Caribe”, *El Trimestre Económico*, vol. LXXXII (2), núm. 326, abril-junio de 2015.

En el conjunto, algunas de estas políticas de transferencias directas e indirectas se anuncian con intenciones de universalidad, pero se implementan en forma sectorial y focalizada.⁶⁸

D. LA PRESTACIÓN DE GUARDERÍA EN MÉXICO

Además de los tres pilares clásicos del Bienestar, la educación, la salud y la seguridad social, el reconocimiento del derecho a cuidar y recibir cuidado a lo largo de la vida ha puesto en el escenario del bienestar a los cuidados como el “cuarto pilar”.⁶⁹

Filgueira, Molina, Papadópulos y Tobar⁷⁰ afirman que la política social se distingue por sistemas compensatorios que no garantizan derechos y están asociados al corporativismo, falta de solidez en las políticas y austeridad presupuestal, que han llevado a la desaparición de servicios y prestaciones. Mientras los sectores de altos ingresos tienen acceso al mercado de seguros de salud, educación y provisión de cuidado infantil, la seguridad social, a través del empleo, y los programas de transferencias, mediante estrategias de focalización en la población pobre, se distinguen como formas de acceso a la protección social, que en este caso aplican para la población infantil.

⁶⁸ Presno, M. López Rocha, C. y Moyá, G., *Políticas de atención y educación para la primera infancia en América Latina. Una aproximación al estado del arte de las investigaciones y estudios 2013-2019*, UNICEF-Fundación Arcor, 2019.

⁶⁹ Montaña, S. y Calderón C. (coords.), “El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo”, *Cuadernos de la CEPAL*, 94, 2010.

⁷⁰ Filgueira, F., Molina, C., Papadópulos, J. y Tobar, F., “Universalismo básico: una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida”, en Molina, Carlos Gerardo (editor), *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Editorial Planeta, 2006, pp. 19-55.

Cuadro 3. Instituciones y Programas que ofrecen la Prestación de Guarderías en México 2023

Esquema/Programa	Tipo de provisión y financiamiento	Población beneficiaria
IMSS – Guarderías directas – Madres IMSS – IMSS Ordinario – Subrogadas – IMSS Vecino-Comunal – Reversión de cuotas	– Aporte tripartito	– Niñas y niños de madres trabajadoras y afiliadas al IMSS – Niñas y niños de trabajadoras de la empresa
ISSSTE – Directas – Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil – Subrogadas – Centros asistenciales para el Desarrollo Infantil	– Aporte tripartito	– Trabajadoras del Estado
DIF – Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAI) – Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)	– Proveedores privados con financiamiento de gobiernos estatales – Proveedores privados con financiamiento mixto (local y federal)	– Población abierta
SEP – Centros de Desarrollo Infantil (CDI) – Centros de Educación Inicial (CEI)	– Proveedores privados con financiamiento de los gobiernos estatales	– Población abierta

Esquema/Programa	Tipo de provisión y financiamiento	Población beneficiaria
– Programa de Estancias Infantiles para Madres y Padres Trabajadores (2018)	– Sedesol – Transferencias indirectas	– Población focal
– Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras (2019)	– Secretaría de Bienestar – Transferencias directas a madres con niñas de 0 a 4 años	– Población focal

Fuente: Elaboración propia con información de López Estrada, S., “Universalismo básico y políticas de cuidado infantil en México; Secretaría de Desarrollo Social, *Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras*; Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social, *Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007-2019*; Mateo Díaz, M., Rodríguez Chamussy, L. y Grafe, F., *Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo*; Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, *Anuario Estadístico*; Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Coordinación de Guarderías. México.

Instituciones y programas para la prestación de guarderías

La prestación de guarderías consiste en servicios de seguridad social para los trabajadores, los que tienen como propósito atender, cuidar y garantizar el desarrollo integral de los hijos del trabajador durante el tiempo de su ocupación laboral.

Los objetivos de esta prestación atienden tanto al propósito de completar los cuidados que la primera infancia recibe en la familia, así como de facilitar la inserción laboral de las mujeres. Con relación al cuidado de la primera infancia, las guarderías pretenden fortalecer la salud y el desarrollo cognitivo y psicosocial de niñas y niños, así como promover el aprendizaje de hábitos saludables y de convivencia.

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil,⁷¹ en el artículo 39, establece que los Centros de Atención pueden presentar alguna de las siguientes modalidades:

- Pública: CAI financiado y administrado, ya sea por la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías, o bien, por sus instituciones públicas.
- Privada: CAI creado, financiado, operado y administrado por particulares.
- Mixta: CAI en el que la Federación o los estados, los municipios, las alcaldías o en su conjunto participan en el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.

Estas modalidades podemos encontrarlas en esquemas y programas de guarderías que forman parte de los sistemas contributivos y no contributivos.

Sistemas contributivos

En primer lugar, se distinguen los sistemas contributivos, que consisten en las prestaciones que integran a la seguridad social y se financian con aportaciones tripartitas: trabajador o trabajadora, empleador y gobierno. El artículo 123 constitucional consagra la prestación de estos servicios, que están orientados al bienestar y protección de la infancia, los y las trabajadoras y sus familias.

Para cumplir este mandato se han creado en México distintas instituciones y programas la provisión de cuidado infantil como parte de la seguridad social, y sus características se determinan por las formas de inserción laboral de la población beneficiaria, modalidades de provisión (pública directa,

⁷¹ Cámara de Diputados, *Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil*, publicada el *Diario Oficial de la Federación* el 24 de octubre de 2011. Última reforma publicada DOF 25-06-2018.

mixta y subrogada), y el financiamiento de los servicios, según se muestra en el cuadro 3.

Estos factores relacionados con las formas de acceso a la protección social expresan la segmentación social del acceso a la prestación de guarderías, y la cobertura que ofrecen es variable. Además, la segmentación de estas diversas políticas se refleja también en la heterogeneidad de sus criterios de elegibilidad, tanto en la edad de las niñas y los niños como en el estatus económico y sociolaboral de las madres y padres.⁷²

El sistema contributivo en México se integra por las siguientes instituciones que contemplan la prestación de guardería en su esquema de seguridad social:

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil; cuenta con las modalidades directa y subrogada.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también cuenta con guarderías propias o subrogadas a particulares, y solamente la población derechohabiente puede acceder a estos servicios. La prestación se destina a las madres trabajadoras beneficiarias de la seguridad social, así como a aquellos padres trabajadores viudos o divorciados que tengan la guarda y custodia de sus hijos. Otorga a los derechohabientes en gratuidad el servicio de guardería para apoyar a los padres y madres en los cuidados integrales (provee servicios nutricionales, educativos y de fomento a la salud) de las niñas y niños. Los cuidados se proveen a menores desde 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) proporciona servicios de guardería a través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria

⁷² López Estrada, S., “Universalismo básico y políticas de cuidado infantil en México”, en Valencia E. (coord.), *Perspectivas del universalismo en México*, ITESO/Konrad Adenauer/UIA León, 2010; Mateo-Berganza, M. y Rodríguez Chamussy, L., *Educación que rinde. Mujeres, trabajo y cuidado infantil en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017.

(CADI) y los Centros de Desarrollo Infantil (CAI), ambos dirigidos a la población abierta, con financiamiento de gobiernos estatales, en el primer caso, y financiamiento mixto, en el segundo.

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y Centros de Educación Inicial (CEI), brinda el servicio a las madres trabajadoras de la institución; en ambas modalidades se cuenta con proveedores privados y financiamiento de los gobiernos estatales.⁷³

La prestación de guarderías del IMSS y del ISSSTE se destacan como modelos de atención y servicios certificados por la norma ISO 9001, por lo que las familias derechohabientes con niños pequeños aspiran a obtener el servicio. Sin embargo, la oferta de guarderías de este sistema a lo largo del tiempo ha sido insuficiente para dar cobertura a la creciente demanda. Con relación a la calidad del servicio, existen algunas críticas y se han presentado quejas relacionadas con la negativa de servicio a algunos niños y los estándares de calidad respecto de la disponibilidad, suficiencia, accesibilidad y vigilancia.⁷⁴

Sobre este tema, sin duda alguna el evento que ha marcado la calidad y seguridad del servicio de guarderías, es el incendio ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, subrogada del IMSS, en Hermosillo, Sonora, en donde murieron 49 niñas y niños y 53 personas resultaron lesionadas. Este suceso reveló las diversas dificultades que caracterizaban al sistema de subrogación, entre los que se destacaban: 1) irregularidades en la seguridad de las instalaciones, 2) discrecionalidad de los contratos y 3) la falta de supervisión y coordinación de los tres niveles de gobierno.⁷⁵

Después de realizar una investigación sobre este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que se habían vulnerado los derechos

⁷³ Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social (CONEVAL), *Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007-2019*, 2019.

⁷⁴ González Carvallo, D., *El derecho a la seguridad social: guarderías*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2021.

⁷⁵ López Estrada, S., "Universalismo básico y políticas de cuidado infantil en México", *op. cit.*

económicos y la seguridad jurídica de las niñas y niños fallecidos, así como de sus familiares, heridos y demás personas que se encontraban en el inmueble cuando ocurrió el accidente.⁷⁶

Acerca de los estándares de seguridad y protección reforzada para garantizar el servicio de guarderías, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo una investigación, ya que los hechos podían constituir una violación a derechos fundamentales. De acuerdo con González Carvallo,⁷⁷ en la resolución de este caso, la Corte acreditó los actos y las omisiones tal como sigue:

Consideró que dichas actuaciones vulneraron los derechos fundamentales de niñas y niños, el interés superior de la niñez, así como los derechos a la protección de la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud. En consecuencia, enunció las acciones mínimas que las autoridades debían realizar para prevenir que se repitiera la tragedia. Identificó, además, a las autoridades que, a su juicio, incumplieron sus obligaciones legales y constitucionales en este caso.⁷⁸

Sistemas no contributivos

Se trata de aquellos programas sociales que ofrecen beneficios similares a los de las prestaciones de la seguridad social, pero se financian mediante impuestos generales u otras fuentes de recursos públicos que no son impuestos laborales a cargo de la población beneficiaria de los mismos.⁷⁹

Estos sistemas están dirigidos a la población que no cuenta con seguridad social y se conforman por Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Cursos de Preescolar Comunitarios, Preescolar Indígena, Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Edu-

⁷⁶ *Idem.*

⁷⁷ González Carvallo, D., *El derecho a la seguridad social: guarderías*, op. cit.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 46.

⁷⁹ CONEVAL, op. cit.

cación Pública y el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a cargo de la Secretaría del Bienestar.⁸⁰

Por su amplia cobertura y alcance nacional, destaca aquí el Programa de Estancias Infantiles. El programa era financiado con recursos fiscales y contaba con sus propias Reglas de Operación,⁸¹ que establecían como población beneficiaria a las niñas y niños de entre un año y hasta cuatro años, hijos de madres que trabajaban, buscaban empleo o estudiaban y de padres solos con niños/as bajo su cuidado para que pudieran trabajar o estudiar. Operaba en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, con el objetivo de facilitar a madres y padres trabajadores en situación de pobreza y sin acceso a servicios de cuidado infantil el acceso y permanencia en el mercado laboral.

Al momento de cierre, en 2019, el programa contaba con 9,195 estancias que atendían a 315,000 niñas y niños inscritos que recibían además el primer año de educación preescolar, contribuyendo así a cubrir el rezago que había en este nivel de enseñanza. Además, de acuerdo con sus Reglas de Operación (RO),⁸² el PEI se caracterizaba por dos modalidades. La primera era un apoyo para madres trabajadoras y padres solos que buscan empleo o estudian, a través de un sistema de transferencias directas a las guarderías como pago del servicio para sus niñas o niños de entre un año y hasta antes de cumplir los cuatro años, o de entre un año y hasta antes de cumplir los seis, que consistía en un apoyo de hasta 950 pesos mensuales por cada infante inscrito, y 1800 pesos en el caso de niñas y niños con discapacidad. La segunda modalidad se refiere al Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. En previas Reglas de Operación se establecía un monto monetario de apoyo a las estancias infantiles que participaban en el Programa, pero las RO de 2018 ya no mencionan este apoyo monetario.

⁸⁰ *Idem.*

⁸¹ Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, 2018.

⁸² *Idem.*

Como hemos señalado en un trabajo previo,⁸³ diversas evaluaciones del PEI documentan las bondades de las transferencias indirectas para la salud, nutrición y desarrollo infantil, así como impacto positivo en el empleo femenino y la reducción de los tiempos de cuidado para las mujeres.⁸⁴ Al incrementar la oferta de guarderías de bajo costo se promovía la igualdad de oportunidades, cubriendo de esta forma la demanda no atendida por el IMSS.

Además, a pesar del énfasis en promover la inserción laboral de las mujeres, con el tiempo el programa puso atención al desarrollo infantil. Se mostraron los efectos positivos en la dieta y el desarrollo psicomotriz y se atendió a la niñez con capacidades diferentes. Sobre este tema, entrevistas realizadas con asistentes educativas que trabajaban en las Estancias Infantiles Sedesol⁸⁵ nos permiten destacar su esfuerzo y dedicación para atender a niñas y niños con diversas discapacidades, alentando a madres y padres a buscar un diagnóstico adecuado sobre problemas de aprendizaje, autismo y discapacidades motrices, tratando de apoyar, en la medida de sus capacidades, para que niñas y niños aprendieran a caminar, a moverse mejor, hablar y relacionarse con las demás personas.

La evaluación de desempeño realizada por Cejudo *et al.*⁸⁶ mostró que las beneficiarias tenían una buena percepción del programa. En nuestro propio estudio con exbeneficiarias del Programa de Estancias Infantiles de Sedesol,⁸⁷ las entrevistadas manifestaron satisfacción por el servicio, ya que consideran

⁸³ López Estrada, S., “Hacia la (re)privatización del cuidado infantil en México. Las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles Sedesol”, *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, vol. 6. 2020.

⁸⁴ Cejudo, G. (Coord.), *Metaevaluación del Programa de Estancias Infantiles*, Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2012; Calderón, G., “The Effects of Child Care Provision in Mexico”, *Documentos de Investigación*, México, Banco de México, 2014.

⁸⁵ López Estrada, S., Políticas de cuidado infantil, trabajo y género. La privatización del cuidado en las familias en tiempos de austeridad. Proyecto de investigación 1311320 Ciencia de Frontera Conahcyt, Trabajo de campo 2022-2023, 2023.

⁸⁶ Cejudo, G. (coord.), *Diagnóstico sobre el problema público en materia de cuidados en México*, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2017.

⁸⁷ Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, 2018.

que sus niñas y niños desarrollaron habilidades motoras y sensoriales, además de que aprendieron matemáticas y lectoescritura como preparación a su ingreso a la educación preescolar. En materia de alimentación, comentaron que sus niñas y niños aprendieron a comer una variedad más amplia de alimentos, que incluían los distintos grupos de nutrientes.

Sobre las condiciones de seguridad de las estancias infantiles, la desafortunada experiencia de la guardería ABC, que reveló la falta de seguridad en las instalaciones, se añadió a las críticas que ya existían sobre las Estancias Infantiles Sedesol, pues la Secretaría de la Función Pública había registrado diversas irregularidades, así que Sedesol modificó las Reglas de Operación para exigir que los inmuebles contaran con dispositivos para detección de humo, extinguidores y salidas de emergencia a fin de evitar incendios y también para prevenir inundaciones en las 8,425 estancias que existían en 2009. Para que se cumpliera con estos requisitos de seguridad, se otorgaron recursos adicionales a las estancias infantiles.

El cumplimiento de estas regulaciones pasó a formar parte de la supervisión que DIF realizaba a las estancias, y de acuerdo con las entrevistas realizadas en forma reciente con responsables de algunos de estos centros de atención infantil que sobrevivieron al cierre del Programa en 2019, había una estricta supervisión que les exigía cumplir con un Programa de Protección Civil. Si en la visita, que no era anunciada, se encontraba alguna irregularidad en el inmueble o las normas de seguridad, se exigía a la responsable que en forma inmediata corrigiera la anomalía, mientras ello ocurría se le marcaba amarillo en el semáforo de seguridad, y si era el caso de poner el semáforo en rojo, la estancia era cerrada en forma definitiva.⁸⁸

En 2019, el gobierno de México decidió dar un giro en la política sobre el cuidado infantil, y con los argumentos de corrupción e irregularidades en la

⁸⁸ López Estrada, S., Políticas de cuidado infantil, trabajo y género. La privatización del cuidado en las familias en tiempos de austeridad. Proyecto de investigación 1311320 Ciencia de Frontera Conahcyt, Trabajo de campo 2022-2023, 2023.

operación de las Estancias Infantiles Sedesol, decidió modificar la modalidad del programa, que pasó de transferencias condicionadas a transferencias monetarias directas.

Entre las diferencias entre el PEI y Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras (PABHHMT) se destaca que, mientras el primero pone en el centro a las madres trabajadoras, el segundo hace referencia al bienestar de niñas y niños. Sin embargo, ambos programas identifican en su diagnóstico que el problema es la inserción laboral femenina, y no se analiza la situación del desarrollo y bienestar de la infancia. De esta forma existe una contradicción en el marco interpretativo del problema y el objetivo del nuevo programa, el cual está orientado hacia el bienestar infantil.⁸⁹

Entre los argumentos del gobierno para fundamentar el cierre de las estancias infantiles también se afirmaba que se trataba de un programa neoliberal que privatizaba los recursos del Estado al otorgarlos a negocios privados.⁹⁰ Sin embargo, desde una mirada feminista, considero que se privatizaron los cuidados, ya que al no contar más con el servicio de estancia infantil, muchas mujeres tuvieron que dejar su empleo para cuidar a sus niñas y niños en sus casas, resultando en un proceso de familiarización del cuidado, que contribuye a su invisibilización y devaluación social.

E. Conclusiones

Hay consenso al señalar que la inversión de los Estados en la protección social de la infancia considera dividendos, en particular, para los niños en desventaja. Así lo revelan los estudios que documentan beneficios en escolaridad, salud y calidad de servicios de cuidado infantil,⁹¹ al mismo que

⁸⁹ López Estrada, S., “Hacia la (re)privatización del cuidado infantil en México. Las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles Sedesol”, *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, vol. 6. 2020. p. 22.

⁹⁰ *Idem.*

⁹¹ Samman, E. y Lombardi, J. *Childcare and Working Families: New Opportunity of Missing Link? An Evidence Brief*, UNICEF, 2019.

también tienen un impacto positivo en la inserción laboral de las madres y en la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y hombres.

Algunos estudios también señalan que la primera infancia es un periodo crítico para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional y de sus logros futuros,⁹² efectos que son de particular importancia para las poblaciones en riesgo de exclusión social que no tienen acceso igualitario a servicios y atención de calidad.⁹³ De ahí que se destaca la importancia de la responsabilidad de las familias, el Estado y las sociedades en el cuidado infantil.

Si bien existen avances en las políticas de protección a la infancia, su tratamiento sectorial, que se expresa en políticas para madres trabajadoras o políticas de educación inicial, representa un desafío, además de que persiste la segmentación en la oferta de servicios de protección social para la infancia, ya que se tiene acceso a la provisión de cuidado a través de la inserción laboral de sus padres y madres. Además, las instituciones que ofrecen la prestación de guardería enfrentan desafíos para cubrir la demanda, que ha sido insuficiente aún a través de la subrogación del servicio, y de los programas de cuidado infantil basados en transferencias indirectas o directas.

El cierre del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras ha contribuido a disminuir la oferta de servicios de cuidado infantil, en particular de los sectores de menores recursos, en tanto que las transferencias monetarias no se usan para pagar la estancia infantil, sino para cubrir necesidades contingentes en las familias beneficiarias del actual programa de entregas monetarias.

Existen también obstáculos culturales que se manifiestan en el predominio de una ideología que promueve representaciones tradicionales de los roles

⁹² Hein, C. y Cassirer, N., *Soluciones para el trabajo infantil en el lugar de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2010; Araujo, M. C. y López-Boo, F., “Los servicios de cuidado infantil en América Latina y el Caribe”, *El Trimestre Económico*, vol. LXXXII (2), núm. 326, abril-junio de 2015.

⁹³ Mateo Díaz, M., Rodríguez Chamussy L. y Grafe, F., *Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo*, BID, 2014.

de género (madres y esposas), donde las mujeres siguen siendo responsables primarias del cuidado, por lo cual persiste la desigualdad de género, y se ha dado poca visibilidad al desarrollo de la primera infancia en nuestro país.

La protección social de la infancia se sustenta en un principio de universalidad que difícilmente se ha logrado en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, ya que no existen políticas nacionales que universalicen la provisión de estos servicios de cuidados, más allá del empleo formal. De ahí que para avanzar en el reconocimiento del cuidado como derecho universal de la infancia se requiere llenar los vacíos en la regulación y provisión del cuidado.

En este sentido, Scuro, Alemany y Coello⁹⁴ consideran que la innovación para avanzar en el reconocimiento de los cuidados consiste en la construcción de sistemas integrales de cuidado, que las autoras definen como “el conjunto de políticas y acciones encaminadas a concretar una nueva organización social de los cuidados con la finalidad de cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieran, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados —que hoy realizan mayoritariamente las mujeres”.⁹⁵

A tono con esta ola innovadora en las políticas de cuidado, en México la Cámara de Diputados aprobó en 2020 una iniciativa sobre el Sistema Nacional de Cuidados; sin embargo, el Senado de la República, aunque organizó foros de debate y discusión, a la fecha no ha aprobado la propuesta. De igual forma, desde 2021 está pendiente la aprobación de la Ley General para el Sistema Nacional de Cuidados.

Espero que para dar integralidad a las políticas de protección a la infancia, la voluntad política de los tomadores de decisiones haga posible en el corto plazo la creación del Sistema Nacional de Cuidados en México, bajo un enfoque

⁹⁴ Scuro, L., Alemany, C. y Coello, R., *Financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe*, op. cit.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 8.

de derechos, igualdad de género e interculturalidad, así como un modelo de corresponsabilidad en donde el Estado garantice la participación de los distintos actores de la organización social del cuidado, además de promover también el reparto equitativo de los cuidados entre mujeres y hombres.

F. Bibliografía

- Aguirre, R., “La necesaria redefinición del trabajo. Consideraciones conceptuales y metodológicas [ponencia]”, en V Congreso Latinoamericano de Sociología, Montevideo, Uruguay, 2007.
- Aguirre, R., “La política de cuidados en Uruguay: ¿un avance para la igualdad de género?”, *Estudios Feministas*, vol. 22, núm. 3, 2014, pp. 795-813.
- Alaniz-Hernández, C., “Atención y cuidado para la primera infancia en México. Un reto para la equidad de género”, *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, vol. 9, núm. 2, Educación, democracia y justicia social: Miradas desde América Latina, 2020.
- Alber, Jens, Fahey, Tony y Saraceno, Chiara (eds.), *Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union*, London y Nueva York, Routledge, 2008.
- Araujo, M. C. y López-Boo, F., “Los servicios de cuidado infantil en América Latina y el Caribe”, *El Trimestre Económico*, vol. LXXXII (2), núm. 326, abril-junio de 2015, pp. 249-275.
- Bahle, Thomas, “Family Policy Patterns in the Enlarged EU”, en Alber, Jens, Fahey, Tony y Saraceno, Chiara (eds.), *Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union*, London y Nueva York, Routledge, 2008.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID), *Y si hablamos de igualdad. Licencias de paternidad en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2023. Disponible en «<https://blogs.iadb.org/igualdad/es/licencias-paternidad-testimonio-colombia/>».
- Batthyány, K., *Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales*. Santiago de Chile, CEPAL-AECID. Serie Asuntos de Género, 2015. Disponible en: «<http://www.cepal.org/es/publica->

- ciones/37726-las-politicas-y-elcuidado-en-america-latina-una-mirada-las-experiencias». [Consultado el 12 de agosto de 2019].
- Batthyány, K., Genta, N. y Perrota, V., “Las representaciones sociales del cuidado infantil desde una perspectiva de género. Principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Representaciones sociales del cuidado”, *Papers*, 99/3, 2014, pp. 335-354.
- Batthyány, K., Genta, N. y Scavino, S., “Análisis de género de las estrategias de cuidado infantil en Uruguay”, *Cadernos de Pesquisa*, vol. 46, núm. 162, 2017. Disponible en: «<http://dx.doi.org/10.1590/198053143710>».
- Batthyány, K. y Katzowickz S., “Percepciones sobre las políticas de cuidado infantil en Uruguay”, *Revista Mexicana de Sociología* 84, núm. 3 (julio-septiembre, 2022): 597-624. Ciudad de México.
- Blofield. M., Lustig, N. y Trasnberg, M., “La protección social durante la pandemia: Casos de Argentina, Brasil, Colombia y México”, CEQ Institute, Tulane University, Working paper 104, 2021.
- Borderías, Cristina, Carrasco, Cristina y Torns, Teresa (eds.), *El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas*, 2a. ed., Madrid, Catarata, 2019.
- Calderón, G., “The Effects of Child Care Provision in Mexico”, *Documentos de Investigación*, México, Banco de México, 2014.
- Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de febrero de 2017. Última reforma publicada DOF 06-06-2023. Disponible en: «https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf». [Consultada el 15 de noviembre de 2023].
- Cámara de Diputados, *Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 21 de diciembre de 1995. Última reforma publicada DOF 25-04-2023.
- Cámara de Diputados, *Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 31 de diciembre de 2004. Última reforma publicada DOF 20-06-2021.
- Cámara de Diputados, *Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado*, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 31 de marzo de 2007. Última reforma publicada DOF 08-05-2023.

- Cámara de Diputados, *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. Última reforma publicada DOF 26-05-2023.
- Cámara de Diputados, *Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011. Última reforma publicada DOF 25-06-2018.
- Cámara de Diputados, *Ley General de Educación* (LGE), última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2022.
- Cecchini, S. y Madariaga, A., *Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la Experiencia Reciente en América Latina*, Santiago de Chile, Cepal/ASDI, 2011.
- Cejudo, G. (coord.), *Meta evaluación del Programa de Estancias Infantiles (PEI)*, Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2012.
- Cejudo, G. (coord.), *Diagnóstico sobre el problema público en materia de cuidados en México*, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2017.
- Comas, D., “Cuidados y derechos. El avance hacia la democratización de los cuidados”, *Cuadernos de Antropología Social*, Núm. 49, 2019, pp. 13-29.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), *Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales*, México, 2012. Disponible en: «https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf». [Consultado el 15 de noviembre de 2023].
- Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social (CONEVAL), *Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007-2019*, 2019.
- Daly, Mary y Lewis, Jane, “El concepto de ‘social care’ y el análisis de los Estados de Bienestar contemporáneos”, en Borderías, Cristina, Carrasco, Cristina y Torns, Teresa (eds.), *El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas*, 2a. ed., Madrid, Catarata, 2019, pp. 225-251.

- Esquivel, V., “El cuidado: de concepto analítico a agenda política”, *Revista Nueva Sociedad*, núm. 256, marzo-abril, 2015.
- Espig-Andersen, C., *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge/Princeton, Polity Press and Princeton University Press., 1999.
- Esquivel, V., Faur, E. y Jelín, E. (eds.), *Las lógicas del cuidado infantil: entre las familias, el Estado y el mercado*, Buenos Aires, IDES, UNFPA, Unicef, 2012.
- Esquivel, V., Faur, E. y Jelín, E., “Hacia la conceptualización del cuidado: familia, mercado y Estado”, en Esquivel, V., Faur, E. y Jelín, E. (Edseds.), *Las lógicas del cuidado infantil: entre las familias, el Estado y el mercado* (1143)., Buenos Aires, IDES, UNFPA, Unicef, 2012, pp. 1143.
- Filgueira, F., C. Molina, C., J. Papadópulos J. y Tobar, F., “U”niversalismo básico: una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida”, en Molina, Carlos Gerardo (editor), *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Editorial Planeta, 2006.
- Gobierno de México, Estrategia Nacional para la Primera Infancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2 de marzo de 2020.
- González Carvallo, D., *El derecho a la seguridad social: guarderías. Cuadernos de Jurisprudencia*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2021.
- Guezmes, A. y Baeza, M. N. (coords.), *Avances de la normativa sobre el cuidado en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, Cepal, División de Asuntos de Género, 2023.
- Hein, C. y Cassirer, N., *Soluciones para el trabajo infantil en el lugar de trabajo*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2010.
- INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda. Tabuladores principales, 2020.
- INEGI, Comunicado de prensa número 578/23. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), Comunicación Social, 3 de octubre de 2023.
- Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, *Anuario Estadístico*, México, 2016.

- Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Coordinación de Guarderías, México, 2016.
- Jácome, T., “¿Quién cuida a quién? Diferencias entre mujeres y hombres que realizan trabajo de cuidado en el hogar”, en Pacheco, Edith (coord.), *Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012*, México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2013, pp. 32-71.
- López Estrada, S., “Hacia la (re)privatización del cuidado infantil en México. Las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles Sedesol”, *Revista Interdisciplinaria De de Estudios De de Género de El Colegio de México*, vol. 6. 2020. Disponible en: «<http://dx.doi.org/10.24201/reg.v6i0.480>».
- López Estrada, S., “Políticas de Cuidado Infantil en América Latina: Análisis comparado de Chile, Costa Rica, Uruguay y México”, *Frontera Norte*, vol. 29, núm. 58, julio-diciembre, 2017, pp. 25-46.
- López Estrada, S., “Universalismo básico y políticas de cuidado infantil en México”, en Valencia, E. (coord.), *Perspectivas del Universalismo en México*, ITESO/Konrad Adenauer/UIA León, 2010.
- López Estrada, S., Políticas de cuidado infantil, trabajo y género. La privatización del cuidado en las familias en tiempos de austeridad. Proyecto de investigación 1311320 Ciencia de Frontera Conahcyt, Trabajo de campo 2022-2023, 2023.
- Martínez Franzoni, J., “Regímenes de Bienestar en América Latina: consideraciones regionales e itinerarios regionales”, *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* de FLACSO, 2005, volumen 4, número 2.
- Mateo Díaz, M., Rodríguez Chamussy, L. y Grafe, F., *Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo*, BID, 2014.
- Mateo-Berganza, M. y Rodríguez Chamussy, L., *Educación que rinde. Mujeres, trabajo y cuidado infantil en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017.
- Mikkelsen, M. y Christensen, P., “Is children’s Children’s Independent Mobility Really Independent? A Study of Children’s Mobility Combining

- Ethnography and GPS/Mobile Phone Technologies”, *Mobilities*, vol. 4, núm 1, 2009, pp. 37-58.
- Molina, Carlos Gerardo (editor), *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, Editorial Planeta, 2006.
- Montaño, S. y Calderón C. (coords.), “El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo”, *Cuadernos de la CEPAL*, 94, 2010.
- Murray, L. y Cortes-Morales, S., *Children’s Mobilities*, Palgrave MacMillan, 2019.
- Myers, R. y Uresti, D., “Atención a niñas y niños menores de 4 años en México durante el gobierno de Amlo: Análisis de un cambio de estrategia”, *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (México), vol. LIII, núm. 1, 2023.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Agenda 230 para el Desarrollo Sostenible*, 2015.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), *Convención de los Derechos del Niño*, 1989.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio 153 sobre duración de trabajo y periodos de descanso, 1979.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio 183 sobre protección de la maternidad, 2000.
- Pacheco, Edith (coord.), *Los cuidados y el trabajo en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012*, México, Instituto Nacional de las Mujeres, 2013.
- Pautassi, L., “El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos”, *Serie Mujer y Desarrollo* 87, Santiago de Chile, Cepal, 87, 2007.
- Pautassi, L. y Zibecchi, C., *La provisión de cuidado y superación de la pobreza infantil. Programas de Transferencias Condicionadas en Argentina y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias*, Santiago de Chile, CEPAL, 2010.

- Presno, M., C. López Rocha, C. y Moyá, G., *Políticas de atención y educación para la primera infancia en América Latina. Una aproximación al estado del arte de las investigaciones y estudios 2013-2019*, UNICEF-Fundación Arcor, 2019.
- Razavi, S., “The Political and Social Economy of Care in the Development Context. Conceptual Issue, Research Questions and Policy Options”, *Gender and Development*, núm. 3, 2007.
- Rodríguez, C., “La organización del cuidado de niñas y niños en Argentina y Uruguay”, eEn: *El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo*, Santiago, CEPAL, 2010, pp. 115-142.
- Rodríguez, C., *Programas de Transferencias Condicionadas. ¿Por dónde anda América Latina?*, Santiago de Chile, CEPAL, 2011.
- Rossel, C. Rico, N. y Filgueira, F., “Protección social para la infancia”, en Cecchine S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (editores), *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*, Santiago de Chile, CEPAL, 2015.
- Samman, E. y Lombardi, J. *Childcare and Working Families: New Opportunity of Missing Link? An Evidence Brief*, UNICEF, 2019.
- Scuro, L., C. Alemany, C. y Coello, R., *Financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe. Aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género*, Santiago de Chile, CEPAL, División de Asuntos de Género, 2022.
- Secretaría de Bienestar, Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras, 2019.
- Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, 2018.
- Secretaría de Gobernación, Estrategia Nacional para la Infancia, Ppublicada en el *Diario Oficial de la Federación*, 23 de marzo de 2020.
- Todaro, R. y Yañez S. (eds.), *El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género*, Santiago de Chile, Ediciones Centro de Estudios de la Mujer, 2004.
- Tronto, J., *Moral boundariesBoundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, 1993.

UNICEF, Marco programático mundial de protección social para la infancia del Unicef, 2019.

Valencia, E. (coord.), *Perspectivas del Universalismo en México*, ITESO/Konrad Adenauer/UIA León, 2010.

Zibecchi, C., “Mujeres cuidadoras en contextos de pobreza. El caso de los Programas de Transferencias Condicionados en Argentina”, *Estudios Feministas, Florianópolis*, vol. 22(1), núm. 416, enero-abril, 2014, pp. 91-114.

Una perspectiva de la pensión de viudez a la luz del concubinato. Reconocimiento y protección en el derecho a la seguridad social

Lizbeth Berenice Montealegre Ramírez*

Gema Patricia Cortés Matus**

* Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; abogada por la Escuela Libre de Derecho; maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España; maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México; maestra en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho; especialista en Relaciones Laborales por el mismo Instituto y Especialidad en el Curso sobre la reforma en Materia de Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial.

** Secretaria Auxiliar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; abogada por la Universidad Veracruzana; especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha, España, y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

SUMARIO: A. Introducción; B. Reconfiguración del concepto *familia*; C. Perspectiva de familia desde el concubinato en el régimen de seguridad social; D. El derecho a la pensión de viudez en el concubinato a la luz de los criterios jurisprudenciales destacados; E. Conclusiones; F. Bibliografía.

A. Introducción

A lo largo del tiempo, el desarrollo de los derechos sociales se ha consolidado mediante procesos históricos, culturales y jurídicos que reflejan la lucha por la exigibilidad de los derechos humanos. La seguridad social no ha sido la excepción, su evolución ha permeado en el renacimiento, protección y exigibilidad de los derechos humanos en la sociedad contemporánea.

A partir de una percepción de derechos humanos, se han visibilizado las dificultades a las que se enfrentan las personas trabajadoras, derechohabientes y sus beneficiarios que buscan la exigibilidad de sus derechos en materia de seguridad social. Por tal motivo, la reinterpretación de los alcances de los requisitos para materializar su otorgamiento tiene como fin ofrecer acceso al sistema de pensiones, asistencia médica, periodos de maternidad, paternidad, entre otros, de una manera más proteccionista.

Los nuevos cambios han impactado directamente en la manera en que interactúan la seguridad social y la familia, entendida ésta no sólo en su contexto tradicional, sino en las distintas formas en que puede conformarse, lo que ha permitido que los derechos de seguridad social se acerquen más a la realidad social y la integración familiar.

En particular, en el caso del concubinato, la reconfiguración del concepto de familia y la interpretación del régimen de pensiones de viudez han evolucionado haciendo frente a una realidad que debe ser atendida, protegida y reconocida bajo la tutela jurisdiccional.

En este trabajo se expone el cambio de paradigma jurisprudencial en materia de concubinato y pensión de viudez emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz del principio de realidad en materia de seguridad social. La primera sección presenta la importancia del reconocimiento de la familia desde del nuevo esquema constitucional y convencional. El segundo apartado destaca el marco legal del régimen de pensión de viudez en el concubinato. Por último, se reconstruyen los principales desarrollos jurisprudenciales adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, finalmente, se exponen las conclusiones.

B. Reconfiguración del concepto *familia*

En la actualidad, nos hemos alejado del concepto tradicional y estereotipado de familia que implica un padre, una madre e hijos; en su lugar, hemos abordado el concepto de familia a partir de una conformación que atiende a los parámetros de libertad y diversidad. Sin embargo, no hay que restarle valor al concepto tradicional, pues éste reconoció al *matrimonio* como la base primaria para la integración de la familia, otorgándole una protección jurídica especial. Tiempo después, comenzamos a migrar al concepto de libertad y se reconoció al *concubinato* como un tipo de familia sujeto a cumplir determinados requisitos regales.

Actualmente, el Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en términos generales, establece que una persona puede ser concubina siempre y cuando ambas partes estén libres de matrimonio, hayan vivido en común durante un período mínimo de dos años o, sin cumplir dichos requisitos, cuando tengan un hijo.¹ Recientemente, también se han regula-

¹ "Artículo 291 Bis. Las concubinas y los concubenarios tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma

do las *sociedades de convivencia* o *uniones de hecho*² otorgándoles derechos y obligaciones.

El cambio de paradigma en materia de derechos humanos a partir de la reforma de junio de 2011 replanteó la manera en que el Estado mexicano reconocía estos derechos, sus obligaciones, así como la manera de protegerlos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las fuentes normativas sobre derechos humanos contenidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte constituyen un mismo conjunto normativo y, por lo tanto, integran el parámetro de control de regularidad, independientemente de su fuente, entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, lo que permite identificar el parámetro de validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, así como la prevalencia de las restricciones constitucionales sobre el derecho internacional.³

En relación con el término familia, la reforma de derechos humanos mencionada impactó en la manera de vislumbrar los derechos a la luz de los nuevos tiempos, así como en la interpretación del artículo 4 de la Constitución federal y diferentes instrumentos internacionales, entre los cuales encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención sobre la Eliminación de Todas

constante y permanente por un período mínimo de dos años, que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común”.

^{Requisitos} que varían de acuerdo con la legislación civil de cada estado, derivado de la libertad configura de cada estado para regular la normativa en esta materia.

² Ley de Sociedades de Convivencia para la Ciudad de México (2017). Disponible en: «https://congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY_DE_SOCIEDAD_DE_CONVIVENCIA_PARA_LA_CIUADAD_DE_MEXICO.pdf». [Consultado el 25 de octubre de 2023].

³ Para mayor referencia sobre el tema, se puede consultar la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de 3 de septiembre de 2013.

las Formas de Discriminación contra la Mujer fundamentos base que han apoyado a redefinir el concepto tradicional de familia y han dado apertura a nuevos modelos, como las sociedades de convivencia o uniones de hecho. Esos modelos visibilizan una unión de hecho en la que sus integrantes deciden hacer una vida en común, e incluso tener hijos, sin que tengan el deseo de contraer matrimonio.

Al identificar estas transformaciones sociales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la familia debe entenderse como una realidad social y señaló que la protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones, como el matrimonio, uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, con cualquiera que denote un vínculo familiar en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones, es decir, la protección constitucional reconoció la pluralidad en que se puede conformar una familia.⁴

Particularmente, el matrimonio y el concubinato representan el vínculo de dos personas cuya intención es vivir bajo una base familiar, es decir, comparten la misma finalidad de conformar una familia.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que tanto los cónyuges como los concubinos pertenecen al grupo familiar de forma esencialmente igual, ya que proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad, por lo que requieren la protección especial otorgada a la familia.⁵

No obstante, para la consolidación del matrimonio es necesaria la intervención del Estado, mientras que para el concubinato sólo basta la voluntad de las partes,⁶ porque a partir del concepto tradicional se otorgó una protección

⁴ Sentencia recaída en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Sergio A. Valls Hernández, 16 de agosto de 2010.

⁵ Sentencia recaída en el Amparo Directo en Revisión 597/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 19 de noviembre de 2014.

⁶ Tesis [A.]: 1ª. XXXI/2018 (10ª.), *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, s. t., Libro 52, marzo de 2018, Tomo I, p. 1093, registro digital 2016483.

jurídica especial a la institución del matrimonio dejando al concubinato sujeto a diversos requisitos establecidos en distintos códigos civiles de cada estado.

En lo que se refiere al ámbito laboral y de seguridad social, la figura del concubinato es examinada dentro de la prelación de derechohabientes o beneficiarios de la persona trabajadora sujeta a una protección. Tanto la Ley Federal del Trabajo como las legislaciones en materia de seguridad social establecen requisitos para su reconocimiento, los cuales son independientes del ámbito civil.

Lo anterior, bajo el principio de interdependencia, que implica que un derecho se verá ligado a otro. Esto es común que suceda cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal es el caso del derecho laboral y de seguridad social. En otras palabras, cuando la persona trabajadora fallece, quien hasta el momento de la muerte se haya desempeñado como su pareja puede acceder al otorgamiento de una pensión por viudez desde el régimen de seguridad social que ha previsto su otorgamiento basado en las condiciones laborales, sociales y económicas,⁷ como se advierte en el siguiente apartado.

C. Perspectiva de familia desde el concubinato en el régimen de seguridad social

En el ámbito internacional, el derecho de seguridad social se reconoce a favor de todas las personas en los artículos XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,⁸ 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,⁹ 9 del Pacto Internacional de Derechos Económi-

⁷ Sentencia recaída en el Amparo en Revisión 219/2008, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz, 19 de junio de 2008.

⁸ “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

⁹ “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organiza-

cos, Sociales y Culturales,¹⁰ y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.¹¹

La Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 102,¹² plasmó las bases mínimas de las prestaciones de este derecho humano, entre las que se encuentra la concesión de prestaciones de sobrevivientes, con motivo de la muerte del sustento de la familia para garantizar la subsistencia de las personas dependientes del trabajador asegurado.

Desde la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC) ha destacado la importancia de la interdependencia de los derechos. Específicamente, respecto de la seguridad social, visibiliza que este derecho ayuda, en gran medida, a reforzar el ejercicio de otras prerrogativas, como el derecho a la salud, alimentación, mínimo vital, protección de la niñez y adolescencia, de las personas con discapacidad, entre otros.

Además, el Comité DESC en la Observación General No. 19 destacó que los elementos base de la seguridad social son a) disponibilidad, b) riesgos e imprevistos sociales, c) nivel suficiente, d) accesibilidad y e) relación con otros derechos.¹³

ción y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

¹⁰ “Artículo 9. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

¹¹ “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social

¹ Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

² Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.

¹² Tesis [J.]: P./J.22/2013 (10a.), *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 5. Reg. digital: 2003953.

¹³ Comité DESC, “*El derecho a la seguridad social (artículo 9)*”, Observación General No. 19, de 23 de noviembre de 2007.

Ese organismo internacional también se ha pronunciado sobre la importancia de la igualdad de género al diseñar y brindar seguridad social. En la Observación General No. 16, sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente, manifestó que se debe tomar en cuenta el contexto social en el que viven las mujeres, dados los prejuicios sociales, leyes, tradiciones y prácticas que encubren discriminación directa o encubierta para adoptar medidas para garantizar sus derechos.¹⁴ Escenario que se agrava cuando coexisten múltiples formas de discriminación al combinarse los motivos de sexo con factores como la raza, el idioma, la religión, condición social, discapacidad, estado civil, entre otras.¹⁵ De ahí la importancia de visibilizar el problema desde una perspectiva interseccional basada en género que proteja todas las realidades de acuerdo con la protección específica que requiera cada persona.¹⁶

Por su parte, el Tribunal Interamericano ha sostenido que una de las finalidades del derecho a la seguridad social a las personas trabajadoras y sus beneficiarias es protegerlos de las presentes y futuras consecuencias generadas por una contingencia ajena que afecten el derecho a una vida digna, garantizando su protección a través del acceso a la asistencia médica, seguridad del ingreso al sistema de pensiones, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.¹⁷

¹⁴ Comité DESC, “La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, Observación General No. 16, de 25 de abril a 13 de mayo de 2005.

¹⁵ En el sistema jurídico mexicano, estas categorías sospechosas se reconocen en el artículo 1o. de la Constitución Federal. En el ámbito internacional, también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

¹⁶ Echarri Cánovas, Carlos Javier, *Interseccionalidad de las desigualdades de género en México. Un análisis para el seguimiento de los ODS*, México, 2020. Disponible en: «<https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Julio%202020/Interseccionalidad%20de%20las%20desigualdades%20de%20genero%20en%20Mxico.pdf>». [Consultado el 22 de octubre de 2023].

¹⁷ Corte IDH, Caso Muelle Flores vs. Perú. “Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019”, Serie C No. 375. Disponible en: «https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.pdf». [Consultado el 24 de octubre de 2023].

Por lo que se refiere al sistema jurídico mexicano, el artículo 123 de la Constitución federal prevé la seguridad social como un derecho humano desarrollado en el apartado A, fracción XXIX, y apartado B, fracción XI, inciso A, que tiene como objeto proteger a las personas trabajadoras y sus familiares beneficiarias.¹⁸

Específicamente, en relación con la pensión de viudez, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Seguro Social¹⁹ establecen el orden de prelación para tener derecho a una pensión derivada del fallecimiento de una persona trabajadora.

¹⁸ “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

^{El} Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales registrarán:

^A Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (...)

^{XXIX.} Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

^B Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

^{XI.} La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: (...). ”.

¹⁹ “Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

^{I.} El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

^{II.} A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión.

^{Para} efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinarios deberán acreditar haber vivido en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común; [...]. ”.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé el siguiente orden.

- La esposa del trabajador o pensionado, a falta de ella;
- La concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en compañía durante los cinco años que antes de su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona trabajadora, tuviere varios concubinatos, ninguno tendrá derecho a pensión.

Mientras que la Ley del Seguro Social²⁰ establece quiénes tienen derecho a la pensión de viudez:

- La persona que fuere cónyuge del asegurado o pensionada.
- A falta de cónyuge, la concubina o el concubinario que haya vivido durante al menos los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte.
- La persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
- La persona que hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o la o el pensionado. Si al morir el asegurado o pensionado

²⁰ “Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrán derecho a recibir la pensión la concubina o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez, que haya vivido durante al menos los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, o la persona que hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o la o el pensionado. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión”.

tenía varias o varios concubinas o concubenarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

A partir del marco normativo constitucional y convencional descrito, se concluye que el derecho a recibir una pensión como consecuencia de la muerte de la persona trabajadora en activo, pensionada o jubilada busca proteger a la familia dependiente del finado derivado de la muerte de uno de los soportes económicos.

D. El derecho a la pensión de viudez en el concubinato a la luz de los criterios jurisprudenciales destacados

El derecho a una pensión de viudez entre concubinos ha sido un tópico desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su línea jurisprudencial a la luz de los derechos de igualdad y no discriminación, así como de seguridad social, previstos en los artículos 1o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la cual se amplían las garantías para acceder a ésta.

Al dotar de contenido al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Constitucional indicó que este precepto no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para las personas trabajadoras al servicio del Estado, sino también se encuentra el principio de previsión social. Tal principio se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar para los trabajadores y sus familiares, ante los riesgos expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento de su nivel de vida,²¹ lo cual es acorde al contenido del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

²¹ Sentencia recaída en el amparo revisión 124/2021, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas, 7 de julio de 2021; Tesis [J.]: P./J.128/2019 (10a.), *Semanario judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, p. 259. Reg. digital: 2020634 y tesis [J.]: P./J.97/2012 (10a.), *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, p. 553. Reg. digital: 2001660.

Desde el panorama de familia construida por el concubinato y la seguridad social, la Segunda Sala ha desarrollado diversas líneas jurisprudenciales en torno a dichos tópicos; no obstante, únicamente abordaremos dos ejes temáticos principales: 1) el requisito de permanecer libre de matrimonio para efectos de la concesión de la pensión de viudez y sus implicaciones con relación al matrimonio y 2) la periodicidad para acreditar el tiempo del concubinato.

Sobre el primer eje temático, relativo al requisito de “permanecer libres de matrimonio” para poder acceder a una pensión de viudez por parte del o la concubina, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado, atendiendo a un enfoque actual, en donde existe una diversidad de uniones familiares que permite tener en cuenta la realidad social.

Como se desarrolló en el apartado previo, en México las legislaciones en materia de seguridad social establecen una serie de requisitos y una prelación de beneficiarios que pueden ser sujetos de pensión por causa de muerte de la persona trabajadora, con el fin de otorgar la pensión de viudez a la esposa del trabajador y, a falta de ésta, a la concubina.

La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 251/2010, se centró en determinar si procedía el otorgamiento de la pensión de viudez, en términos del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a la mujer con quien el asegurado tuvo hijos, a pesar de que éstos hayan nacido cuando aquél estaba casado con una tercera persona, pero al momento de fallecer ambos se encontraban libres de matrimonio.

Dicho precedente reconoció el otorgamiento de una pensión de viudez en los casos en que, a la muerte de una persona trabajadora, se acredite que la persona asegurada y la reclamante de la pensión estén “libres de matrimonio” y hayan cohabitado como pareja antes del fallecimiento, además, procreado hijos. En el precedente fortaleció el cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación.

El criterio que prevaleció en ese asunto fue que la concubina puede acceder a una pensión de viudez, siempre y cuando el asegurado no esté casado,

pues, de lo contrario, dicha pensión correspondería a la esposa,²² lo que fortaleció posicionar, en orden de prelación, al concubinato en un segundo lugar, frente al matrimonio.

De ese asunto se emitió la jurisprudencia 2a./J. 192/2010, de rubro: PENSIÓN DE VIUDEZ EN FAVOR DE LA CONCUBINA. PROCEDE SU OTORGAMIENTO CUANDO HAYA TENIDO HIJOS CON EL ASEGURADO, SI EN LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO AMBOS ESTABAN LIBRES DE MATRIMONIO.²³

Así, el criterio fue reiterado en otras sentencias como en el amparo en revisión 404/2018, en el que, al interpretar el artículo 130 de la Ley del Seguro Social vigente, que regula la pensión de viudez, determinó que “tal prestación se debe conceder a la persona que se ostenta como concubina del asegurado, cuando acredite que [‘]ambos libres de matrimonio, cohabitaron como si fueran marido y mujer antes del fallecimiento de aquél y además procrearon hijos, independientemente de que éstos hubiesen nacido antes del concubinato[’]”.²⁴

Ese asunto concluyó que en el caso de que el trabajador fallecido tenga varias concubinas al morir, para el otorgamiento de la pensión de viudez no será procedente concederle el derecho, pues aún cuando cotizó en los diversos ramos de seguridad social para asegurar el bienestar de él y su familia, tal circunstancia no implica que

todas las personas con las que vivió en pareja y/o tuvo hijos en común, tengan derecho a esa prestación económica, dado que su objeto es garantizar la subsistencia de quien vivió con el asegurado —o

²² Sentencia recaída en la contradicción de tesis 251/2020, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, 10 de noviembre de 2010.

²³ Tesis [J.]: P./J.192/2010 (9a.), *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, p. 999. Reg. digital: 163066.

²⁴ Sentencia recaída en el Amparo en Revisión 404/2018, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán, 19 de septiembre de 2018.

pensionado fallecido— hasta la fecha de su deceso, como si fuese su cónyuge, durante un plazo mínimo de cinco años, o por un tiempo menor, en caso de haber procreados hijos en común, lo que resulta acorde con el derecho a la protección de la familia.

También manifestó que el concubinato, al igual que el matrimonio,

tiene como fin proteger a las personas que deciden formar una pareja y establecer un hogar común con intención de permanencia y ayuda mutua, de ahí que no es jurídicamente posible aceptar que pueden coexistir dos o más concubinas del asegurado —o pensionado fallecido— para efectos del otorgamiento de la pensión de viudez, habida cuenta que su financiamiento se calcula atendiendo a que en nuestro sistema jurídico sólo se reconocen los matrimonios y concubinatos monogámicos.²⁵

Por otra parte, atendiendo al principio de realidad y en busca de ampliar la protección del derecho a la seguridad social en materia de concubinato, tiempo después la Segunda Sala, al resolver el amparo directo 18/2021, declaró que la porción normativa que exigía estar libres de matrimonio era inconstitucional, por ser contraria a los derechos de igualdad y no discriminación, dado que desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como las distintas modalidades en que se puede conformar un vínculo familiar, dado que en la realidad social pueden coexistir la unión jurídica de matrimonio con una persona y una verdadera unión de hecho con otras.²⁶

En el precedente, la Segunda Sala advirtió que el artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establecía limitantes para que la persona con la que el trabajador convivió por los cinco años anteriores a su muerte, o con la que tuvo hijos en común, pudiera concurrir a solicitar los derechos derivados de la muerte del trabajador, por lo que ameritaba ser analizada,

²⁵ *Idem*.

²⁶ Sentencia recaída en el amparo directo 18/22021, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa, 9 de marzo de 2022.

por una parte, desde una perspectiva de género, a partir de la existencia de una discriminación basada en estereotipos y, por otra, bajo un escrutinio estricto al tratarse de una categoría sospechosa.²⁷

Desde la perspectiva de género, se indicó que esta metodología debía ser utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho, así como para apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Además de evaluar si la norma provocaba una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género.²⁸

Precisó que excluir del acceso a la pensión de viudez por existir un vínculo matrimonial no debía significar la exclusión de la protección a aquellas personas que, desconociendo o aun conociendo de la subsistencia de dicho vínculo matrimonial, decidan unirse a fin de conformar una familia.²⁹

A partir del principio de primacía de la realidad —derivado del desinterés o la indiferencia de las personas para disolver un matrimonio previamente establecido antes de conformar una nueva relación de pareja, ya sea por cuestiones económicas o simplemente por evitar la realización de los diversos trámites legales, trae como consecuencia la subsistencia de un vínculo jurídico con una persona con la que ya no existe trato alguno. Esto frente a una relación de hecho en la que sí comparte los vínculos de afectividad y solidaridad—,³⁰ se debía reconocer el carácter de beneficiaria a quien acredite que convivió con la persona trabajadora durante los cinco años que precedieron a su muerte, o con la que tuvo hijos, independientemente de que alguno de los dos haya sostenido un vínculo matrimonial con diversa persona.

Al desarrollar el estudio sobre los derechos de igualdad y no discriminación, aplicó el test de escrutinio estricto para advertir que el precepto impugnado

²⁷ *Idem.*

²⁸ *Idem.*

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Idem.*

establecía un trato diferente a partir del estado civil entre las personas que en una relación de hecho coexisten con un matrimonio.

A partir del test determinó que las distinciones legales no protegían a los integrantes de la familia al excluir del derecho a la pensión de viudez a otras parejas por la existencia de un vínculo matrimonial, puesto que no impedía que las personas pudieran unirse para conformar una familia.

Asimismo, la Segunda Sala consideró que las restricciones impuestas en la norma no cumplen con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues, por un lado, el requisito de que sólo “a falta de cónyuge supérstite” pueda concurrir a demandar los derechos del trabajador finado, la persona con la que el trabajador convivió durante los cinco años anteriores a su muerte, o con la que tuvo hijos, aunado a la exigencia de que ambas personas “hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato”, no persigue un fin constitucionalmente importante,³¹ sino que representa una restricción para gozar de ese derecho sin tomar en cuenta la realidad en que se sustentan muchas relaciones familiares actualmente.³²

Finalmente, declaró la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, por ser contrario a los principios de igualdad y discriminación, al limitar el derecho a la protección de la familia a las uniones de hecho, o que hayan tenido hijos en común, ante la subsistencia de un vínculo matrimonial con otra persona, sin que haya justificación razonable constitucionalmente.

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en el reconocimiento desde una perspectiva de género de los derechos de igualdad y no discriminación de las mujeres que atiende a la realidad social, ampliando su protección, visibilizando un entorno social y actual.

³¹ *Ibidem*, párrafo 104.

³² *Ibidem*, párrafo 108.

Esto es, los requisitos para que la concubina o concubino puedan acceder a una pensión de viudez dentro del sistema de seguridad social, en general, se hicieron más acordes a una realidad social que se encontraba restringida bajo el término de familia tradicional. Pero que ante la apertura de nuevas formas de unión familiar se permitió acceder a ese beneficio económico, pues de ninguna manera deja de lado el cumplimiento de éstos, simplemente elimina obstáculos que impiden una protección más amplia. De ahí que en materia de pensiones de viudez la dinámica probatoria adquiere gran relevancia para comprobar la existencia del concubinato, ya que no debe perderse de vista que la inconstitucionalidad mencionada no soslaya el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, es decir, acreditar que hacían vida en común.

Ahora bien, respecto del segundo eje temático, consistente en la periodicidad para acreditar el tiempo del concubinato, también se ha avanzado en la protección de los derechos pensionarios de los concubinatos.

La Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 193/2018,³³ estableció que para fijar el término de cinco años previos a la fecha del fallecimiento para hacer vida en común es constitucional, pues ese periodo obedece a la necesidad de regular una situación de hecho y representa la verificación o constatación de los requisitos previstos para tener derecho a la pensión ya que, contrario a la figura del matrimonio, en el supuesto de que dentro del concubinato no se hubieran tenido hijos en común se generen derechos en materia de seguridad social es necesario que se revele que la persona solicitante sí desarrolló vida en compañía con la parte trabajadora.³⁴

Precisó que su exigencia sólo supone el establecimiento de los requisitos necesarios para tener derecho a la pensión correspondiente sin que contraviñera el derecho de seguridad social basado en el cálculo actuarial que diseñó

³³ Sentencia recaída en el amparo en revisión 193/2018, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas, 16 de mayo de 2018.

³⁴ *Idem*.

el legislador ordinario, que consideró adecuado para garantizar el derecho constitucional a la seguridad social en el ramo del seguro de muerte.³⁵

En ese asunto, declaró la constitucionalidad del plazo, dado que imponer un periodo mínimo de convivencia entre las personas unidas en concubinato, en el caso de que no hayan tenido hijos, sólo representa la verificación de los requisitos necesarios para tener derecho a la pensión de viudez.³⁶

Hay que mencionar, además, que la Segunda Sala al fallar el amparo en revisión 438/2022 confirmó la inconstitucionalidad de la norma³⁷ que sujetaba el derecho de la concubina que convivió con el trabajador hasta antes de su muerte, a que ambos *se mantengan libres de matrimonio* porque desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad y vulnera los derechos de igualdad y no discriminación. Esto pues la legislación no reconoce los diversos modos en que se puede conformar un vínculo familiar y el hecho de que puede coexistir la unión jurídica del matrimonio con una unión de hecho con otra persona.³⁸

En dicho precedente se señaló que la exigencia de que el concubino o concubina sobreviviente haya vivido durante un periodo mínimo de cinco años con la persona trabajadora fallecida para estar en condiciones de solicitar una pensión constituye un requisito que por sí solo no se contrapone al régimen de seguridad social, pues el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a)

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

³⁷ Se analizó la constitucionalidad del artículo 36, fracción II, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, al establecer como requisito para el otorgamiento de una pensión por viudez que la concubina durante el cumplimiento del requisito de temporalidad —cinco años de convivencia— se encuentren libres de matrimonio, y si tal situación vulnera el derecho de igualdad y no discriminación y, consecuentemente, el derecho de seguridad social.

³⁸ Sentencia recaída en el amparo en revisión 438/2022, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Loretta Ortiz Ahlf, 3 de mayo de 2023.

de la Constitución federal³⁹ prevé la seguridad social como derecho fundamental que tiene como objeto proteger a las personas, entre otros, contra el riesgo de muerte.⁴⁰ Sin embargo, determinó que tal circunstancia sí vulnera los derechos de protección a la familia, igualdad y no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, pues soslaya los diversos modos en que puede conformarse un vínculo familiar.

En conclusión, es posible advertir que ha existido un desarrollo progresivo en materia de pensión de viudez en el concubinato, pues atendiendo al principio de realidad y a la reconfiguración del concepto de familia la interpretación dada a las limitantes establecidas desde las legislaciones en materia de seguridad social que en su momento se consideraron válidas se transformaron con el fin de dar mayor protección y acceso para su otorgamiento. De ahí que el avance en la protección de las y los concubinos que demandan el otorgamiento de una pensión de viudez a la luz de su situación particular permite, primero, ubicar a las personas beneficiarias en una situación de igualdad para exigir sus derechos sociales, sin la limitante de que durante el tiempo de convivencia haya tenido que existir un matrimonio previo o coexistiendo tengan la posibilidad de probar su calidad de concubino o concubina.

E. Conclusiones

La realidad debe ser protegida por un derecho dinámico que entienda los cambios sociales sin restricciones o limitaciones a derechos humanos. Ante

³⁹ “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

^{EI} Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

^B Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

^{XI} La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

^{a)} Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte”.

⁴⁰ Párrafo 45 del amparo en revisión 438/2022.

la evolución de lo que se debe entender por familia y sus implicaciones, el derecho a la seguridad social debe mirarse con perspectiva de género atendiendo y reconociendo situaciones que antes no eran visibles.

El concubinato como institución de derecho social amplió su margen de protección para dejar de considerar ciertos aspectos que limitaban su actuación, sin que eso signifique dejar de atender a los requisitos y exigencias legales.

La declaración de inconstitucionalidad de la porción normativa “libres de matrimonio”, por ser contraria al principio de igualdad y no discriminación dentro de los requisitos para acceder a una pensión de viudez, es un paso importante en la construcción de una realidad social que impedía reconocer situaciones de hecho existentes que no eran visibilizadas.

La determinación que hace la Segunda Sala de la Suprema Corte en relación con el tiempo que debía permanecer libre de matrimonio la concubina para acceder a la pensión de viudez es un paso importante en el reconocimiento de situaciones de hecho, sin que eso implique dejar de cumplir requisitos y cargas probatorias previstos en ley.

F. Bibliografía

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, “El derecho a la seguridad social (artículo 9)”, Observación General Núm. 19, de 23 de noviembre de 2007.

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, “La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, Observación General Núm. 16, de 25 de abril a 13 de mayo de 2005.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2018. Disponible en: «https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm». [Consultado el 25 de octubre de 2023].

- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Muelle Flores vs. Perú. “Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019”, Serie C No. 375. Disponible en: «https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.pdf». [Consultado el 24 de octubre de 2023].
- Echarri Cánovas, Carlos Javier, *Interseccionalidad de las desigualdades de género en México. Un análisis para el seguimiento de los ODS*, México, 2020. Disponible en «<https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Julio%202020/Interseccionalidad%20de%20las%20desigualdades%20de%20genero%20en%20Mexico.pdf>». [Consultado el 22 de octubre de 2023].
- Ley de Sociedades de Convivencia para la Ciudad de México, 2017. Disponible en: «https://congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY_DE_SOCIEDAD_DE_CONVIVENCIA_PARA_LA_CIUDDAD_DE_MEXICO.pdf». [Consultado el 25 de octubre de 2023].
- Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Sergio A. Valls Hernández, 16 de agosto de 2010.
- Sentencia recaída al Amparo Directo en Revisión 597/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 19 de noviembre de 2014.
- Sentencia recaída el Amparo en Revisión 219/2008, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz, 19 de junio de 2008.
- Sentencia recaída en el Amparo Directo 18/22021, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa, 9 de marzo de 2022.
- Sentencia recaída en el Amparo Directo 193/2018, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas, 16 de mayo de 2018.
- Sentencia recaída en el Amparo en Revisión 438/2022, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Loretta Ortiz Ahlf, 3 de mayo de 2023.

Sentencia recaída en el Amparo Revisión 124/2021, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas, 7 de julio de 2021.

Sentencia recaída en la Contradicción de Tesis 251/2020, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, 10 de noviembre de 2010.

El derecho a la seguridad social de las trabajadoras domésticas remuneradas

Flavia Marco Navarro *

* Consultora internacional, investigadora en temas de cuidado, seguridad social, legislación comparada y otros temas relativos a las políticas sociales. Correo electrónico: marconavarroflavia@gmail.com

SUMARIO: A. Introducción; B. El derecho a la seguridad social: una obligación estatal que debe materializarse en condiciones igualitarias; C. Cuidado y seguridad social: superando la relación paradójica; D. El acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social; I. Panorama iberoamericano; II. Causales de desigualdad; 1. Discriminación directa; 2. Discriminación indirecta; E. Algunas notas sobre México; I. Un repaso de las condiciones laborales y de seguridad social; II. Los resultados recientes; III. La igualdad en la seguridad social para la Suprema Corte; F. Conclusiones y propuestas; I. Generar una cultura previsional; II. Cambios normativos e institucionales; III. Procedimientos ágiles y trámites amigables; IV. Inspección laboral y campañas de creación de conciencia; V. Mejorar la situación de las personas trabajadoras migrantes; VI. Fomentar el diálogo social; VII. Generación y difusión de información estadística; VIII. A manera de cierre; G. Bibliografía.

A. Introducción

Este texto aborda el derecho a la seguridad social de las trabajadoras domésticas remuneradas. La realidad de estas trabajadoras en materia de seguridad social constituye un campo privilegiado para el estudio de los déficits en el ejercicio de derechos económicos y sociales y del carácter transversal de la igualdad, consustancial a todos los derechos. En otras palabras, no se trata sólo de ser titular de derechos y de ejercerlos, sino de hacerlo en condiciones de igualdad.

Este documento se basa en una investigación sobre el tema que abarcó los 22 países de Iberoamérica (19 de América Latina más España, Andorra y

Portugal).¹ Así, puede sostenerse que la masiva exclusión de estas trabajadoras de la seguridad social, que ocurre en la mayoría de los casos abordados, responde a formas de discriminación directa e indirecta.

El artículo presenta primero un apartado relativo a la igualdad en la seguridad social, con base en el derecho internacional de los derechos humanos; luego aborda la relación entre cuidado y seguridad social, dado que el empleo doméstico es cuidado remunerado, y da cuenta de esta relación problemática y de exclusión.

En un tercer apartado se analiza el acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social y las causales de exclusión o limitada participación, para posteriormente dedicarse al caso mexicano con algunas notas referentes a la realidad reciente y los cambios acontecidos a partir de la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la exclusión de las trabajadoras domésticas remuneradas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Finalmente se presentan las conclusiones y propuestas.

B. El derecho a la seguridad social: una obligación estatal que debe materializarse en condiciones igualitarias

El derecho a la seguridad social está reconocido como derecho humano desde hace casi 80 años. En efecto, el derecho a la seguridad social es parte de los derechos económicos, sociales y culturales, y fue establecido como derecho en la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo.

Fue reconocido también como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que señala en el artículo 22 que “toda

¹ Desde el apartado III, este artículo se basa en la investigación realizada para ONU Mujeres, OISS y OIT conjuntamente con Claudia Giacometti y Tebelia Huertas, titulada “El acceso de las personas trabajadoras domésticas remuneradas a la Seguridad Social en Iberoamérica”. Disponible en «<https://lac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/acceso-de-las-personas-trabajadoras-domesticas-remuneradas-a-la-seguridad-social-en-iberoamerica>».

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y en el párrafo 1 del artículo 25, que establece que toda persona tiene “derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Asimismo, se reconoce en el Convenio 102 sobre seguridad social de la OIT (1952). Este derecho fue luego consagrado en otros convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (1969), el Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9) y el Protocolo de San Salvador (artículo 9) y, por último, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015).

Hay además convenios sobre poblaciones que experimentan dificultades para el ejercicio de derechos que abordan el derecho a la seguridad social. Por ello, la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999), destinada a que la condición de discapacidad de las personas deje de ser un obstáculo para el ejercicio de todos derechos, ratifica el derecho a la seguridad social. En el mismo sentido, la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias (1990) dispone que los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán, con respecto a la seguridad social, el mismo trato que los nacionales. Igualmente, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) ratifica el derecho a la seguridad social de las personas pertenecientes a pueblos indígenas.

Por supuesto, también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar a las mujeres el ejercicio del derecho a la seguridad social en igualdad de condiciones con los hombres.

Además, todos los convenios mencionados se consideran parte del bloque de constitucionalidad en buena parte de los ordenamientos jurídicos de los países de América Latina, es decir, además de la consagración del derecho a

la seguridad social en sus constituciones, éste se considera integrado en las mismas en los términos en que es reconocido por los instrumentos internacionales de derechos humanos y la interpretación que de los mismos hacen los organismos encargados de velar por su cumplimiento y su interpretación (cortes, comités, grupos de trabajo y relatorías de derechos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas).

Los convenios citados generan para los Estados obligaciones de respetar (no conculcar desde el propio Estado), proteger (frente a terceros) y realizar el derecho a la seguridad social (brindar condiciones de posibilidad para el ejercicio).

Para el cumplimiento de estas obligaciones, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado una serie de estándares. En materia de DESC, los principales estándares son: 1) contenido mínimo de los derechos y universalidad, 2) utilización del máximo de recursos disponibles, 3) progresividad y no regresividad, 4) igualdad y no discriminación, 5) acceso a la justicia y mecanismos de reclamo, 6) producción de información y acceso a la misma y 7) participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas.²

Para cada uno de estos estándares, el Grupo de Expertos para la Aplicación del Protocolo de San Salvador ha desarrollado una serie de indicadores con base en los cuales los Estados dan cuenta del cumplimiento del mencionado convenio.³ Estos indicadores se estructuran en una matriz en la que justamente el Grupo de Expertos hace más de una década ejemplificó el cumplimiento de los estándares con el derecho a la seguridad social.⁴

² Pautassi, Laura, "Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición", en Abramovich, Victor, y Pautassi, Laura, (Compiladores), *La medición de las políticas sociales*, Buenos Aires, Del Puerto Editores, 2010.

³ Organización de Estados Americanos (OEA), *Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador*, Segunda Edición, 2015.

⁴ Al respecto, véase el Anexo de Abramovich, Victor, y Pautassi, Laura (compiladores), *La medición de las políticas sociales*, Buenos Aires, Del Puerto Editores, 2010.

La igualdad es un estándar, un principio transversal para el ejercicio de los derechos humanos y un derecho en sí. Sin embargo, la igualdad en la seguridad social debe ser una de sus expresiones menos frecuentes. Hay abundante evidencia en los últimos 20 años de la desigualdad de género en la seguridad social,⁵ como también de las desigualdades de cobertura entre áreas urbanas y rurales, sectores socioeconómicos y pertenencia étnica. Hay grupos ocupacionales directamente excluidos históricamente y cuya inclusión es reciente. Este es el caso que en el que se centra este artículo, el de las trabajadoras domésticas remuneradas.

La igualdad en la seguridad social debe entenderse a la luz de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, principios que no sólo representan un horizonte ético, sino que tienen implicaciones jurídicas concretas para los Estados. Es así que, una vez reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales, la ciudadanía social no puede plantearse como secundaria respecto de la ciudadanía civil o política. Por lo mismo, el sistema de derechos rompe con la concepción lineal de los mismos, de manera que no es válido pretender concretar primero los derechos civiles y políticos para luego promover y garantizar los DESC.⁶ Pero ¿de qué depende la igualdad en la seguridad social? Para empezar de que no haya exclusiones explícitas ni ninguna forma de discriminación.

La experiencia muestra que cuando el estatus ciudadano es el vector de la seguridad social y no la calidad de trabajador o trabajadora, los derechos económicos y sociales quedan más garantizados y las mujeres gozan de un

⁵ Marco Navarro, Flavia, "Rasgos generales de los sistemas previsionales de capitalización individual y de sus contextos laborales y demográficos", en Marco, Flavia (coord.), *Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género*. Cuadernos de la Cepal No. 90, Santiago de Chile, CEPAL, 2004, pp. 31-58 y Marco Navarro, Flavia, *La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género en América Latina*, Serie Asuntos de Género, No. 139, Santiago de Chile, CEPAL, 2016.

⁶ Cecchini, Simone y Rico, María Nieves, "El enfoque de derechos en la protección social", en *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*, en Cecchini, Simón, Filgueira, Fernando, Martínez, Rodrigo y Rossel, Cecilia (eds.), Santiago de Chile, CEPAL, 2015 (LC/L G.2644-P).

acceso igualitario.⁷ Se sabe también que los sistemas más solidarios y con más compromiso fiscal resultan más igualitarios y que, a la inversa, los sistemas que estrechan más la relación entre aportes y beneficios o aquellos ligados exclusivamente a la formalidad laboral son más excluyentes. Por supuesto, además de crear las condiciones de posibilidad para el acceso de las personas a la seguridad social, la igualdad depende de la ausencia de discriminaciones.

Respecto del carácter universal de los derechos a la igualdad y no discriminación y del carácter transversal del principio de igualdad en el derecho internacional de los derechos humanos, diversos organismos encargados del seguimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos han emitido observaciones, dictámenes e informes. Hay abundantes sugerencias y recomendaciones desde los organismos que velan por el cumplimiento de los convenios o evalúan el mismo sobre qué deben hacer los estados en materia de seguridad social para lograr la igualdad.⁸

Sin embargo, lejos está de materializarse para la gran mayoría de la población en muchos países de América Latina, y en este contexto de exclusión, hay poblaciones para las cuales la exclusión es más severa. Es el caso de las personas trabajadoras domésticas. Con el cometido de saldar deudas históricas en materia de igualdad y de brindar protección específica a este segmento de personas trabajadoras, el Convenio 189, en su artículo 14, establece que los Estados deberán “adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condicio-

⁷ Pautassi, 2005.; y Pautassi, Laura, Giacometti, Claudia y Gherardi, Natalia, “Sistema previsional en Argentina y Equidad de Género. Situación actual (2003-2011) y perspectivas futuras”, *Serie Documento de Trabajo ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-ELA*, 2011.

⁸ Observaciones Generales No. 6, No. 16 y No. 20 del Comité PIDESC; Observaciones a varios países de la región del Comité CEDAW; Relatoría especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en su informe de 2017, Naciones Unidas; Relatoría especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Naciones Unidas, en su informe de 2015; el Informe de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad al Consejo de Derechos Humanos de 2016; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de Naciones Unidas en su Informe de 2014.

nes aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

C. Cuidado y seguridad social: superando la relación paradójica

El cuidado no remunerado aporta a las economías de los países y a los Estados y, en particular, a las políticas sociales. Aporta, por tanto, a la seguridad social. Si las mujeres no se hicieran cargo del cuidado de personas ancianas, enfermas crónicas, de la niñez y de la asistencia cotidiana a personas con discapacidad, el Estado tendría que asumir esta labor. Las mujeres están subsidiando a los Estados.

Paradójicamente, por subsidiar a los Estados, históricamente se ha castigado a las mujeres porque al estar en el cuidado no remunerado no están en el empleo o lo están en condiciones distintas a las masculinas. Se las castiga y excluye de la seguridad social o se mediatiza el derecho, es decir, se hace depender el acceso y la situación de las mujeres en la seguridad social de su vínculo con una pareja masculina (derecho derivado, cuyo paradigma es la pensión de viudez). Por cierto que esta configuración tiene que ver con el origen y desarrollo de la seguridad social pensada para un mundo de empleo asalariado formal, con familias heterosexuales con un varón proveedor y una mujer ama de casa. Sin embargo, el desarrollo de la seguridad social ha experimentado cambios en lo doctrinario y en lo operativo que han ido a un ritmo más rápido que aquellas modificaciones que tienen que ver con recoger los cambios operados en el último siglo en la realidad de las mujeres.

La subvaloración y desconocimiento del cuidado no remunerado en la seguridad social se extiende al trabajo de cuidado remunerado, cuya figura más visible es, al menos en América Latina, el empleo doméstico. En las trabajadoras domésticas puede apreciarse claramente la interseccionalidad de las exclusiones y discriminaciones en diversos derechos, entre ellos, el de la seguridad social. Se trata, para empezar, de un nicho de empleo femenino; en estas trabajadoras hay una alta presencia de mujeres migrantes del campo, indígenas y afrodes-

cendientes. A pesar de ser una forma de empleo dependiente, criterio que vincula una relación de trabajo con la ley laboral, tradicionalmente ha sido discriminado por el derecho laboral y la seguridad social con regulaciones hasta hace muy poco de excepción, regímenes especiales y menos favorables que el resto del empleo asalariado, por tanto, discriminatorios.

Afortunadamente, ya se aprecian cambios, y estos tienen que ver con la relación entre cuidado y seguridad social y con las interdependencias de estos derechos. Pero ¿cuál debiera ser el rol de la seguridad social con relación al cuidado? Identificamos al menos cuatro funciones que deben cumplir los sistemas de seguridad social para hacer efectivos tanto el derecho al cuidado como el derecho a la seguridad social:

- 1) Recompensar el tiempo de cuidado de trabajadores y trabajadoras, es decir, licencias de cuidado cubiertas por la seguridad social, que vayan más allá de las licencias por nacimiento de hijos e hijas, que abarquen otras etapas de la crianza e incluyan otros motivos de cuidado de familiares (padres y madres ancianos, por ejemplo).
- 2) Compensar el tiempo del cuidado no remunerado en las trayectorias de cotizaciones en los sistemas de jubilaciones y pensiones, es decir, integrar mecanismos o medidas que eviten lagunas en las historias previsionales, motivadas por retiros del empleo por razones de cuidado.⁹
- 3) Reparar las discriminaciones históricas y exclusiones de las cuidadoras remuneradas, es decir, de las trabajadoras domésticas, equiparando sus condiciones de acceso y prestaciones con el resto del empleo asalariado, que es el tema que se aborda a continuación.

⁹ Al respecto, véase Marco, Flavia, Giacometti, Claudia, Huertas, Tebelia y Pautassi, Laura, *Las medidas compensatorias de los cuidados no remunerados en los sistemas de seguridad social en Iberoamérica*, Madrid, OISS, 2019. Disponible en: «<https://oiss.org/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en-iberoamerica/>».

4) Entregar cobertura a personas dedicadas al cuidado no remunerado.

La relación entre cuidado y seguridad social es la de interdependencia de derechos: no puede ejercerse plenamente uno de ellos sin que este materializado el otro. Así, los sistemas de seguridad social deben cumplir al menos las cuatro funciones señaladas anteriormente para facilitar el ejercicio de ambos derechos.

En otras palabras, el cuidado es un derecho en sí mismo, pero su ejercicio, como el en caso de los otros derechos humanos, depende de una serie de condiciones de posibilidad que incluyen el ejercicio de otros derechos.¹⁰

Esto no quiere decir que el cuidado no pueda, en ciertos contextos, ser además un servicio prestado dentro de los sistemas de seguridad social o en conexión con los sistemas. Éste es precisamente el caso de los centros de cuidado infantil, aún llamados guarderías, en el caso mexicano, que son parte de las coberturas del sistema de seguridad social. Otro ejemplo es el cuidado provisto a personas mayores en el marco del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), en el caso argentino, prestado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Se trata, sin embargo, de casos excepcionales.

El que haya servicios de cuidado dentro de los sistemas de seguridad social no quiere decir que el cuidado sea en esencia una contingencia y menos aún un riesgo. Es un derecho que, al igual que la salud, puede estar cubierto por los sistemas de seguridad social, pero lo ideal es que el ejercicio de estos derechos no dependa de la calidad de trabajador o trabajadora de las personas, sino de su estatus ciudadano. Este status se refiere al vínculo jurídico de pertenencia de las personas con el Estado y no a la dimensión política de la ciudadanía, expresada en el derecho al voto y que está restringida bajo ciertas condiciones a las personas extranjeras y a todas las personas hasta cierta edad.

¹⁰ Pautassi, Laura, "En cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato", *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 68 (272-2), 2018, pp. 717-742.

La esencia del cuidado, es decir, lo que es común al fenómeno del cuidado, más allá de su carácter situado (dependiente del lugar, pertenencia étnica, raza, edad nivel de ingresos y, sobre todo, género), es su carácter de vital, de imprescindible para la vida, y, en tal sentido, es un derecho y un trabajo (vital, pero hasta hace poco invisible);¹¹ es decir, quien lo presta realiza un aporte vital, y para quien lo recibe hay bienestar, dignidad y posibilidades de funcionamiento cotidiano involucrados.

Si bien los estudios del cuidado tienen un lugar ganado en la academia a nivel global, y de la mano de los feminismos han incidido en las políticas públicas, hay áreas menos abordadas y en actual desarrollo. Este precisamente es el caso de la relación entre cuidado y seguridad social.

D. El acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social¹²

Las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas remuneradas han sido históricamente reguladas en regímenes laborales específicos o capítulos dentro de las legislaciones laborales que consignaban condiciones menos beneficiosas, supuestamente atendiendo a las características particulares de esta relación laboral que tiene como lugar de trabajo el hogar de la parte empleadora. Este tratamiento laboral diferenciado y, como se verá, discriminatorio también se verificaba en la seguridad social.

Sólo en los últimos 15 o 20 años hay una especie de campaña que intenta compensar estas desigualdades, a pesar de que siempre hubo actoras sociales

¹¹ Montaña, Sonia y Calderón, Coral (Coords.), *El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo*, Cuadernos de la CEPAL No. 94, Santiago de Chile, CEPAL, 2010.

¹² En la investigación original (Marco, Giacometti y Huertas, 2022) se pueden encontrar fichas para cada uno de los 22 países de la comunidad iberoamericana, que sistematiza información sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT; normativa laboral de directa incidencia en la seguridad social; normativa sobre seguridad social, incluyendo el detalle de los procedimientos y trámites de afiliación y cotización; cifras relevantes sobre empleo doméstico; políticas específicas en la materia desarrolladas para incrementar la cobertura efectiva; derechos colectivos y desafíos, para lo cual se recogen las recomendaciones del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR).

y, sobre todo, sindicatos y asociaciones de estas trabajadoras que lucharon por la igualdad. Esta campaña global se da con motivo de la preparación, negociación y, finalmente, aprobación del convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011) y de la recomendación 201 de la OIT. Se marca así un hito a partir del cual los países empiezan a reparar, en alguna medida, las históricas desigualdades. Sin embargo, como se verá a continuación, aún persisten importantes formas de discriminación.

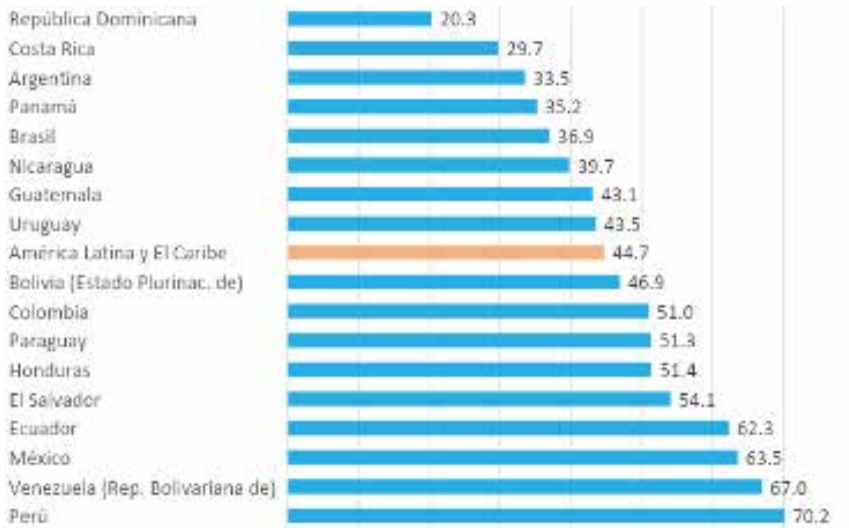
Para este análisis interesa conocer al menos las normas relativas a la propia definición legal de empleo doméstico; la jornada laboral; el salario, si los salarios mínimos rigen para el empleo doméstico; el alcance de la protección de la seguridad y salud en el trabajo; sobre la protección de la maternidad; la previsión para la vejez y las regulaciones sobre derechos colectivos del trabajo, además de otra normativa que puede tener diverso rango, incluyendo reglamentos, resoluciones ministeriales o simples circulares en algunos casos que establecen la forma de los trámites o incluso aspectos de tutela de derechos como las posibilidades de las inspecciones del trabajo.

I. Panorama iberoamericano

El empleo doméstico en América Latina sigue siendo femenino, con sueldos bajos y con baja o nula cobertura de seguridad social. En 2019, una de cada nueve mujeres ocupadas (11.3%) era trabajadora doméstica remunerada en la región, aunque con variaciones importantes entre países, pues la proporción de estas trabajadoras en el total del empleo femenino representa entre 17% (Argentina, Costa Rica) y 4.8% (Perú) del empleo femenino (OIT, Base de datos en línea).

En el gráfico 1 puede apreciarse que el empleo doméstico presenta desigualdades de ingresos importantes en relación con el resto del empleo asalariado.

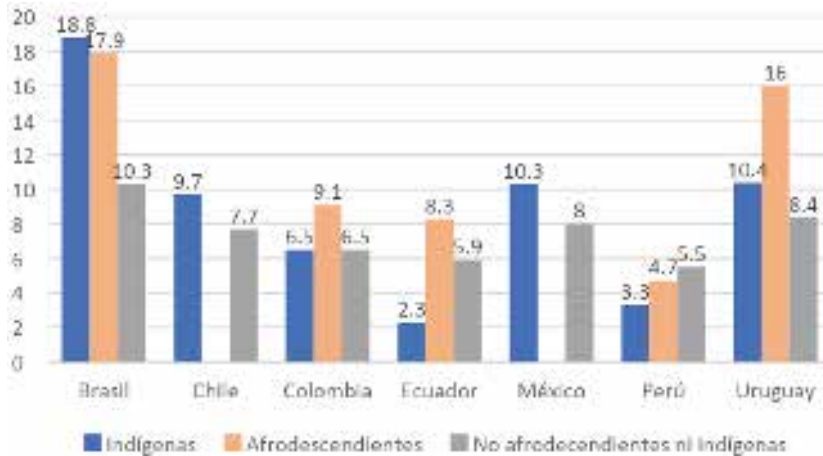
Gráfica 1. América Latina y el Caribe (20 países).
Ingreso promedio mensual de las trabajadoras domésticas
como porcentaje del salario promedio mensual del resto de personas
asalariadas, 2019



Fuente: OIT 2021.

Las personas empleadas en trabajo doméstico remunerado presentan algunas características sociodemográficas que son importantes tener en cuenta en el diseño de políticas orientadas a garantizar el derecho a la seguridad social. El trabajo doméstico remunerado es todavía un espacio en el que confluyen las desigualdades de género, clase, étnicas y raciales. En España, Portugal y Andorra es muy importante la presencia de migrantes internacionales.

Gráfica 2. Mujeres de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico remunerado según condición étnico racial, alrededor de 2018

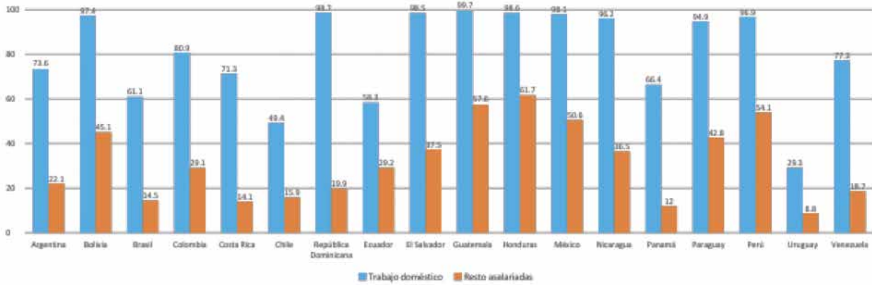


Fuente: Con base en CEPAL (2020), Panorama social.

Al mismo tiempo, hay cambios importantes en varios países que parecen estar marcando la tendencia que se espera en los años venideros para otros países de la región: disminuye el empleo de semana y jornada completa para dar paso al multiempleo, disminuye el empleo sin retiro y aumenta la edad promedio de las trabajadoras.

Todos los cambios mencionados representan desafíos adicionales para la seguridad social y para que las trabajadoras domésticas puedan ejercer este derecho, en circunstancias en las que, tal como puede apreciarse en el gráfico 3, la exclusión es masiva.

Gráfica 3. Trabajadoras domésticas remuneradas y trabajadoras asalariadas sin cobertura de seguridad social, alrededor de 2018



Fuente: CEPAL, 2020.

II. Causales de desigualdad

La desigualdad suele ser multicausal. Aquí interesan aquellas razones que constituyen discriminación y que, por tanto, afectan el derecho a la seguridad social de las trabajadoras domésticas con causales imputables a los Estados, por acción u omisión.

En otras palabras, la desigualdad que experimenta un segmento de trabajadoras obedece a causas sistémicas e interseccionales (patriarcado, racismo, falta de oportunidades), pero también a factores jurídicos y de política pública muy concretos. Hay elementos de la regulación de las condiciones de trabajo y de consagración de derechos y deberes de las partes de la relación laboral que condicionan o restringen el acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social. También hay regulaciones o ausencia que directamente determinan la falta de cobertura en ciertas áreas, como por ejemplo riesgos laborales o salud ocupacional.

Estos elementos de las regulaciones laborales condicionantes se convierten en discriminatorios cuando conllevan un trato diferencial y menos favorable, una exclusión o restricción.

Se entiende que la exclusión o limitada cobertura de las personas trabajadoras domésticas en la seguridad social (en sus distintos regímenes, para las distintas

contingencias) responden, generalmente, a alguna forma de discriminación y representan siempre un atentado a la igualdad.

Se considera que el abordaje desde la igualdad y no discriminación es especialmente clave para el empleo doméstico no sólo por la histórica discriminación que han padecido y por la intersección de variables de desigualdad que se presentan en muchos casos (mujeres, migrantes, rurales, indígenas, afrodescendientes, pobres), sino también porque las características del empleo (en hogares no empresas, trabajo sin relación con pares, empleadores individuales que no siempre se conciben como tales) hacen que sea necesario ubicarse entre la necesidad del tratamiento específico y el rechazo a la diferencia que genera desigualdad.

En efecto, los elementos que configuran la discriminación derivan de la definición de discriminación en la CEDAW, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos, que consignan las siguientes características de la discriminación:

- Exclusión.
- Distinción.
- Restricción.
- Preferencia a una población o grupo (que tiene como correlato trato menos favorable para otra categoría, grupo o población).

Según la CEDAW y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se entiende por discriminación directa aquel trato desigual y perjudicial establecido en función del sexo y que está explícitamente dispuesto en una política, norma, reglamento, disposición administrativa o de cualquier índole. Por su parte, la discriminación indirecta puede surgir de un tratamiento formalmente neutro pero que, por sus

efectos y sus resultados, resulte perjudicial para una población o parte de ella o menoscabe, anule o restrinja el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

La Observación General No. 20 de 2009 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), titulada “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”, interpreta el artículo 2, párrafo 2 del PIDESC, que establece el derecho a la no discriminación. El Comité recuerda en este instrumento que la igualdad y no discriminación son parte sustancial de las normas de derechos humanos, son fundantes. Asimismo, define la discriminación en conformidad con la CEDAW en los términos ya referidos. También especifica las definiciones de discriminación formal y sustantiva que corresponden a las transgresiones a la igualdad formal y real o sustantivas. Además, reitera las tipologías de discriminación directa e indirecta que ya fueran mencionadas (Comité de Derechos económicos, sociales y culturales, Observación General No. 20, párrafo 7 en Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2018).

1. Discriminación directa

En 15 de los 22 países considerados existe alguna forma de discriminación directa contra las trabajadoras domésticas remuneradas en relación con su derecho a la seguridad social. Estas formas de exclusión o de trato menos favorable en relación con el resto del empleo asalariado son diversas, y se dan en algunos casos en países que al mismo tiempo tienen o han tenido buenas prácticas tendientes a favorecer el acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social.

Las formas de discriminación directa identificadas son las siguientes.

- 1) Exclusión explícita total o de ciertos regímenes o contingencias.
 - a) Régimen de vejez, invalidez y muerte.
 - a) Riesgos laborales.

- b) Maternidad.
- c) Desempleo.
- 2) Regímenes voluntarios cuando para el resto de los empleos son obligatorios.
- 3) Exclusión por tiempo de trabajo o por trabajo ocasional.
- 4) Trato menos favorable en aspectos de directa incidencia:
 - a) Salario mínimo.
 - b) Regulaciones de la jornada.

1.1. Exclusión explícita

Si bien no hay una exclusión explícita total de las trabajadoras domésticas de la seguridad social, la suma de factores como exclusión parcial, es decir, de un régimen o contingencia, con otros como la voluntariedad para la integración deriva en una exclusión casi absoluta en algunos casos. De todas formas, lo más usual es la presencia de exclusiones explícitas parciales que configuran igualmente discriminación directa.

Régimen de vejez, invalidez y muerte

Hay varios casos en la región donde las trabajadoras domésticas están excluidas de los sistemas de jubilaciones y pensiones que cubren las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, y República Dominicana, donde las propias normas dejan fuera a esta población.

En algunos casos, llama la atención que a lo largo de los años ha habido distintas oportunidades propicias para abordar la integración de las personas domésticas a este régimen. Por ejemplo, en Bolivia, la Ley del Trabajo Asa-

lariado del Hogar data del año 2003, oportunidad en la que se estableció la obligatoriedad de inclusión de las personas trabajadoras domésticas a la Caja Nacional de Salud (que cubre enfermedad, maternidad y riesgos laborales), pero no en el régimen de invalidez, vejez y muerte. En 2010 se reforma el sistema de jubilaciones y pensiones y tampoco se realiza esta reparación. A casi 20 años de la legislación sobre empleo doméstico, en el año 2022, se reglamenta la inclusión de las personas trabajadoras domésticas a la Caja Nacional de Salud, haciendo recién posible este derecho, pero tampoco se aborda su inclusión en el sistema de jubilaciones y pensiones. Durante el año 2023 se debate una reforma a la ley de pensiones y tampoco se aborda la inclusión de las trabajadoras asalariadas del hogar.

Igualmente, en El Salvador ha habido diversos debates parlamentarios e iniciativas de reformas de pensiones en distintos momentos, sin que se trate la integración de estas personas trabajadoras.

Riesgos laborales

Esta contingencia suele ser parte de la cobertura del régimen de salud o puede ser cubierta con un seguro específico, pero hay muchos casos en que se excluye a las trabajadoras domésticas. Esta es la situación en Costa Rica, mientras que en Nicaragua procede una indemnización menor a la establecida para el resto del empleo y a cargo del empleador en caso de accidentes laborales.

En Panamá, las trabajadoras domésticas no tienen cobertura de riesgos laborales; el Seguro Nacional de Salud (SENASA) de República Dominicana que se ha venido promocionando para las personas trabajadoras domésticas tampoco cubre esta contingencia.

Maternidad/paternidad/parentalidad

En América Latina, las licencias por cuidado son insuficientes para todos los casos, pero lo son más aún para las trabajadoras domésticas remuneradas. La cobertura legal de las contingencias ligadas a la maternidad, paternidad,

o al cuidado en términos más amplios, suelen estar ligadas a los regímenes previsionales de salud. Esto no sucede en Honduras y República Dominicana, que no cubren la prestación durante estas licencias; en el último caso, ni siquiera se reconoce la licencia.

Desempleo

La exclusión explícita se da en Argentina respecto del seguro de desempleo vigente para el resto del empleo asalariado. Igualmente, en Brasil el seguro de desempleo tiene un trato menos favorable, pues para las trabajadoras domésticas se debe haber cotizado durante al menos 15 meses, en los últimos 24 meses; es un requisito mayor que el resto del empleo asalariado. En España esta exclusión se subsanó recientemente.

1.2. Regímenes voluntarios

La inclusión de las trabajadoras domésticas de manera voluntaria a la seguridad social o alguno de sus regímenes, mientras es obligatoria para la generalidad de los y las trabajadores, constituye un trato menos favorable que para el resto del empleo, una distinción sin asidero y, por tanto, una forma de discriminación directa. Es el caso de El Salvador, donde la inclusión al régimen de salud previsual que cubre enfermedades comunes, riesgos laborales y maternidad es voluntaria. De manera que las trabajadoras domésticas tienen virtualmente una exclusión total de la seguridad social en ese país, pues, tal como se apreció en párrafos anteriores, están excluidas del régimen de vejez, invalidez y muerte.

De similar manera, en República Dominicana, las trabajadoras domésticas no están excluidas del régimen general, pero su inclusión no es explícita y opera como voluntaria. Los esfuerzos se han concentrado en desarrollar acciones promocionales para su integración al Seguro Nacional de Salud (SENASA) bajo el régimen subsidiado. En este tipo de régimen las aportaciones económicas son realizadas en su totalidad por el Estado dominicano. Es decir, se trata de una cobertura asistencial no contributiva, y desde la Asociación de Trabajadoras del

Hogar (ATH) no se considera adecuada para el empleo doméstico, pues está pensada para quienes no acceden a mercado laboral. Además, no cubre riesgos profesionales ni maternidad, según se mencionó.

1.3. Exclusión por tiempo de trabajo o por trabajo ocasional

Esta forma de discriminación directa es bastante frecuente y deriva de la definición misma de empleo doméstico en muchos países, que excluye de la configuración de la relación laboral al trabajo eventual u ocasional, con lo que este contingente de personas trabajadoras domésticas queda, por extensión, excluido de la seguridad social. Es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Portugal y Venezuela. El problema además es que se confunde el trabajo ocasional, que, según el propio convenio 189, no se considera empleo doméstico, con el trabajo por horas, sea periódico o no, que no es a tiempo completo ni todos los días, pero que sí configura trabajo doméstico.

De manera similar, hay otros casos que determinan la configuración de la relación laboral a partir de cierto tiempo de trabajo a la semana, quienes no cumplen con ese tiempo mínimo quedan también excluidos de la seguridad social. Este es el caso de Brasil, donde la obligación de afiliación a la seguridad social se genera a partir de los tres días semanales, y de Colombia, donde el supuesto de trabajo por días no es obligatorio cuando las personas trabajadoras domésticas están afiliadas al Régimen Subsidiado (Piso de Protección Social) o resulten beneficiarias de esta prestación en el Régimen Contributivo. Algunos estudios muestran que en ocasiones se pide a las personas trabajadoras el soporte de afiliación al régimen subsidiado para evitar la inclusión al régimen contributivo.

Igualmente, en Guatemala el seguro de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cubre accidentes, maternidad y el programa Control Niño Sano¹³

¹³ Programa a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que ofrece controles pediátricos para infantes hijos e hijas de personas aseguradas hasta los 7 años de edad.

para quienes trabajan más de tres días a la semana, y no existe cobertura de enfermedades comunes, mientras que en Panamá están excluidas las trabajadoras domésticas que trabajan menos de tres días a la semana y que hacen trabajo ocasional.

1.4. Trato menos favorable en aspectos de directa incidencia

El trato menos favorable para el empleo doméstico continúa dándose en dos condiciones laborales básicas, que son el salario y la jornada. Estas tienen directa repercusión en la cuantía de las cotizaciones a la seguridad social. A pesar de que en estos campos del derecho laboral pueden apreciarse mejoras sustanciales en el tratamiento de las trabajadoras domésticas con relación a un par de décadas atrás, aún son varios los casos en que persiste discriminación en la materia.

Salario mínimo

Resulta incomprensible que en pleno siglo XXI aún existan tratos perjudiciales en las leyes y se discuta si cierto contingente de trabajadoras es o no merecedor de un salario mínimo que rige para todos los demás trabajadores. Son cada vez menos, pero aun estos tratos discriminatorios persisten. En Costa Rica se está realizando un trabajo de equiparación del salario mínimo de las personas trabajadoras domésticas, pero dado que se está efectuando en un proceso progresivo hasta 2034, mientras el mismo culmine hay un salario inferior para las trabajadoras domésticas. En El Salvador, Honduras y República Dominicana no rige el salario mínimo para estas personas, y en Panamá rige un salario mínimo para las trabajadoras domésticas por debajo del establecido para otras categorías de trabajadores.

En la actualidad, en República Dominicana este es el tema de demanda prioritaria de las organizaciones de trabajadoras domésticas, además con la claridad de la importancia del salario mínimo en sí mismo y de su repercusión directa sobre el acceso a la seguridad social, puesto que no se puede cotizar por debajo del salario mínimo.

Cuadro 1. Regulación del salario mínimo: Convenio 198

Artículo 11. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.

Artículo 12

1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento del trabajador interesado.

2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá disponer que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal, y que el valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y razonable.

Gráfica 4. Exigencia de salario mínimo nacional para empleo doméstico y posibilidad de pago en especie



Fuente: Marco, Giacometti y Huertas, 2022.

Regulaciones y duración de la jornada

La jornada laboral es de las primeras conquistas plasmadas en el derecho laboral, extendidas en distintos países, quizás sólo precedida en su difusión y antigüedad por las Leyes de la Silla y en muchos casos coincidente con éstas. Sin embargo, hasta hace poco esta conquista no regía para las trabajadoras domésticas y aún no lo hace en algunos casos.

Una jornada más extensa que para el resto del empleo asalariado o directamente no regulada es frecuente para el empleo doméstico sin retiro. La incidencia de esta situación en la seguridad social es que al reducir la posibilidad del cobro de horas extraordinarias, se reduce el salario y, en consecuencia, las cotizaciones.

Esta normativa discriminatoria se presenta en Bolivia, Colombia, Chile y Paraguay, donde las jornadas para las trabajadoras domésticas sin retiro es mayor o no está definida. En Portugal, además de esta situación, para quienes trabajan bajo la modalidad con retiro hay una jornada mayor que para el resto del empleo asalariado.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana no regulan la jornada de las trabajadoras domésticas en general ni para la modalidad con retiro ni para quienes residen en domicilio de la persona empleadora.

Cuadro 2. Regulación sobre la jornada laboral en el Convenio 189

Artículo 10.

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico.
2. El periodo de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas.
3. Los periodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional.

Gráfico 5. Regulación de la jornada laboral de trabajadoras domésticas remuneradas



Fuente: Marco, Giacometti y Huertas, 2022.

2. Discriminación indirecta

La discriminación indirecta se refiere a todo tratamiento formalmente neutro en las normas o políticas que, ya sea estableciendo una distinción o no, y aunque no tenga la finalidad de perjudicar a un grupo o persona, termine siendo perjudicial o discriminatorio por su objeto o resultado e incida de manera negativa en el ejercicio de sus derechos.

En el sentido expuesto es que operan en varios casos los requisitos y trámites de afiliación y cotización. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el trámite de uso de prestaciones de salud se debe primero ir a la Caja Nacional de Salud a “sacar ficha”, igual que todos los trabajadores y trabajadoras, llevando constancia de pago, que debe solicitarse a la persona empleadora. Esta constancia de cotización se convierte en una desventaja manifiesta para la

trabajadora doméstica. Este requisito podría haberse evitado y la Caja debió proporcionarlo y emitirlo desde su base de datos.

De manera similar, en Cuba el trámite de afiliación resulta engorroso y la consideración de las trabajadoras domésticas bajo la categoría ocupacional de cuenta propia puede redundar en su exclusión, lo que no puede constatare a ciencia cierta por la invisibilidad estadística del grupo ocupacional.

Igualmente, en Honduras, las dificultades de información para conocer el trámite de afiliación y cotización y en sí mismo este trámite se constituyen en una desventaja para las trabajadoras domésticas, puesto que en las condiciones actuales es muy difícil enterarse y comprender por ejemplo cuánto se debe cotizar. En Nicaragua, un aspecto a destacar es el mayor costo de la seguridad social para las personas que no alcanzan a percibir el salario mínimo, como el caso de las trabajadoras domésticas, esto supone un mayor costo de cotización, pues deben pagar un mayor porcentaje.

En España, desde 2012, en los casos de empleo por horas (multi empleo), la obligación de encuadramiento (afiliación o inscripción) y de alta es responsabilidad de la trabajadora doméstica, lo que además de resultar fácticamente más difícil tiene la consecuencia de que el sujeto jurídicamente responsable del encuadramiento lo es también del pago de las prestaciones y responsable legal de las mismas cuando se actualiza una contingencia. Además, el hecho de que sean las trabajadoras quienes deban pagar las cotizaciones, colaborando obligatoriamente como agentes de retención de la persona empleadora, en la práctica expone a las personas trabajadoras al conflicto y al impago de estas cotizaciones. De manera que el tratamiento para la afiliación, cotización y alta de las trabajadoras domésticas que trabajan menos de 60 horas mensuales para una misma persona empleadora resulta más oneroso para las personas trabajadoras y las expone a quedar sin cobertura ante el acontecimiento de contingencias. Esto sucede aun cuando la finalidad declarada de regular de esta forma los actos de encuadramiento fuese evitar una disminución de la cobertura de esta categoría ocupacional, configurando una forma de discriminación indirecta al haber resultado en incremento del riesgo y mayor onerosidad.

En Venezuela, en el reglamento de Seguridad Social se establece que la trabajadora que preste servicios a varios patronos deberá ser inscrita por aquél de quien devengue mayor salario. En el caso que percibiera igual remuneración, lo inscribirá aquella persona con quién tenga mayor antigüedad. No obstante, luego afirma que la trabajadora que preste servicios a varios patronos podrá exigir a dos o más de ellos que coticen hasta la concurrencia del límite establecido para cotizar (cinco salarios mínimos). Este procedimiento para el caso de las personas trabajadoras domésticas deviene en una situación de desventaja y no identifica un sujeto directamente responsable del encuadramiento.

Otra forma de discriminación indirecta es la existencia de pagos en especie, pues incide negativamente en la base imponible, en el monto de las cotizaciones. Según artículo 12 del Convenio 189 se debe privilegiar el pago en efectivo y limitar la posibilidad de realizar pagos en especie sólo a cuando se dan ciertas condiciones. En 15 de las 22 legislaciones analizadas se admite el pago parcial en especie.

E. Algunas notas sobre México

En muchos países, el camino seguido para la igualación de las condiciones y derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras domésticas con el resto del empleo asalariado ha sido la lucha social de las asociaciones y sindicatos de estas trabajadoras, en ocasiones con la colaboración de organismos internacionales, mientras que en otros casos las mejoras laborales son posteriores a la ratificación del convenio 189, de manera que aun habiendo demandas y trabajo desde la sociedad civil lo determinante ha sido la presión internacional, lo que no resta que detrás de la propia ratificación no haya habido también procesos de abogacía desde actores sociales. En cualquier caso, el convenio 189 marca un hito.

El camino seguido en el caso mexicano es similar, pero además la jurisprudencia y la Suprema Corte marcan la diferencia. Esta sentencia está también precedida de trabajo de actores sociales. El rol del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) fue determinante. A

pesar de que desde 2013 los Programas Nacionales de Igualdad de Oportunidades contemplaban el objetivo de la incorporación plena al Seguro Social del trabajo del hogar, el objetivo nunca se consiguió hasta la sentencia AD 9/2018 de la Corte Suprema de Justicia. El papel del sindicato y de las organizaciones de la sociedad civil fue determinante para cambiar el sentido de sus resoluciones, pues la Corte venía rechazando el reconocimiento de los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar.

El Estado mexicano ratificó el Convenio 189 en 2020, pero previamente ya había modificado el régimen laboral y de seguridad social del empleo doméstico en virtud de la sentencia de la Suprema Corte. De hecho, la ratificación del convenio deviene en una de las consecuencias de esta histórica sentencia.

Mediante la sentencia del 5 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Amparo Directo 9/2018 relacionado con el Amparo Directo 8/2019, declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, que excluía del régimen obligatorio de la Seguridad Social a las personas trabajadoras de hogar.

Con la mencionada reforma se derogó en el artículo 13 de la Ley de Seguro Social el carácter voluntario de la afiliación de las trabajadoras domésticas y se las incorporó como sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio, artículo 12 de la misma norma.

Al igual que otras relaciones laborales, las correspondientes al empleo doméstico están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, y este capítulo experimenta una modificación con el Decreto contenido en el Diario Oficial DOF 02-07-2019, que cambia el título Sexto, capítulo XIII, PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR, artículos 331 a 343, al igual que la Ley de Seguro Social, que es también reformada por el citado decreto.

La mencionada sentencia emana como resultado de un amparo interpuesto contra un laudo arbitral dictado en un juicio laboral y dictamina que el hecho de que la parte empleadora careciera de obligación jurídica de inscribir

a las trabajadoras domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social constituía un trato discriminatorio proscrito por el artículo 1 constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social tutelado por el artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal.

La sentencia, además, encargó al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) implementar una prueba piloto para el aseguramiento obligatorio que entró en vigor, en su primera fase, en abril de 2019 y posteriormente una segunda fase en julio de 2020.

Una vez puesta en marcha la prueba piloto por el IMSS, los sindicatos y entidades defensoras de derechos han realizado valiosas aportaciones que han motivado cambios importantes en la implementación de sus dos fases, formando parte del “Grupo de trabajo intersecretarial y de organizaciones de la sociedad civil sobre trabajo del hogar”. Este grupo cuenta con representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STYFE), organizaciones de la sociedad civil, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y Agencias de Naciones Unidas (ONU-Mujeres y la OIT). Las organizaciones de la sociedad civil focalizadas en este trabajo que participaron activamente en las campañas incluyen al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), NOSOTRX y Hogar Justo hogar. Por último, el SINACTRAHO ha participado en el proceso legislativo para la modificación de la Ley de Seguro Social haciendo llegar sus propuestas de reforma al dictamen del proyecto de Ley.

Tras la sentencia y con la consecuente modificación de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y la ratificación del convenio 189 OIT, queda el desafío de transformar un programa en un componente consolidado de un sistema de seguridad social.

I. Un repaso de las condiciones laborales y de seguridad social

La Ley Federal del Trabajo contiene una amplia regulación que define a la persona trabajadora del hogar, la relación laboral que se establece y los tipos de empleo doméstico (con residencia en el domicilio de la persona empleadora o de planta, sin residencia o de entrada por salida o para diferentes personas empleadoras sin residencia en el domicilio de ninguna de ellas. Artículo 331, LFT). Esta definición no es ociosa y resulta de utilidad para la aplicación normativa.

Se excluye a quienes realicen trabajo del hogar “de forma ocasional o esporádica” y a quienes presten servicios de aseo, asistencia y atención a clientes en establecimientos de restauración, hospedaje, sanitarios y análogos. Esta excepción, si bien tiene asidero, puede resultar en exclusión si no está sujeta a una correcta interpretación. Es así que en otros casos “esporádica” se ha interpretado como no fija o regular, mientras que puede haber prestaciones laborales periódicas que se ciñen a otras prescripciones de los regímenes laborales y de seguridad social. También aquí la sentencia es de suma utilidad, pues explicita la realidad del multiempleo (que al no estar explicitado puede confundirse con trabajo esporádico cuando, por ejemplo, implica unas pocas horas a la semana concentradas en un día no fijo).

En la legislación mexicana, además, existe la obligatoriedad de contrato escrito, otro elemento que contribuye a la exigibilidad de derechos. Su contenido mínimo está regulado en la LFT (art. 331) y existe un modelo de contrato elaborado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social accesible en la web del Gobierno de México.¹⁴ El SINACTRAHO tiene también en su sitio web su propio modelo de contrato colectivo (entre personas empleadoras y trabajadoras afiliadas a esta organización sindical), de planta y de entrada por salida y las dos modalidades de contratos individuales.¹⁵

¹⁴ Disponible en: «<https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-contrato-de-trabajo-del-hogar>».

¹⁵ Disponible en: «<https://hogarjustohogar.org/contratos/>».

Por otra parte, la fijación de salarios mínimos se realiza por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, diferenciando dos territorios: Zona Libre de la Frontera Norte y resto del país. Siempre considerando esta división territorial, se fijan un salario mínimo general y 61 salarios mínimos, en profesiones y oficios diferentes entre los que se encuentra ésta, todos ellos resultan superiores al salario mínimo general. No obstante, salvo lo que expresamente se pacte, la retribución comprende, además del pago en efectivo, el valor de los alimentos y habitación que se estimarán equivalentes al 50% del salario abonado en efectivo (art. 334 LFT).

La jornada laboral está regulada en iguales condiciones con el resto de las personas trabajadoras, es decir, la jornada máxima diaria es de ocho horas diurna, siete nocturna y siete y media la mixta. Sólo hay una regulación diferenciada en cuanto a los descansos. Para quienes trabajan en planta se establece un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas; un descanso mínimo diario entre jornadas matutinas y vespertinas de tres horas y un límite a la jornada diurna (la que va de las 6:00 a las 20:00h), que no puede pasar de ocho horas diarias, todos los excesos se consideran horas extraordinarias (art. 333 LFT). Para todas las personas trabajadoras del hogar se establece un descanso semanal de día y medio, preferiblemente entre sábado y domingo. Por acuerdo de las partes se pueden acumular los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse un día completo a la semana (artículo 336 LFT).

Asimismo, licencia de maternidad es la misma que para el resto del trabajo dependiente: seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, con una asignación por maternidad a cargo de la seguridad social en dinero del 100% del último salario diario cotizado (artículo 170 LFT).

En materia de inspección de trabajo, si bien la LFT no contiene facultades expresas de entrada en los domicilios particulares, sí contiene un mandato de prestar especial atención a las personas trabajadoras del hogar migrantes, que pertenezcan a grupos vulnerables y menores de dieciocho años (artículo 542 LFT). El artículo 15.V de la Ley del Seguro Social establece como obligación de los patronos permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto.

En cuanto a la seguridad social, como se dijo, desde la reforma resultante de la sentencia, las trabajadoras domésticas quedarían incluidas en Seguro de Invalidez y Vida, que da lugar a pensión en caso de invalidez para la asegurada y para los beneficiarios legales de ésta; Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Seguro de Riesgos de Trabajo, que puede dar lugar a las correspondientes pensiones; Seguro de Enfermedades y Maternidad, con prestaciones de asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para la persona trabajadora y su familia y prestaciones en dinero durante las licencias por maternidad e Incapacidades por enfermedad común. Se incluye también el Seguro de Guarderías y prestaciones sociales.

El trámite de afiliación y aportación, como consecuencia de los hallazgos y los compromisos adquiridos en la prueba piloto, es relativamente fácil. Tanto en los casos de afiliación a tiempo completo como en los de multiempleo, el sujeto responsable es siempre la persona empleadora. El IMSS cuenta con un micrositio dedicado exclusivamente al aseguramiento de este grupo laboral, que incluye una descripción de sus beneficios y de las personas beneficiarias, un simulador de cuotas, un tutorial para el registro de las personas trabajadoras en el sistema del instituto, una sección de preguntas frecuentes y los canales de contacto como servicio de ayuda.

La sentencia AD 9-2018 obliga a IMSS a ver situaciones de multiempleo, especificidad necesaria al tipo de empleo, es decir, diferencias razonables que no constituyan trato menos favorable sino que más bien brinden condiciones de posibilidad para el ejercicio del derecho a la seguridad social en condiciones de igualdad.

En el procedimiento vigente, el pago de las cotizaciones debe efectuarse por cada empleador de acuerdo con el salario diario y los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar y el aseguramiento se podrá realizar por día, mes, bimestre, semestre o año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo, siempre y cuando se entere al menos el monto de las cuotas obrero patronales equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado mensual de la Ciudad de México. Este último

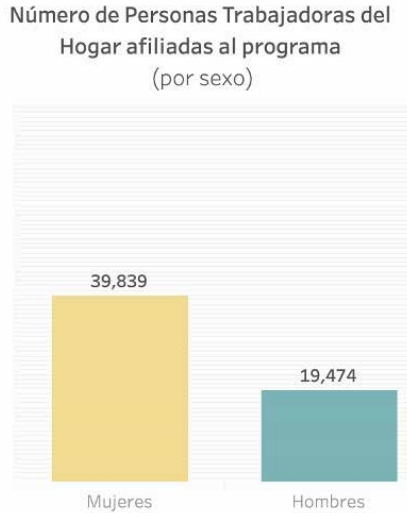
factor puede constituirse en una causa de desprotección, por lo que resulta recomendable darle seguimiento.

II. Los resultados recientes

Según la OIT, hasta 2019 había un total de 2,374,731 personas trabajadoras domésticas. Datos más recientes del registro de la ONG Hogar Justo Hogar¹⁶ dicen que había 2,480,466 en 2023, de las cuales, las mujeres constituían 91.1%, y este porcentaje representa 11% de del total de mujeres ocupadas en el país.

Hasta mayo de 2023, la afiliación del empleo doméstico rondaba las 60,000 personas, tal como se aprecia en la gráfica 6.

Gráfica 6. Afiliación al Programa de Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar Mayo 2023



Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social. Disponible en: <http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/datos-estadisticas>.

¹⁶ Disponible en: «<https://hogarjustohogar.org/>».

III. La igualdad en la seguridad social para la Suprema Corte

La sentencia AD 09/2018 hace una interpretación de la igualdad en la seguridad social consistente con el derecho internacional de los derechos humanos. La sentencia recoge definiciones planteadas por el amparo que le da origen, tales como igualdad formal y real, que han sido vitales para mostrar la discriminación contra las mujeres y que se emparentan con las definiciones de discriminación directa e indirecta referidas en el primer apartado de este documento.

La Corte es clara al mencionar que “al excluir del régimen obligatorio del Seguro Social, a las trabajadoras del hogar, resulta discriminatorio y violatorio del derecho humano a la seguridad social” (sentencia AD 9/2018, p. 46). La sentencia todo el tiempo asume la igualdad como consustancial al derecho a la seguridad social. En otras palabras, la seguridad social en condiciones igualitarias.

De igual manera, en tanto derecho humano, la seguridad social representa obligaciones para el Estado mexicano que debe asumir conforme a ciertas pautas que la Corte menciona, y, quizás lo más interesante, es que se asume como garante del derecho, en tanto parte del Estado, y ordena a la autoridad administrativa actuar en el mismo sentido, es decir, le dice al IMSS que está obligado a garantizar este derecho.

En el sentido expuesto, la sentencia asume el Estado garante, al sostener que

esta Corte Constitucional, al apreciar la existencia de normas discriminatorias que afectan la dignidad de un sector vulnerable, como lo son las trabajadoras del hogar, se encuentra obligado a emitir directrices que orienten a las autoridades estatales competentes, respecto a la necesidad y el deber que tienen de cumplimentar, de manera efectiva, con la protección y goce del derecho humano a la seguridad social de las trabajadoras domésticas. [...] las autoridades estatales cuya competencia se vincula con el otorgamiento de una cobertura adecuada, disponible, accesible y suficiente de seguridad social de las

trabajadoras del hogar, deban a su vez, emprender las medidas necesarias para modificar, estructuralmente, las normas y políticas públicas que atañen a la seguridad social de ese sector altamente vulnerable, a fin de que el Estado mexicano pueda cumplimentar con los débitos relacionados con el pleno goce de tal derecho humano (sentencia AD 9/2018, pp. 47 y 49).

La sentencia aclara también que este deber estatal abarca el de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Otro aspecto importante es que la Corte aclara que la inclusión de las trabajadoras domésticas al régimen obligatorio de seguridad social debe hacerse en condiciones no menos favorables que las del resto del trabajo dependiente y, por lo tanto, abarcar riesgos de trabajo; enfermedades; maternidad; guarderías y prestaciones sociales; invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero tomando en cuenta las particularidades del empleo doméstico, especialmente porque se trata de un segmento de difícil cobertura, explicitando entre las dificultades de cobertura el multiempleo y la irregularidad de ingresos.

Por lo expuesto, la sentencia da al IMSS una serie de requisitos o pautas, tales como que el sistema debe ser de fácil acceso para las partes empleadoras; viable financieramente; incentivar a las partes; por tanto, exime a empleadores de su registro en la Administración Tributaria; considerar un salario base cotizable específico (este tema es materia de debate en otros países y no hay una recomendación uniforme en la materia) y, por supuesto, obligatorio.

Precisamente, a poco de entrar en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) por la cual las personas empleadoras están obligadas a inscribir a las trabajadoras domésticas en el IMSS, el SINACTRAHO interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial en contra del decreto de reforma por estar el

aseguramiento ligado a cotizar sobre un salario mínimo, lo que en la práctica resulta en exclusión de parte importante de estas trabajadoras.

Otro desafío a enfrentar por la institucionalidad estatal es el tema de los incumplimientos de la ley, para los cuales aplican las mismas sanciones que para el resto del empleo asalariado, pero que en este caso representan un seguimiento más complejo y que además de sancionar la falta de afiliación, la falta de notificación de cambios en el salario o la entrega de información falsa deberán sancionar las lagunas previsionales o incumplimientos en las cotizaciones.

F. Conclusiones y propuestas

Los Estados, como garantes principales de los derechos, deben diseñar, implementar y monitorear políticas integrales tendientes a efectivizar los derechos humanos. Estas políticas deben contemplar los estándares de cumplimiento de los derechos humanos: 1) el derecho a la igualdad y no discriminación; 2) contenido mínimo de los derechos y universalidad; 3) utilización al máximo de los recursos disponibles; 4) progresividad y no regresividad; 5) acceso a la justicia y mecanismos de reclamo; 6) producción de información y acceso a la información pública; 7) participación de los sectores receptores en el diseño de las políticas públicas.¹⁷

Teniendo esto presente se plantean los siguientes desafíos y propuestas.

I. Generar una cultura previsional

La cultura previsional es un tema escasamente documentado; tiene que ver con la tradición de estados de bienestar, con la conciencia de derechos y la confianza en el Estado, que a su vez está relacionada con la gobernanza institucional. Los países pioneros en seguridad social son también los que

¹⁷ Pautassi, Laura, "Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición", en Abramovich, Victor, y Pautassi, Laura (compiladores), *La medición de las políticas sociales*, Buenos Aires, Del Puerto Editores, 2010.

tienen mejores cifras de cobertura de las personas trabajadoras en general y también de las personas trabajadoras domésticas. La tradición opera en favor de una cultura previsional, pero también lo hace la gobernanza institucional y la confianza de la población en los sistemas.

Si bien no hay evidencias del peso específico de este factor en la escasa cobertura de las trabajadoras domésticas en particular, los estudios de caso sugieren que juegan un papel importante y que, por tanto, la cultura previsional y la gobernanza institucional son desafíos interdependientes necesarios de abordar.

II. Cambios normativos e institucionales

Hay importantes avances en la ratificación del Convenio 189 en Iberoamérica y en las modificaciones legales producidas como consecuencia, pero algunos países, sobre todo de Centroamérica, deben avanzar en el plano normativo para adecuar las regulaciones actuales a lo establecido en el Convenio, sobre todo para:

- Asegurar una definición amplia de trabajo doméstico.
- Obligatoriedad del contrato por escrito y el registro de las obligaciones, que luego condiciona el acceso a la justicia.
- Avanzar en materia de igualdad de la jornada laboral, sobre todo en la modalidad de empleo sin retiro.
- Reducir el pago de salario en pago en especie y, en lo posible, no admitirlo, pues tiene efectos negativos en el monto cotizante.
- Asegurar el acceso a la información sobre los derechos laborales y sobre riesgos laborales y salud ocupacional.

Asimismo, se identificó la necesidad de abordar en todos los países políticas de seguridad y salud en el trabajo que contemplen los riesgos específicos del

trabajo doméstico y establezcan medidas eficaces para prevenirlos y proteger a las personas que se desempeñan en este sector.

Algunos países aún deben avanzar en el plano normativo para garantizar el derecho. En este sentido, es imprescindible establecer la obligatoriedad en la afiliación de las personas trabajadoras domésticas a las distintas ramas de la seguridad social en igualdad de condiciones que el resto del empleo asalariado.

Como es sabido, las reformas legales no logran por sí solas mejorar las condiciones laborales y formalizar el trabajo doméstico. Son necesarias, pero insuficientes y requieren ir acompañadas de diseños institucionales que contemplen las particularidades del trabajo doméstico. La implementación de acciones para incentivar la afiliación del trabajo a tiempo parcial y con multiempleo son opciones para avanzar en esta línea.

III. Procedimientos ágiles y trámites amigables

En directa relación con lo anterior, es recomendable que los procedimientos de afiliación y cotización sean amigables para personas empleadoras y trabajadoras, eliminar los requisitos innecesarios, centralizar los trámites y recaudaciones y establecer mecanismos de ayuda que realmente hagan la diferencia. Estas medidas se han puesto en práctica en algunos países de la región y se ha demostrado su eficacia.

La práctica ha mostrado también que el avance en la generación de sistemas de encuadramiento y pago es importante, pero es preciso tener en cuenta las características de la población que las utilizará. Empezar campañas de capacitación, diseño de sistemas de ayuda y el uso de grupos focales para identificar el mejor diseño de los mismos pueden ser de utilidad para fortalecerlos.

IV. Inspección laboral y campañas de creación de conciencia

Los cambios legales deben ir acompañados de acciones de inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa, junto con campañas participativas

que difundan derechos y obligaciones en el trabajo doméstico, y que además estén orientadas a cambiar patrones socioculturales de desvalorización del trabajo doméstico.

En este sentido, la experiencia muestra el efecto virtuoso de aunar esfuerzos en cambios legales, procedimentales e institucionales, junto con capacitaciones a cuerpo inspectivo seguidas de campañas de inspección de oficio (no sólo a denuncia de parte) y acciones en los medios de comunicación dando a conocer derechos, obligaciones, cambios legales y nuevas facilidades al respecto.

En efecto, las acciones para la divulgación de información acerca de los derechos de las personas trabajadoras domésticas son de particular importancia para dar a conocer los cambios en la legislación y para sensibilizar a la población. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se realizan de forma puntual o aislada. En este sentido, deben planificarse estrategias de comunicación a corto y mediano plazo, considerando diferentes medios de comunicación, alcanzando a públicos diversos e involucrando a diversos actores institucionales y de la sociedad civil. Es preciso que las campañas contemplen las heterogeneidades del trabajo doméstico y las desigualdades a nivel regional.

V. Mejorar la situación de las personas trabajadoras migrantes

Una mención especial merece la situación de las personas trabajadoras migrantes y los desafíos que implica su sobrerrepresentación en el empleo doméstico, que da cuenta de una manifestación más de la interseccionalidad de la desigualdad.

Es preciso que se avance en acuerdos multilaterales o bilaterales de seguridad social para asegurar la transferibilidad de los derechos y las prestaciones a las personas migrantes, de manera de hacer más atractivo el ingreso a la seguridad social. En este sentido, actúa, por ejemplo, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que ha beneficiado a personas trabajadoras migrantes de 12 países de la región.

VI. Fomentar el diálogo social

Generar las condiciones adecuadas para el diálogo social es un aspecto pendiente en casi todos los países de la región. Tan sólo en Uruguay y Argentina existen las condiciones para la negociación colectiva en este sector. Por ello, la incidencia política desde las organizaciones de personas trabajadoras domésticas y sus aliados ha sido fundamental y posiblemente lo seguirá siendo.

VII. Generación y difusión de información estadística

La carencia de datos de cobertura efectiva es una falencia mayoritaria, en circunstancias en que la visibilidad estadística de un fenómeno o sujeto es reflejo de la importancia social y política que se le atribuye. Es preciso tener en cuenta que los sistemas estadísticos, como otras políticas del Estado, no son neutros y, por lo tanto, reflejan los patrones culturales, económicos y sociales, así como también prioridades.

Los sistemas de información que genere el Estado son centrales en la definición y monitoreo de las políticas con enfoque de derechos y deberían permitir medir las desigualdades en el tiempo. Esto no se observa en los datos que en general se publican oficialmente sobre trabajo doméstico y seguridad social.

Desde una perspectiva de derechos, el deber de producir información no se limita al insumo necesario para el diseño de políticas. La producción y difusión de información, como obligación de las políticas públicas, también debe atender a la necesidad de rendir cuentas y generar una base de conocimiento en la sociedad que permita la participación política.

Los datos registrales de seguridad social, cuando se presentan, lo hacen de manera agregada, indicando el total de cotizantes, pero sería importante que pudiesen avanzar en la presentación de datos desagregados por tiempo de trabajo. También sería de interés que presenten datos para analizar cuántos de los cotizantes lo hacen en condición de pluriempleo. Además, es frecuente que se entreguen y publiquen datos de totales de afiliación

en números absolutos, cuando es recomendable poner a disposición de la sociedad civil datos de cobertura, es decir, proporciones.

VIII. A manera de cierre

Para el caso mexicano, las cifras de implementación son alentadoras, aun cuando luego de la subida inicial parece haber un estancamiento. De todas formas, la dificultad de realizar políticas públicas en un territorio que presenta mucha diversidad, en cuanto a las poblaciones a las que hay que llegar (urbanas, rurales, población migrante, indígenas) y sus distintos niveles de acceso a las herramientas online, posiblemente requiere medidas diferenciadas a cada tipo de población.

Durante las dos fases piloto, la coordinación entre las distintas instituciones implicadas ha sido una de sus fortalezas. En adelante será necesario darle continuidad, mantenerla y sostenerla en el tiempo, utilizando los espacios de participación y de diálogo social que se han creado.

Cabe revisar si el pago anticipado de las cotizaciones a que está obligada la parte empleadora, desde el segundo mes posterior al registro, no actúa como un desincentivo o una complicación.

Asimismo, habrá que evaluar las alternativas para compatibilizar la posibilidad de afiliación multiempleo, ya existente en la legislación, con la cotización multiempleo, lo que implica revisar los mínimos cotizables en consonancia con el amparo recientemente interpuesto por el SINACTRAHO.

Por último, se retoman algunas de recomendaciones de Picado e Irra (2020), en su análisis del programa piloto para incluir a las trabajadoras domésticas remuneradas en el IMSS:

- Considerar la posibilidad de reducir los montos de las cotizaciones en los primeros años de implantación del seguro obligatorio como medida promocional.

- Garantizar el acceso efectivo a la cobertura en los casos de incumplimiento de las personas empleadoras.
- Diversificar las estrategias de información, educación y sensibilización.
- Desarrollar modelos de inspección y fiscalización basados en la información y la construcción y cruzado de bases de datos.
- Articular acciones e iniciativas con múltiples actores.

G. Bibliografía

Bensusan, Graciela, *Perfil del trabajo doméstico remunerado en México*. Ciudad de México, OIT y Nacional Monte de Piedad, 2019.

Cecchini, Simone y Rico, María Nieves, “El enfoque de derechos en la protección social”, en *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*, en Cecchini, Simón, Filgueira, Fernando, Martínez, Rodrigo y Rossel, Cecilia (editores), Santiago de Chile, CEPAL, 2015 (LC/L G.2644-P).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Panorama Social de América Latina 2020*. Santiago de Chile, CEPAL, 2020

Lexartza, Larraitz; Chaves, María José y Carcedo, Ana, *Equidad laboral para las trabajadoras domésticas en América Latina en políticas de formalización en América Latina: avances y desafíos*, Lima, OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FORLAC, 2018.

Marco Navarro, Flavia, Giacometti, Claudia, Huertas, Tebelia y Pautassi, Laura, *Las medidas compensatorias de los cuidados no remunerados en los sistemas de seguridad social en Iberoamérica*, Madrid, OISS, 2019. Disponible en «oiss.org/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en-iberoamerica».

Marco Navarro, Flavia, *La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género en América Latina*, Serie Asuntos de Género, No. 139, Santiago de Chile, CEPAL, 2016.

- Marco Navarro, Flavia, “Rasgos generales de los sistemas previsionales de capitalización individual y de sus contextos laborales y demográficos”, en Marco, Flavia (coord.), *Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género*. Cuadernos de la Cepal No. 90, Santiago de Chile, CEPAL, 2004, pp. 31-58.
- Montaño, Sonia y Calderón, Coral (Coords.), *El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo*, Cuadernos de la CEPAL No. 94, Santiago de Chile, CEPAL, 2010.
- ONU Mujeres, OIT y CEPAL, *Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19*, 2020.
- OIT, *El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a 10 años del Convenio núm. 189*, Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2021.
- OIT, “Trabajo del hogar y trabajo decente en América Latina: Buenas prácticas y aprendizajes para el caso mexicano”. Oficina de País de la OIT para México y Cuba, México, 2019.
- Organización de Estados Americanos, *Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador*, Segunda Edición, 2015.
- Organización Internacional del Trabajo OIT, *Panorama Laboral 2015 de América Latina y el Caribe*, 2015.
- Pautassi, Laura, “En cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 68(272-2), 2018, pp. 717-742.
- Pautassi, Laura, Giacometti, Claudia y Gherardi, Natalia, “Sistema previsional en Argentina y Equidad de Género. Situación actual (2003-2011) y perspectivas futuras”, *Serie Documento de Trabajo ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-ELA*, 2011.
- Pautassi, Laura, “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición”, en Abramovich, Victor, y Pautassi, Laura, (Compiladores), *La medición de las políticas sociales*, Buenos Aires, Del Puerto Editores, 2010.

Picado, Gustavo, *Doce recomendaciones para el programa de trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), OIT y Nacional Monte de Piedad*, 2019.

Picado, Gustavo e Irra Fernández, Ricardo, *La Prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social Estudio de resultados y recomendaciones para el régimen obligatorio*, 2020.

¿Tragedias privadas? El derecho familiar como seguro social*

Anne L. Alstott**

* Traducido al español por Ismael Martínez Torres. Publicado originalmente como Alstott, Anne L., "Private tragedies? Family law as social insurance" (octubre 20, 2009), *Harvard Law and Policy Review* 3, 2009.

** Profesora Manley O. Hudson en Harvard Law School. Agradezco a Janet Halley por sus útiles comentarios.

SUMARIO: A. Introducción; B. El caso *marriage wilson*: manutención conyugal y discapacidad; I. La tragedia: divorcio y discapacidad; II. La manutención conyugal como una forma de seguridad social; III. Reformas legales: el derecho familiar y más allá; C. EL CASO *BROWN VS. BROWN*: MANUTENCIÓN INFANTIL Y FAMILIAS MÚLTIPLES; I. La tragedia: divorcio y familias múltiples; II. Manutención infantil como una instancia de la seguridad social; III. Reforma legal: el derecho familiar y más allá; D. CONCLUSIÓN: DISRUPCIÓN FAMILIAR Y SEGURIDAD SOCIAL; E. BIBLIOGRAFÍA.

A. Introducción

El derecho familiar está repleto de tragedias privadas. Cada caso es un enfrentamiento de un miembro de la familia en contra de otro en una lucha de suma cero (necesariamente una parte gana y la otra pierde) por recursos. Los cónyuges pelean sobre bienes limitados, los padres chocan con respecto a la manutención de los hijos y los hijos luchan entre ellos por recursos cuando el ingreso de los padres está dividido entre múltiples familias. Las malas decisiones y la mala suerte, parece, precipitan la calamidad y hay poco que el derecho puede hacer cuando las familias se autodestruyen en medio del desempleo, la pobreza, las enfermedades mentales, las discapacidades, el abuso de sustancias, la violencia doméstica, el abuso infantil y otros problemas.¹

¹ Para varios ejemplos de estos problemas de derecho jurisprudencial, véase, por ejemplo, Areen Judith y Regan, Milton C. Jr., *Family Law*, 5a ed., 2006.

Por tradición jurídica, el derecho familiar forma parte del derecho privado: regula las relaciones entre individuos, en lugar de las relaciones entre individuos y el Estado.² Desde este punto de vista, el derecho familiar, como otras formas de derecho privado, existe principalmente para promover el orden en el ámbito privado. Desde esta perspectiva, el derecho familiar debería implementar las intenciones de los individuos —y no debería redistribuir los riesgos y los recursos de conformidad con algún ideal público—. Así, en tanto derecho privado, la misión principal del derecho familiar es resolver disputas entre los miembros de una familia cuando el orden en el ámbito privado se rompe. De conformidad con esto, las familias funcionales deberían tener poco que ver con el derecho, pues son capaces de lidiar con sus propios asuntos sin la supervisión del derecho. Las familias disfuncionales, en cambio, involucran al derecho en una tragedia inevitable. Una vez que los lazos afectivos se han desgastado y el orden en el ámbito privado ha fallado, los tribunales deben resolver los conflictos de la mejor manera que les sea posible y con mucha frecuencia cualquier decisión que tomen lastimará a una de las partes o a la otra.

Este ensayo sostiene que esta forma de entender el derecho familiar descansa en una distinción exagerada entre lo privado y lo público. El derecho familiar es más que sólo un mecanismo que sirve para implementar preferencias privadas y para resolver disputas cuando el orden en el ámbito privado se rompe. Más bien, el derecho privado forma parte de un sistema más amplio de derecho público —un sistema de seguridad social que distribuye los riesgos que implican algunos eventos en la vida de las personas, tales como las discapacidades, los rompimientos familiares, las enfermedades mentales,

² En general, véase Weinrib, Ernest J., *The Idea of Private Law*, 1995 (que describe al derecho privado como “conect[ando] dos partes particulares a través del fenómeno de la responsabilidad jurídica”). No todos los elementos del derecho que típicamente se enseñan en un curso de derecho familiar corresponden al “derecho privado” en este sentido: el derecho constitucional de los derechos reproductivos, por ejemplo, es derecho público. Pero el divorcio, la manutención, la distribución de bienes, y la manutención infantil —temas centrales que se enseñan en un curso introductorio estándar de derecho familiar— son típicamente considerados derecho privado, porque establecen los derechos jurídicos de los cónyuges.

el abuso de sustancias y la pobreza de los padres. El derecho familiar no sirve simplemente para recoger los platos rotos cuando los individuos toman malas decisiones o sufren de mala suerte. Más bien, el derecho crea reglas distributivas que ayudan a determinar qué decisiones son malas y cuál es la mala suerte (o de quién) que conduce a consecuencias ruinosas. Si adoptamos este punto de vista, entonces no son sólo las personas disfuncionales las que viven bajo el dominio del derecho: las familias exitosas florecen entre reglas jurídicas que protegen a algunas personas de los riesgos de la vida mientras que a otras las dejan vulnerables.

Puesto de otra manera, las normas de derecho familiar que establecen relaciones financieras y de responsabilidad civil entre los individuos constituyen una forma de seguridad social: las normas del derecho familiar complementan aquéllas de programas públicos orientados a las familias, tales como la seguridad social y la asistencia temporal a familias en estado de necesidad (TANF, ATFN, por sus siglas en inglés), las cuales abordan los riesgos de la vida incluyendo la pobreza, el desempleo y la discapacidad. Por ejemplo, el derecho familiar confiere un derecho legal al cuidado y al apoyo financiero con base en el matrimonio formalizado, la paternidad/maternidad biológica y adoptiva y ciertas formas de comportamiento reconocido y recompensado durante el matrimonio. La seguridad social en los Estados Unidos también adopta protecciones categóricas y, mientras que éstas varían a través de distintos programas, las distinciones pueden ser un reflejo del estatus marital formal, el historial de empleo pagado y el nivel de ingreso. Las categorías y sus consecuencias pueden ser diferentes en los dos regímenes, pero ambos sistemas de derecho aportan clasificaciones normativas que reconocen algunas relaciones (y no otras) y protegen en contra de algunos riesgos (y no otros). Más aún, ambos sistemas de derecho pueden entenderse como la distribución de riesgos *ex ante*, en lugar de simplemente encargarse de fallas que tienen lugar *ex post*.

Una diferencia aparente entre el ámbito obviamente público de la seguridad social y la supuesta esfera privada del derecho de familia se encuentra en el poder redistributivo de los dos tipos de derecho. El derecho familiar típica-

mente limita las obligaciones de sustento a una pequeña clase de personas con relaciones entre ellas: impone obligaciones matrimoniales sobre los cónyuges y deberes de sustento/alimentarias sobre los padres y madres o los hijos. Y el derecho de familia no tiene acceso a la potestad tributaria del Estado, sin importar qué tan grande sea la necesidad de uno de los cónyuges o de un hijo. Por el contrario, la seguridad social deliberadamente usa el poder del Estado para ejercer una redistribución amplia —que impone impuestos a los trabajadores, a quienes obtienen ingresos y a los consumidores, para el beneficio legal de terceras partes—.

Pero esta diferencia es también exagerada a menudo. Algunas normas de derecho familiar utilizan el poder del Estado para imponer obligaciones permanentes en personas que son de forma efectiva o literal desconocidos, que se piense que han, o que son activamente hostiles uno con otro. Pensemos en las obligaciones de sustento/alimenticias hacia los hijos de un padre separado o de un padrastro o madrastra divorciado o divorciada, las normas de responsabilidad filial que gravan a los hijos con el sustento de sus padres ancianos o la manutención impuesta en los cónyuges que han estado divorciados por largo tiempo. Un académico ha propuesto un plan de garantía de manutención infantil que combinaría los dos regímenes, expandiendo el mandato del derecho familiar de incluir una pretensión sobre fondos públicos en caso de ser necesario.³ Al mismo tiempo, algunos programas de seguridad social no redistribuyen recursos entre individuos. Éstos pueden simplemente extraer un pago por servicios, o regular la compra de ciertos bienes, o pueden crear una obligación interpersonal de un individuo hacia su propia persona en el futuro o su propia familia. Pensemos en las cuentas privadas que se han propuesto como un remplazo de la seguridad social o beneficios mandados como la licencia familiar, que puede reducir el salario de los trabajadores mismos.

³ Véase Garfinkel, Irwin, *Assuring Child Support*, 1994, pp. 45-50; para una discusión véanse las notas *infra* 54-58 y el texto que las acompaña.

En este ensayo, comienzo a integrar el derecho familiar y la seguridad social con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de ambos regímenes y de la relación entre ellos. Para hacer que la discusión sea concreta, considero dos casos —uno que involucra la manutención conyugal y la discapacidad y otro que comprende la manutención infantil para familias múltiples— y demuestro que éstos ilustran dos puntos de solapamiento entre el derecho familiar y la seguridad social. En primer lugar, ambos ejemplos ilustran la interdependencia de los derechos económicos en el derecho familiar y en la seguridad social. Ambos regímenes jurídicos hacen presunciones acerca del otro y sobre la existencia de la manutención económica y el cuidado familiar. Y los dos regímenes operan de manera conjunta para determinar quién sufre una carencia financiera cuando las familias se desintegran y cuando la discapacidad y la pobreza golpean.

En segundo lugar, ambos casos demuestran que una serie de cambios en el derecho familiar, en el derecho de la seguridad social o en otros elementos del derecho podría alterar la distribución de los riesgos de vida —y así la probabilidad y las consecuencias de tragedias aparentemente privadas. Por ejemplo, algunos investigadores han discutido si la manutención infantil debería ser impuesta a los padres en solitario o si debería compartirse con el Estado.⁴ Un análisis desde la perspectiva de la seguridad social desafía la distinción binaria (padre o madre/Estado) y abre nuevas posibilidades que van desde pequeños impuestos al salario sobre todos los miembros de la familia hasta la imposición de impuestos sobre las ganancias obtenidas por los hijos (como adultos).

Para estar seguros, en el presente, el derecho familiar y la seguridad social se hacen cargo de diferentes, incluso en ocasiones simultáneos, riesgos de vida. El derecho familiar regula interrupciones en lo que he llamado “vida afectiva” —el ámbito de la vida que incluye los lazos familiares formalizados del matrimonio y la paternidad/maternidad, así como relaciones emocionales menos

⁴ Esta es una pregunta vieja y todavía controvertida. Para una discusión sobre el debate y una contribución, véase Alstoot, Anne L., *No Exit*, 2004.

formales pero importantes como la cohabitación e incluso potencialmente la amistad—. ⁵ Por el contrario, la seguridad social se encarga de disrupciones en la vida laboral —incapacidad, desempleo, retiro y bajos salarios—. Podría parecer, entonces, que los dos cuerpos de derecho son lo suficientemente distintos como para ocupar categorías analíticas separadas.

Pero un propósito de este ensayo es desafiar la separación encarnada en el derecho actual entre las protecciones públicas, *ex ante*, de gran escala de la vida laboral y las supuestamente privadas protecciones, *ex post*, de menor escala de la vida afectiva. Puesto de otra forma, quiero mostrar como problemático el hecho de que la seguridad social convencional toma las disrupciones en el ámbito laboral —y solamente éstas— como su objeto. Los riesgos de la vida laboral son, de hecho, riesgos mayúsculos en una sociedad capitalista. Pero un compromiso con el derecho familiar ayuda a recordarnos que una serie más amplia de riesgos puede amenazar el bienestar de los adultos y el desarrollo de los niños. Las disrupciones a la vida afectiva también pueden amenazar la seguridad económica y el desarrollo individual: el divorcio, el abandono del padre o la madre y la disfunción de los padres, por ejemplo, pueden llevar a la calamidad de manera tan segura como el desempleo y la discapacidad.

Lo que quiero decir es, entonces, que una vez que entendemos a la seguridad social como el uso del derecho para abordar, de manera deliberada, los principales riesgos de la vida, entonces el enfoque que tienen los programas actuales para aminorar los riesgos del empleo remunerado comienza a parecer extrañamente estrecho. Un primer paso, que doy en este texto, es mostrar cómo el derecho de familia opera —a pesar de tener tradicionalmente la etiqueta de derecho privado— como una instancia de la seguridad social para

⁵ Para más literatura que recomienda poner atención a lo que he llamado “vida afectiva”, véase, por ejemplo, Huntington, Clare, “Repairing Family Law”, *Duke Law Journal*, vol. 57, 2008, pp. 101-175 (en donde se recomienda una integración más profunda de los modelos psicoanalíticos del desarrollo emocional en el derecho de familia a fin de reconocer la importancia de las relaciones emocionales fuera de los límites jurídicos formales) y Rosenbury, Laura A., “Friends With Benefits?”, *Michigan Law Review*, vol. 106, 2007, pp. 189-242 (en donde se sugiere que el derecho familiar debería reconocer las relaciones de cuidado más allá del matrimonio y relaciones similares al matrimonio).

la vida afectiva. Un segundo paso, que dejaré para un proyecto más grande, es preguntarnos si los programas públicos deben encargarse, de manera más explícita, de las consecuencias de los riesgos tradicionalmente cubiertos por el derecho familiar —riesgos propios del divorcio, el no matrimonio, la paternidad/maternidad y la infancia—.

¿Sería sensible, realizable, o deseable que el sistema de seguridad social convencional expandiera su misión para dar respuesta a disrupciones en la vida afectiva así como a disrupciones en la vida laboral? Un proyecto más extenso se encargaría de delinear en mayor detalle los elementos del derecho actual que aseguran la vida afectiva. La conclusión en este texto describe el alcance del proyecto en mayor detalle y reconoce la dificultad de las preguntas normativas y empíricas a las que dicho proyecto da lugar.

Este ensayo, y el proyecto más amplio del que forma parte, le deben mucho a la teoría feminista que conecta el bienestar social con el derecho de familia y que desafía las distinciones entre público y privado y entre trabajo y cuidado.⁶ Por ejemplo, numerosos investigadores (soy una de ellos) han recomendado reformar el esquema de bienestar social y los programas de seguridad social con el fin de mejorar la seguridad económica de los infantes y sus cuidadores.⁷ Este ensayo tiene por objetivo expandir el trabajo existente sobre el bienestar social, las familias y el género al sugerir cómo mapear de manera más completa las estructuras jurídicas que distribuyen una serie más amplia de riesgos vitales, incluyendo no sólo el trabajo de cuidados sino la discapacidad, el desempleo, la violencia doméstica, el abuso de sustancias y la pobreza.

⁶ Véanse, por ejemplo, Fineman, Martha Albertson, *The Neutered Mother, The Sexual Family*, 1995 (en donde que se argumenta que el Estado y la familia apoyan la dependencia inevitable); McClain, Linda C., *The Place of Families*, 2006 (en donde se considera cómo el Estado debería apoyar la vida familiar); Okin, Susan Moller *Justice, Gender, and The Family*, 1989 (donde se argumenta que la justicia requiere atención pública, y reforma, al ámbito supuestamente privado de la vida familiar) y Lester, Gillian, "A Defense of Paid Family Leave", *Harv. J. L. & Gender*, vol. 28, 2005, pp. 1-83 (donde se abordan propuestas con respecto a las regulaciones laborales para mejorar las condiciones de trabajo de los padres).

⁷ Véanse Alstott, *op. cit.*, pp. 171-204 (donde se recomiendan programas públicos nuevos para enfrentar la vulnerabilidad económica de los padres) y Fineman, *op. cit.*, pp. 230-33 (donde se recomienda manutención del Estado para madres).

En un sentido más amplio, este ensayo también profundiza la teoría del derecho familiar al desafiar la distinción público/privado y al situar a la familia en su contexto jurídico completo. Gracias a los esfuerzos de numerosos académicos, el derecho familiar comprende hoy el estudio del género, de la violencia doméstica, los derechos reproductivos y la regulación de la sexualidad —asuntos que van del derecho constitucional al derecho de responsabilidad civil, el derecho penal y más allá—. ⁸ Como esos académicos, mi objetivo es ubicar a las supuestamente tragedias privadas de la vida familiar en un contexto jurídico más amplio.

B. El caso *marriage wilson*: manutención conyugal y discapacidad

La manutención conyugal (*alimony*, en el sistema jurídico de Estados Unidos) ofrece a uno de los cónyuges divorciados una pretensión jurídica hacia la manutención económica continuada de parte del otro. Un caso en California, Estados Unidos, *In Re Marriage of Wilson*,⁹ ilustra la interrelación que existe entre la manutención conyugal y la seguridad social por discapacidad, y muestra cómo, al cambiar las reglas de derecho familiar, los derechos de seguridad social u otros regímenes jurídicos, se puede alterar la tragedia privada supuestamente de suma cero del matrimonio Wilson.

I. La tragedia: divorcio y discapacidad

Tom y Elma Wilson se casaron en 1976, cuando él tenía 36 y ella 38 años.¹⁰ Su matrimonio duró poco menos de seis años. Cuatro años después de casados, en 1980, Elma tuvo una caída y sufrió daño cerebral severo y déficit en el juicio social, el sentido común y la inteligencia social. Elma no fue capaz

⁸ Véase, por ejemplo, Areen, Judith, *Family Law*, 4ª. ed., 1999, pp. 136-180 (roles de género), pp. 291-325 y 1334-1343 (violencia doméstica), 1029-1056 (derechos reproductivos), 25-45 (identidad sexual).

⁹ *In re Marriage of Wilson*, 247 Cal. Rptr. 522 (Cal. Ct. App. 1988).

¹⁰ *Idem*, p. 524 (donde se hace notar que en 1986, cuando tuvo lugar la audiencia de manutención, Tom tenía 46 años y Elma, 48).

de volver a trabajar y los doctores predijeron que el daño sería permanente. Tom y Elma se divorciaron en 1982, y Tom pagaba a Elma una manutención mensual de 500 dólares. Junto con 436 dólares que recibía al mes por una pensión de seguridad social por discapacidad, Elma podía apenas llegar a fin de mes.

Pero después de pagar la manutención conyugal por más de cuatro años, Tom se cansó. Él demandó para dejar de pagar la manutención y Elma impugnó. Su disputa, *Wilson vs. Wilson*, ejemplifica el tipo de tragedia privada al que el derecho familiar enfrenta de manera rutinaria. El tribunal de primera instancia, y después el tribunal de apelaciones, se enfrentaron a un juego de suma cero. Liberar a Tom de su obligación de manutención dejaría a la discapacitada Elma en estado de necesidad y sin la capacidad de mantenerse a sí misma. Pero continuar la obligación de manutención de Tom limitaría su capacidad para tener un nuevo comienzo en la vida. (Nótese que en *Wilson* y en este ensayo, el término técnico “manutención conyugal” [*spousal support*] quiere decir legalmente mandado, pagos posteriores a la separación o posteriores al divorcio; el término no se refiere al apoyo económico ofrecido a un esposo/a en un matrimonio intacto).

De acuerdo con el tribunal de primera instancia, *Wilson* presentaba un conflicto entre dos líneas doctrinales del derecho familiar. Por un lado, el derecho trata al matrimonio como una obligación seria con consecuencias duraderas. Los cónyuges son considerados como parte de una comunidad económica, de modo que un (ex) cónyuge tiene una pretensión legítima en relación con un cónyuge próspero incluso después de un divorcio. De los ocho factores que debían ser ponderados en casos de manutención conyugal, de conformidad con la ley en California en aquel tiempo, seis implementaban este principio de necesidad: los factores daban peso a la discapacidad de Elma, su edad, sus posibilidades de conseguir empleo, y a la mayor cantidad de ingresos y bienes de Tom, y su estándar de vida superior.¹¹ Por otro lado, el tribunal señaló

¹¹ *Id.*, para una lista de factores.

que la ley permite la disolución del matrimonio,¹² e implícito en esa decisión debe haber un principio según el cual en algún momento las obligaciones conyugales cesan de modo que cada cónyuge pueda continuar con su vida.

El tribunal de primera instancia se preguntó “¿[e]n qué punto en el tiempo la obligación de asistir a la señora Wilson se convierte en una obligación de la sociedad distinta de la obligación que tiene el señor Wilson? Y resolvió que “es la obligación de la sociedad en este punto en el tiempo”.¹³ La corte de apelaciones encontró que el tribunal de primera instancia no había abusado de su discrecionalidad al ponderar los valores y resolver que “bajo estas circunstancias la obligación de asistir a Elma debe pasar de Tom a la sociedad”.¹⁴

El tribunal de apelaciones mencionó, de pasada, que Elma recibía 436 dólares al mes como pensión de “Seguridad Social”. La referencia, presumiblemente, es al Seguro de Incapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance [SSDI]), mismo que se paga a los trabajadores con un historial laboral sustantivo. En 1986, cuando el caso *Wilson* dio por terminada la obligación de manutención de Tom, el límite de pobreza federal para una persona era de 5,360 dólares al año.¹⁵ Con la manutención que Tom pagaba, Elma vivía modesta pero sosteniblemente al 200% de la línea de la pobreza oficial. Sin la manutención de Tom, los 436 dólares por mes (5,232 dólares por año) la dejarían por debajo de la línea oficial de pobreza, un estándar de vida que representa una espantosa carencia económica.¹⁶

¹² *Id.* Para otro caso que involucra manutención conyugal y discapacidad, véase *Marriage of Biderman*, 6 Cal. Rptr. 2d 791 (Cal. Ct. App. 1992) (en el que se sostiene la resolución del tribunal que concede manutención conyugal para un esposo con depresión clínica y desempleado).

¹³ *Wilson*, 247 Cal. Rptr. p. 524 (citando al tribunal de primera instancia).

¹⁴ *Id.* pp. 525-527.

¹⁵ Véase U.S. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVS., PRIOR HHS POVERTY GUIDELINES AND FEDERAL REGISTER REFERENCES, 1986, citando a 51 Fed. REG. 5105 (11 de febrero de 1986). Disponible en «<http://aspe.hhs.gov/poverty/figures-fed-reg.shtml>».

¹⁶ La medida oficial de pobreza es bien conocida por reflejar un cúmulo de errores analíticos y juicios normativos cuestionables. Elaborada en los inicios de la década de 1960 con datos limitados, la línea de la pobreza ha sido actualizada únicamente de conformidad con la inflación (y no de acuerdo con el crecimiento del ingreso nacional y los estándares de vida) desde entonces, con el resultado de que la línea de la pobreza hoy representa carencia económica extremadamente severa. Muchos científicos

Wilson es, hasta nuestros días, derecho válido, aunque su aplicación en casos particulares es incierta, dados los determinantes multifactoriales que se necesitan. Un caso subsecuente en California declinó entender a Wilson como el establecimiento de una política pública amplia en contra de la manutención conyugal a largo plazo.¹⁷ En ese caso, el tribunal de apelaciones rechazó la orden de un tribunal de primera instancia que terminaba la manutención conyugal para una mujer discapacitada funcional de 59 años después de un matrimonio de nueve años. El tribunal advirtió que la decisión tomada en Wilson debía ser considerada en el contexto específico del matrimonio en cuestión y requería una ponderación cuidadosa de todos los factores en cada caso.

El caso Wilson tiene lugar en un contexto de reformas jurídicas que buscaban proteger a las personas encargadas del hogar del riesgo de ser desplazadas. Estos cónyuges, típicamente esposas, pasaban años criando a sus hijos y subordinando sus carreras (si es que tenían) para asegurar que sus esposos pudieran trabajar tiempo completo y desarrollar sus propias carreras. Al divorciarse, estas mujeres, a menudo de mediana edad, se encontraban en una posición de desventaja en el mercado laboral, y a pesar de esto, en algún momento, la doctrina de la manutención conyugal les requería convertirse en autosuficientes de conformidad con la teoría de que la disolución del matrimonio deja a cada uno de los excónyuges la responsabilidad de subsistir únicamente de su capacidad para generar ingresos. En efecto la eliminación de la manutención conyugal permitió a los esposos retener la mayoría del valor de sus ingresos al tiempo que a las esposas las consignaba a vivir de sus propias ganancias —típicamente ubicándolas en un estándar de vida inferior al que tenían al estar casadas—. ¹⁸

sociales (aunque no todos) creen que la línea oficial de la pobreza es demasiado baja; ellos adoptan más bien una medida en el rango del 200% de pobreza con el fin de tener una mejor aproximación a la privación económica relativa al estándar de vida en los Estados Unidos actualmente. Véase Anne L. Alstott, "Why the EITC Doesn't Make Work Pay", *Colum J. L. & Soc., Probs.*, 43, 2009 (pp. 6-8, en archivo de la biblioteca de Harvard Law School).

¹⁷ *In re Marriage of Heistermann*, 286 Cal. Rptr. 127, 130, 133 (Cal. Ct. App. 1991).

¹⁸ Véase Krause, Harry D. y Meyer, David D., *Family Law in a Nutshell*, 5a. ed., 2007, pp. 297-98.

En respuesta al criticismo hecho por académicos, legisladores y otros, el derecho sobre manutención conyugal se ha desarrollado, aunque de manera desigual, para incorporar protecciones para las personas encargadas del hogar que han sido desplazadas. Podemos ver estas protecciones en el caso *Wilson*, en el que el tribunal reconoció las protecciones acordadas para matrimonios de mayor duración, aquellos con hijos y aquellos en los cuales uno de los cónyuges se sacrificó por el otro.

La ironía, por supuesto, es que el tribunal en *Wilson* no sólo decidió que estas protecciones eran inaplicables para Elma sino que también las usó para dar por terminada su manutención conyugal. Dibujando un contraste con la buena madre, casada por mucho tiempo, que se sacrifica a sí misma, que es a la que la ley protege, el tribunal de apelación describió al matrimonio *Wilson* como “un matrimonio sin hijos de corta duración”¹⁹ y se refirió a Elma como “una bartender de mediana edad con hijos adultos”.²⁰ En el enunciado siguiente, el tribunal hizo la implicación de que Elma hizo poco para acomodar las necesidades de Tom, una vez más dibujando un contraste implícito entre el caso de Elma y el de la ama de casa centrada en su familia que deja su trabajo: “El estilo de vida [de Elma] fue establecido [al tiempo del matrimonio y no cambió después de eso]”.²¹

De este modo, *Wilson* coloca preguntas complicadas acerca de la naturaleza del matrimonio: ¿Debería el derecho asumir que todos los matrimonios crean obligaciones solemnes que duran toda la vida?, ¿o debería el derecho, en efecto, reconocer una categoría inferior de matrimonio de compañía, marcado por la entrada en la mediana edad y la ausencia de hijos, y acomodado por el derecho a través de un conjunto de obligaciones fáciles de adquirir y fáciles de abandonar?

¹⁹ *Wilson*, 247 Cal. Rptr., p. 524.

²⁰ *Id.*, p. 526.

²¹ *Id.* El tribunal repite también en una nota al pie el alegato de Tom de que Elma cayó mientras se encontraba en un estado de delirio alcohólico y la respuesta bastante incoherente de Elma en el sentido de que tenía una corazonada, pero no una memoria específica, de que Tom hubiera estado involucrado en su caída. *Id.*, n. 1, p. 523.

A primera vista, *Wilson* representa una tragedia privada clásica. El derecho de manutención conyugal presenta ante el tribunal un juego de suma cero: el tribunal puede proteger a la necesitada Elma, pero sólo si se somete a Tom a una carga financiera de largo plazo que limitaría sus opciones de vida y le negaría, quizás, la capacidad de contraer un nuevo matrimonio.

Los tribunales, entonces, deben causar daño en una parte del conflicto o en la otra, y quizás por esa razón, la resolución tanto el tribunal de primera instancia como la de el tribunal de apelaciones adoptan un vocabulario que enfatiza las decisiones (riesgosas) de Elma y su mala suerte: ella es una “bartender de mediana edad” con hijos adultos cuyo padre no está presente. Su mala suerte —o quizás su “delirio de embriaguez”— la dejó con daño cerebral. Al mismo tiempo, los tribunales implícitamente tratan las (mejores) decisiones y suerte de Tom como privada y personalmente atribuibles. Elma no hizo sacrificios, dice el tribunal, para promover la carrera de Tom y tampoco tienen hijos juntos. Al final, los tribunales resuelven la tragedia privada apelando al derecho público. La obligación privada que Tom tiene con Elma, los tribunales deciden, ha llegado a su final, y entonces Elma debe convertirse en responsabilidad del Estado, en una carga pública.

Pero un vistazo más cercano al contexto jurídico de *Wilson* revela cómo las elecciones y suerte de Tom y Elma ocurrieron en medio de dos sistemas de seguridad social, la ley que regula el matrimonio y el programa de seguridad social. No siempre pensamos el matrimonio jurídico como una forma de seguridad social y, por supuesto, el matrimonio representa más que eso. Aun así, las obligaciones de apoyo financiero y de otras formas de cuidado similares que acompañan al matrimonio (así como aquellas que persisten después del divorcio) representan un recurso potencial significativo para las personas con discapacidad. El alcance de la obligación marital es claramente la cuestión presentada en *Wilson*, y el tribunal de primera instancia lo abordó de frente: desde el punto de vista del tribunal, Elma había agotado el derecho de seguridad social correspondiente a su matrimonio particular y se convertiría ahora en responsabilidad del Estado.

Pero la decisión en *Wilson* probablemente no calificó a Elma para ningún apoyo estatal adicional, a pesar de su grave situación. El seguro por discapacidad de la seguridad social es categórico, lo que significa que solamente aquéllos que sufren de discapacidad severa provocada por actividades laborales pueden calificar, y quienes regresan a la vida laboral no pueden reclamar beneficios. Pero el programa no está tasado por ingreso, esto quiere decir que los beneficios no aumentan si los ingresos del beneficiario disminuyen. Así, el beneficio en efectivo que recibía Elma cada mes estuvo determinado por sus propios ingresos e historial laboral y no incrementaría si sus otras fuentes de ingreso desaparecieran.²²

El ingreso suplementario de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa tasado de conformidad con los medios económicos del beneficiario que puede ser complementario con los beneficios por discapacidad de la seguridad social, pero sólo ayuda a personas en extrema pobreza. Mientras que el SSDI provee beneficios con base solamente en los ingresos pasados (y de este modo se paga sin considerar el ingreso actual), el SSI está tasado de conformidad con los medios económicos del beneficiario y sólo se paga a las personas en las circunstancias económicas más graves. En 1982, Elma habría sido con mayor probabilidad no elegible para el SSI, el cual, durante ese periodo, proveía máximos beneficios para una persona soltera, que ascendían a menos de 75% de la línea individual de pobreza.²³

²² A la edad de 62 años puede ser que la situación de Elma mejore, —o puede ser que no—. Podría no calificar para adquirir mayores beneficios con base en el récord de ingresos de Tom, puesto que estuvieron casados menos de diez años. Si hubiera estado casada antes (una cuestión que no es clara en la resolución) y si su primer matrimonio hubiera durado diez años o más, podría calificar a la edad de sesenta y dos a un beneficio por retiro mayor si los ingresos de su primer marido fueran suficientemente altos. Su matrimonio intermedio con Tom no afectaría su elegibilidad, pues el matrimonio terminó en divorcio.

²³ Véase Staff of The House Comm. On Ways & Means, 110th Cong., 2008 Green Book: Background Material and Data on Programs Within The Jurisdiction of the Committee on Ways and Means § 3-17 tbl. 3-3 (Comm. Print 2008). Disponible en: «<http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/110/ssi.pdf>». Las prestaciones del SSI se reducen dólar por dólar de las prestaciones de la Seguridad Social. Véase *id.* § 3-22 tbl. 3-5, § 3-23 tbl. 3-6.

Sorprendentemente, entonces, y a pesar de la retórica del tribunal, la negación de manutención conyugal en el caso de Elma no impuso ninguna responsabilidad adicional al Estado. En su lugar, la decisión dejaba a Elma viviendo en la pobreza extrema, subsistiendo solamente del ingreso proveniente del SSDI, a menos de que pudiera volver a casarse o persuadir a sus hijos adultos para que la asistieran.

Otra característica sorprendente del sistema derecho familiar/seguridad social es que la manutención conyugal que sigue al divorcio es francamente redistributiva en una manera en que la seguridad social no puede ser. La manutención conyugal dada por Tom representaba una redistribución de recursos de una persona que se encuentra en una mejor posición económica a una persona que se encuentra en una peor, y tomaba lugar entre dos personas ahora sin relación, hostiles el uno con el otro. Sin embargo, el beneficio proveniente del SSDI de Elma representaba en cierta medida un retorno de sus propias contribuciones al impuesto sobre la nómina, con las cuales se adquirirían ahorros para el retiro y un contrato de seguro contra discapacidad. Sin duda, la seguridad social redistribuye el ingreso al dar a los trabajadores con menos ingresos una ventaja relativa comparada con una prima de seguro puramente actuarial.²⁴ Aun así, los beneficios públicos recibidos por Elma tenían un componente sustancial privado, justo como si estuviera retirando sus ahorros o hubiese adquirido un seguro privado por discapacidad.

II. La manutención conyugal como una forma de seguridad social

Al poner al derecho familiar y a la seguridad social juntos, podemos ver que la tragedia nominalmente privada en *Wilson* ocurrió en medio de dos fuentes jurídicas de seguridad social: un derecho otorgado por el derecho familiar a la

²⁴ Véase Liebman, Jeffrey B., "Redistribution in the Current U. S. Social Security System", 1-2, *National Bureau of Economic Research*, Working Paper No. 8625, 2001 (donde se hacen notar los índices de reemplazo más altos para los trabajadores de bajos ingresos pero también que una expectativa de vida más corta y otros factores tienden a reducir el promedio de la redistribución de trabajadores con altos ingresos a trabajadores con bajos ingresos).

manutención conyugal y un derecho público a la seguridad social. Apartándose del caso particular de Wilson con el fin de generalizar, el cuadro 1 presenta el sistema combinado de derecho familiar/seguridad social para los adultos²⁵ que desarrollan alguna discapacidad. El cuadro 1 describe los derechos jurídicamente exigibles del individuo (y omite considerar el apoyo financiero y cuidado voluntario dado por parejas afectivas, hijos y otras personas).

Cuadro 1. Regulaciones de derecho familiar y seguridad social para adultos (hasta 62 años) con discapacidades²⁶

	Beneficios potenciales	Riesgos potenciales
Casado/a	• El/la cónyuge del individuo tiene una obligación de manutención ilimitada, aunque mínimamente exigible.²⁷ • El SSDI provee beneficios con base en el historial laboral del individuo. • El SSDI puede proveer beneficios adicionales al cónyuge si el cónyuge está criando a los hijos pequeños de la persona que trabaja.	• El ingreso del cónyuge es bajo o el cónyuge retiene la manutención o el cuidado (dentro de los límites legales). • El individuo no tiene hijos pequeños, lo que elimina el beneficio conyugal otorgado por el SSDI. • El individuo es pobre pero no suficientemente como para calificar para el SSI.

²⁵ Los adultos cuyas discapacidades se desarrollaron durante la infancia son tratados como niños para fines de la seguridad social: ellos califican por beneficios (o no) con base en el historial de ingreso de sus padres. Soc. Sec. Admin., Pub No. 05-10026, *Benefits for Children with Disabilities*, 10-1. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/pubs/10026.pdf>».

²⁶ A la edad de 62 años, un trabajador con discapacidad puede calificar por un beneficio mayor con base en el historial laboral de su cónyuge o el historial laboral de un cónyuge anterior (si el matrimonio duró diez años o más y si el trabajador no está casado/a la edad de sesenta y dos, incluso si contrajo segundas nupcias y se divorció en los años intermedios). 42 U. S. C. § 402 (2006).

²⁷ Véase, por ejemplo, *McGuire vs. McGuire*, 59 N. W. 2d 336, 342 (Neb. 1953); véase también *Krause & Meyer, op. cit.*, pp. 91-93.

	Beneficios potenciales	Riesgos potenciales
Divorciado/a; Si es que se realiza trabajo de crianza	• La obligación de manutención del cónyuge puede ser extendida después del divorcio. • El SSDI provee beneficios con base en el historial laboral del individuo.	• El ingreso del excónyuge es demasiado bajo como para garantizar manutención conyugal. • Los pagos provenientes del SSDI son bajos debido a las bajas ganancias que el individuo percibía o por un historial laboral intermitente. • El individuo es pobre pero no suficientemente como para calificar para el SSI.
Divorciado/a; Si es que jamás se ha realizado trabajo de crianza	• El/la cónyuge puede tener la obligación de manutención por un tiempo limitado después del divorcio. • El SSDI provee beneficios con base en el historial laboral del individuo.	• El ingreso del excónyuge es demasiado bajo como para garantizar manutención conyugal. • La manutención conyugal es denegada o se da por terminada. • Los pagos provenientes del SSDI son bajos debido a las bajas ganancias que el individuo percibía o por un historial laboral intermitente. • El individuo es pobre pero no suficientemente como para calificar para el SSI.

	Beneficios potenciales	Riesgos potenciales
Nunca casado/a	• El SSDI provee beneficios con base en el historial laboral del individuo.	• No existe la pretensión legal de manutención hacia ningún compañero anterior, excepto por las pretensiones de “palimony” (obligaciones contractuales de manutención entre parejas no casadas). • Los pagos provenientes del SSDI son bajos debido a las bajas ganancias que el individuo percibía o por un historial laboral intermitente. • El individuo es pobre pero no suficientemente como para calificar para el SSI.

Elma Wilson caía en una de las categorías más vulnerables: estaba divorciada después de un matrimonio corto sin hijos. Su trabajo e historial de ingresos la calificaba para un beneficio modesto proveniente del SSDI, de modo que era más afortunada que aquellos con ingresos menores o con un registro de trabajo esporádico. Y los ingresos de clase media de Tom respaldaron una concesión de manutención conyugal por cerca de cinco años. Tomados en conjunto, la pensión conyugal de Elma de 500 dólares más el ingreso de la seguridad social de 436 dólares al mes le daban 11,232 dólares al año, justo por encima del 200% de la línea de la pobreza y menos de la mitad del ingreso medio. No obstante, incluso ese ingreso dejaba a Elma en un estándar de vida muy por debajo del de clase media de Tom, cuyos ingresos²⁸ de 38,400 dólares lo ponían aproximadamente

²⁸ En 1986, Tom tenía un salario de 2,200 dólares al mes y 1000 dólares en fondo de retiro de la Marina. *Marriage of Wilson*, 247 Cal. Rptr. 522, 524 (Cal. Ct. App. 1988).

700% sobre la línea de la pobreza y 150% del ingreso medio de 24,897 dólares.²⁹ La conclusión de la manutención conyugal dejó a Elma en graves problemas económicos, debajo de la línea de la pobreza.

Tratar al derecho familiar como un instrumento de seguridad social parece pasar por alto diferencias jurídicas y sustantivas que existen entre los dos regímenes. Después de todo, Tom es el exesposo de Elma, no un desconocido; él está ayudando a la manutención de su excompañera de vida no pagando impuestos al estado. Pero estas distinciones —como la mayoría de dualismos jurídicos— son exageradas. El derecho mandató las obligaciones de Tom, al igual que establece los términos del pago de impuestos. Después del divorcio, Tom era, en algún sentido, un extraño para Elma —él ya no tenía obligaciones cotidianas hacia ella—. Y tanto él como los tribunales entendían su manutención conyugal como un “impuesto” al ingreso —una carga financiera calibrada de conformidad con el ingreso de Tom para el beneficio de alguien más—. El tribunal concluyó finalmente que el impuesto que gravaba a Tom era demasiado oneroso y debía ser distribuido más ampliamente. Del lado de Elma, como hemos visto, sus beneficios aparentemente públicos tenían un componente privado sustancial, pues el SSDI refleja contribuciones al impuesto de nómina, así como subsidios estatales (y el valor del subsidio varía de positivo a negativo, alguna gente recibe menos, en términos reales, de lo que recibirían si hubiesen adquirido una póliza de seguro privada).

Por el lado de los beneficios, también podemos analizar la manutención conyugal en los mismos términos que usaríamos para analizar un programa de seguridad social. El cuadro 2 compara la manutención conyugal y el SSDI a lo largo de seis dimensiones.

²⁹ Véase U.S. Census Bureau, Historical Income Tables: Table H-6. Disponible en: «<http://www.census.gov/hhes/www/income/histinc/h06ar.html>» (en archivos de la biblioteca de the Harvard Law School).

Cuadro 2. Comparación entre la manutención conyugal y el SSDI

	Manutención conyugal	SSDI
Categorico	• Matrimonio formal.³⁰ • Matrimonio duradero. • Cuidado de los hijos y otra forma de sacrificar el poder de generar ingresos.	• Discapacidad permanente severa. • Historial laboral.
Tasado conforme al trabajo	• La manutención puede ser reducida o eliminada si el sujeto es susceptible de conseguir empleo.	• Cesan los beneficios si el sujeto es susceptible de conseguir empleo.³¹
Tasado conforme a los medios económicos	• Se toma en cuenta la necesidad de la manutención junto con la capacidad de generar ingresos.	• No
Determinación de elegibilidad	• La determinación la lleva a cabo un juez de forma individualizada (a menos que se haya negociado un contrato válido).	• La determinación individualizada de discapacidad la llevan a cabo trabajadores sociales y un juez de derecho administrativo.

³⁰ Las obligaciones de manutención hacia excónyuges no casados están reconocidas por la ley, pero con resultados variables, dependiendo en el estado y el grado en el que las partes hayan hecho promesas expresas de manutención. Véase Krause & Meyer, *op. cit.*, pp. 67-73.

³¹ Ver Staff of the House Comm. On Ways & Means, *supra* nota 23, § 1. Disponible en: «<http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/111/ssgb.pdf>» (donde se discuten reglas y excepciones sustanciales de empleo remunerado).

	Manutención conyugal	SSDI
Límite de tiempo	• Sí, particularmente si se trata de un matrimonio corto, si no existen hijos y si no se puede demostrar un sacrificio para construir la capacidad del cónyuge para generar ingresos.	• No.
Condicionado al ingreso del excónyuge	• Sí	• No

El cuadro 2 sugiere similitudes sustanciales. Tanto la manutención conyugal como el SSDI son derechos jurídicamente exigibles, no transferencias voluntarias. Ambos son programas categóricos en los que las determinaciones de elegibilidad son individualizadas. En ambos, el apoyo termina cuando el destinatario es —o puede ser—autosuficiente a través del empleo. Al final, tanto el derecho familiar como la seguridad social proveen transferencias de dinero que pueden satisfacer las necesidades de personas con discapacidades, o no satisfacerlas, dependiendo de las circunstancias.

Una distinción jurídica importante entre los dos regímenes no aparece en el cuadro 2. La manutención conyugal puede ser negociada, o bien antes del matrimonio en un arreglo prenupcial, o durante el divorcio en un acuerdo de separación. Dependiendo del derecho de cada estado, los términos sustantivos del acuerdo y la situación de las partes, estos acuerdos privados pueden ser exigibles, lo cual quiere decir que pueden negar la aplicación de las reglas default que fueron aplicadas en *Wilson*.³²

³² Véase Krause & Meyer, *op. cit.*, pp. 81-87, 337-342 (donde se explican las condiciones jurídicas generales para sostener acuerdos prenupciales y de separación).

Por el contrario, los impuestos destinados al SSDI son obligatorios para casi todos los trabajadores en los Estados Unidos y no hay oportunidad para personalizarlos a través de un contrato. No obstante, esta diferencia formal es probablemente menos significativa de lo que podría parecer al principio, en la medida en que las partes negocian a la sombra de los derechos básicos establecidos por el derecho.

Puede ser que la distinción convencional entre beneficios públicos y privados descansa sobre la información de la última columna de la derecha. El derecho de un individuo a la manutención conyugal depende del ingreso de su excónyuge, mientras que el derecho al SSDI, no. Sin dudas, la distinción no es del todo nítida. Si un excónyuge se encuentra en una posición suficientemente aventajada, su ingreso no es una limitación importante al beneficio del reclamante. Y no todos los programas de bienestar social configuran derechos: las subvenciones generales, por ejemplo, pueden negar sus servicios a individuos elegibles simplemente porque el presupuesto del gobierno no es suficiente para cubrir la demanda.

De cualquier modo, en el rango ordinario de casos, la distinción tiene algo de atractivo: si el excónyuge es pobre, incluso el reclamante que más mereciere manutención conyugal se retirará sin nada. Dicho de otra forma, la porción de derecho familiar en el sistema de seguridad social concede derechos de “calidad crediticia” variable. Aquellas personas casadas formalmente con compañeros ricos tienen derechos de calidad AAA, mientras que otros tienen derechos financieramente contingentes.³³

Los dos sistemas de seguridad social —el derecho familiar y la seguridad social— tienen en cuenta al otro, pero los mecanismos jurídicos son diferentes.

³³ Una idea paralela en el contexto de la manutención infantil llevó a Irwin Garfinkel a proponer un seguro de manutención infantil en el que los padres pagarían una manutención determinada por reglas estándar, pero si los padres no podían pagar, el Estado intervendría de modo que el niño recibiera la cantidad completa. Garfinkel llamó a su propuesta una “adición” a la seguridad social. Garfinkel, *op. cit.*, p. 51.

Los tribunales familiares generalmente pueden (o deben) tomar en cuenta el estado de necesidad al determinar si se concede o no la manutención conyugal, como en el caso *Wilson*, y entonces el derecho al SSDI de Elma tendería a reducir su manutención conyugal, provisto todo lo demás en igualdad de circunstancias. Pero, justo como en *Wilson*, cuando el derecho a la manutención conyugal termina, el nivel de ingresos del cónyuge se vuelve irrelevante. La decisión en *Wilson* dejó a Elma por debajo de la línea de la pobreza a nivel federal, una medida que los científicos sociales ven como representación de la pobreza extrema.³⁴ El tribunal no menciona el nivel de pobreza, ni reconoce que vivir bajo la línea de la pobreza significa probablemente una privación severa. En su lugar, la corte de apelaciones apoya la conclusión del tribunal de primera instancia, según la cual el bienestar de Elma es ahora la obligación del Estado, sin dar mucha consideración al contenido de esa obligación.

Por el contrario, los beneficios otorgados por el SSDI se establecen sin necesidad de tasar los medios económicos del beneficiario y, por tanto, no toman en cuenta explícitamente otro ingreso. Implícitamente, sin embargo, el SSDI establece beneficios tan bajos para algunos trabajadores que, para escapar de la pobreza, los beneficiarios deben mantener o formar funcionalmente una relación familiar o hacer una reclamación exitosa sobre un excónyuge.

En resumen, el derecho crea un sistema combinado de seguridad social que distribuye el riesgo de discapacidad en una forma distintiva: en las mismas circunstancias, trabajadores con altos ingresos en matrimonios intactos (o divorcios después de matrimonios duraderos donde se criaron hijos) con cónyuges de altos ingresos reciben los beneficios más altos. Trabajadores de bajos ingresos (sin hijos) cuyos matrimonios se disuelven en una peor manera y trabajadores de bajos ingresos que jamás contrajeron matrimonio tienen las protecciones legales más endebles.

³⁴ Véase Alstott, "Why the EITC Doesn't Make Work Pay", pp. 7-10.

Analizándolo desde una perspectiva *ex ante*, Elma Wilson estaba en una situación de vulnerabilidad mucho antes de su caída en 1980. Dada su situación marital, su contexto de crianza y sus ingresos, se enfrentaba a un riesgo financiero sustancial en caso de que un divorcio o una incapacidad se presentaran. Si sus bajos ingresos hubieran estado conectados a los deberes de crianza o a un matrimonio de larga duración, le habría ido mejor con la porción de derecho familiar que le otorgaba el sistema (al calificar para una manutención conyugal de larga duración). Y si sus ingresos hubieran sido más altos, le habría ido mejor con la porción pública del SSDI del sistema (al calificar para recibir beneficios más elevados).³⁵

Quizás no sorprenda que a las personas con mayores ingresos con matrimonios de larga duración y roles tradicionales de género les vaya mejor bajo lo que establecen el derecho familiar y la seguridad social. El derecho a menudo perpetúa el privilegio y reproduce inequidades subyacentes. No obstante, una visión integrada del derecho familiar y el SSDI nos ayudan a ver la medida en la que el sistema de seguridad social como un todo mitiga —o falla en mitigar— los riesgos creados por el matrimonio y el mercado laboral.

El derecho familiar y la seguridad social distribuyen las consecuencias de los riesgos de la vida en medio de otras estructuras jurídicas que afianzan el privilegio y la vulnerabilidad. Consideremos dos elementos del sistema legal en Estados Unidos que a menudo se dan por hecho. Primero, las leyes laborales y de empleo estadounidenses influenciaron el historial laboral y las condiciones de trabajo de Elma. El trabajo de atender bares tiende a ser de ingresos relativamente bajos y a proveer pocos beneficios; así, se dejó aparentemente a Elma sin acceso a la tercera porción del sistema estadounidense de seguridad social—beneficios de seguros privados por discapacidad y retiro—. En ocasiones se habla del mercado laboral como si existiera en una especie de espacio natural fuera de la ley, pero los economistas saben que el derecho

³⁵ Cuando un trabajador o trabajadora tiene alguna discapacidad, su cónyuge puede también reclamar beneficios derivados si él o ella aún están casados, no son mayores a 62 años y realizan trabajos de cuidados con los hijos, o si están casados o divorciados y tienen 62 años o más.

estructura las interacciones de mercado. Así, hay múltiples formas posibles que puede tener un mercado laboral “libre”, las cuales se corresponden con una colección de posibles decisiones jurídico-institucionales acerca de cuestiones como la negociación colectiva de contratos y los mandatos legales sobre salarios, condiciones de trabajo, prestaciones, etcétera.³⁶

Segundo, La discapacidad de Elma y el rompimiento de su matrimonio ocurrieron en medio de un contexto legal que le requería —y casi a todas las demás personas— comprar la mayoría de bienes en un mercado a precios establecidos por el mercado. Vivienda, comida, ropa y transporte debía ser todo financiado después de que la decisión en *Wilson* descartara los 436 dólares al mes de Elma que recibía gracias al beneficio proveniente del SSDI. Ya hemos visto que era poco probable que Elma calificara para el SSI, y sin hijos ella no podía cobrar los beneficios de asistencia social patrocinados por el gobierno federal (en ese entonces llamado Asistencia para Familias con Hijos Dependientes [AFDC, por sus siglas en inglés], y ahora llamado TANF [por sus siglas en inglés]). El principal beneficio complementario que recibiría era el seguro médico del Estado (Medicare), el cual, después de un periodo de espera, pagaría por una parte importante (aunque no en su totalidad) la atención médica de Elma.³⁷

III. Reformas legales: el derecho familiar y más allá

Armados con este mapa del derecho familiar, el SSDI y otras estructuras legales, podemos ver ahora al menos cuatro puntos de entrada para reformas legales. Cambios en el derecho familiar, en la seguridad social, en los mercados laborales y en la distribución de bienes primarios podrían cambiar la naturaleza trágica de la decisión del tribunal en *Wilson* al alterar la distribución

³⁶ Véase Freeman, Richard B., *America Works*, 2007, pp. 7-19.

³⁷ El tribunal en *Wilson* hizo notar que la orden inicial de manutención conyugal incluía cobertura por seguro médico. *Marriage of Wilson*, 247 Cal. Rptr. 522, 523 (Cal. Ct. App. 1988). La resolución no clarifica los términos del seguro o si debía continuar cuando Elma se convirtiera en elegible para Medicare.

ex ante de los riesgos de incapacidad o disolución del matrimonio. Para estar seguros, no he ofrecido —y aquí no ofreceré— un argumento normativo que apoye ninguna reforma específica o, de hecho, ninguna reforma en absoluto. Mi meta aquí no es prescribir la forma correcta que debería tener el sistema de seguridad social; más bien, lo que quiero es ofrecer simplemente opciones para la discusión que ilustren cómo algunas decisiones legales son contraintuitivas.

El derecho familiar representa una vía de reforma. En respuesta a *Wilson*, los tribunales o legislaturas deberían ordenar obligaciones de manutención conyugal de mayor duración cuando se combinan discapacidad severa y necesidad extrema. En lugar de distinguir entre matrimonios que crían hijos, por un lado, y matrimonios de compañía, por el otro, la ley podría —contrariamente al punto de vista adoptado por el tribunal en *Wilson*— tratar a todos los matrimonios como una forma explícita de seguridad social en contra de la discapacidad, con obligaciones maritales que duraran por un tiempo prolongado, incluso permanente, después del divorcio.

Esta dirección de reforma legal marcaría, por supuesto, un cambio importante en la forma presente de entender el matrimonio y el divorcio. Actualmente, el divorcio ofrece un nuevo comienzo, con la excepción de matrimonios duraderos que hayan criado hijos, en los que uno de los cónyuges haya asumido el trabajo de cuidados y sacrificado oportunidades de mercado. Cambiar el resultado en *Wilson* marcaría el comienzo de un nuevo enfoque, y uno que da lugar a muchas preguntas. En la actualidad, Estados Unidos tiene un alto grado de monogamia serial, con un alto índice de divorcios y segundas nupcias.³⁸ Extender la obligación de manutención podría ir en contra de ese patrón cultural y atar a los excónyuges financieramente en el largo plazo. Y por supuesto existe la pregunta normativa más profunda: ¿debería el matrimonio involucrar un seguro de ingreso de largo plazo de cada cónyuge para con el otro? Preguntas

³⁸ Véase Cherlin, Andrew J., *The Marriage Go-Round*, 2009, pp. 4-5.

operacionales también surgen: ¿deberían los matrimonios de muy poca duración ser excepciones?, ¿se les debería permitir a los cónyuges optar por no participar del nuevo sistema a través de acuerdos prenupciales?

No ofrezco aquí una propuesta concreta de reforma legal. En su lugar, mi limitado punto en esta etapa es que podemos concebir tal cambio en términos de seguridad social. Una obligación de manutención extendida proveería un beneficio de mayor duración, tasado conforme a medios para el excónyuge que sufre la discapacidad, financiado por un “impuesto” al ingreso a recaer sobre el otro excónyuge.

El programa SSDI es otro candidato de reforma legal. Mayores beneficios del SSDI mejorarían la situación de la gente con discapacidades, y, en el camino, se establecería un piso más alto para la pérdida de otros ingresos, incluida la manutención conyugal. Alternativamente, el programa podría adoptar un complemento tasado sobre el ingreso, o podría expandir los beneficios del SSI. Un cambio así empujaría, por supuesto, al SSDI en la dirección de convertirse en un programa de asistencia social, una dirección que muchos defensores de la seguridad social han rechazado (históricamente) por razones políticas.³⁹

Un enfoque diferente sería alterar el SSDI para pagar más a quienes no tienen familia y menos a aquéllos que pueden contar con apoyo financiero familiar. Este enfoque no requeriría una prueba de medios económicos a gran escala, lo cual es administrativamente complejo y carga la marca de asistencia social que temen los defensores de la seguridad social.

En cambio, el programa de beneficios podría simplemente ser ajustado de forma aproximada para reflejar la presencia o ausencia de otro adulto en el hogar. Esta reforma estaría en tensión con el enfoque tradicional de la seguridad social, el cual trata a un segundo adulto en la familia como un

³⁹ Véase, porejemplo, Marmor, Theodore R. *et al.*, *America's Misundertood Welfare State*, 1990, pp. 156-60.

dependiente en lugar de como una fuente de apoyo. Hoy, el SSDI paga más a una pareja casada que a un trabajador no casado si el cónyuge del trabajador beneficiario se encarga de cuidar a sus hijos pequeños.⁴⁰

Ajustar los beneficios categóricamente de acuerdo con la presencia o ausencia de la familia podría ser o no una dirección deseable, y no intento articular aquí el caso normativo para ello o desarrollar los detalles administrativos. (¿Cualquier otro adulto contaría como alguien que provee apoyo familiar, incluso si la relación es de corto plazo, informal o autoconscientemente casual? ¿Dicha regla autorizaría intrusiones a la privacidad personal?) En cambio, el punto es cuestionar las presuposiciones acerca de la vida familiar integradas en nuestro sistema de seguridad social: hoy, la preocupación principal son los trabajadores incapaces de mantener a sus dependientes. Hay un punto ciego —o quizás una brecha deliberada— con respecto a quienes trabajan, pero no están en una situación aventajada y quienes ni mantienen dependientes ni califican para recibir el apoyo de alguien más.

Mirando más allá de los programas formales de seguridad social, ajustes en estructuras legales más profundas también podrían modificar lo que está en juego en casos como *Wilson*. Cambios en el mercado laboral, que van desde la negociación colectiva de contratos que elevarían los salarios hasta mandatos legales sobre prestaciones, podrían mejorar el perfil financiero de Elma y su acceso a un seguro privado complementario por discapacidad. Programas que debiliten el vínculo entre el ingreso de mercado y el acceso a bienes primarios también podrían ayudar a que el cheque del SSDI de Elma se ensanche más: asistencia ampliada para vivienda y transporte, por ejemplo, cambiaría la importancia de los beneficios del SSDI, transformándolo en un significativo complemento en efectivo una vez que las necesidades básicas han sido satisfechas, en lugar de un beneficio todo en uno, lamentablemente inadecuado.

⁴⁰ 42 U. S. C., 2007, § 402(b).

Al final, la tragedia privada en *Wilson* refleja decisiones públicas acerca de la distribución de riesgos sociales. Sin hijos, sin un matrimonio de larga duración y con ingresos limitados, el perfil de riesgo de Elma era grave: discapacidad, especialmente en combinación con divorcio, significaba desastre financiero.

B. El caso *brown vs. Brown*: manutención infantil y familias múltiples

El derecho familiar enmarca a la manutención infantil también como una cuestión privada. Los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos, y cuando los padres no cumplen, los hijos deben sufrir. O por lo menos eso parece.

Sin duda, el Estado intervendrá para colocar a los niños en cuidado adoptivo en los casos de hambre severa o daño físico grave. Pero dentro de un amplio rango, el derecho permite que las decisiones parentales gobiernen las condiciones de vida de los hijos. Un caso en Wisconsin, *Brown vs. Brown*,⁴¹ ilustra los problemas que surgen cuando los padres divorciados o que jamás se casaron contraen segundas nupcias e inician una segunda familia y los ingresos parentales no pueden mantener adecuadamente a ambas.

I. La tragedia: divorcio y familias múltiples

Sheldon y Sharon Brown se casaron en 1984 y se divorciaron tres años después. Sharon tomó la custodia de su hijo. Las pautas de Wisconsin requerían que Sheldon pagara 17% de sus ingresos brutos por manutención infantil. Más tarde, Sheldon contrajo segundas nupcias y tuvo tres hijos con su nueva esposa, y él pidió a los tribunales una reducción de sus pagos de manutención infantil debido a su obligación de mantener a sus nuevos hijos. La corte de apelaciones negó la petición, sostuvo que las reglas en Wisconsin,

⁴¹ *Brown vs. Brown*, 503 N.W. 2d 280 (Wis. Ct. App. 1993).

que regulaban a “pagadores familiares seriales”, no podían ser aplicadas para reducir la manutención debida a un hijo nacido anteriormente.⁴²

Inicialmente *Brown vs. Brown* no parece presentar la tragedia desgarradora mostrada en *Wilson*. El dictamen de la corte de apelaciones ofrece solamente una presentación sobria de los hechos y dedica la mayoría de su análisis al lenguaje y estructura de las pautas de manutención infantil en Wisconsin. El dictamen no revela si Sharon o Sheldon o sus respectivas familias se encontraban en una situación económica aventajada o marginal. No es claro si la segunda familia de Sheldon estaba teniendo problemas para llegar a final de mes, o si Sheldon se estaba simplemente aprovechando de un vacío jurídico que podía reducir su manutención infantil.

No obstante, hay una tragedia privada al acecho aquí, y ha dividido a los tribunales de todo Estados Unidos.⁴³ La naturaleza de la tragedia surge en los pocos párrafos que el decreto de la corte de apelaciones en *Brown* dedica a cuestiones de política pública. Sheldon, enfatiza la corte, ha tomado una (mala) decisión, y es “una buena política pública” que él asuma las consecuencias financieras: “la reducción voluntaria de la capacidad de un padre/madre para mantener una familia al tener más hijos no debería automáticamente penalizar a los hijos nacidos con anterioridad”.⁴⁴

Pero, como en cada tragedia privada, existe el otro lado de la historia: ¿qué pasa con la segunda esposa y el segundo grupo de hijos? Consideremos, por

⁴² *Idem*, p. 281.

⁴³ Véase Minow, Martha, “How Should We Think About Child Support Obligations?”, en Garfinkel, Irwin *et al.* (eds.), *Fathers Under Fire*, 1998, p. 302 y ss. Para un resumen de varios enfoques de los estados sobre las familias múltiples, véase Casper, Emma, *Review of Child Support Policies for Multiple Family Obligations*, septiembre de 2006 (manuscrito no publicado, en archivo de la biblioteca de la Harvard Law School. Disponible en: «<http://www.irp.wisc.edu/research/childsup/cspolicy/pdfs/Casper-Task4A-2006.pdf>»). Véase también Lockie, Adrienne Jennings, “Multiple Families, Multiple Goals, Multiple Failures”, *Harv. J. L. & Gender*, vol. 32, 2009, pp. 109, 111, 152-63 (donde se propone un sistema de “igualación limitada” que trazaría un camino intermedio).

⁴⁴ *Brown*, 503. N. W. 2nd, p. 283.

ejemplo, un caso en Nueva York, *Lonsdale vs. McEwen*.⁴⁵ Después de un segundo matrimonio y el nacimiento de gemelos, Mark McEwen solicitó a los tribunales la reducción de la manutención infantil que debía a un hijo de su primer matrimonio. Una corte de apelaciones empática ordenó una audiencia sobre el fondo en esta cuestión, llegando a la conclusión de que “[i]ndependientemente de si el demandado [padre] puede ser justamente culpado por haber contraído segundas nupcias y criar hijos con su nueva esposa... sus hijos pequeños se encuentran sin culpa y [el tribunal de primera instancia] no debería haber desdeñado la necesidad del inculpado de mantenerlos”.⁴⁶

Al trabajar dentro del constreñimiento de los juegos de suma cero, el derecho ha adoptado típicamente uno de dos enfoques a los que Martha Minow llama “primeras familias primero” e “igualdad de trato”.⁴⁷ “Primeras familias primero” es el enfoque adoptado en *Brown*: el derecho da prioridad las necesidades financieras del grupo de hijos nacidos primero. Por el contrario, el enfoque de “igualdad de trato” enfatiza la igualdad entre los hijos nacidos antes y los hijos nacidos después y busca igualar sus estándares de vida.⁴⁸ Cualquier aspiración por la igualdad genera numerosas preguntas: por ejemplo, ¿deberían las ganancias de los padrastrós/madrastras tomarse en consideración con respecto al cálculo de igualación?⁴⁹ No obstante, el anhelo de lograr la igualdad de estándares de vida entre la primera y la segunda familia contrasta, en abstracto, con el enfoque de “primeras familias primero”.

Entonces, justamente como en *Wilson*, el problema de mantener múltiples familias parece introducir un dilema insoluble creado por la mala suerte y las malas

⁴⁵ *Lonsdale vs. McEwen*, 821 N. Y. S. 2d, 155 (N. Y. App. Div. 2006).

⁴⁶ *Id.*, p. 158.

⁴⁷ Véase Minow, *op. cit.*, p. 309.

⁴⁸ Véase, por ejemplo, *Lonsdale vs. McEwen*, 821 N. Y. S. 2d, 159 (donde se sostiene que el nacimiento de gemelos en la familia actual del padre constituye un evento no anticipado con necesidad concomitante, potencialmente justificando una revisión hacia debajo de los pagos requeridos por un acuerdo de manutención al que se entró con la madre de un niño de un matrimonio anterior).

⁴⁹ Véase Ellman, Mark Ira y Ellman, Tara O’Toole, “The Theory of Child Support”, *Harv. J. on Legis.*, vol. 45, 2008, pp. 107, 153-59.

decisiones. Cuando los padres no ganan lo suficiente como para mantener dos familias, el derecho no puede crear algo de la nada. O bien un grupo de hijos gana a expensas del otro, o bien el derecho divide un ingreso inferior al adecuado entre las dos familias, repartiendo el mismo sufrimiento entre ambas.

II. Manutención infantil como una instancia de la seguridad social

Pero, como en *Wilson*, un vistazo más cercano sugiere que el derecho familiar y la seguridad social operan juntos para determinar cuáles decisiones son riesgosas y cuáles son seguras. El cuadro 3 describe las principales reglas jurídicas y los riesgos que crean desde la perspectiva de un infante.

Cuadro 3. Derecho familiar y seguridad social para los hijos

	Beneficios potenciales	Riesgos potenciales
Hijo de padres casados	• Ambos padres tienen la obligación legal de mantener al hijo. • El Estado provee educación pública gratuita de calidad variable. • Pequeños beneficios de asistencia social por tiempo limitado están disponibles si la familia se encuentra en situación de pobreza extrema, además de vales para alimentos y posiblemente el programa estatal de seguro médico para niños (SCHIP, por sus siglas en inglés, es un seguro médico subsidiado). • Pequeños beneficios fiscales por hijo.	• Los padres no ganan lo suficiente para mantener a sus hijos. • Los padres fallan en (o no pueden) proporcionar cuidados.

	Beneficios potenciales	Riesgos potenciales
	• La seguridad social provee beneficios para los padres y el hijo si uno de los padres muere o sufre discapacidad severa, dependiendo del historial laboral del padre/madre.	
Hijo de padres divorciados o que nunca contrajeron matrimonio	• Ambos padres tienen la obligación legal de mantener al hijo, sujetos a proceso legal en caso de incumplimiento (el padre con la custodia debe obtener una orden judicial). • Dependiendo de la ley estatal, la segunda familia de alguno de los padres puede reducir la manutención que se paga al primer grupo de hijos. • Pequeños beneficios de asistencia social por tiempo limitado están disponibles si la familia se encuentra en situación de pobreza extrema, además de vales para alimentos y posiblemente el SCHP. • Pequeños beneficios fiscales por hijo. • La seguridad social provee beneficios para los padres y el hijo si uno de los padres muere o sufre discapacidad severa, dependiendo del historial laboral del padre/madre.	• El padre con la custodia tiene bajos ingresos, y el padre sin la custodia tiene bajos ingresos o falla en pagar la manutención infantil. • El padre con la custodia falla en (o no puede) proporcionar cuidados. • El padre sin la custodia falla en proveer cuidados y manutención similar. • Uno de los padres que tiene o no la custodia tiene múltiples familias y un ingreso insuficiente para mantener ambas (dependiendo en la ley estatal, el riesgo puede recaer en uno o ambos grupos de hijos).

El rompimiento de la familia, los bajos ingresos y la multiplicidad de familias crean así riesgos financieros para los hijos. La incapacidad o falta de voluntad de los padres para proporcionar cuidados crea un riesgo de descuido. El sistema de seguridad social de Estados Unidos ofrece pocas protecciones contra estos riesgos. Una educación básica (K-12) pública y gratuita asegura por lo menos un acceso mínimo a la educación básica, pero los precios de vivienda se correlacionan con la calidad de las escuelas, y la educación, más allá de la secundaria, es costosa.

Los créditos fiscales pequeños, principalmente simbólicos, proveen, a lo más, unos pocos miles de dólares, y los beneficios del TANF, temporalmente limitados y tasados de conformidad con los medios económicos, asisten sólo a familias en circunstancias extremas. Para los hijos, estos riesgos financieros significan peligros en el desarrollo, pues la pobreza puede llevar a la privación nutricional, a la salud y el estrés, los cuales afectan negativamente su desarrollo.⁵⁰ El sistema de bienestar infantil es notoriamente malo para detectar negligencia hasta que alcanza proporciones mayores y se vuelven obvias para las personas al exterior de la familia; el sistema depende de los reportes de una tercera parte e, incluso cuando la negligencia es reportada, puede ser que el Estado no actúe si no existe un peligro grave inmediato.⁵¹

Por el contrario, la seguridad social brinda mayor apoyo financiero cuando alguno de los padres muere o sufre una discapacidad severa, siempre que el padre tenga un historial suficiente de trabajo remunerado e ingresos. El SSDI paga mensualmente beneficios no sólo al trabajador sino también a sus hijos menores, incluso si el padre/la madre no tiene la custodia del hijo, y

⁵⁰ Hay una larga bibliografía donde se establece una conexión entre pobreza y mala salud, mal desempeño académico y riesgos de abandono escolar y embarazo no deseado temprano. Véase, por ejemplo, Duncan, Greg J. y Brooks-Gunn, Jeanne (eds.), *Consequences of Growing Up Poor*, 1997 (donde se ofrece un conjunto de ensayos que establecen los efectos de la pobreza en el desarrollo infantil). Existe un debate entre los científicos sociales sobre la medida en la que la pobreza en sí misma cause estos resultados y sobre si los pagos por ingreso directos solamente podrían revertirlos. Véase, en general, Mayer, Susan E., *What Money Can't Buy*, 1997.

⁵¹ Waldfogel, Jane, *The Future of Child Protection*, 1998, capítulos 1-2.

lo mismo hace el seguro de sobrevivientes del seguro social (una forma de seguro de vida público adquirido con los mismos impuestos sobre nómina que financian el más conocido programa de seguro por vejez y discapacidad de la seguridad social).

Justo como en *Wilson*, esta distribución de riesgo también refleja otros elementos del derecho. El derecho estructura los mercados laborales con pocas protecciones para los trabajadores: en estos mercados, algunos padres/madres ganan salarios bajos y se encuentran con pocas opciones para mejorar sus ingresos. Y el derecho consigna a otro mercado la distribución de bienes primarios como la salud, los alimentos y la vivienda. Tomados juntos, el mercado laboral y el mercado de bienes crean una vulnerabilidad predecible para los padres/madres de bajos ingresos y para los padres/madres con costos de vida altos.

III. Reforma legal: el derecho familiar y más allá

Justo como en *Wilson*, un mapa exhaustivo del paisaje jurídico ayuda a resaltar los muchos puntos de entrada para una reforma legal. La siguiente discusión asume —sin justificar— el objetivo de asegurar manutención material adecuada para todos los hijos.⁵² Una meta diferente motivaría, por supuesto, reformas distintas; el análisis siguiente sirve sólo para ilustrar los tipos de preguntas que uno podría plantear.

Las discusiones típicas tratan al nivel de manutención requerido por parte de los padres sin custodia como la variable primaria para la reforma del derecho familiar. Dada dicha suposición, y aceptando el constreñimiento del ingreso parental como la fuente única de fondos disponible para los hijos, el enfoque de igualdad de trato parece servir al objetivo de equidad material para los hijos. Si la norma motivante es consideración igual para todos los

⁵² Para un argumento normativo a favor de la igualdad de recursos para el desarrollo, véase Alstott, Anne L., “Is the Family at Odds With Equality? The Legal Implications of Equality for Children”, *S. Cal. L. Rev.*, 82, 2008, pp. 1-44.

hijos, la implicación en términos de política pública sería definir los recursos parentales de manera amplia (por ejemplo, incluir los ingresos de los nuevos cónyuges) e igualar los estándares de vida de ambos grupos de hijos.⁵³

Pero tener para con todos los hijos igual consideración contradice las limitaciones a los ingresos parentales por manutención infantil. El reconocimiento de la no culpabilidad de los hijos milita a favor de otorgar recursos adecuados para el desarrollo para cada hijo, una meta difícil de alcanzar cuando las reformas legales están constreñidas al ingreso parental y cuando se toma como punto de referencia una medida *ad hoc* como el estándar de vida original o posterior de la primera familia, o el estándar de vida actual de la segunda familia.

El derecho podría responder flexibilizando la restricción del presupuesto, por ejemplo, al expandir el círculo de adultos con responsabilidad financiera hacia los hijos. El derecho podría, en principio, obligar a los padrastros/madrastras y a los abuelos o incluso a las tías y los tíos a contribuir a la manutención de los hijos. Este enfoque no tradicional empujaría al derecho familiar hacia adelante en el espectro con dirección hacia la tributación, sin duda, y daría lugar a preguntas sobre justicia, incentivos y administración. ¿Sería justo requerir contribución económica a personas que han elegido no tener hijos? ¿Desincentivaría el sistema la realización de segundas nupcias? ¿Tendría el sistema jurídico para “padres perezosos”, que ahora está en vigor, que intensificarse para perseguir a “abuelas perezosas” y “tías fugitivas”? ¿O una obligación de manutención más extensa mejoraría el bienestar de los hijos al ampliar la carga financiera en una manera que reduce la presión sobre los padres?

Otra reforma podría obligar a los hijos mismos a contribuir a su manutención. Con seguridad, no estoy proponiendo ninguna forma de trabajo infantil ni un asilo al estilo de *Oliver Twist*. En su lugar, el derecho podría

⁵³ Véase Minow, *op. cit.*, p. 316. Para una discusión sobre las complejidades de la aspiración al trato igual, véase Ellman & Ellman, *op. cit.*

conceptualizar la manutención infantil como algo que debe ser otorgado por el Estado durante la infancia y pagado de vuelta por el adulto durante su vida. Muchos diseños son posibles: ¿debería el Estado/niño pagar el monto completo por su manutención o solamente cualquier déficit con respecto a lo que la familia puede aportar? ¿Debería la persona adulta ser responsable de una deuda fija, reembolsable incluso a costa de dificultades financieras? ¿O tendría la persona adulta que reembolsar su manutención solamente si su ingreso cómodamente lo permite, quizás vía un impuesto de nómina?

No ofreceré aquí un análisis completo de una obligación de manutención impuesta sobre la familia extendida ni de una transferencia intertemporal a los niños de sus seres futuros. Ambas reformas parecen radicales, pero ambas ilustran un punto conceptual. Entender al derecho familiar como una instancia de seguridad social revela —pone en cuestión— la presuposición de que sólo los padres pueden contribuir a la manutención de un hijo. Cambiar la obligación de manutención hacia la familia extendida o al hijo mismo ilustra que el financiamiento de la manutención infantil puede tener una base estrecha (solamente padre y madre), una más amplia (los padres y además la familia extendida) o la más amplia (el Estado, lo que es decir un grupo más extenso de contribuyentes).

Una segunda palanca jurídica para una reforma es el sistema formal de seguridad social. Aquí, el derecho opera fuera del constreñimiento impuesto por la capacidad de ingreso parental, y de este modo puede alcanzar más fácilmente la igualdad financiera —o un mínimo decente— para todos los hijos. Irwin Garfinkel ha propuesto un sistema de “seguro de manutención infantil”, el cual garantizaría a cada hijo de padres divorciados o que jamás estuvieron casados un pago fijo mínimo de manutención infantil.⁵⁴ La manutención infantil sería financiada por el padre/madre que no tiene la custodia en primera instancia, pero si el padre/madre fallara en pagar (debido a incapacidad o falta de voluntad), el Estado pagaría por cada hijo por lo menos el beneficio mínimo. Garfinkel

⁵⁴ Garfinkel, *op. cit.*

llamó a su propuesta una adición a la seguridad social,⁵⁵ y argumentó que el programa se haría cargo de los riesgos que enfrentan los hijos a consecuencia del divorcio, la falta de matrimonio, la ausencia de pago de la manutención infantil y la pobreza parental.⁵⁶ Su intención era mejorar los cobros de manutención infantil (una agenda que ha sido ampliamente adoptada desde la publicación inicial de su idea) y complementar las contribuciones parentales (una idea que ha demostrado ser menos popular).⁵⁷

La propuesta de Garfinkel no se ajusta perfectamente al derecho familiar o a la seguridad social. El seguro de manutención infantil requeriría una determinación legal de manutención infantil hecha por un tribunal, y el nivel de pago estaría basado en el ingreso parental y una fórmula estándar de manutención infantil. Así, como en el derecho familiar, los padres seguirían siendo los obligados primarios y los montos reales de manutención infantil podrían variar entre los hijos. Solamente el nivel mínimo sería fijo, para asegurar que cada hijo reciba algo, incluso si los padres pudieran pagar pero decidieran evadir su responsabilidad.

La propuesta de Garfinkel podría, por supuesto, ser ampliada para cubrir a hijos en todas las familias cuyos padres —ausentes o presentes— no puedan proporcionar a los hijos una manutención adecuada. Garfinkel rechazó extender su programa en esa dirección: su meta era abordar solamente el problema de la manutención infantil para hijos cuyos padres están divorciados o no están casados, y deliberadamente buscó tomar distancia con respecto a la asistencia social tradicional.⁵⁸ Por supuesto, el costo es que el seguro de manutención infantil podría dejar a los hijos de padres pobres, divorciados o no casados, en una mejor situación que a los hijos de padres pobres pero casados.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 51.

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 50-55.

⁵⁷ Véase Corbett, Thomas, "The Wisconsin Child Support Assutance System: From Plausible Proposals to Improbable Porspects", en Garfinkel, Irwin *et al.* (eds.), *Child Support Assurance*, 1992, pp. 27-29.

⁵⁸ Garfinkel, *Assuming Child Support*, pp. 50-51.

Las reformas legales también podrían apuntar a otros elementos del derecho. Hoy, las oportunidades de un niño y su acceso a bienes primarios dependen de manera importante de las ganancias de mercado de sus padres. El derecho podría cambiar las estructuras del mercado laboral para incrementar salarios y mejorar las condiciones de trabajo desde abajo;⁵⁹ reformas adicionales podrían mejorar la posición en el mercado laboral de los padres involucrados en el trabajo de cuidados.⁶⁰

Aun otro enfoque podría buscar debilitar, incluso terminar, el vínculo entre ingresos parentales y el acceso de los hijos a bienes primarios. Sería posible, por ejemplo, para el Estado garantizar un conjunto universal de bienes primarios —vivienda, alimentos, ropa, salud, cuidados infantiles complementarios— para cada hijo, independientemente del ingreso parental. Un sistema así transformaría las obligaciones de la paternidad removiendo el componente de responsabilidad financiera, pero reteniendo las responsabilidades emocionales, sociales y morales propias de dicho papel. Por supuesto, esto es una idea radical en el contexto estadounidense, aunque lo es menos comparado con los estados del bienestar europeos, lo cuales proporcionan apoyos más generosos para los niños.⁶¹ En otro trabajo, me he encargado con cierto detalle de las justificaciones en favor de un sistema tal, así como de las objeciones que se le pueden presentar.⁶²

Como Elma Wilson, los hijos de padres con bajos ingresos y múltiples familias viven con un alto nivel de riesgo mucho antes de que la tragedia se presente. Un niño cuyos padres no ganan lo suficiente para mantener a dos familias es vulnerable frente al rompimiento familiar si está en la primera familia, o a la existencia de una familia anterior, si está en la segunda. La privación que experimentan estos niños refleja no sólo las decisiones y

⁵⁹ Véase Freeman, *op. cit.*, pp. 141-48.

⁶⁰ Véase Heymann, Jody, *The Widening Gap*, 2000, pp. 15-66.

⁶¹ Ver Alstott, "Why the EITC Doesn't Make Work Pay", pp. 19-20 (donde se resumen datos comparativos sobre apoyo público para padres en edad laboral y sus hijos).

⁶² Alstott, "Is the Family at Odds with Equality? The Legal Implications of Equality for Children".

suerte de los padres sino también la distribución de riesgos ordenada por el derecho. Los adultos también enfrentan riesgos determinados por el derecho. El derecho actual considera “padres perezosos” a los padres con múltiples familias que no pagan la manutención debida, los cuales “victimizan” a sus hijos.⁶³ Pero la naturaleza trágica de tales situaciones refleja la distribución jurídica de la responsabilidad financiera hacia los niños. En un sistema legal que garantizara recursos para el desarrollo adecuado para todos los niños, no haríamos que el éxito de los padres dependiera de su destino en el mercado laboral. En un sistema así, incluso los padres de bajos ingresos podrían desempeñar su papel exitosamente, y un padre perezoso sería aquél que abandona o descuida a sus hijos en lugar de uno que no puede pagar.

C. Conclusión: disrupción familiar y seguridad social

Por tradición, el derecho familiar y la seguridad social ocupan distintos campos en el derecho. El derecho familiar, que se enseña en un conjunto de cursos, se centra en la adjudicación de casos trágicos. Un curso de derecho familiar típico ilustra de manera exhaustiva (y emocionalmente agotadora) la gama de riesgos que pueden destruir la vida familiar. El divorcio, el abandono de alguno de los padres, la enfermedad mental, la pobreza, la discapacidad, el abuso de sustancias, la violencia doméstica, todas pueden producir la ruina financiera y personal.

La seguridad social, si es que se enseña en las facultades de derecho estadounidenses, se enseña en un curso sobre políticas públicas de bienestar social o derecho de la pobreza o en forma de clínica. Los cursos académicos se concentran en las reglas que aseguran a los trabajadores en contra de disrupciones laborales causadas por desempleo, incapacidad y muerte temprana. El problema central para el derecho parece a menudo ser el riesgo moral: ¿Cómo pueden los programas amortiguar el riesgo sin incentivar a los tra-

⁶³ Véase, por ejemplo, *State vs. Oakley*, 2001 WI 103, párrafos 9, 20, 45 Wis 2d 447, 629 N.W.2d 200.

bajadores a tomar trabajos riesgosos, renunciar a la capacitación, prolongar el desempleo, o exagerar la discapacidad?⁶⁴

En este ensayo, he sugerido que el derecho familiar puede ser entendido como una parte del sistema de seguridad social y que los académicos pueden aplicar al derecho familiar algunas de las herramientas analíticas y categorías usadas en la seguridad social. Los casos *Wilson* y *Brown* ilustran cómo los dos sistemas operan juntos para distribuir los riesgos de incapacidad y disrupción familiar, y cómo algunos cambios en cada uno de los regímenes podrían alterar el perfil de riesgo.

El análisis en este texto también plantea la pregunta de si las preocupaciones que animan al derecho familiar podrían tener aplicaciones importantes en la seguridad social. El derecho familiar pone al frente y al centro los riesgos por disrupciones en dos funciones de la familia: manutención financiera y cuidado práctico. Cuando las familias se disuelven o fallan en formarse, o cuando familias aparentemente intactas fallan en cumplir las responsabilidades de manutención y cuidado que les son asignadas por el derecho, puede resultar una tragedia.

En un proyecto en curso, me pregunto si la seguridad social podría y debería hacer más para reconocer y abordar las disrupciones en la vida afectiva. La seguridad social ahora asegura el papel del trabajador/proveedor o de la trabajadora/proveedora y los beneficios intentan remplazar los cheques de pago perdidos. Pero las disrupciones en la vida afectiva pueden tener consecuencias tan graves como las disrupciones en el trabajo.

El derecho suele suponer que los individuos existen dentro de las familias. Como en el caso de Elma Wilson, los beneficios de seguridad social para

⁶⁴ Véanse Mashaw, Jerry L. y Reno, Virginia, "Social Security Disability Insurance: A Policy Review", en Thomason, Terry *et al.* (eds.), *New Approaches to Disability in the Workplace*, 1998, pp. 245, 247 (donde se resumen datos que muestran resultados económicos negativos entre la gente que reclama beneficios por un seguro de discapacidad pero que son considerados no elegibles) y Alstoot, "Why the EITC Doesn't Make Work Pay", p. 19 (donde se resumen datos sobre la prevalencia de la discapacidad relacionada con accidentes de trabajo entre la gente que no recibe el SSI o el SSDI).

individuos, incluyendo el SSDI, son a menudo inadecuados en cantidad, en ausencia de contribuciones familiares. El derecho familiar asume que los cónyuges en un matrimonio en curso proporcionan cuidado financiero y práctico.⁶⁵ Y se presume que los padres son custodios adecuados si no existe una prueba sólida que indique lo contrario.⁶⁶ Estas presunciones legales a menudo operan incluso cuando la familia se encuentra ausente o cuando falla en satisfacer sus funciones, con graves consecuencias para el desarrollo de adultos y niños.⁶⁷

Sin duda, el derecho actual amortigua la disrupción familiar en diversos grados, dependiendo de las circunstancias. La seguridad social, en particular, es una fuente principal de apoyo financiero para las familias, pero no aborda —porque no está diseñada para eso— las deficiencias financieras que surgen de otras fuentes que no sean la disrupción en el trabajo. Una persona en edad laboral sin discapacidades no tiene ninguna pretensión que pueda ejercer en el sistema, incluso si es incapaz de mantenerse a sí misma o a sus dependientes debido a la disrupción de la familia. Mas allá de la seguridad social, una variedad de programas tasados de conformidad con los medios económicos asiste a las familias y a los niños que caen en la pobreza. Los padres (divorciados o no) pueden recurrir al TANF o a la asistencia general

⁶⁵ Véase Rosenbury, *op. cit.*, p. 191.

⁶⁶ Véase Santosky vs. Kramer, 455 U. S. 745, 760 (1982).

⁶⁷ Véase Romero, Adam P., *Living Alone: New Demographic Research*, en Fneman Martha A. (ed.), *Transcending The Boundaries of Law* 2009, pp. 3-4 (manuscrito en archivo en la biblioteca de Harvard Law School). Para una ilustración de las consecuencias de la presunción jurídica de la aptitud parental, véase, por ejemplo, Eden F., 741 A.2d 873 (Conn. 1999) (donde se termina con los derechos parentales de una madre con una enfermedad mental de un niño con necesidades especiales). Por años, el niño, Eden, pasó entre diversas casas adoptivas y el cuidado de su madre. La educación especial y otros servicios fueron a menudo interrumpidos y la madre recibió tratamiento inadecuado para su propia enfermedad mental y servicios de apoyo ineficientes durante los esfuerzos de reunificación. Para cuando el caso de terminación llegó a los tribunales, Eden había desarrollado un desorden en la capacidad para vincularse con personas—, una discapacidad emocional de larga duración con consecuencias potencialmente graves. Aunque la madre, desde el punto de vista del tribunal, amaba sinceramente a su hijo, necesitaba ayuda significativa dada su discapacidad. Las protecciones de seguridad social existentes —una mezcla del SSI, orfanatos, Medicaid, y educación especial escolar— le fallaron al niño y también a la madre.

si la pobreza es extrema. El seguro médico público (Medicaid) y las expansiones del SCHIP ofrecen seguro médico a muchos niños pobres y casi pobres.⁶⁸ El SSI para las personas de la tercera edad y con discapacidad y los programas estatales de asistencia general, así como los vales para alimentos también asisten a los pobres. Programas especiales y generales de educación también complementan el cuidado parental de los hijos. Pero, una vez más, son programas antipobreza generalizados en lugar de esfuerzos dirigidos a abordar la ausencia o disfuncionalidad de la familia.

Una idea preliminar, que merece mayor exploración, se basa en la idea del estado de bienestar de dos niveles que a menudo se invoca en discusiones sobre el trabajo de cuidados de las mujeres.⁶⁹ El derecho actual da a la disrupción familiar —como al trabajo de cuidados— una prioridad menor y un estatus inferior, y ofrece protecciones fragmentadas que abordan solamente la pobreza extrema. En el caso de fallas en el cuidado familiar, los adultos no tienen una pretensión legal de cuidado a menos que la falta de cuidado lleve a una condición médica reconocida que autorice hospitalización o cuidado especializado en casa. Las fallas en el cuidado familiar de niños —el descuido infantil— teóricamente dispara la acción estatal, pero en la práctica el descuido tiene que ser severo, duradero, detectable por alguna persona externa a la familia, y el Estado debe actuar sobre él, con muchas brechas en el sistema.⁷⁰

⁶⁸ Para datos sobre la cobertura de seguros médicos, véase U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI02. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h02_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School); U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI03. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h03_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School); U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI04. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h04_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School).

⁶⁹ Véase, por ejemplo, Gordon, Linda, *Pitied But Not Entitled*, 1994, pp. 293-99 (donde se describe una dicotomía en la previsión social en los Estados Unidos entre la seguridad social y la asistencia pública). En contraste, véase Howard, Christopher, *The Welfare State Nobody Knows*, pp. 2007, 29-31 (donde se argumenta que el reclamo de dos niveles exagera las diferencias entre programas de bienestar social).

⁷⁰ Véase Waldfogel, *op. cit.*, capítulos 1-2.

Quizás las protecciones actuales son suficientes: quizás es adecuado proteger simplemente en contra de la forma más extrema de pobreza. Pero esto presupone las cuestiones normativas importantes: ¿debería la gente estar asegurada en contra de la falla de la familia solamente cuando hay pobreza? ¿O deberían tener alguna pretensión exigible a un estándar de vida más alto o un apoyo menos estigmatizador?

Las mismas preguntas surgen en la seguridad social tradicional relacionada con el empleo, y, en ese contexto, la sociedad ofrece respuestas diferentes. Cuando algún proveedor o proveedora abandona o sufre discapacidad o muerte temprana, su suerte dispara una gama de protecciones estándar de seguridad social que intentan no solamente mantener a la persona fuera de la pobreza sino prevenir una caída radical en el estándar de vida.⁷¹ Los beneficiarios incluyen al trabajador o trabajadora, a sus hijos jóvenes, su cónyuge (si los hijos son jóvenes) y posiblemente a su excónyuge. Los beneficios son financiados como un derecho por el gobierno federal, y son concedidos como un paquete por una sola agencia. No todo trabajador con discapacidad o retirado califica,⁷² pero los beneficios son relativamente generosos para aquellos que sí.

⁷¹ Como demuestra el caso de Elma Wilson, el sistema no opera necesariamente de esa manera para cada persona que recibe ingresos; sino para los trabajadores con ingresos estables de largo plazo, el sistema provee hoy un ingreso por encima del nivel de pobreza. En 2007, un trabajador que durante un largo plazo ganaba el salario mínimo habría recibido un beneficio mensual de 845.70 dólares o un beneficio anual de 10,148 dólares al retirarse. Un trabajador que gana 75% de los ingresos promedio recibiría 13,922 dólares por año al retirarse. Soc. Sec. Admin., Office of Retirement and Disability Policy: *Bulletin Annual Statistical Supplement*, 2008. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2008/2a20-2a28.html#table2.a20>» (archivo en la biblioteca de Harvard Law School). El umbral de pobreza en 2007 para una persona (de 65 años de edad) era de 9,944 dólares. U.S. Census Bureau, *Poverty Thresholds for 2007*. Disponible en: «<http://www.census.gov/hhes/www/poverty/threshld/thresh07.html>» (archivo en la biblioteca de Harvard Law School). Para un trabajador que ha ganado bajos ingresos durante un largo periodo, la seguridad social ahora contribuye aproximadamente 65% del salario del trabajador retirado. Véase Martin, Patricia P., "Comparing Replacement Rates Under Private and Federal Retirement Systems", *Soc. Security Bull.*, 65, 2003-2004. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v65n1/v65n1p17.html>».

⁷² Véase Mashaw & Reno, *op. cit.*, p. 247.

Algunas feministas han cuestionado a la seguridad social actual sobre la base de dos razones principales. Primero, han hecho notar que la seguridad social toma como modelo al proveedor o la proveedora con un matrimonio duradero, con un historial de trabajo estable de largo plazo y un cónyuge dependiente. Los académicos han señalado que las esposas en parejas donde existen dos personas que generan ingresos pagan impuestos desproporcionadamente altos y que las mujeres cuyo historial laboral incluye periodos de trabajo de cuidados no remunerado pueden calificar a beneficios menores.⁷³ Segundo, los académicos han hecho notar que el seguro por desempleo y la seguridad social no protegen en contra de la disrupción en el trabajo debida a obligaciones de cuidado familiar.⁷⁴

Las feministas han trabajado también para mejorar el estatus de las mujeres después del divorcio. Aunque se discute la magnitud de las dificultades financieras sufridas por una mujer después del divorcio, la disolución de la familia parece producir desventajas de largo plazo. Una extensa bibliografía que se extiende a lo largo de varias décadas ha propuesto reformas en las reglas de derecho familiar que regulan la manutención, la división de propiedad y la manutención infantil.⁷⁵

⁷³ Las protecciones existentes para quienes prestan trabajos de cuidado presuponen un matrimonio duradero con un hombre proveedor, una condición cada vez más en contradicción con la realidad de la vida de varias mujeres. El resultado es que las mujeres que nunca se han casado, divorciadas y viudas a menudo se encuentran en un estado de menos seguridad que otras. Los investigadores han propuesto integrar el trabajo de cuidados al modelo de seguridad social basado en el empleo —por ejemplo, al ofrecer crédito de ganancias en la seguridad social por los años dedicados a los trabajos de cuidado—.

⁷⁴ Abandonar el trabajo para cuidar a un hijo o cónyuge, por ejemplo, ha sido tradicionalmente causa de descalificación para que un trabajador reciba compensación. Los beneficios de incapacidad por maternidad nacionales solamente cubren a la mitad de la fuerza de trabajo y proporcionan solamente incapacidad sin goce de sueldo. Véase U.S. Department of Labor, *Wage and Hour Division: Appendix A1 Tables*. Disponible en: «<http://www.dol.gov/whd/fmla/APPX-A-1-TABLES.htm>». (Tabla A1-3.1) (Archivo en la biblioteca de Harvard Law School). Los académicos han propuesto expandir los programas de incapacidad por maternidad con goce de sueldo y de asistencia de cuidados infantiles.

⁷⁵ Véase, en general, “Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations”, *Am. Law Inst.*, 2000.

Por el contrario, mi proyecto considerará si la seguridad social debería abordar la disrupción familiar directamente. Existe algún traslape con preocupaciones existentes: el seguro por disrupciones en la vida afectiva asistiría a los trabajadores de cuidados que se encuentren sin apoyo familiar, como las mujeres divorciadas, las que nunca han estado casadas y las viudas identificadas como en necesidad por el primer grupo de académicos. Pero la seguridad social por disrupción en la vida familiar cuestionaría el modelo de disrupción laboral en lugar de trabajar con él. También pondría la atención en una clase de personas más amplia, abordando no solamente a los trabajadores y trabajadoras de cuidado sino también a personas que dependen del apoyo financiero de sus familias en sus trabajos de cuidado.

Entonces, en términos más amplios, la pregunta que me planteo es si el derecho podría y debería ampliar el catálogo de roles sociales y riesgos que califican para la seguridad social más allá del papel de trabajador y los riesgos de disrupción laboral. ¿Sería realizable, deseable? ¿Y qué significaría promulgar un seguro social para proteger a adultos y niños contra los riesgos presentados por las disrupciones en la vida afectiva?

Me viene a la mente una serie de cuestiones normativas y tecnocráticas. Alguien podría objetar que son las personas las que generan para sí mismas la disrupción de la familia a través de decisiones personales —casarse a pesar de la incompatibilidad, tener hijos cuando se tienen pocos ingresos o depender de una pareja de la que no se puede depender—. ¿Sería justo esperar que personas con diferentes creencias religiosas o personales sobre la familia subsidiaran las decisiones más íntimas de unos y otros? ¿Sería justo imponer a las familias exitosas la carga de los resultados de uniones desacertadas o arriesgadas? ¿Cómo serían los beneficios? ¿Cómo puede el Estado dar un seguro contra un evento tan común como el divorcio? ¿Y cómo serían los beneficios? ¿Qué forma de tributación debería sostener el sistema?

El riesgo moral representa otro gran desafío: ¿las personas se casarían y divorciarían muy casualmente, poniendo en peligro más aún a la frágil familia estadounidense? ¿Tendría hijos la gente con demasiada facilidad? ¿Se

basaría el sistema en relaciones formales —como matrimonio, divorcio y paternidad— o intentaría reconocer otras relaciones de apoyo y cuidado? Y, de ser así, ¿cómo?

¿Y qué hay de las personas sin familias? Los sistemas de salud y de bienestar social, sólo por mencionar dos ejemplos, a menudo asumen que los individuos tienen familiares que están listos para defender sus intereses y proporcionar cuidado práctico.⁷⁶ ¿Pero qué pasa con los individuos que no cuentan con el apoyo de su familia? El derecho actualmente trata la falta de una familia como una cuestión privada, y deja que los individuos asuman las consecuencias. Pero un régimen jurídico alternativo podría tratar la falta de una familia de manera diferente: el derecho podría expandir, más allá del matrimonio y la paternidad formales, las categorías de cuidadores privilegiados o cuidadoras privilegiadas. O podría tomar en cuenta la falta de una familia al determinar los beneficios sociales, al pagar —por ejemplo— beneficios más altos a un individuo con una discapacidad que vive solo (como Elma Wilson).

Pero, una vez más, ¿deberíamos conceptualizar la falta de familia como una decisión individual? Después de todo, algunas personas tienen rasgos personales (irritabilidad o rigidez) o hábitos que alejan a los demás. ¿O deberíamos tomar en cuenta que la falta de una familia puede surgir en diferentes formas —y a menudo refleja una mezcla de suerte, rasgos personales y la situación social en general?

En principio, puede parecer incómodo concebir las relaciones personales como una cuestión de interés del Estado. Puede parecer obviamente injusto que quienes forman relaciones fácilmente y se mantienen en ellas subsidien a los que son hostiles, quisquillosos o simplemente peripatéticos en sus relaciones. Pero una mayor reflexión sugiere que preocupaciones similares surgen con relación al establecimiento de seguros contra la disrupción laboral. Por ejemplo, a algunas personas les preocupa que el seguro de desempleo

⁷⁶ Véase Romero, *op. cit.*, pp. 3-4.

subsidia gente que provoca su propia condición de desempleo, al escoger una carrera equivocada, un jefe equivocado o una compañía deficiente. Otras objetan que los trabajadores en trabajos de bajo riesgo deben pagar por otros que escogen trabajos más riesgosos. A otras le preocupa que el seguro social por desempleo y discapacidad pueda conducir a las personas oportunistas a permanecer desempleadas por mucho tiempo.

Pero todos estos se consideran problemas tratables —si no completamente solucionables— en el ámbito de la seguridad social dirigida a la disrupción laboral, y podemos usar las mismas herramientas teóricas y técnicas para analizar las disrupciones de la vida afectiva. Los subsidios combinados culturales y morales son omnipresentes en los estados modernos y hay teorías normativas que abordan la cuestión de cuándo es —y no es— permisible pedir a un grupo de personas que asuma los riesgos tomados por otros. El riesgo moral permea toda forma de seguro, y si bien el riesgo moral puede imposibilitar los seguros en su totalidad, hay una gran cantidad de herramientas para administrar dicho riesgo, que incluyen los pagos compartidos, la elegibilidad categórica, los pagos retrasados, los beneficios limitados, la autofinanciación, etcétera.

Si bien estas preguntas esperan un tratamiento más sostenido, este ensayo ha intentado plantar la primera semilla: la tragedia familiar no es simplemente el producto de fallas, decisiones y suerte privadas. Más bien, el sufrimiento familiar refleja estructuras legales que distribuyen riesgos y definen las obligaciones que los ciudadanos tienen unos con otros. Para alterar los patrones actuales de privilegio y vulnerabilidad, debemos buscar reformar el derecho familiar, la seguridad social y otras estructuras jurídicas.

D. Bibliografía

42 U. S. C. 2006, § 402.

42 U. S. C., 2007, § 402(b).

Alstoot, Anne L., *No Exit*, 2004.

- Alstott, Anne L., "Is the Family at Odds With Equality? The Legal Implications of Equality for Children", *S. Cal. L. Rev.*, 82, 2008.
- Alstott, Anne L., "Why the EITC Doesn't Make Work Pay", *Colum J. L. & Soc., Probs.*, 43, 2009.
- Areen, Judith, *Family Law*, 4^a. ed., 1999.
- Areen Judith y Regan, Milton C. Jr., *Family Law*, 5a ed., 2006.
- Caso de Brown vs. Brown, 503 N.W. 2d 280 (Wis. Ct. App. 1993).
- Caso de Eden F., 741 A.2d 873 (Conn. 1999)
- Caso de *Lonsdale vs. McEwen*, 821 N. Y. S. 2d, 155 (N. Y. App. Div. 2006).
- Caso de *Marriage of Biderman*, 6 Cal. Rptr. 2d 791 (Cal. Ct. App. 1992).
- Caso de *Marriage of Heistermann*, 286 Cal. Rptr. 127, 130, 133 (Cal. Ct. App. 1991).
- Caso de *Marriage of Wilson*, 247 Cal. Rptr. 522 (Cal. Ct. App. 1988).
- Caso de McGuire vs. McGuire, 59 N. W. 2d 336, 342 (Neb. 1953);
- Caso de Santosky vs. Kramer, 455 U. S. 745, 760 (1982).
- Caso de State vs. Oakley, 2001 WI 103, párrafos 9, 20, 45 Wis 2d 447, 629 N.W.2d 200.
- Casper, Emma, *Review of Child Support Policies for Multiple Family Obligations*, septiembre de 2006. Disponible en: «<http://www.irlp.wisc.edu/research/childsup/cspolicy/pdfs/Caspar-Task4A-2006.pdf>».
- Cherlin, Andrew J., *The Marriage Go-Round*, 2009.
- Corbett, Thomas, "The Wisconsin Child Support Assutance System: From Plausible Proposals to Improbable Porspects", en Garfinkel, Irwin *et al.* (eds.), *Child Support Assurance*, 1992.
- Duncan, Greg J. y Brooks-Gunn, Jeanne (eds.), *Consequences of Growing Up Poor*, 1997.
- Ellman, Mark Ira y Ellman, Tara O'Toole, "The Theory of Child Support", *Harv. J. on Legis.*, vol. 45, 2008.
- Fineman, Martha Albertson, *The Neutered Mother, The Sexual Family*, 1995.
- Fneman Martha A. (ed.), *Transcending The Boundaries of Law* 2009
- Freeman, Richard B., *America Works*, 2007.
- Garfinkel, Irwin *et al.* (eds.), *Child Support Assurance*, 1992.
- Garfinkel, Irwin *et al.* (eds.), *Fathers Under Fire*, 1998.

- Garfinkel, Irwin, *Assuring Child Support*, 1994.
- Gordon, Linda, *Pitied But Not Entitled*, 1994.
- Heymann, Jody, *The Widening Gap*, 2000.
- Howard, Christopher, *The Welfare State Nobody Knows*, 2007.
- Huntington, Clare, "Repairing Family Law", *Duke Law Journal*, vol. 57, 2008.
- Krause, Harry D. y Meyer, David D., *Family Law in a Nustshell*, 5a. ed., 2007.
- Lester, Gillian, "A Defense of Paid Family Leave", *Harv. J. L. & Gender*, vol. 28, 2005.
- Liebman, Jeffrey B., "Redistribution in the Current U. S. Social Security System", *National Bureau of Economic Research*, Working Paper No. 8625, 2001.
- Lockie, Adrienne Jennings, "Multiple Families, Multiple Goals, Multiple Failures", *Harv. J. L. & Gender*, vol. 32, 2009.
- Marmor, Theodore R. et al., *America's Misundertood Welfare State*, 1990.
- Martin, Patricia P., "Comparing Replacement Rates Under Private and Federal Retirement Systems", *Soc. Security Bull.*, 65, 2003-2004. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v65n1/v65n1p17.html>».
- Mashaw, Jerry L. y Reno, Virginia, "Social Security Disability Insurance: A Policy Review", en Thomason, Terry et al. (eds.), *New Approaches to Disability in the Workplace*, 1998.
- Mayer, Susan E., *What Money Can't Buy*, 1997.
- McClain, Linda C., *The Place of Families*, 2006.
- Minow, Martha, "How Should We Think About Child Support Obligations?", en Garfinkel, Irwin et al. (eds.), *Fathers Under Fire*, 1998,
- Okin, Susan Moller *Justice, Gender, and The Family*, 1989.
- "Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations", *Am. Law Inst.*, 2000.
- Romero, Adam P., *Living Alone: New Demographic Research*, en Fneman Martha A. (ed.), *Transcending The Boundaries of Law* 2009, pp. 3-4
- Rosenbury, Laura A., "Friends With Benefits?", *Michigan Law Review*, Vol. 106, 2007.

- Soc. Sec. Admin., Office of Retirement and Disability Policy: *Bulletin Annual Statistical Supplement*, 2008. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2008/2a20-2a28.html#table2.a20>»
- Soc. Sec. Admin., Pub No. 05-10026, *Benefits for Children with Disabilities*, 10-1. Disponible en: «<http://www.ssa.gov/pubs/10026.pdf>».
- Staff of The House Comm. On Ways & Means, 110th Cong., 2008 *Green Book: Background Material and Data on Programs Within The Jurisdiction of the Committee on Ways and Means* § 3-17. Disponible en: «<http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/110/ssi.pdf>».
- Staff of the House Comm. On Ways & Means, *supra* nota 23, §1. Disponible en: «<http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/111/ssgb.pdf>».
- Thomason, Terry *et al.* (eds.), *New Approaches to Disability in the Workplace*, 1998.
- U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI02. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h02_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School); U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI03. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h03_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School); U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Table HI04. Disponible en: «http://www.census.gov/hhes/www/macro/032008/health/h04_001.Htm» (en archivo en la biblioteca de Harvard Law School).
- U.S. Census Bureau, Historical Income Tables, Table H-6. Disponible en: «<http://www.census.gov/hhes/www/income/histinc/h06ar.html>» (en archivos de la biblioteca de the Harvard Law School).
- U.S. Census Bureau, *Poverty Thresholds for 2007*. Disponible en: «<http://www.census.gov/hhes/www/poverty/threshld/thresh07.html>»
- U.S. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVS., PRIOR HHS POVERTY GUIDELINES AND FEDERAL REGISTER REFERENCES, 1986. Disponible en «<http://aspe.hhs.gov/poverty/figures-fed-reg.shtml>».
- U.S. Department of Labor, *Wage and Hour Division: Appendix A1 Tables*. Disponible en: «<http://www.dol.gov/whd/fmla/APPX-A-1-TABLES>».

htm». (Tabla A1-3.1) (Archivo en la biblioteca de Harvard Law School). Los académicos han propuesto expandir los programas de incapacidad por maternidad con goce de sueldo y de asistencia de cuidados infantiles.

Waldfoegel, Jane, *The Future of Child Protection*, 1982.

Weinrib, Ernest J., *The Idea of Private Law*, 1995.

De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina *

Magdalena Sepúlveda **

* Este artículo fue publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Series de Política social, No. 189. Marzo 2014.

Este documento fue elaborado por Magdalena Sepúlveda Carmona, consultora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, en el marco del programa de cooperación conjunto de la CEPAL y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, “Promoting equality in Latin America and the Caribbean”. Una versión preliminar de este documento fue presentada en el seminario internacional “Políticas públicas para la igualdad: hacia sistemas de protección social universal”, que tuvo lugar en Montevideo, los días 4 y 5 de diciembre de 2013. El documento incorpora comentarios de Simone Cecchini, Rodrigo Martínez y María Nieves Rico. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la organización.

** Directora Ejecutiva de la *Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights* (Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para Lograr la Agenda 2030.

SUMARIO: A. Introducción; B. La obligatoriedad y valor agregado del enfoque de derechos; C. La protección social con enfoque de derechos; I. ¿Derecho a la protección social o derecho a la seguridad social?; II. Contenido normativo del derecho a la seguridad social; III. El derecho a la seguridad social (protección social) como herramienta para el disfrute de otros derechos; D. Elementos básicos de un enfoque basado en derechos; I. Marco legal e institucional adecuado; II. Estrategia integral, coherente y coordinada de protección social; III. Principios de igualdad y no discriminación; 1. La vocación universal de los derechos. ¿Programas focalizados o universales?; 2. Asegurar que las mujeres se beneficien en igualdad de condiciones que los varones; 3. Necesidades particulares de las personas y grupos más vulnerables y marginados; 4. Estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y adecuación; IV. Asegurar la no vulneración de derechos mediante las condicionalidades (corresponsabilidades); V. Participación; VI. Transparencia y acceso a la información; VII. Rendición de cuentas y acceso a mecanismos de reclamo y reparación; E. Lecciones aprendidas; I. La consolidación de un marco legal e institucional adecuado; II. La búsqueda de estrategias integrales de protección social; III. Los desafíos en el respeto de los principios de igualdad y no discriminación; 1. En camino a la universalidad: el ejemplo de la salud; 2. Medidas para asegurar la inclusión de grupos especialmente desventajados; IV. Participación; V. Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información; F. La judicialización de los derechos sociales y su impacto en el diseño de las políticas de protección social; I. El caso de la Corte Constitucional de Colombia; II. Logros y desafíos de la judicialización; G. Conclusiones y recomendaciones de política pública; I. Dar el salto de la retórica a la práctica; II. Avanzar en el establecimiento de sistemas de protección social; III. Aprender de y consolidar las innovaciones de los programas de transferencia en efectivo en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas; IV. Realizar cambios estructurales para la igualdad; 1. Mejorar la calidad, adecuación y accesibilidad de los servicios públicos; 2. Avanzar en la educación de calidad; 3. Avanzar en los derechos laborales; V. Avanzar en la equidad de género y en las políticas públicas de cuidado; VI. Fomentar la armonización de las políticas fiscales con los derechos económicos, sociales y culturales; VII. Superar las barreras de capacidad e institucionales; VIII. Avanzar en la protección del medio ambiente; IX. Asegurar la rendición de cuentas y acceso a mecanismos de reclamo incluyendo la vía judicial; X. Respetar las libertades y derechos esenciales para la participación social; H. Bibliografía.

A. Introducción

Como ha indicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la gran tarea del siglo XXI es la construcción de sociedades inclusivas, más igualitarias y con pleno respeto de un marco de derechos (CEPAL, 2010). Una de las herramientas para lograr estos objetivos es asegurar que toda la población se encuentre protegida a través de sistemas de protección social.

En los últimos años, los sistemas de protección social han ganado preponderancia y apoyo político en el discurso de desarrollo y reducción de la pobreza, de una manera casi sin precedentes. Esto ha llevado a considerar la protección social como “una revolución silenciosa” (Barrientos y Hulmes, 2008). Los países latinoamericanos han estado a la cabeza de esta revolución, invirtiendo considerables recursos públicos en programas de protección social. Estos avances en materia de protección social han ido de la mano con un creciente discurso en favor de un enfoque de derechos en las agendas de desarrollo.

El creciente discurso de derechos va en línea con las obligaciones constitucionales e internacionales de los países de la región. La protección de los derechos humanos, que incluye el respeto y protección a las particularidades y requerimientos específicos de los diversos grupos de población, no es una opción más de política pública, sino que responde a obligaciones estatales asumidas en virtud de una amplia gama de normas jurídicas nacionales e internacionales de derechos humanos. Conforme a las cuales, los Estados están obligados a garantizar que los derechos humanos guíen el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas, incluyendo las relativas a la protección social.

Sin embargo, a pesar de la fuerte retórica de derechos que se advierte en diversos documentos de política pública, los países de la región aún tienen mucho que avanzar en su implementación práctica. Para hacer realidad el enfoque de derechos, parece necesario seguir avanzando en un marco conceptual que defina con mayor claridad cómo diseñar, implementar y evaluar políticas y programas de protección social desde una perspectiva de derechos.

Este documento busca contribuir al desarrollo teórico conceptual de un enfoque de derechos en las políticas y programas de protección social y analiza las lecciones aprendidas en algunos programas emblemáticos de la región, que han buscado avanzar en un enfoque de derechos.

El documento inicia con una breve referencia a la obligatoriedad y el valor agregado del enfoque de derechos. A continuación describe el contenido normativo del derecho a la seguridad social y como éste derecho es entendido como sinónimo de protección social en el derecho internacional de los derechos humanos. El documento luego describe en detalle los elementos básicos de un enfoque de derechos humanos, analizando en detalle cuáles son las implicaciones que el respeto de estos principios requeriría en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas de protección social. Una vez descritos los elementos básicos del enfoque de derecho, se analizan algunos programas específicos de protección social implementados en la región. A través del análisis de algunos casos, el documento busca demostrar que a pesar de la gran brecha que sigue existiendo entre la retórica de un enfoque de derechos y su operacionalización en políticas concretas de protección social, en algunos países de la región ha habido avances importantes. Los logros conseguidos pueden servir de ejemplo para la consolidación de un enfoque de derechos dentro y fuera de la región. El documento concluye con algunas recomendaciones de política pública para consolidar un enfoque de derecho en las políticas y programas de protección social.

B. La obligatoriedad y valor agregado del enfoque de derechos

El desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos ha marcado una transformación profunda en el derecho internacional y constitucional moderno, al momento que impone a los Estados el respeto a la dignidad humana y las normas de derechos humanos como un límite a la soberanía o potestad estatal.

La mayoría de las constituciones de los países de América Latina incorporan una amplia gama de derechos humanos o fundamentales, que incluye no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales (DESC).¹ Al mismo tiempo, las constituciones de la región consagran una protección amplia del principio de igualdad y no discriminación. Este principio impone la prohibición de la discriminación en razón del sexo, edad, etnia, discapacidad, estado de salud, y otros; la garantía de un trato en igualdad de condiciones para toda la población; y la obligación de adoptar medidas especiales para la protección de ciertos grupos que han sufrido de discriminación estructural, tales como mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con diferente orientación sexual o personas con VIH/SIDA.²

Además de los DESC expresamente consagrados en las constituciones nacionales, se debe de tener en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos adoptados tanto a nivel de las Naciones Unidas, como a nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos tratados internacionales, que consagran una amplitud de derechos,³ han sido incorporados en las

¹ Véase, por ejemplo, Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución de Colombia, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución de Brasil, Constitución del Ecuador, Constitución de la República de Paraguay.

² Véase, por ejemplo, Constitución de Colombia (artículos 7, 10, 23, 47, 68 y 70), Constitución de Ecuador, artículo 11 que establece "...Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad." El énfasis en políticas afirmativas que busquen mejorar el disfrute de los derechos por parte de los grupos más desventajados, es evidente también en un gran número de planes nacionales de derechos humanos, por ejemplo, Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú 2006-2011; Plan de Acción 2010-2011, República del Paraguay y Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos 2007-1017, Gobierno de Guatemala.

³ Aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el instrumento normativo que de manera más comprehensiva elabora estos derechos, otros tratados internacionales posteriores, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las

Constituciones de los países de la región, estableciéndose su jerarquía sobre el derecho interno y en algunos casos incluso sobre la misma norma Constitucional.⁴ Esto significa que los derechos humanos incluyendo los DESC, consagrados en tratados internacionales hacen parte del ordenamiento legal doméstico de los Estados partes.

Este marco normativo constituye la base de la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas públicas. En efecto, la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas públicas y en particular en los programas de protección social es el resultado de un desarrollo legal e institucional demandado por las mismas constituciones nacionales que establecen la obligatoriedad de la protección, promoción y cumplimiento de todos los derechos humanos.

Este avance normativo en materia de derechos humanos se ha visto reflejado en la creciente incorporación de un enfoque de derechos en una diversidad de instrumentos de política pública. Así en la región, ya no es extraño encontrar que los planes nacionales de desarrollo utilizan un lenguaje de derechos o colocan la observancia de los derechos humanos, como uno de sus ejes centrales o soportes transversales.⁵

Formas de Discriminación Racial (CERD), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a nivel global, así como el Protocolo de San Salvador, a nivel regional, consagran también importantes derechos económicos, sociales y culturales, en muchos casos adaptados a las particularidades de los grupos específicos que protegen.

⁴ Véase, por ejemplo, Constitución Chilena (1980), art. 5.2; Constitución de Guatemala (1986), art. 46; Constitución de Nicaragua (1995), art. 46; Constitución de Brasil (1998) art. 4; Constitución de Colombia (1991) art. 93; Constitución de Argentina (1994) art. 75; Constitución de Ecuador (2008) art. 11; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), art. 2; Constitución del Paraguay (1992), art. 137, Constitución de Costa Rica (2001), art. 7, Constitución de El Salvador (2000), art. 144.

⁵ Véase por ejemplo, República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, 2009; República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2011 y República del Paraguay. Paraguay para Todos y Todas, Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020, Asunción, 2010.

De esta forma, la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas sociales no es una opción de política pública más, que los países pueden optar por dar cumplimiento, sino que es una obligación jurídica asumida a través de las propias constituciones, los tratados internacionales y las leyes nacionales.

Un enfoque de derechos en la protección social no sólo es una obligación legal, sino que además puede servir a varios fines.

En primer lugar, un enfoque de derechos puede servir como catalizador del establecimiento o fortalecimiento de sistemas de protección social, en particular de sistemas no contributivos. El enfoque de derechos puede contribuir a lograr consensos políticos y sociales que den prioridad en la agenda política a la expansión o fortalecimiento de sistemas de protección social y la asignación de los recursos necesarios y sustentables para su puesta en práctica.

En segundo lugar, también puede contribuir a definir los niveles de protección social que se consideren aceptables en cada sociedad. En cumplimiento con los estándares internacionales, niveles aceptables de protección social serían aquellos que aseguren a todos los individuos un nivel de vida adecuado, con una garantía mínima de disfrute de DESC y sin discriminación.

En tercer lugar, el enfoque de derecho puede contribuir a la igualdad mediante la reducción de las brechas de oportunidades y la exclusión social que persiste en la región. Las normas internacionales promueven el acceso universal e impone el cumplimiento de estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, adecuación y calidad de los servicios públicos.

En cuarto lugar, teniendo en cuenta la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, un enfoque de derechos puede aportar en la búsqueda de un diseño institucional integral que haga hincapié en las sinergias y la coordinación entre las agencias y los proveedores de programas sociales con el objetivo de lograr alcanzar su máximo potencial.

Finalmente, puede contribuir al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas e impulsar la movilización ciudadana contra las diversas formas de discriminación y un mayor disfrute de los derechos.

En el contexto actual de altos niveles de desigualdad en la distribución de ingresos y riqueza en la región, el enfoque de derechos tiene el potencial de ser una herramienta eficaz para alcanzar el objetivo de protección social universal. Al poner énfasis en la universalidad, un enfoque de derecho puede lograr avances en la protección de los sectores más desaventajados de la población, a pesar de que por lo general no tienen voz directa en los procesos políticos.

C. La protección social con enfoque de derechos

Un enfoque de derechos humanos no prescribe las políticas públicas que los Estados deben adoptar, ya que los Estados tienen la facultad de formular las políticas públicas que sean más adecuada a sus propias circunstancias. Sin embargo, el debido cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de derechos humanos impone ciertas obligaciones de conducta y de resultado. Esto significa que las políticas públicas no sólo deben tender a un mayor disfrute de los derechos humanos de toda la población, sino que además, los procesos a través de los cuales se diseña, implementa y evalúan las políticas públicas deben estar en consonancia con los estándares de derechos humanos.

En materia de protección social, existe una amplia variedad de disposiciones constitucionales que son importantes para el desarrollo de un enfoque de derechos. Por ejemplo, nos encontramos que dentro del amplio listado de DESC consagrados en las constituciones de la región se incluye, en varias de ellas, el derecho a la seguridad social entendido en su ámbito contributivo y no contributivo.⁶ Asimismo, se deben tener en cuenta las disposiciones que

⁶ Véase, por ejemplo, Constitución Política de la República de Colombia, Colombia, art. 48; Constitución de la República Federativa de Brasil, Brasil, sección IV; y Constitución Política de Costa Rica, Costa Rica, art. 73.

consagran la igualdad de trato, la prohibición de toda forma de discriminación y la obligación de tomar medidas afirmativas para la protección de ciertos grupos que han sufrido de discriminación estructural o que son vulnerables.⁷ Otras disposiciones constitucionales, tales como las que consagran el derecho de participación de la población en la formulación de las políticas, el principio de rendición de cuentas, el acceso a la información y las relativas a la descentralización político-administrativa son también relevantes y deben guiar el establecimiento de programas de protección social.

I. ¿Derecho a la protección social o derecho a la seguridad social?

Los términos protección social y seguridad social se utilizan con una amplia variedad de significados, por lo que es necesario explicar la forma en que serán utilizados en este documento. El “derecho a la seguridad social” se establece en varios tratados internacionales de derechos humanos (ver cuadro 1).

Por lo tanto, es necesario hacer una breve referencia al contenido normativo de este derecho en los diversos instrumentos.

El primer instrumento internacional que consagró la seguridad social como un derecho fue la Declaración de Filadelfia, adoptada en 1944. Posteriormente, en 1948, el derecho a la seguridad social de cada ser humano, como miembro de la sociedad, fue oficialmente reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22).

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece:

Art. 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

⁷ Véase note 5 supra.

Art. 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Este derecho fue posteriormente incluido en una serie de tratados internacionales de carácter vinculante tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 (artículos 9 y 10), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 (artículo 5.e.iv), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 (artículo 11.1e), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) de 1989 (artículo 26), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990 (artículo 27) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006 (artículo 28).

En el ámbito regional (por ejemplo en el ámbito de la OEA), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San Salvador”) de 1988⁸ también consagra explícitamente el derecho a la seguridad social. Asimismo, este derecho se consagra en varios convenios adoptados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).⁹

⁸ Los Estados partes a febrero de 2014 son: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

⁹ Véase, por ejemplo, Convenio 102 (1952), Convenio 118 (1962), y Convenio 157 (1982). Particularmente relevante (aunque no vinculante para los Estados), es la Recomendación 202 (2012) relativa a los pisos de protección social.

En la mayoría de los instrumentos jurídicos mencionados se utiliza la expresión “derecho a la seguridad social”, salvo en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 28), que utiliza el término “protección social”.

Del trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del PIDESC) se puede deducir que los conceptos de “seguridad social” y “protección social” son sinónimos.¹⁰

Esto es evidente, por ejemplo, en la Observación General núm. 19 del Comité que señala:

1. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto) dispone que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto.
2. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gas-

¹⁰ Sobre el tema hay visiones diferentes. Pautassi (2013) argumenta que seguridad social y protección social no pueden ser asumidas como sinónimos, dado que el primer concepto se relaciona a un paquete de prestaciones (establecidas, por ejemplo, en el Convenio 102 de la OIT) y a un papel fuerte del Estado en su provisión, regulación y financiamiento, mientras que el concepto de protección social se referiría a un modelo más restringido, en que las personas, las familias, las comunidades y la sociedad civil desempeñan un papel más activo. A su vez, Cecchini y Martínez (2011) —reconociendo que la protección social es un concepto en evolución— diferencian entre protección y seguridad social, siendo el segundo uno de los componentes de la protección social, junto a la asistencia social y la regulación del mercado laboral.

tos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.

3. La seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social.
4. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluida el seguro social. La formulación del artículo 9 del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano. Estas medidas pueden consistir en:
 - a) Planes contributivos o planes basados en un seguro, como el seguro social expresamente mencionado en el artículo 9. Estos planes implican generalmente el pago de cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, los empleadores y a veces el Estado, juntamente con el pago de las prestaciones y los gastos administrativos con cargo a un fondo común.
 - b) Los planes no contributivos, como los planes universales (que en principio ofrecen la prestación correspondiente a toda persona expuesta a un riesgo o situación imprevista particular) o los planes de asistencia social destinados a determinados beneficiarios (en que reciben las prestaciones las personas necesitadas). En casi todos los Estados habrá necesidad de planes no contributivos, ya que es poco probable que pueda proporcionarse la protección necesaria a todas las personas mediante un sistema basado en un seguro.”

De tal manera, y en línea con la forma en que es utilizado el concepto por la OIT, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y por ende, para este documento, se utilizan las expresiones “derecho a la seguridad social” y “protección social” como sinónimos.

Cuadro 1. El derecho a la seguridad social en los instrumentos internacionales de derechos humanos

Tratados internacionales	Disposiciones
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)	El artículo 22 garantiza el derecho a la seguridad social. El artículo 25 reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial,... la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)	El artículo 9 reconoce el derecho de cada persona a la seguridad social. El artículo 10, 2) reconoce a las madres trabajadoras el derecho a percibir «prestaciones adecuadas de seguridad social». El artículo 10, 3) requiere de los Estados Partes la adopción de medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños y adolescentes.

Tratados internacionales	Disposiciones
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979)	El artículo 11, 1), inciso e), dispone que los Estados Partes deben eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en particular,... el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas. El artículo 11, 2), inciso b), requiere que los Estados Partes adopten medidas apropiadas para la adquisición de prestaciones sociales durante la licencia de maternidad. El artículo 14, 2) proclama el deber de los Estados Partes de eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y, en particular, asegurarle... el derecho a beneficiarse directamente de los programas de seguridad social.
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)	El artículo 26 reconoce a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluida el seguro social. Además, el artículo 27, 1) reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 27, los Estados Partes están obligados a adoptar, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, medidas apropiadas para ayudar a los padres a hacer efectivo este derecho y, en caso
	necesario, proporcionar asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

Tratados internacionales	Disposiciones
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)	El artículo 5, e), apartado iv), reconoce el deber de los Estados Partes de prohibir y eliminar la discriminación racial en el ejercicio, entre otros, del derecho a la seguridad social y los servicios sociales.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (1990)	El artículo 27 dispone que, con respecto a la seguridad social, todos los trabajadores migrantes y sus familiares gocen, en el Estado de empleo, del mismo trato que los nacionales en la medida que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de empleo pueden tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migrantes y sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado del que se trate deberá considerar la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieran aportado en relación con esas prestaciones, sobre la base del trato otorgado a los nacionales en situación similar. El artículo 54 dispone que los trabajadores migrantes que estén documentados o que se encuentren en situación regular gocen de igual trato que los nacionales del Estado de empleo, entre otras cosas en relación con las prestaciones de desempleo.

Tratados internacionales	Disposiciones
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)	El artículo 28 dispone que los Estados Partes reconozcan el derecho de las personas discapacitadas a la protección social y a gozar de este derecho sin ninguna discriminación por motivos de discapacidad, y que adopten medidas apropiadas para proteger y promover el ejercicio de este derecho.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”	El artículo 9 dispone que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. Asimismo, indica que cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de OIT (2011b).

II. Contenido normativo del derecho a la seguridad social

Las mayoría de los países de la región son partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)¹¹ que consagra el “derecho a la seguridad social” (artículo 9).

¹¹ A febrero 2014, los siguientes países de la región eran Estados partes del PIDESC: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité), órgano encargado de la supervisión del PIDESC, ha desarrollado el contenido de este derecho. Por analogía, es posible aplicar esta interpretación a las demás disposiciones internacionales de derechos humanos que contienen el derecho a la seguridad social.

En su Observación General núm. 19 sobre el derecho a la seguridad social, el Comité ha indicado que dentro de los elementos esenciales del derecho a la seguridad se incluye “el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”.¹²

El Comité es enfático en señalar que el contenido normativo del derecho a la seguridad social abarca tanto el seguro social (regímenes contributivos) como la asistencia social (regímenes no contributivos).¹³

El Comité ha especificado el sistema de seguridad social, debe abarcar: i) la atención de salud; ii) enfermedad; iii) vejez; iv) desempleo; v) accidentes laborales; vi) prestaciones familiares; vii) maternidad; viii) discapacidad y; ix) sobrevivientes y huérfanos,¹⁴ haciendo ver que el nivel de las prestaciones debe ser suficiente y que todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de la seguridad social. Las condiciones para acogerse a esas prestaciones deben ser razonables, proporcionadas, transparentes y asequibles a quienes tienen derecho a ellas.

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de). Por su parte, Belice y Cuba, son Estados firmantes.

¹² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante CDESC), Observación general núm. 19, párr. 2.

¹³ CDESC, Observación general núm. 19, párrs. 2-4.

¹⁴ CDESC, Observación general núm. 19, párrs. 12-21.

Las prestaciones deben ser de un nivel adecuado, esto es, que sean suficientes en importe y duración para asegurar a un nivel de vida adecuado y a la atención de salud. Asimismo, este derecho debe ser ejercido sin discriminación y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. De manera explícita se menciona la prohibición de discriminar en el ejercicio de este derecho por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social.¹⁵

Asimismo, el Comité ha enfatizado la importancia de dar prioridad a los grupos más desventajados. En palabras del Comité “aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las personas con discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que trabajan en su domicilio, los grupos minoritarios, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos.”¹⁶

El derecho a participar en la administración del sistema y el derecho al acceso a la información, también son elementos esenciales de este derecho. Según indica el Comité, “los beneficiarios de los planes de seguridad social deben poder participar en la administración del sistema. El sistema debe establecerse en el marco de la legislación nacional y garantizar el derecho de las personas

¹⁵ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 29.

¹⁶ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 31.

y las organizaciones a recabar, recibir y distribuir información sobre todos los derechos ofrecidos por la seguridad social de manera clara y transparente”.¹⁷

Aunque el Pacto prevé una aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que plantean los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes también tienen obligaciones inmediatas relativas al derecho a la seguridad social, como, por ejemplo, garantizar el ejercicio de ese derecho sin discriminación alguna; asegurar la igualdad de derechos de hombres y mujeres; entre otras.

El Comité ha indicado que una de las obligaciones básicas que este derecho impone sobre los Estados Partes, es la de proporcionar la satisfacción de un nivel mínimo indispensable de prestaciones que permita a las personas obtener al menos la atención de salud esencial, alojamiento y vivienda básicos, agua y saneamiento, alimentos y las formas más elementales de educación. Si un Estado Parte no puede proporcionar ese nivel mínimo para todos los riesgos e imprevistos hasta el máximo de los recursos de que dispone, el Comité recomienda que el Estado Parte, tras celebrar amplias consultas, seleccione un grupo básico de riesgos e imprevistos sociales.¹⁸

Es importante observar que la asignación de los recursos no queda librada enteramente a la discreción de los Estados. Los Estados Partes deben conceder cierta prioridad a la asignación de los recursos para garantizar el disfrute de los DESC de todas las personas en su territorio.

La obligación de progresividad significa que las medidas regresivas son inaceptables (Sepúlveda, 2001). Por lo tanto, si los Estados Partes adoptan medidas para reducir el ámbito o el nivel de beneficios de los programas de protección social, deben demostrar que esas medidas se han adoptado tras

¹⁷ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 26.

¹⁸ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 59.

un examen de todas las alternativas y que son enteramente justificables en lo que concierne a la protección de todos los DESC.¹⁹

El Comité reconoce que el ejercicio del derecho a la seguridad social conlleva importantes consecuencias financieras para los Estados Partes, pero observa que la importancia fundamental de la seguridad social para la dignidad humana y el reconocimiento jurídico de este derecho por los Estados Partes suponen que se le debe dar la prioridad adecuada en la legislación y en la política del Estado. Los Estados Partes deben elaborar una estrategia nacional para lograr que se ponga plenamente en práctica el derecho a la seguridad social, y asignar suficientes recursos fiscales y de otro tipo a nivel nacional. De ser necesario, deben tratar de obtener cooperación y asistencia técnica internacionales de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC.²⁰

III. El derecho a la seguridad social (protección social) como herramienta para el disfrute de otros derechos

En sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas, el respeto de los derechos humanos incluyendo los DESC, así como la garantía del principio de igualdad y no-discriminación imponen la adopción de medidas concretas de protección a los sectores más vulnerables de la población, que busquen asegurar el disfrute de al menos niveles mínimos esenciales de los DESC en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Existe una relación simbiótica entre el derecho a la seguridad social o protección social y los demás DESC tales como, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a la educación; el derecho a un nivel de vida adecuado incluyendo el derecho a la alimentación, vestido y vivienda; el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo (ver cuadro 2). En efecto, la evidencia muestra que los programas de protección social pueden contribuir

¹⁹ Véase CDESC, Observación general núm. 3, párr. 12; Observación general núm. 12, párr. 28; Observación general núm. 14, párr. 18; y Observación general núm. 19, párrs. 40 a 42.

²⁰ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 41.

significativamente a que las personas más pobres puedan disfrutar de niveles mínimos esenciales de algunos DESC (Barrientos y Niño-Zarazúa, 2010).

Como se ha señalado, “la protección social reduce considerablemente o elimina la probabilidad de no poder hacer frente a un riesgo contingente; limita la reproducción del círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad al evitar que las familias hipotequen a futuro activos claves para el desarrollo humano, como la salud y la educación, y facilita la implementación de estrategias dirigidas a empoderar a aquellos grupos más vulnerables frente a riesgos, particularmente a los niños, los ancianos y las mujeres” (Cecchini y Martínez, 2011, pág. 11). En otras palabras, la puesta en marcha de programas de protección social facilita el cumplimiento de una serie de derechos humanos, sobre todo los relacionados con el disfrute de los niveles mínimos esenciales de DESC.

Cuadro 2. Funciones de un sistema integral de protección social y su marco normativo en el derecho internacional de los derechos humanos

Funciones de un sistema integral de protección social	Marco normativo
I. Garantizar un ingreso que posibilite sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas.	Obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la seguridad social/protección social Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9 PIDESC) • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 CEDAW) • Convención sobre los Derechos del Niño (art. 26 CRC) • Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28 CDPD) Obligación de mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11 PIDESC)

Funciones de un sistema integral de protección social	Marco normativo
II. Identificar la demanda insatisfecha y garantizar el acceso a servicios sociales (salud, educación y vivienda, entre otros) y de promoción, para fortalecer el capital humano y la capacidad de respuesta autónoma de la población	Adoptar medidas progresivas hasta el máximo de los recursos disponibles, asegurando la satisfacción de al menos niveles mínimos esenciales (art. 2(2) PIDESC, art. 4 CRC) de los siguientes derechos: • Derecho a un nivel de vida adecuado incluyendo vivienda, vestido y alimentación (artículo 11 PIDESC, art. 27 CRC) • Derecho a la salud (art. 12 PIDESC, art. 12 CEDAW, art. 24 CRC) • Derecho a la educación (art. 13 PIDESC, art. 10 CEDAW, art. 28 CRC)
III. Fomentar el trabajo decente, promoviendo mejores políticas laborales para contribuir a la superación del riesgo asociado al mundo laboral, velando por la realización de los derechos laborales e integrando progresivamente al mercado formal de trabajo al grueso de la población económicamente activa de un país	Respetar, proteger y cumplir: • Derecho al trabajo y derechos en el trabajo (arts. 6 y 7 PIDESC, art. 11 CEDAW) Inclusión de las mujeres: Asegurar la igualdad en el goce del derecho al trabajo y los DESC entre hombres y mujeres (art. 2 PIDESC, art. 1 CEDAW) • Eliminar funciones estereotipadas y prejuicios que obstaculizan la incorporación al mercado laboral de las mujeres (art. 5 CEDAW) Inclusión de las personas con discapacidad: • Proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad del derecho al trabajo y los demás derechos a las personas con discapacidad (art. 1 CDPD) • Asegurar la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad (art. 3 CDPD)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Cecchini y Martínez (2011).

D. Elementos básicos de un enfoque basado en derechos

Como se ha señalado, un enfoque de la protección social (seguridad social) basada en derechos, implica que las políticas e instituciones de protección social deben tender al logro de un mayor disfrute de los derechos de toda la población, al tiempo que deben basarse en las normas y principios de derechos humanos, consagrados en la constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por el país.

Para contribuir a operacionalizar un enfoque de derechos en las políticas y programas de protección, esta sección identifica los elementos esenciales de un marco de derechos, de conformidad a las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

I. Marco legal e institucional adecuado

Un aspecto central del enfoque de derechos humanos es que las políticas y los programas de protección social estén establecidos y definidos a través de un marco legal e institucional adecuado, apoyados por una estrategia nacional y un plan de acción. La existencia de marco jurídico constituye la expresión formal de las intenciones de un Estado, tiene un carácter jurídicamente vinculante y con permanencia.

En general, los marcos jurídicos consisten en diferentes niveles, con una cierta coherencia jerárquica que comprende la constitución (poder constituyente), las leyes (poder legislativo) y los reglamentos y los documentos de política pública (poder ejecutivo). Un marco adecuado para la seguridad social comprendería todo el ámbito normativo, desde la consagración constitucional del derecho a la seguridad social, hasta un manual operacional que contenga detalles específicos de un programa determinado.

Aunque esto varía en los diferentes países, resulta esencial que las políticas y los programas de protección social se establezcan mediante una ley resultado de un proceso legislativo democrático. Asimismo, es adecuado examinar el

conjunto de la normativa relativa al tema, para cerciorarse que no existen otras leyes contradictorias, debiendo derogar, enmendar o cambiar las que sean incompatibles con un enfoque de derechos.²¹

Cuando los programas de protección social no se basan en leyes, sino que simplemente en decretos presidenciales, declaraciones de política, directrices o manuales operacionales (adoptados por el poder ejecutivo), se pone en peligro el disfrute de los derechos humanos por parte de los beneficiarios del programa. En efecto, sin la aprobación de una ley formal, las políticas y programas son muy vulnerables a los cambios gubernamentales arriesgándose la existencia misma del programa en caso de que un nuevo gobierno no lo considere políticamente valioso.

La ausencia de un marco legal adecuado socava la idea misma de un enfoque de derechos, puesto que el programa difícilmente será considerado como un derecho de los titulares o beneficiarios, que pueden exigir del Estado y por el cual las autoridades públicas son responsables. Asimismo, la ausencia de un marco legal e institucional adecuado atenta contra el principio de rendición de cuentas, puesto que dificulta la identificación de los diversos componentes del programa, tales como quiénes son sus beneficiarios, su duración o cuáles son las autoridades responsables de su ejecución.

Si los programas de protección social no están establecidos por la ley, también existe un mayor riesgo de que no sean sostenibles y por ende que se les dé término de manera abrupta dejando a los beneficiarios en una situación más difícil que antes de su institución, debido a la pérdida de los beneficios que recibían como parte del programa.

Un marco jurídico e institucional y una estrategia nacional son requisitos esenciales para garantizar que se trata de una política de Estado, que cuenta con un compromiso institucional a largo plazo, donde se garantiza la existencia de recursos financieros y humanos adecuados.

²¹ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 67.

Como mínimo, un marco legal e institucional adecuado es aquel que contiene: i) los criterios de elegibilidad; ii) define las distintas funciones y responsabilidades de los diversos actores involucrados en la ejecución los programas (por ejemplo, los gobiernos a nivel nacional y local); iii) articula las necesidades financieras a largo plazo y su sostenibilidad; iv) establece mecanismos de denuncias y quejas; y v) establece las vías de participación de la sociedad civil y los beneficiarios.

II. Estrategia integral, coherente y coordinada de protección social

La interdependencia, indivisibilidad y fortalecimiento mutuo de los derechos humanos hace necesario un enfoque integral. La fragmentación y la falta de coordinación entre diversos programas, actores y entre los varios niveles de gobierno responsables de la aplicación de políticas sociales aumentan la probabilidad de que una política social determinada sea ineficaz y que se vulneren los derechos de las personas que viven en situación de pobreza.

Como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para garantizar el derecho a la seguridad social “la estrategia y el plan de acción deben concebirse razonablemente en función de las circunstancias; tener en cuenta la igualdad de derechos de hombres y mujeres y los derechos de los grupos más marginados y desfavorecidos; basarse en los principios y normas de derechos humanos; abarcar todos los aspectos del derecho a la seguridad social; establecer los objetivos o metas que han de alcanzarse y los plazos para su consecución, junto con los correspondientes criterios de referencia e indicadores para vigilarlos; y contener mecanismos para obtener recursos financieros y humanos. Al formular y aplicar las estrategias nacionales relativas al derecho a la seguridad social, los Estados Partes, en caso necesario, deberán recurrir a la asistencia técnica y la cooperación de los organismos especializados de las Naciones Unidas”.²²

²² CDESC, Observación general núm. 19, párr. 68.

Cuando existen múltiples iniciativas aisladas, cada una de ellas ejecutada por diferentes ministerios u organizaciones públicas o de la sociedad civil, existe el riesgo de que se superpongan y se socave su eficacia. La fragmentación, duplicación o falta de coordinación entre las políticas sociales no sólo disminuye su impacto, sino que presenta un problema desde una perspectiva de derechos humanos, ya que no permite una clara asignación de responsabilidades en su ejecución o la identificación de quién es responsable por su fracaso.

Para que los programas de protección social sean efectivos y de conformidad a los derechos humanos, han de ser parte de estrategias nacionales amplias para hacer frente a la multi-dimensionalidad de la pobreza. Un enfoque de derechos humanos, debe tener una visión integral de todos los derechos económicos, civiles, sociales, políticos y culturales, y tener en cuenta la manera en que estos dependen e interactúan entre sí.

III. Principios de igualdad y no discriminación

La prohibición de la discriminación y el principio de igualdad son elementos fundamentales de un enfoque de derechos. Estos principios imponen a los Estados una serie de obligaciones concretas en relación al diseño de las políticas públicas en general y los sistemas de protección social en particular.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por razones “de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.²³ La expresión “cualquier otra condición” implica que se trata de un listado abierto. Por ende, otros motivos de discriminación prohibidos incluyen la discapacidad física o mental, el estado de salud (incluido el VIH/SIDA), la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda

²³ Véase, por ejemplo, el artículo 2 tanto del PIDESC como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio de los derechos.²⁴ Algunos tratados internacionales han expandido o especificado las razones prohibidas de discriminación en razón al sexo y la discapacidad.²⁵

La discriminación está prohibida, sea esta directa o indirecta, esto es, aquella medida que sin tener por objeto discriminar, tiene como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos.²⁶

De conformidad al derecho internacional de los derechos humanos, dar cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación no se agota con la simple prohibición de actos discriminatorios, sino obliga a tomar medidas para lograr la igualdad sustantiva. De tal manera, se entiende que estos principios imponen la obligación de prestar atención especial a los grupos o individuos que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes. En relación a ellos, no es suficiente que se les dé el mismo el trato formal que reciben otras personas que no se encuentran en la misma situación de desventaja. Los Estados deben, por tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. Con este fin, se reconoce que en ocasiones los Estados están obligados a adoptar medidas especiales —como por ejemplo medidas de acción positiva— que establezcan diferencias explícitas basadas en los motivos prohibidos de discriminación. Esas medidas serán legítimas siempre que supongan una forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación de facto y se dejen de emplear una vez conseguida una igualdad sustantiva sostenible.²⁷

La aplicación de estos principios en relación a la legislación y la práctica de la protección social requeriría entre otros: a) extender progresivamente la

²⁴ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general núm. 19, párr. 29.

²⁵ Véase, por ejemplo, CEDAW y CDPD.

²⁶ Véase, por ejemplo, CDESC, Observación general núm. 20, párr. 7.

²⁷ Véase por ejemplo, CDESC, Observación general núm. 20, párrs. 8 y 9.

cobertura de la protección social a todos los habitantes del país sin distinción alguna dando prioridad a las personas o grupos más desventajados; b) asegurar una igualdad de trato entre hombres y mujeres y c) asegurar el acceso a los grupos más vulnerables atendiendo a sus necesidades particulares.

1. La vocación universal de los derechos ¿Programas focalizados o universales?

Desde una perspectiva del derecho, todas las personas son iguales ante la ley y debieran disfrutar de todos sus derechos incluyendo los DESC sin discriminación alguna. Aplicado al derecho a la seguridad social, significa que todas las personas debieran estar cubiertas por un sistema de protección social, dando prioridad a las personas pertenecientes a los grupos más desfavorecidos o marginados.

Esto implica que las decisiones de política pública debieran tener como objetivo buscar la universalidad del disfrute de todos los derechos, incluyendo el derecho a la seguridad social. De esta forma, teniendo la universalidad como fin, la focalización debiera ser sólo un instrumento. Los Estados deben tomar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para ir progresivamente ampliando la cobertura de los sistemas de protección social. Para garantizar la cobertura de todos, resultarán necesarios los sistemas no contributivos.

Cuando los programas de protección social no son universales, los mecanismos de focalización deben ser analizados con mucha cautela desde un enfoque de derechos humanos. La aplicación efectiva de mecanismos de focalización depende de la capacidad de gestión de los órganos de administración del programa. Mientras más sofisticado y complicado sea el método de cálculo adoptado para la focalización, más opacos pasan a ser los criterios de elegibilidad, lo que puede llevar a que el proceso de escrutinio por parte de los beneficiarios sea difícil, si no imposible. Asimismo, a medida que el proceso se vuelve menos transparente, se hace más difícil que las personas entiendan cómo se accede al programa y por ende no lo considerarán un

derecho al cual tienen titularidad sino, por el contrario, lo tenderán a ver como una prebenda política.

Muchas veces, el acceso universal a programas sociales es la estructura más simple, más transparente, y la que cuenta con el menor gasto administrativo. Además, la cobertura universal está más en línea con la universalidad de los derechos, reduce las oportunidades de corrupción y no genera ningún estigma en los beneficiarios. Asimismo, al incluir a las clases medias se generaría el apoyo político para asegurar la sostenibilidad de los programas de protección social a través del tiempo.

Cuando debido a las limitaciones de recursos se debe optar por programas focalizados, éstos también han de respetar los principios de igualdad y no discriminación, lo que significa, por ejemplo, que los criterios de elegibilidad deben ser justos, razonables, objetivos y transparentes y las personas deben tener acceso a recursos para subsanar posibles errores de exclusión. Los programas focalizados deben también evitar la estigmatización de los beneficiarios.

Para cumplir estos requisitos, especialmente en los países en que la capacidad de gestión del gobierno es limitada, pareciera conveniente la utilización de mecanismos de focalización sencillos como es una focalización categórica (por ejemplo, focalización en la niñez, adulto mayor o en relación al domicilio) y, dentro de cada categoría, la prestación debiera ser universal (por ejemplo, la cobertura universal de todas las personas de más de 65 años de edad). A medida que evoluciona la capacidad de gestión del Gobierno, se podría incorporar mecanismos de focalización de mayor sofisticación. En todo caso, el enfoque de derechos requiere que se tomen medidas para velar porque la cobertura se vaya ampliando progresivamente a medida de que existan recursos disponibles.

Es importante destacar que si bien ningún mecanismo de focalización puede ser perfecto, desde una perspectiva de derechos humanos, los errores de inclusión (por los que se proporciona una prestación o servicio a alguien que no está en el grupo al que se quiere llegar) no son tan problemáticos como los errores de exclusión (no llegar a quienes se quería llegar).

2. Asegurar que las mujeres se beneficien en igualdad de condiciones que los varones

El logro de la plena igualdad de los derechos entre hombres y mujeres es un tema fundamental para el enfoque de derechos.²⁸ Los sistemas de protección social deberían fomentar activamente la igualdad de género y empoderar a la mujer. Para ello es necesario que las políticas y los programas de protección social aborden las asimetrías de poder y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Políticas y programas de protección social que sean neutrales al género pueden dar por resultado una discriminación de facto contra la mujer. Para asegurar que las mujeres disfruten de los mismos derechos que los hombres y alcancen la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos, en ocasiones es necesario otorgarles un trato diferenciado, como por ejemplo a través de cuotas.²⁹

El diseño de programas de protección social debe tener en cuenta las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres y garantizar que se aborden sus necesidades concretas a lo largo de toda su vida: niñez, adolescencia, edad adulta y vejez.

Teniendo en cuenta de que los programas de protección social se ejecutan en distintos contextos sociales, económicos, políticos y culturales, no existe una solución única, válida para todos los casos. No obstante, pueden definirse algunas dimensiones de género básicas que los programas de protección social han de respetar.

Antes de diseñar y ejecutar un programa de protección social, los Estados deben realizar un análisis integral de las cuestiones de género, evaluando las vulnerabilidades de ambos sexos como potenciales beneficiarios. La existencia de datos desglosados, tanto por sexo como por edad, es esencial no sólo para

²⁸ Véanse, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts. 2.1 y 3, el PIDESC arts. 2.2 y 3, y CEDAW, en particular, arts. 2(f), 5(a) y 11.

²⁹ Comité CEDAW, Recomendación general 28, párr. 22.

establecer programas de protección social eficaces, sino también para develar las dinámicas de género que subyacen en cada contexto.

Las políticas y programas de protección social deben abordar los desequilibrios, los riesgos y las barreras que enfrentan de las mujeres, en particular respecto del acceso a los recursos productivos, la educación, la salud y el trabajo, y deben tener en cuenta la función reproductiva y productiva de la mujer. Para ello deben abordar los obstáculos concretos que impiden que los hombres y las mujeres participen en los programas de protección social en condiciones de igualdad.

Considerando que el derecho internacional de los derechos humanos exige a los Estados que tomen medidas para eliminar las prácticas culturales y tradicionales que se basen en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, o en funciones estereotipadas del hombre y la mujer,³⁰ todas las políticas sociales han de buscar transformar la dinámica de género existente en la sociedad desafiando toda forma de patriarcado que perpetúe la pobreza en las mujeres. Los programas de protección social deben respetar y reconocer el papel que desempeña la mujer como cuidadora, sin reforzar los patrones de discriminación ni los estereotipos negativos (art. 5, CEDAW). En este sentido, como se analizará más adelante, un enfoque de derechos mira con cautela la corresponsabilidad que algunos programas de transferencias en efectivo de la región imponen a la mujeres jefas de hogar, puesto que podrían perpetuar las ideas tradicionales sobre los roles de género en el seno familiar en lugar de contribuir a cambiarlo.³¹

Los programas de protección social deben buscar una distribución equitativa de la carga del trabajo de cuidado no remunerado, que en su mayoría es efectuado por mujeres, constituyéndose en un enorme obstáculo para el disfrute de una amplia gama de derechos, desde el acceso al trabajo remunerado como el disfrute del derecho a la educación y la salud (Sepúlveda,

³⁰ Véase, por ejemplo, CEDAW, artículo 5.

³¹ Véase Capítulo III, sección 4.

2013b). Deben adoptarse medidas para promover el valor del trabajo de cuidado y distribuir las responsabilidades relativas a esta labor desde las familias y comunidades al Estado, alentando a los hombres a que participen más activamente en tareas de cuidado de los miembros de la familia.

Los programas de protección social deben buscar mitigar las asimetrías de poder basadas en el género y abordar estas asimetrías de poder en los procesos de toma de decisiones tanto en el hogar como en la comunidad. Los Estados deberían garantizar, por ejemplo, la participación efectiva de las mujeres en los programas de protección social estableciendo cupos en las estructuras de gobernanza de los programas.

Los programas de protección social deberían utilizar todas las oportunidades posibles para promover la igualdad de género y movilizar a las mujeres a fin de que se organicen. Así pues, los administradores de los programas deberían analizar de qué forma la interacción permanente con los beneficiarios puede ser utilizada para abordar las desigualdades de género imperantes en la comunidad e identificar los obstáculos a que hacen frente las mujeres para acceder al mismo. Así, por ejemplo, si se celebran reuniones comunitarias, estas podrían aprovecharse para tratar la cuestión de las limitaciones de tiempo de la mujer y movilizar a grupos de mujeres en torno a temas de violencia de género.

Los programas deberían fomentar la capacidad de las mujeres para que reivindiquen sus derechos. Asimismo, es fundamental que los programas de protección social incorporen mecanismos de participación y rendición de cuentas accesibles tanto a las mujeres como a los hombres.

Además, deberían integrarse indicadores de género en el seguimiento y evaluación de los programas de protección social. Para lograr estos objetivos es necesario que se capacite a quienes ejecutan programas sociales tanto a nivel nacional como local para que sean más sensibles a las cuestiones de género. Además, para asegurar la igualdad de la mujeres en el disfrute de los beneficios de una política o programa de protección social, es esencial

también que se garantice el acceso (tanto económico como físico) sin discriminación a los servicios públicos, los que deben también tener en cuenta cuestiones de género. Ello exige que los encargados de formular políticas públicas comprendan y tengan en cuenta los distintos problemas a que hacen frente las mujeres y los hombres al tratar de obtener acceso a estos servicios.

Se debe también asegurar a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, asegurando desde el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva hasta la existencia de un marco legal y social que garantice que las mujeres puedan adoptar decisiones libres y exentas de restricciones, por ejemplo respecto del número y el espaciamiento de los embarazos.

Para que las políticas sociales ayuden a disminuir la inequidad de género, es fundamental que se acompañen también de medidas legislativas y de otra índole, destinadas a fomentar la igualdad de la mujer en otros ámbitos. En la mayoría de los países de la región la situación de desventaja de la mujer no cambiará únicamente por medio de la protección social. Las políticas para garantizar el acceso de la mujer a la tierra, los recursos productivos y el crédito; la protección contra violencia de género; el acceso a la justicia y una mayor participación política de las mujeres, entre otros, son esenciales para avanzar en la igualdad de género.

3. Necesidades particulares de las personas y grupos más vulnerables y marginados

El derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo reconoce las especificidades y peculiaridades de sus diversos titulares y busca el logro de la igualdad material (sustantiva). Para ello obliga a los Estados de prestar especial atención a las personas que forman parte de los grupos más desaventajados y marginados. El principio de la igualdad es entendido no sólo como la prohibición de toda forma de discriminación, sino también como la exigencia de que en ciertas situaciones se adopten medidas afirmativas o positivas para disminuir o eliminar las condiciones que dan origen a la discriminación o tienden a perpetuarla.

Dar atención a problemas concretos en relación con el género, la edad y las discapacidades es una tarea esencial desde un enfoque de derechos. En este sentido son especialmente relevantes la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (ver recuadro 1).

Recuadro 1. Medidas especiales en relación a mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) busca no sólo erradicar la discriminación contra la mujer y sus causas, sino que también estimular estrategias de promoción de la igualdad. Por ende, contiene normas que por una parte prohíben la discriminación así como normas que buscan acelerar la igualdad, mediante la adopción de medidas afirmativas, como medidas especiales y temporales que procuren aliviar y remediar el modelo discriminatorio que perjudica a las mujeres.

La Convención de Derechos del Niño (1989) marcó un hito en el trato de los niños, niñas y adolescentes al reconocerlos como sujetos de derecho, enfatizar la necesidad de proteger todos sus derechos humanos, civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, y la obligación de respetar el interés superior del niño, entre otros.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), también supuso importantes consecuencias para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este tratado no sólo da “visibilidad” a este grupo dentro del sistema internacional de protección de derechos, pero se asume irreversiblemente el fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos en que los Estados se comprometen a adoptar “ajustes razonables” para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (Preámbulo y art. 5).

Fuente: Elaboración propia.

Esto significa, por ejemplo, que las políticas y programas de protección social deben responder a las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las

niñas y los niños. Reconociendo el papel fundamental de los adultos que son responsables del mantenimiento del niño/a (madre/padre o guardadores) se debe también tener presente que los niños/as experimentan pobreza y vulnerabilidad de manera diferente que los adultos (por ejemplo, son más vulnerables a la desnutrición, las enfermedades, el abuso y la explotación que los adultos) y que dependen de los adultos para su desarrollo y protección.

Mientras que muchas de las medidas de protección social benefician directa e indirectamente a los niños y niñas, incluso pequeños matices que hagan el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas de protección social más sensibles a las necesidades particulares de los niños y niñas pueden hacer una gran diferencia y tienen el potencial de beneficiar no sólo a la población infantil, sino también a sus familias, las comunidades y aportar al desarrollo nacional en su conjunto (DFID y otros, 2009, pág. 2) (ver recuadro 2).

Recuadro 2. Principios de la protección social adaptados a las niñas y niños

Los siguientes principios deben ser considerados en el diseño, implementación y evaluación de los programas de protección social adaptados a las necesidades de las niñas y los niños:

- Evitar impactos adversos en los niños/as, y reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la vida de los niños/as.
- Intervenir lo más temprano posible en casos en que los niños/as están en riesgo, con el fin de evitar el deterioro o daño irreversible .
- Considerar los riesgos y las vulnerabilidades en función de la edad y del género a lo largo del ciclo de vida de los niños/as.
- Mitigar los efectos de las crisis, la exclusión y la pobreza en las familias, reconociendo que las familias que crían niños/as necesitan apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Tomar medidas especiales para llegar a los niños/as que son especialmente vulnerables y excluidos, incluidos los niños/as separados de sus padres, y los que están marginados dentro de sus familias o comunidades debido a su género, la discapacidad, el origen étnico, el VIH y el SIDA u otros factores.

- Considerar los mecanismos y la dinámica interna de los hogares que pueden afectar el cómo llegar a los niños/as, con especial atención a las asimetrías de poder entre hombres y mujeres dentro del hogar y en la comunidad en general.
- Incluir las voces y opiniones de los niños/as, sus cuidadores y los jóvenes en la comprensión y el diseño de los sistemas y programas de protección social.

Fuente: www.unicef.org/socialpolicy (traducido por la autora).

El sexo, la edad y la discapacidad, no son los únicos aspectos que han de tenerse en cuenta. Los programas de protección social tienen un impacto diferenciado también en relación a otros criterios, tales como la etnia, la ubicación geográfica u otras características de los beneficiarios.

Un enfoque diferenciado en cuanto a la ubicación geográfica implicaría, por ejemplo, establecer mecanismos específicos que aseguren el acceso a los programas de protección social a quienes viven en zonas geográficas o territoriales más desventajadas, aquellas donde exista una mayor concentración de pobreza, que por lo general son aquellas que también tienen menos infraestructura y menos servicios públicos. En muchos casos, un enfoque territorial permitiría cubrir algunos otros aspectos interseccionales de vulnerabilidad. Según datos estadísticos, la mayoría de las personas con discapacidad tanto en el mundo como en países de América Latina (por ejemplo Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay) habitan en una zona rural, especialmente después de los 60 años (CEPAL 2012b, pág. 203). Por ende, asegurándose el acceso de las personas en zonas rurales se lograría llegar a un mayor número de personas con discapacidad.

Cuando se trata de atender a las necesidades de grupos particularmente desaventajados, cuyo desarrollo e inclusión social depende del acceso a los servicios sociales, es esencial comprender que debe existir un sistema de protección social, con un conjunto integral de políticas que van más allá de la transferencia de ingresos.

Los niños y las niñas son los principales beneficiarios indirectos de transferencias de ingresos. Sin embargo, también hay evidencia de que las transferencias

de ingresos son insuficientes para mejorar la situación general de los niños y niñas cuando no existen servicios públicos disponibles o son inadecuados. Análogamente, la ausencia de servicios públicos integrados para las personas de edad y las personas con discapacidades, indudablemente reducen los efectos de las transferencias de ingresos.

4. Estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y adecuación

El principio de igualdad y no discriminación también exige que las políticas públicas cumplan con los estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y adecuación que se han desarrollado en relación a los DESC.

Que los programas sociales sean asequibles, implica que se deben remover los obstáculos administrativos y físicos que impiden a los sectores más excluidos o desventajados de beneficiarse del programa debido a su edad, discapacidad, origen étnico, ubicación geográfica u otros factores.

Por ejemplo, algunos requisitos administrativos para beneficiarse de un programa social, como es la presentación de documentos de identificación para el registro pueden significar la exclusión del programa de algunos sectores de la población. A menudo, los documentos de identificación son costosos y se pueden obtener sólo en centros urbanos alejados donde viven los más excluidos. Otros requisitos, tales como pedir completar un formulario por escrito, en el cual se utiliza un lenguaje complejo y formalista, también puede excluir a los más vulnerables de un programa de protección social.

Los programas de protección social también deben ser físicamente accesibles. Las prestaciones deben ser entregadas en un lugar conveniente y de manera oportuna sin que suponga un costo desproporcionado para los beneficiarios. Las poblaciones más necesitadas de programas de protección social suelen ser las que se encuentren en zonas más aisladas y quienes deben enfrentar mayores obstáculos físicos y prácticos, tales como recorrer largas distancias

para recoger los pagos, alto costo de transporte y de oportunidad para acceder a las prestaciones.

Asimismo, se debe tener en cuenta las barreras adicionales que enfrentan ciertos grupos tales como las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y las personas con VIH/SIDA.

Los programas sociales también deben adaptarse a las diferentes necesidades de la población y a los contextos y privaciones locales. La información y la difusión de los programas sociales deben realizarse con el objetivo específico de llegar a los grupos particularmente vulnerables o excluidos. Para ello deberían utilizarse canales accesibles a los sectores más pobres de la sociedad (por ejemplo, anuncios de radio, obras de teatro comunitarias) y debería incluir mecanismos concretos para superar barreras de movilidad, en especial las que enfrentan las personas con discapacidad y los adultos mayores.

Los programas de protección social también deben ser culturalmente aceptables en el contexto de las múltiples formas de discriminación que pudieran surgir en la intersección de raza, género, clase, discapacidad, etc. Los valores culturales de los pueblos indígenas y las minorías étnicas deben ser tomados en cuenta en el diseño e implementación de todo programa social. Esto significa, por ejemplo, que para garantizar la aceptación cultural de un programa de salud en zonas donde viven pueblos indígenas, quienes atienden los centros de salud debieran poder hablar o al menos entender su lengua y debieran integrarse, en la medida de lo posible, las prácticas de salud tradicionales. Asimismo, la información acerca de los programas y los mecanismos de denuncias y quejas debieran estar disponible en los idiomas hablados por los pueblos indígenas, y debieran incluso ser accesibles a las personas analfabetas o con discapacidad.

Finalmente, los programas de protección social deben otorgar beneficios que sean adecuados en cuantía y duración. De conformidad al marco normativo internacional, los Estados tienen la obligación de garantizar por lo menos niveles mínimos esenciales de DESC y adoptar medidas hasta el máximo de

los recursos que se disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos (artículo 2 del PIDESC). Esta obligación requiere en casos de transferencias en efectivo, por ejemplo, que se analice regularmente el impacto que tienen en el poder adquisitivo de los beneficiarios, en especial que les brinden la posibilidad de acceder a un mínimo esencial de bienes y servicios y que se establezcan mecanismos de ajuste de los montos de las transferencias a través del tiempo y la presión inflacionaria.

Asimismo, es necesario que los servicios públicos sean suficientes en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades de la población. Los servicios esenciales para el ejercicio de los DESC, como la atención de salud y la educación, deben estar económica y físicamente al alcance de quienes viven en situación de pobreza. Nadie debe ser privado del acceso a servicios públicos esenciales por no tener la posibilidad de pagar. Para asegurar que los costos directos e indirectos de los servicios públicos estén al alcance de los segmentos más desfavorecidos de la población, en algunos casos, los Estados deben proporcionar el acceso gratuito. Por ejemplo, de conformidad a las obligaciones internacionales, la educación primaria debe ser gratuita, obligatoria y estar exenta de costos indirectos.³²

IV. Asegurar la no vulneración de derechos mediante las condicionalidades (corresponsabilidades)

Los programas de protección social más emblemáticos de la región son los programas de transferencia condicionadas (PTC).³³ Aunque los PTC que se implementan en la región presentan diferencias importantes en relación a su magnitud, cobertura, modo de gestión, forma de implementación de los beneficios, etc., existen algunos aspectos comunes a todos ellos que pueden

³² Ver artículos 13 y 14 del PIDESC y la Observación general núm. 13 del Comité DESC, artículo 29, CDN; artículos 10 y 14 de la CEDAW, artículo 5 CERD y artículo 20 en la Convención de Derechos de los Trabajadores Migrantes.

³³ Estos programas han sido extensamente estudiados, por ende esta sección se limita simplemente a señalar las tensiones que estos programas pueden generar en relación al disfrute de los derechos humanos de sus beneficiarios.

entrar en tensión con un enfoque de derecho. Estos aspectos se relacionan con: a) la imposición de una condición (co-responsabilidad) ligada al disfrute de un derecho; b) el establecimiento de sanciones ante el incumplimiento de las condicionalidades; c) los desequilibrios entre el aumento de la demanda creada por la condicionalidad y la oferta de servicios públicos; y d) el impacto de género.

En la esencia misma del concepto de derechos, está la dignidad, el respeto de la autonomía y la libertad de todas las personas de tomar decisiones sobre el bienestar propio y el de sus familias. Los derechos humanos, incluyendo los DESC, no dependen del cumplimiento de ninguna condición, son derechos inherentes a la persona. Asimismo, es responsabilidad del Estado el garantizar los servicios sociales básicos que aseguren el disfrute de derechos tales como la educación y la salud, los que no dependen del cumplimiento de responsabilidades por parte de sus titulares. Desde un enfoque de derechos, los “beneficiarios” de un programa de protección social, son más bien “titulares” del derecho a la seguridad social (incluyendo la asistencia social) y el Estado tiene la obligación de satisfacerlo, al menos en un nivel mínimo esencial.

Por ende, la imposición de condiciones atentaría al fundamento mismo de los derechos humanos, al exigir que las personas que viven en situación de pobreza deban demostrar (a través del cumplimiento de las condicionalidades) que son “merecedoras” del disfrute de su derecho a la seguridad social. Asimismo se atenta a su dignidad y la autonomía al suponer que no pueden hacer elecciones racionales que mejoren sus condiciones de vida o la de sus hijos.

Si, como se ha indicado, no existe evidencia social y económica de peso que demuestre que las condicionalidades en los PTC son necesarias para lograr la inversión deseada en términos de capital humano, puesto que las mismas mejoras en salud y educación podrían lograrse sin imponer condicionalidades (Barrientos, 2011, pág. 19), las condicionalidades además de vulnerar la autonomía serían innecesarias.

Las condicionalidades también pueden entrar en tensión con los principios de igualdad y no discriminación, en particular al concepto de trato igualitario, puesto que se aplica un control de conducta a los sectores más pobres de la población, que no se exige a otros sectores sociales y económicos que también se benefician de las políticas públicas, tales como los contribuyentes de altos ingresos que gozan de créditos fiscales (CEPAL, 2012c, pág. 59).

En algunos casos, imponer condiciones puede resultar en el deterioro de las circunstancias específicas en las que viven los más desventajados. La imposición de condicionalidades a menudo aumenta los desequilibrios de poder entre la comunidad beneficiaria y las autoridades del programa, al tiempo que aumenta las oportunidades de abusos por parte de los agentes implicados en el control del cumplimiento de condicionalidades (como maestros, personal de salud, y los administradores del programa). Por ejemplo, la exigencia de que los niños y niñas asistan a la escuela o consigan ciertos niveles de notas que deben ser certificadas por profesores puede tener una influencia negativa en el ambiente escolar. Por un lado, se les proporciona a los profesores una herramienta para influir directamente en el bienestar de las familias que viven en situación de pobreza, que no está relacionada con la calidad de la enseñanza que brindan.

Desde un enfoque de derechos, es esencial también analizar los controles del cumplimiento y las sanciones que se establecen en cada caso, que varían en cada programa, y van desde el apercibimiento y los descuentos en la transferencia hasta la exclusión del programa. Mientras más punitivo sea el método de control, la tensión con los derechos humanos será más alta. Ninguna persona debiera verse excluida de programas y servicios que son esenciales para el disfrute de los niveles mínimos esenciales de DESC.

En algunos casos, es posible encontrar programas que dicen establecer una sanción en caso de incumplimiento de la condicionalidad, pero que en la práctica no cuentan con ningún mecanismo de control o supervisión (por lo general, debido a los altos costos administrativos que esto conlleva), en estos casos, también existiría una tensión con los estándares de derechos humanos.

Hacer creer a la población que existen condicionalidades para el beneficio de un programa cuando éstas en la práctica no se controlan, no sólo choca con la moral pero también con el derecho a la información y la transparencia.

La imposición de condiciones aumenta la demanda de servicios públicos. Si una mayor demanda no se acompaña con un aumento de la oferta y una mejora de la calidad de los servicios, los derechos de los beneficiarios también se ponen en riesgo. Una mayor demanda insatisfecha perjudica la calidad de la prestación de servicios y crea desincentivos de acceso para los beneficiarios. A menudo, debido a la insuficiencia de recursos financieros y humanos, los proveedores de servicios públicos carecen de las habilidades y la capacidad para hacer frente de manera adecuada a las necesidades de las personas que viven en situación de pobreza, que a menudo experimentan prejuicios y estigmatización en el acceso a los servicios públicos básicos.

Es importante notar, que no basta con aumentar sólo la oferta de los servicios, sino que también es necesario mejorar la calidad y asegurar un enfoque de género. Se debe tener en cuenta las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres y niñas (por ejemplo, mujeres indígenas o mujeres con discapacidades), que acrecientan los obstáculos para el cumplimiento con las condicionalidades impuestas por los PTC. Mejorar la calidad y el enfoque de género, en la mayoría de los casos, requiere de la capacitación de los proveedores de servicio público en las prácticas culturalmente apropiadas y de conformidad a las necesidades específicas de las mujeres.

Los costos de administración, así como los costos privados que asumen los beneficiarios para dar cumplimiento a las condicionalidades también deben ser analizados cuidadosamente. En México, por ejemplo, estudios sugieren que en el año 2000 el costo de implementar las condicionalidades representaron un 24% de los costos administrativos generales del programa Oportunidades y los costos privados de los beneficiarios para cumplirlas fueron aproximadamente 50% más altos que los costos en un programa sin condiciones (Kidd and Calder, 2011). De esta forma, se ha argumentado que en países de bajos ingresos los recursos puede ser mejor invertidos en la

ampliación de los servicios sociales existentes en lugar de aumentar los costos asociados con el seguimiento de las condicionalidades (Cecchini, 2009).

Finalmente, existe una tensión entre la imposición de condiciones y los derechos de las mujeres (madres) responsables de velar por el cumplimiento de las mismas. Como se ha indicado, en los PTC las mujeres son perceptoras de las transferencias, no como titulares del derecho a la seguridad social o en su condición de mujer sino que como beneficiarias operativas en calidad de madres de un beneficio destinado a sus hijos/as (CEPAL, 2012c).

Responsabilizar únicamente a las madres de garantizar el cumplimiento de las condicionalidades puede afectar directamente el ejercicio de sus derechos. Esta tarea demanda una dedicación de tiempo importante, en particular en países donde los servicios públicos son deficientes, donde existe mala infraestructura, transporte público insuficiente y costoso, y falta de apoyo a las tareas de cuidados (por ejemplo, insuficientes guarderías infantiles). La carga desigual del trabajo de cuidado no remunerado, puede tener un enorme impacto en el disfrute de una gama de derechos de las mujeres, desde su derecho a la salud, educación y participación en la vida política, económica y social (Sepúlveda, 2013b).

Asimismo, al atribuir únicamente a las madres la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas en materia de educación y salud, no sólo se aumenta la carga de trabajo y la escasez de tiempo de las mujeres, que es una de las razones de su desigualdad social y económica, sino que además refuerza el estereotipo de género de que el hombre es el principal sostén de la familia y la mujer la principal y natural responsable de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas. Esto va en contra de las obligaciones asumidas por los Estados partes a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que busca la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5). Como se ha señalado anteriormente, las políticas sociales no debieran reforzar y

perpetuar los roles tradicionales de género, sino que debieran contribuir a cambiarlos promoviendo una distribución más equitativa de la carga de trabajo de cuidado entre hombres y mujeres.

V. Participación³⁴

El derecho de las personas y los grupos a participar en la adopción de decisiones que les afecten debe incorporarse en todo programa, política o estrategia de protección social.³⁵

Para que las políticas y programas de protección social contribuyan al proceso de transformación que exigen los derechos humanos, éstas deben basarse y garantizar una participación efectiva y significativa de la población. Desde un enfoque de derechos, la participación no es simplemente conveniente desde el punto de vista de la titularidad y la sostenibilidad de la política o programa, sino que corresponde a un derecho en sí mismo: el derecho a participar en los asuntos públicos.

Los Estados deberían establecer un entorno propicio para la participación efectiva de todos los grupos vulnerables y desventajados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas de protección social, teniendo en cuenta sus limitaciones, así como las asimetrías de poder existentes a nivel nacional y local (en las comunidades).

Dada la asimetría de poder entre los beneficiarios de los programas sociales y las autoridades públicas que los administran, aquellos son a menudo incapaces de proteger sus derechos sin mecanismos justos y eficaces que les permitan participar activamente en el programa. Sin mecanismos de participación los programas de protección social corren el riesgo de ser objeto de manipulación política.

³⁴ Este apartado se basa en informe sobre participación preparado por la autora para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documento A/HRC/23/36, 2013.

³⁵ CDESC, Observación general núm. 19, párr. 69.

La falta de participación también significa que los administradores del programa y los encargados de formular políticas públicas no reciben insumos de los beneficiarios, lo que a su vez socava la eficacia y la sostenibilidad del programa. La participación también contribuye a garantizar la cohesión social y conseguir apoyo político para los programas.

El objetivo principal de los derechos humanos es transformar las dinámicas de poder en las sociedades, a fin de hacer frente a la opresión, subvertir la subordinación y marginación de determinados grupos o personas, y promover la agencia individual (entendida como la capacidad de actuar en defensa de los propios intereses), la autonomía y el respeto de la dignidad inherente a cada ser humano. De esta forma, una cuestión central para la teoría y la práctica de los derechos humanos es impedir que los actores poderosos impongan su voluntad o sus intereses a expensas de otros mediante la coacción, la fuerza o la manipulación. En consecuencia, los procesos participativos basados en los derechos humanos son aquellos que no aceptan la dinámica del poder tal cual es, sino que más bien parten de la premisa de que deben eliminarse las asimetrías de poder, y por ello buscan detectar y afrontar explícitamente la desigualdad, incluidos los desequilibrios de poder estructurales y sistémicos existentes en la vida social y económica. Para lograrlo, es necesario conocer el modo en que se manifiesta el poder en un contexto determinado, diagnosticar las relaciones de poder asimétricas, y entender la manera en que se ejerce dicho poder tanto dentro de las comunidades como entre ellas para controlar y excluir a los grupos desfavorecidos.

Mediante una participación genuina y efectiva, los beneficiarios de un programa pueden ejercer su agencia, autonomía y libre determinación. La participación limita también la capacidad de las élites de imponer su voluntad sobre las personas y los grupos que quizás no cuentan con los medios de defender sus intereses.

Concebida como un derecho, la participación es un medio de hacer frente a las formas de dominación que restringen la agencia y la libre determinación de las personas, y otorga a las personas que viven en situación de pobreza,

poder sobre las decisiones que afectan a sus vidas, transformando las estructuras de poder existentes en la sociedad y permitiendo un goce de los derechos humanos mayor y compartido de manera más amplia.

La participación basada en los derechos es especialmente necesaria para que las personas más pobres y marginadas puedan hacer oír su voz, ya que se fundamenta en los principios de dignidad, no discriminación e igualdad. Por lo tanto, en contraste con algunos procesos supuestamente “participativos” que son puramente formales, simbólicos o llevados a cabo para dar una pátina de legitimidad a políticas predeterminadas, la participación basada en los derechos pretende ser transformadora y no superficial o instrumental, y promueve y exige la participación activa, libre, informada y genuina de las personas que viven en situación de pobreza en todas las etapas de la formulación, aplicación y evaluación de las políticas que les afectan, basándose en un análisis amplio de sus derechos, capacidad y vulnerabilidades, de las relaciones de poder y las relaciones entre los géneros, y de los papeles que desempeñan los diferentes actores e instituciones.

Un enfoque de derechos requiere que se establezcan mecanismos de participación en todo el ciclo de un programa de protección social, desde su diseño hasta su evaluación. Para ello es necesario fortalecer la capacidad de los beneficiarios para conocer y demandar sus derechos y establecer mecanismos institucionales específicos, en distintos niveles de la adopción de decisiones, para superar los obstáculos que se oponen a la participación efectiva de los grupos más desventajados.

Recuadro 3. La participación como mecanismo contra la corrupción

La mayor parte de los países de la región son Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La UNCAC, que entró en vigor en 2005, establece una serie de medidas que los Estados partes han de adoptar para prevenir y luchar contra la corrupción. Se destaca el Artículo 13 que prevé:

Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

- a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;
- b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
- c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
- d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
 - i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros; ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

Fuente: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

VI. Transparencia y acceso a la información

Desde un enfoque de derechos es esencial que todas las políticas públicas sean transparentes a fin de evitar la corrupción, el abuso, la mala gestión y la manipulación política. Asimismo, la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales de la rendición de cuentas.

Transparencia significa que los beneficiarios —y la sociedad en general— deben ser capaces de entender el funcionamiento del programa y los actores responsables de llevarlo a la práctica, tanto en el plano nacional como local. También debe haber transparencia en relación con varios componentes de los

programas sociales, como la selección de los beneficiarios, los mecanismos de focalización, los criterios de elegibilidad, las prestaciones, los mecanismos de quejas, y las vías de recurso. Asimismo, es necesario que regularmente se publiquen los resultados del programa incluyendo el resultado de evaluaciones y estudios de impacto que se hayan efectuado. Como se verá a continuación, se debe garantizar el acceso de la ciudadanía a toda información relevante y actualizada.

La información debe ser proporcionada de manera fácil de comprender y por canales accesibles (física y culturalmente) a las personas o grupos más desventajados y deben estar diseñados de manera tal que les permita superar las barreras que enfrentan, tales como falta o limitada: alfabetización, acceso a tecnologías (por ejemplo, internet) o recursos económicos para transporte.

Acceso flexible e inclusivo a los mecanismos de información podría incluir, por ejemplo, números telefónicos gratuitos y mecanismos que permitan superar barreras de alfabetización. Particularmente relevante en la región es que la información relativa a los programas de protección social esté disponible en lenguas indígenas.

Las asimetrías de poder, la desigualdad de género y los patrones de discriminación afectan en gran medida las oportunidades que tienen diversos grupos para acceder a la información de un programa social. De esta forma, por ejemplo, para asegurar el acceso igualitario de las mujeres a la información de un programa es necesario que los canales de información sean sensibles al género.

El acceso a la información relativa a un programa social es un derecho de todos los habitantes que debe ser garantizado por el Estado (ver recuadro 4). Por ello, es necesario que los funcionarios de los programas estén capacitados para procesar solicitudes de información y responder con prontitud y de manera cabal a tales solicitudes. Asimismo, se debe garantizar que el acceso a la información pública no sea en detrimento del derecho a la privacidad de la información.

Recuadro 4. Libertad de pensamiento y de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), incluyen el derecho a buscar y recibir información bajo el control del Estado. Según la Corte, este artículo:

“...protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.”

Fuente: *Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile*, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párrafo 77.

VII. Rendición de cuentas y acceso a mecanismos de reclamo y reparación

Otro de los elementos esenciales de un enfoque de derechos es habilitar a las personas para que puedan reclamar la garantía efectiva de su derecho a la seguridad social y hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de errores, abusos o mala administración.

Teniendo en cuenta las profundas asimetrías de poder que existen entre quienes están encargados de la gestión de los programas sociales y a quienes

están dirigidos, el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas es esencial para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de los grupos más desventajados.

Sin mecanismos de rendición de cuentas o de reparación, las políticas sociales tendrán menos probabilidades de ser entendidas en términos de prestaciones y derechos, y serán vistas como instrumentos de clientelismo y por ende estarán sujetas a manipulación política.

En relación a las políticas y programas de protección social esto significa, por ejemplo, que deben establecerse normas, procedimientos y controles para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados y políticos en el ejercicio de la función pública, así como mecanismos para investigar y sancionar faltas cometidas por los servidores públicos.

Estos mecanismos de rendición de cuentas son esenciales, en particular, con relación a tres elementos fundamentales de los programas: a) la cualificación y el mantenimiento dentro del programa;

b) la denuncia de exigencias impropias en el marco del programa tales como, de apoyo político, de solicitudes de dinero, de amenazas o de acoso sexual; y c) la supervisión de los procedimientos de pago.

Los mecanismos de reclamos han de ser independientes de las injerencias políticas y eficaces para supervisar la administración de programas sociales y para recoger y procesar las denuncias. Asimismo, deben cumplir determinados requisitos técnicos que aseguren que los individuos o grupos más desventajados tengan acceso a ellos, tales como ser accesibles física y económicamente, garantizar la confidencialidad, permitir las denuncias individuales y colectivas, contar con los recursos humanos y financieros suficientes para su efectividad, y tener en cuenta las cuestiones culturales y de género.

Asimismo, debe contarse con la posibilidad de acceder a la vía judicial o de otra índole que permita al titular del derecho reclamar en caso de violaciones a sus derechos. La práctica del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deja claro que la existencia de recursos —tanto individual como colectivo— en caso de violaciones a los derechos, es una parte fundamental e indispensable para la realización de los DESC.³⁶

Para garantizar la rendición de cuentas, existen varias áreas institucionales a las cuales también se les debe prestar especial atención por presentar factores de riesgo, tales como la capacitación y conocimiento del programa por parte de los funcionarios públicos encargados del mismo; la existencia de manuales y reglamentos; el reclutamiento y selección del personal; y la coordinación interinstitucional.

Uno de los obstáculos principales es el acceso físico y económico a los mecanismos de información y denuncia. En este sentido, un avance importante es el establecer líneas telefónicas gratuitas, que estén al alcance de toda la población incluyendo quienes no hablan el idioma oficial mayoritario (por ejemplo, que hablen lenguas indígenas). Se debe diseminar ampliamente la existencia de estas líneas, el personal que trabaje en estas líneas debe estar suficientemente preparado, y debe asegurarse la confidencialidad.

E. Lecciones aprendidas

Esta sección examina algunas políticas y programas de protección social llevadas a cabo en la región, que son prometedoras en sus esfuerzos por poner en la práctica un enfoque de derechos. Teniendo en cuenta que un enfoque de derechos supone estándares de protección igualitarios para toda la población, el análisis se enfoca en aquellos programas de protección social que, en sociedades altamente desiguales y con fuerte persistencia e incidencia de la pobreza, tienen como objetivo luchar contra la desigualdad buscando

³⁶ CDESC, Observación general núm. 9, la aplicación interna del Pacto.

la inclusión de los grupos más desventajados y excluidos. De esta forma, se da prioridad en este análisis a programas no contributivos.

I. La consolidación de un marco legal e institucional adecuado

Como se ha señalado, en general las constituciones de los países de la América Latina incorporan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluyendo en algunos casos el derecho a la seguridad social.³⁷

La consagración constitucional y legal de los derechos humanos en los países de la región se ha traducido en la creciente incorporación del enfoque de derechos humanos en una diversidad de instrumentos de política pública. Así en la región, ya no es extraño encontrar que los planes nacionales de desarrollo utilicen un lenguaje directo de derechos o incluso coloquen la observancia de los derechos humanos, como uno de sus ejes centrales o soportes transversales.³⁸ Por ejemplo, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 del Ecuador indica que “Los derechos humanos y de la naturaleza pasan a ser parte constitutiva del Plan, son su objetivo, su esencia y razón de ser. Por lo tanto, los derechos son la parte sustantiva del Plan y no solamente se expresan como “un enfoque”.³⁹

Por su parte en el Uruguay, el Plan de Equidad indica que “asegurar que las y los habitantes de esta nación tengan posibilidades efectivas de desarrollar una vida digna es uno de los derechos fundamentales que propician la condición de ciudadano/a y por ende es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en particular. Brindar protección a quienes la necesitan, amparar a la población garantizando sus derechos fundamentales y hacerlo

³⁷ Véase nota 5 supra.

³⁸ Véase nota 2 supra.

³⁹ República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, 2009, pág. 81.

durante toda su vida, construyendo equidad, generando iguales condiciones y oportunidades para todas y todos frente a diversas circunstancias vitales, sociales y económicas”.⁴⁰

Además de la referencia explícita a la necesidad de lograr un desarrollo con pleno respeto de los derechos humanos de sus habitantes, en sintonía con sus constituciones, los planes nacionales de desarrollo de los países de la región tienen un fuerte énfasis en el logro de la equidad, y la superación de las desigualdades de ingreso (Armijo, 2010). Al tiempo que priorizan áreas sociales que van en línea con derechos económicos y sociales tales como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda adecuada y a la participación.

En varios países de la región la incorporación de un enfoque de derechos en la construcción de sistemas de protección social es el resultado del desarrollo legal e institucional demandado por sus propias constituciones. Por ejemplo, si tomamos el caso de Brasil, podemos observar que la Constitución de 1998, consagra un amplio abanico de derechos sociales (capítulo segundo), tales como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad social, la previsión social, la protección de la maternidad, así como el derecho a la asistencia social (sección IV) que incluye la garantía de un salario mínimo (artículo 203). También establece amplias normas de protección especial para los niños y ancianos (capítulo VII) y a los pueblos indígenas (Capítulo VIII). Varias otras normas constitucionales son también determinantes para el desarrollo de un enfoque de derecho en la protección social, tales como las disposiciones relativas a la descentralización político-administrativa, el derecho a la participación de la población en la formulación de las políticas y en el control de las acciones en todos los niveles (artículo 204), el principio de igualdad ante la ley y el acceso a la información (capítulo primero).

⁴⁰ Véase http://www.bps.gub.uy/5420/plan_de_equidad.html

En cumplimiento de esta normativa constitucional, se han ido desarrollando de manera progresiva un marco legal e institucional que garantiza un enfoque de derechos en la protección social. Este marco incluye una gran variedad de leyes, tales como la Ley Orgánica de Asistencia Social (Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, 1993) y el establecimiento de diversas instituciones para apoyar los programas sociales y su articulación, destacándose la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS) en el año 2004.⁴¹

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, a pesar de no existir una norma constitucional explícita que consagre “el derecho a la seguridad social”, una serie de otras normas constitucionales son relevantes para un enfoque de derechos en la protección social. Se destaca en este sentido las normas relativas al modelo, fines y valores del Estado (Capítulo I y II) y la amplia protección de DESC tales como, el derecho a la alimentación, a la educación, el derecho a la salud y vivienda adecuada, el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Otras normas relevantes son las que consagran el derecho a la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud, así como la garantía de derechos específicos relativos a la niñez, adulto mayor y personas con discapacidad. Todos estos derechos (y consiguientes obligaciones) son la base legal para el establecimiento de programas de protección social con enfoque de derechos.

En la región es particularmente destacable el establecimiento de marcos legales con explícito enfoque de derechos en materia de salud. Varias constituciones consagran la salud como un derecho⁴² y en línea con dichas normas constitucionales varios países han establecido una serie de garantías legales tales

⁴¹ Para un análisis en detalle del marco legislativo e institucional véase Robles y Mirosevic (2013).

⁴² Véase, por ejemplo, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 83), Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (art. 7), Constitución de Colombia (arts. 44 y 49), Constitución de El Salvador (art. 35), Constitución del Paraguay (arts. 68 - 72), Constitución del Ecuador (art. 32).

como participación de la comunidad, transparencia y acceso a la información en materia de salud.⁴³

El impacto que tiene el marco legal e institucional en la implementación de una política social puede apreciarse, por ejemplo, en la amplia gama de marcos legales e institucionales a través de los cuales se han implementados en la región los programas de transferencia monetarias. No es coincidencia de que en aquellos países donde estos programas han sido institucionalizados e incorporados a una estrategia nacional de protección social, a través de un marco legal amplio que comprende normas de distinta jerarquía y detalle (por ejemplo, la constitución, diversas leyes nacionales además de normas operativas), se han consolidado como políticas de Estado, con una mayor certeza jurídica y protección de los beneficiarios y por ende, han funcionado mejor que en aquellos países donde los programas de transferencia se basan sólo en decretos presidenciales o manuales y directrices de tipo operativo, sin que exista un arraigo jurídico legal.

II. La búsqueda de estrategias integrales de protección social

Como se ha señalado anteriormente, la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos impone la necesidad de adoptar una estrategia integral para la protección social. En la región, la búsqueda de un enfoque integral parece ser una lección aprendida, aunque aplicada con mayor o menor éxito por varios países. Una de las primeras experiencias de un enfoque integral fue Chile Solidario,⁴⁴ cuyo diseño se basó en cuatro componentes (apoyo psicosocial, bono de protección a la familia, subsidios monetarios garantizados y acceso preferente a programas de promoción social, prestaciones laborales y de previsión).

⁴³ Ver, por ejemplo, Perú: Ley General de Salud núm. 26842; Chile: Ley 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud.

⁴⁴ Chile Solidario se estableció en el año 2002. Se trata de un modelo de gestión que trabaja a través de diferentes programas: Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema; Vínculos (adultos mayores vulnerables); Calle (adultos en esta situación) y Caminos (niños y niñas de familias donde hay situaciones de separación forzosa por cumplimiento de condena). Véase <http://www.chilesolidario.gob.cl>

Varios otros países de la región fueron paulatinamente incorporando una concepción integral en sus estrategias de protección social. Una de las experiencias positivas más recientes es el Plan Brasil Sin Miseria (Brasil Sem Miséria).⁴⁵ Este plan se compone de tres ejes: a) garantía de ingreso (Bolsa Familia, Beneficio de Prestación Continuada, Bolsa Verde); b) inclusión productiva (a nivel urbano con la búsqueda de generación de empleos e ingreso, y a nivel rural, con aumento de la producción y con la incorporación de asalariados rurales); y c) acceso a los servicios públicos. Se destacan dos elementos esenciales para asegurar la mayor integralidad de este plan: un mayor involucramiento del Estado para asegurar la inclusión en el programa de todos aquellos habitantes que permanecen invisibles para la acción pública, y un énfasis en la coordinación, que se materializa a través de la firma de varios convenios con los niveles sub-nacionales con participación de todos los ministerios.⁴⁶

A pesar de los significativos avances, la construcción de sistemas de protección social sigue siendo uno de los grandes retos en la región. Es necesario seguir avanzando para poner en práctica un diseño institucional con abordaje sistémico que supere los abordajes sectoriales. Asimismo, es necesario que reforzar los esfuerzos para integrar los programas de transferencias a la institucionalidad social, puesto que en ocasiones continúan siendo intervenciones aisladas (Cecchini y Madariaga, 2011).

El logro de la integralidad no está necesariamente determinado por la existencia de altos recursos económicos. Incluso en el contexto actual de limitación de recursos, algunos países de la región podrían lograr que sus habitantes tuvieran una mayor protección social mejorando la gerencia y la coordinación intersectorial.

De la experiencia de algunos países de la región, se podría concluir que una mayor integralidad requiere que el Estado asuma un rol promotor activo; que

⁴⁵ Decreto 7.492 del 2 de junio de 2011.

⁴⁶ <http://www.brasilsemiseriala.gov.br>

se establezcan estructuras formales que aseguren la coordinación intersectorial; sistemas de información adecuados que apoyen la gestión integral e instituciones de seguridad social que cuenten con los recursos, las capacidades y el apoyo necesarios (financieros y políticos) para implementar programas desde la integralidad. Un desafío pendiente es lograr la mejor integración entre los programas, en particular entre los contributivos y no contributivos, para consolidar un verdadero sistema de protección social (Fiszbein, 2013).

En resumen, los países de la región han de reforzar la puesta en marcha de un enfoque integral y continuar mejorando la coordinación de las diversas políticas públicas, sin ello no se podrá alcanzar el respeto irrestricto a los derechos humanos a través de la protección social.

III. Los desafíos en el respeto de los principios de igualdad y no discriminación

Para la mayoría de los países de la región, el principio de igualdad de trato y de no discriminación es uno de los pilares de sus sistema de protección social, tal como lo consagra sus respectivas constituciones y legislaciones. Como se ha señalado, este principio se entiende como el logro de una igualdad material (no sólo formal) y comprende la necesidad de tomar medidas afirmativas para asegurar que quienes sufren de discriminación estructural o se encuentran en situación de vulnerabilidad sean objeto de una atención especial.

La tendencia de aumentar la cobertura de los programas de protección social y en algunos casos proporcionar un acceso universal, va en línea con la obligación —impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos— de buscar progresivamente el disfrute de los DESC por todos los habitantes sin discriminación.

En la región se han llevado a cabo diversos esfuerzos tanto para lograr el acceso a universal a ciertos programas sociales como para incluir de manera activa a los grupos más desventajados de la sociedad en algún programa, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

1. En camino a la universalidad: el ejemplo de la salud

En las últimas décadas se destacan en la región los esfuerzos, que con diversos grados de éxito, han buscado alcanzar la universalidad en materia de salud. En este sentido, conviene examinar comparativamente dos reformas importantes relativas al acceso a la salud: el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas en Salud de Chile y el Sistema Único de Salud de Brasil.

El Plan AUGGE-Garantías Explícitas en Salud (GES),⁴⁷ garantiza la cobertura de 80 enfermedades que son constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido por los titulares. Existe además un marco jurídico (ley y decreto), que garantiza el acceso, la calidad, la oportunidad y el financiamiento.⁴⁸

Se destaca que este ha logrado incrementar progresivamente el listado de enfermedades cubiertas, que los pacientes tienen el derecho a recurrir a los Tribunales de Justicia cuando las garantías no se cumplen y la existencia de un marco legal centrado en los derechos y en las garantías de los pacientes.

Sin embargo, a pesar de su marcada retórica de derechos, este sistema tiene limitaciones importantes:

El plan es gratuito sólo para ciertos afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA), pero quienes están afiliados al sistema de Instituciones de Salud Provisional (ISAPRE) deben realizar un copago (20%). Asimismo, el Fondo de Compensación Solidario⁴⁹ atentaría al principio de equidad, pues los contribuyentes de menores ingresos pagarían proporcionalmente más que los de ingresos altos, tanto sean partícipes de FONASA como de ISAPRE (Román y Muñoz, 2008 pág. 1602).

⁴⁷ Ley 19.966 del 3 de septiembre de 2004.

⁴⁸ Ley 19.966 (2004) y Decreto 4 (2013) del Ministerio de Salud.

⁴⁹ El Fondo tiene por objeto solidarizar los riesgos en salud entre los beneficiarios de las Isapres, con relación a los problemas de salud contenidos en el Decreto que aprueba las Garantías Explícitas en Salud. Véase Decreto 142 del 23 de junio de 2005.

Por otro lado, aunque se define como de acceso universal, el acceso al tratamiento está limitado a los pacientes cuya enfermedad sea una de las 80 pre-definidas. Esto ha sido criticado por algunos autores por vulnerar así el derecho a la salud integral de toda la población (Román y Muñoz, 2008 pág. 1600-1602). Esto significa, que si el enfermo no tiene una de las afecciones incluidas en la “canasta de prestaciones” no está protegido. A esto se suma el hecho de que se excluyen enfermedades poco frecuentes o marginales, que podrían requerir de una atención especial. Asimismo, esta garantía “universal” excluye a los inmigrantes ilegales y personas indocumentadas, quienes no pueden acceder a los servicios disponibles (Banco Mundial, 2007).

Asimismo, algunos estudios evidencian que a pesar de las estrategias orientadas a lograr una participación activa del público para exigir sus derechos, aún existe una generalizada falta de información por parte de los beneficiarios, quienes al no conocer sus derechos dependen en alta medida del apoyo por parte de los profesionales de la salud, apoyo que en la mayoría de los casos no ocurre (Missoni y Solimano, 2010). Por ejemplo, en una encuesta el 45% de los entrevistados dijo que sus médicos no les recomendaron el régimen de garantías de uso, incluso si se veían obligados a hacerlo por ley (Banco Mundial, 2007). Otra falencia desde un enfoque de derechos es la falta de mecanismos explícitos de rendición de cuentas y control social.

En definitiva, a pesar del enorme impacto positivo que ha significado la introducción de un plan de garantías explícitas de salud, que buscó mejorar un sistema altamente inequitativo de acceso a la salud en Chile, desde un enfoque de derecho aún existen importantes falencias por corregir. El acceso a la salud como derecho, está lejos de garantizarse de manera universal y sin discriminación alguna, y en términos financieros, sigue siendo muy regresivo, debido a la persistencia de las enormes diferencias en el tipo y la calidad de la atención entre quienes tienen y no tienen recursos.

Más en línea con un enfoque de derechos, encontramos al sistema público de salud, único y universal del Brasil: el Sistema Único de Salud (Sistema Único de Saúde, SUS). El SUS es uno de los mayores sistemas públicos de

salud del mundo, garantizando la asistencia integral y totalmente gratuita para la totalidad de la población, a un amplio número de enfermedades. El SUS ha estado en vigor por más de dos décadas, convirtiéndose en un sólido sistema de salud pública con resultados satisfactorios. El programa busca la universalidad y la gratuidad del sistema a través de una serie de medidas, dentro de las que se destacan, el reconocimiento de la salud como un derecho, las medidas especiales para incluir a la población indígena, medidas para proteger a los consumidores de la salud frente a las asimetrías de información y los mecanismos para garantizar la participación de la comunidad (De Souza, 2012). Estas características hacen que el SUS sea particularmente destacable en la región.

Es importante resaltar que la universalidad de la cobertura de salud está definida en la misma Constitución de Brasil que establece “La salud es derecho de todos y deber del Estado...” (artículo 196). En cumplimiento del mandato constitucional, el SUS reconoce a la salud como un derecho y una responsabilidad del Estado, y se guía por los principios de acceso universal y equitativo a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. En efecto, la Ley Orgánica de la Salud⁵⁰ que instituye el Sistema Único de Salud, en su Capítulo II – De los Principios y Directrices, establece entre los principios del SUS la “universalidad de acceso a los servicios de salud en todos los niveles de asistencia” (artículo 7).

Para lograr la universalidad en la práctica, se dio lugar a un importante proceso de descentralización de responsabilidades, atribuciones y recursos desde la esfera federal a los estados y municipios, de manera de garantizar que toda la población tuviera acceso al sistema, en todos sus niveles de atención, con calidad, sin importar el lugar de residencia. El marco normativo para la descentralización se estableció a lo largo de todo el sistema normativo: Constitución, la Ley Orgánica de la Salud, las directrices operacionales y las normas operativas (instituidas por medio de órdenes ministeriales). Su

⁵⁰ Ley 8.080 del 19 de septiembre de 1990.

puesta en práctica fue acompañada de procesos de capacitación y evaluación continua de desempeño (De Souza, 2012).

Desde un enfoque de derechos, destacan también las medidas especiales establecidas en 1999 para incorporar el acceso a las poblaciones indígenas al SUS, quienes hasta esa fecha se encontraban en condiciones de salud desproporcionadamente inferiores que la población general.⁵¹ Así como la creación de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS)⁵² que busca garantizar los derechos de los consumidores de servicios de salud, quienes requieren de protección especial debido a la asimetría de información y del establecimiento de instrumentos eficaces para impedir abusos.

El SUS también destaca por el respeto al derecho a la participación de la comunidad, que se concretiza a través de Conferencias de Salud y de los Consejos de Salud establecidos en la Ley Orgánica de Salud.⁵³

Las Conferencias de Salud se realizan a cada cuatrienio, con representantes de los diferentes segmentos sociales, con el objetivo de evaluar la situación de la salud y proponer las directrices para la formulación de las políticas de la salud en los niveles correspondientes.

Dichas Conferencias se realizan en un proceso ascendente, desde Conferencias Municipales de Salud, pasando por una Conferencia Estadual de Salud en cada estado y culminando con una Conferencia Nacional de Salud. Los Consejos de Salud, a su vez, son organismos colegiados compuestos por representantes del gobierno, prestadores de servicios, profesionales de la salud y usuarios, estos últimos, detienen el 50% de los miembros de los mencionados Consejos (De Souza, 2012). Dichas instituciones colegiadas tienen un carácter permanente y deliberativo y actúan en la formulación de estrategias y en el control de la ejecución de la política de la salud en la esfera

⁵¹ Ley 9.836, del 23 de septiembre de 1999.

⁵² Ley 9.961, del 28 de enero de 2000.

⁵³ Ley complementaria 8.142, del 28 de diciembre de 1990.

correspondiente. Los Consejos constituyen una red ascendente, con Consejos Municipales de Salud, un Consejo Estadual de Salud en cada Estado y un Consejo Nacional de Salud. Entre las tareas de los consejos de salud están las de definir las estrategias y monitorear la ejecución de las políticas de salud.

Por las características enunciadas, a la fecha el SUS forma parte de una política social del Estado que trasciende a los gobiernos que se han sucedido en estos más de veinte años. A pesar del significativo impacto, algunos desafíos para la plena implementación de un enfoque de derechos continúan, tales como las desigualdades de los indicadores de salud entre los ricos y los pobres, los blancos y los negros e indígenas, las áreas urbanas y las rurales, y entre los hombres y las mujeres (Organización Panamericana de la Salud, 2012).

2. Medidas para asegurar la inclusión de grupos especialmente desventajados

a) Mujeres y enfoque de género

El logro de la plena igualdad de los derechos entre hombres y mujeres en el disfrute del derecho a la seguridad social, tanto en su componente contributivo como no contributivo, es una de los grandes desafíos que persisten en la región donde la proporción de mujeres dentro de los pobres ha aumentado, a pesar del crecimiento económico y la disminución de la pobreza (CEPAL, 2012c, pág. 38).

En el plano contributivo, varios países de la región han tomado varias medidas para hacer frente al hecho de que las mujeres adultas mayores a menudo están excluidas de la seguridad social (por haber trabajado en el sector informal o desempeñando actividades de cuidado no remuneradas) o sus pensiones son muy inferiores a las de los hombres (por haber dejado de trabajar en algún momento de su vida para hacerse cargo de la crianza de los hijos, por haber recibido una remuneración inferior y en algunos países por estar obligadas a jubilar antes que los hombres teniendo una esperanza de vida superior).

En esta área, se destaca, por ejemplo, la reforma previsional en Chile que estableció la pensión básica solidaria con bono por hijo que tiene como objetivo aumentar el ahorro previsional de las mujeres y lograr así una mayor equidad.⁵⁴ Esta reforma, previsional se vio acompañada (ese mismo año) de varias otras medidas que buscaban aumentar la protección de las mujeres trabajadoras tales como leyes para asegurar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres; ampliar las garantías para atención médica en los servicios de salud; asegurar políticas públicas con énfasis en las mujeres jefas de hogar; ampliar sus posibilidades de capacitación y el acceso a la justicia.⁵⁵

En general, muchos de los programas de transferencia condicionada (PTC) implementados en la región han sido presentados como programas que buscan una mayor inclusión de las mujeres. Sin embargo, en materia de igualdad de género, estos programas requieren de un análisis particular. A pesar de que las mujeres son las receptoras de los beneficios, los PTC han sido ampliamente criticados por operar una visión “maternalista” (CEPAL 2012c). En otras palabras, el enfoque hacia la mujer no se basa en un reconocimiento de sus derechos sino más bien de manera instrumental para beneficiar a sus hijos (niños, niñas y adolescentes). Asimismo, los PTC asumen que las mujeres deben hacerse cargo de la vida doméstica, del cuidado y la crianza de los hijos excluyendo a los hombres de toda responsabilidad en estas tareas (Cecchini y Madariaga, 2011).

A manera de escueto resumen de la amplia literatura respecto al impacto de género de los PTC, es posible señalar los siguientes aspectos críticos desde un enfoque de derechos:

Los PTC no ayudan a transformar las relaciones y actitudes patriarcales y los estereotipos según los cuales el hombre es el principal sostén de la familia,

⁵⁴ Ley 20.255 (2008) sobre Reforma Previsional consagra derecho a pensión básica solidaria, bono por hijo, asegura el pago de compensaciones económicas por divorcio y establece, en forma progresiva, el deber de imponer, al menos por la remuneración mínima a las trabajadoras de casa particular.

⁵⁵ Ver, por ejemplo, Ley 20.348 (2009), Ley 20.336 (2008); Ley 20.286 (2008); y Ley 20.279 (2008).

mientras que la mujer es la principal responsable de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas tradicionales. Al asumir la responsabilidad exclusiva de las mujeres respecto al trabajo doméstico no remunerado, los PTC estarían más bien perpetuando estos estereotipos tradicionales y con ello impactando negativamente en una serie de derechos de las mujeres (Sepúlveda 2013).

Los PTC no promueven el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, sino que por el contrario, animan a su confinamiento en el hogar. Los PTC no reorganizan los roles de género para reducir o evitar las tensiones entre el trabajo remunerado y no remunerado, y en algunos casos aumentan las tensiones en términos de igualdad en el empleo del tiempo.

Las críticas a los PTC por estas falencias han sido contundentes y se han avanzado importantes recomendaciones de política pública para superarlas (ver recuadro 5).

Recuadro 5. Recomendaciones para revisar y reformular los PTC desde una perspectiva de género

La CEPAL ha elaborado una serie de recomendaciones que se resumen a continuación:

- *Abandonar toda visión maternalista de la política social. Las mujeres tienen derecho propio a la protección social.*
- *Revisar las condicionalidades y sus formas de implementación y transformarlas de manera que permitan advertir los espacios donde el Estado falla sin controlar ni penalizar.*
- *Buscar modificar los roles tradicionales de género, en particular el rol cuidador de las mujeres.*
- *Revisar los programas para que las transferencias contribuyan a una mayor autonomía de las mujeres.*

Fuente: CEPAL 2012c págs. 70 y 71.

Así como existiría cierto consenso en la necesidad de reformar los programas de transferencias condicionadas de manera de asegurar un enfoque de género, otro ámbito de la protección social que amerita un análisis más detallado es

la invisibilidad de tema del trabajo de cuidado no remunerado en la mayoría de las políticas públicas de la región.

A pesar de algunas excepciones notables, sólo una proporción muy pequeña de las políticas de protección social de la región aborda de manera explícita las preocupaciones de cuidado no remunerado.

En un estudio reciente, en que se analizaron 50 políticas públicas en 18 países de la región, se identificaron sólo seis políticas de protección social (implementadas en cuatro países) que se consideraron “exitosas” al abordar el tema de trabajo de cuidado no remunerado de manera explícita. Se trata de Argentina (en relación al programa Asignación Universal por Hijo, el antiguo programa Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y la Asignación Universal por Embarazo); Chile (Chile Solidario); El Salvador (Pensión Básica Universal) y Uruguay (PANES).

Sin embargo, con la excepción del programa Pensión Básica Universal de El Salvador, todas las políticas “exitosas” estaban dirigidas a redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado de la familia para el Estado. No se identificaron políticas “exitosas” que abordaran la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres a los hombres (Chopra y otros, 2013).

En el caso de Chile, Chile Solidario⁵⁶ se destaca al prevér guarderías infantiles durante las sesiones de formación de las mujeres jefas de hogar. Otro aspecto destacable es que Chile Solidario establece programas pre-escolares adaptados para llegar a la población objetivo, proporcionando no sólo acceso gratuito sino que un horario flexible para satisfacer las necesidades de las madres que trabajan.

A pesar de la flexibilidad de horarios para satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras, algunas evaluaciones mostraron que la tasa de escolarización pre-escolar era baja (4,6%) debido a percepciones culturales que los

⁵⁶ Ver nota 46 supra.

niños y niñas son mejor cuidados en el hogar, representando el 90% de los motivos de auto-reporte de la falta de inscripción (Galasso, 2011).

En relación a la distribución de la carga del trabajo de cuidado no remunerado, en la región sobresalen los programas de atención integral a la primera infancia. Algunos de estos programas tienen un impacto positivo no sólo respecto a la mayor protección y disfrute de los derechos de los niños y niñas, sino que además ayudan a distribuir la carga del trabajo de cuidado no remunerado desde las familias al Estado así como dentro de la familia (de la mujer al hombre).

Dentro de las políticas y programas más comprehensivos, con un enfoque de derechos explícito, encontramos la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA), del Uruguay. La ENIA señala explícitamente que la distribución equitativa de las cargas de cuidado entre hombres y mujeres y, sobre todo, su reconocimiento como responsabilidad social son claves de una real ampliación de los derechos y oportunidades de bienestar (ENIA 2010, pág. 25)

Varios programas de la región han tenido como objetivo la redistribución del trabajo de cuidado de la familia hacia el Estado ofreciendo servicios de guardería asequibles que satisfagan las necesidades de las madres trabajadoras, dando así importantes pasos respecto a la igualdad de género. En este sentido encontramos los programas de Hogares Comunitarios. Estos programas están siendo implementados en varios países de la región, por ejemplo en el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, México, Perú y Colombia. Estos programas en general tienen un impacto positivo en la incorporación al empleo formal por parte de las mujeres, así como en la nutrición y hasta la talla de los niños y niñas.

En Guatemala, por ejemplo, el Programa de Hogares Comunitarios permite a las mujeres (especialmente las mujeres solteras) participar en el empleo formal, que suele ser más estable y mejor remunerado, proporcionando mayores beneficios sociales y de salud (Ruel y otros, 2006). En Perú, el

Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW) reporta desde mejoras en la reducción de la desnutrición crónica, aumento al acceso al documento nacional de identificación en las niñas y niños beneficiarios (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2011), hasta impactos positivos en permitir a las madres trabajar o estudiar, como consecuencia de enviar a sus hijos a los Wawa Wasi, sin preocuparse por su seguridad (Cueto y otros, 2009).

En Colombia, el programa de cuidado infantil y nutrición, Hogares Comunitarios, establecido en 1986 —ahora el programa de bienestar más grande en el país— proporciona cuidado infantil y alimento a menores de 7 años de edad, atendiendo a más de un millón de menores en aproximadamente 80.000 centros con un impacto positivo incluso en el talla de los niños y niñas (Attanasio y otros, 2010 pág. 3).

En conclusión, en la región ha habido importantes avances en relación a la capacitación y apoyo a las familias (padres y madres), y una mejora en la distribución de las tareas de cuidado desde la familia hacia el Estado, sin embargo, a pesar de los progresos, seguir avanzando en la igualdad de género en la región requiere aumentar la visibilidad del trabajo de cuidado en las agendas políticas nacionales y lograr una redistribución más equitativa de la carga de trabajo entre la mujer y el varón y entre las familias y el Estado. La incorporación de los hombres en las políticas de cuidado, —elemento indispensable de un enfoque de derechos— es una tarea aún pendiente en la región. Se requiere de políticas integrales que trabajen de forma intersectorial, coordinada y sostenida, desde los diferentes sectores del Estado proveedores de servicios de salud, cuidado, educación, atención integral, entre otros.

b) Niñas/niños

Las estrategias para la infancia implementadas en la región a menudo tienen un enfoque explícito de derechos, enfatizando como objetivos primordiales la igualdad de todos los niños y niñas en el desarrollo de capacidades, la priorización de la niñez como sujeto de derechos y el interés superior del niño, entre otros.

En la región se destaca la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030 (ENIA) del Uruguay. La ENIA señala explícitamente que su abordaje está basado en la normativa internacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y en especial aquellos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (ENIA, 2008, pág. 3). Asimismo, teniendo en cuenta que la CDN establece como uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas la participación activa en la comunidad, en la formulación de la ENIA se llevaron a cabo consultas con los propios niños, niñas y adolescentes, quienes aportaron su voz y su perspectiva al texto final. Asimismo, la estrategia establece expresamente que la implementación de la misma “debe estar presidida por un enfoque de promoción y respeto de los derechos” (ENIA 2008, pág. 29).

En Brasil, se destaca el programa Brasil Carinhoso,⁵⁷ que forma parte de Brasil Sém Miséria. Este programa se estableció con el compromiso político firme para erradicar y revertir —a través de estrategias directas— las trampas de pobreza y desigualdad persistentes que afectaban a los niños/as del Brasil a pesar de los 10 años de operación del Bolsa Família (Robles y Mirosevic, 2013). El programa tiene tres pilares: a) provisión de ingreso, a través del Beneficio de Superación de la Extrema Pobreza en la Primera Infancia (Benefício de Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância); b) educación a través del aumento del número de plazas disponibles en guarderías; y, c) salud, a través de acciones para aumentar el suplemento de vitamina A, sulfato de hierro, y acceso a medicinas gratuitas contra el asma.

En Argentina, se destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH),⁵⁸ que ofrece una asignación familiar mensual para los padres que están desempleados o trabajan en la economía informal que son padres o madres de un menor de 18 años (reconociendo que la gran mayoría de las mujeres no trabajan en el sector formal) (Roca, 2011). La AUH, enmarcada en un enfoque de derechos, amplió entonces la cobertura a grupos de trabajadores que tradicionalmente

⁵⁷ Véase <http://www.brasilsemmiseria.gov.br/brasil-carinhoso/brasil-carinhoso>.

⁵⁸ Decreto 1.602/09 que modifica la Ley de Asignaciones Familiares núm. 24.714.

se encontraban excluidos. Esta asignación se justifica desde un enfoque de derechos, en el que se entiende que “el interés superior del niño” incluye lograr proteger “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos se les reconoce, entre los que se encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad Social.”

A pesar del avance que supuso esta asignación, desde un enfoque de derechos es cuestionable que se haya establecido sólo a través de un Decreto y no por una ley formal, que la protegería de cambios de gobierno. Este programa también ha sido criticado desde el punto de vista de los derechos humanos en relación al no cumplimiento con el principio de universalidad ni los de igualdad y no discriminación, al imponer requisitos que excluyen a ciertos grupos tales como las personas privadas de libertad, personas migrantes que no acrediten una residencia mínima de tres años en el país, y por establecer un límite de cinco hijos en el pago (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013).

Asimismo, se ha considerado que algunas de las condicionalidades del programa, pueden excluir innecesariamente a ciertos beneficiados. Por ejemplo, el requisito de que la escolarización se cumpla en establecimientos públicos, excluiría al 20% de los potenciales beneficiarios que asisten a escuelas privadas subsidiadas, con comedores y doble escolaridad que les permiten trabajar. La EPH de 2009 indica que el 6,8% de los pobres extremos y el 10,5% de los moderados sigue este comportamiento (Gasparini y Cruces, 2010).⁵⁹

El requisito de que los trabajadores informales reciban menos del salario mínimo, también ha sido criticado por considerarse que es imposible su aplicación práctica y que abre una ventana al clientelismo. Un alternativa propuesta para minimizar el clientelismo sería generalizar las asignaciones a

⁵⁹ En reconocimiento de esta debilidad, se ha reportado que la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES) ha iniciado un estudio para subsanarla. Véase <http://www.anses.gob.ar/noticia/los-chicos-que-concurren-a-escuelas-privadas-continuaran-cobrando-la-asignacion-universal-por-hijo-15>.

toda la población que no las reciba por su empleo formal (Gasparini y Cruces, 2010). Por otra parte, se ha considerado que las contraprestaciones en materia de salud y educación sobrecargan a las mujeres con responsabilidades sin que exista adecuado apoyo a través de infraestructura de cuidado (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013).

c) Adultos mayores

La región presenta altos niveles de precariedad de la población adulta mayor. Esto no llama la atención si se tiene en cuenta el alto porcentaje de adultos mayores de la región que no reciben ni pensión ni jubilación. En el año 2009, por ejemplo, apenas cuatro de cada diez latinoamericanos de 65 años y más recibía una jubilación o pensión, existiendo grandes diferencias entre los países, con una cobertura que alcanza al 89% en Argentina frente a un 7% en Honduras (CEPAL, 2011).

Frente a esta situación de vulnerabilidad, la opción de transferencias universales de ingreso a los adultos mayores se ha presentado como una herramienta efectiva para lograr asegurar niveles mínimos esenciales del disfrute de los DESC de todos los adultos mayores, sin discriminación.

Esto es precisamente lo que se ha establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia a través del programa Renta Dignidad,⁶⁰ que consiste en una pensión universal no contributiva para el adulto mayor. El programa está en línea con la amplia protección de los derechos del adulto mayor consagrados en la Constitución, que establece que “todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley” (Artículo 67). A nivel sub-nacional, se destaca también la pensión alimentaria de adultos mayores en la Ciudad de México.⁶¹

⁶⁰ Ley 378, del 16 de mayo de 2013 sobre Renta Universal de Vejez.

⁶¹ Se benefician todos aquellos que teniendo 68 años cumplidos vivan en el Distrito Federal por tres años o más. Véase http://www.adultomayor.df.gob.mx/documentos/pension_alimentaria.php y Yanes, 2011.

Las transferencias no contributivas universales al adulto mayor, a diferencia de los programas focalizados, requieren de una estructura más simple con costos administrativos más reducidos, lo cual les confiere mejores posibilidades de éxito en el logro de sus fines. Estas pensiones universales permiten evitar la falta de incentivos para los trabajadores de ingresos bajos en el sentido de que ahorren para la vejez, así como de incentivos para las personas de edad de seguir trabajando después de la edad de la jubilación (Mkandawir, 2005). También pueden reducir las oportunidades de corrupción puesto que están disponibles para todos quienes cumplen el requisito de la edad y evita el estigma social en los beneficiarios.

Asimismo, las pensiones no contributivas son más sensibles a las cuestiones de género, puesto que los hombres y las mujeres reciben el mismo nivel de prestación independientemente de su actividad en el mercado laboral, con lo cual se reconoce la contribución de la mujer en forma de trabajo de cuidado no remunerado. Otra ventaja potencial de los programas universales sobre los focalizados es que la discriminación estructural de las mujeres sobre la base de estereotipos de género, imperantes en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, puede significar que se encuentran en peores condiciones de ejercer influencia en los procesos de decisión y por ende pueden quedar excluidas de las pensiones focalizadas. En los regímenes universales no puede manipularse el acceso en detrimento de la mujer. Esto significa, que en muchos países de la región, las pensiones universales como la Renta Dignidad, pueden ser el único medio de dar a la mayoría de las mujeres la garantía de que percibirán ingresos en su vejez.

d) Pueblos indígenas

En la última década han habido importantes avances legislativos y jurisprudenciales en materia de reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la región (OIT, 2009). En cuanto al diseño de política pública, también se puede identificar un avance en una mayor incorporación de un enfoque de interculturalidad que busca el fortalecimiento de la identidad de diferentes comunidades resaltando sus valores, costumbres y saberes.

Varios planes nacionales de desarrollo así como políticas o estrategias específicas adoptadas por países de la región, reconocen y valoran la diversidad cultural de cada país. Asimismo, en el ámbito de implementación de programas específicos, muchos se han orientado a responder a las características y necesidades de los usuarios en regiones de población indígena. Tomar medidas específicas para llegar a la población indígena es especialmente importante en la región, donde los pueblos indígenas son más proclives a la pobreza que los no indígenas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004).

Los avances normativos se han traducido en algunos avances en el disfrute de los derechos. Por ejemplo, ha habido un incremento significativo en la proporción de niños y niñas indígenas que ha ingresado al sistema escolar (CEPAL, 2013, pág. 83). Este avance ha sido especialmente significativo en el caso de las niñas y adolescentes indígenas de 12 a 17 años. A inicios del presente siglo, alrededor de la mitad de ellas estaban fuera del sistema educativo formal, mientras que los censos de 2010 muestran que ya más del 70% de las adolescentes indígenas están escolarizadas. Uno de los factores que puede haber impactado en la cobertura escolar han sido los programas de transferencia condicionada (PTC), que han comenzado a llegar también a los pueblos indígenas (Robles, 2010), a pesar de que muy pocos países de la región han adaptado el diseño e implementación de los PTC a los requerimientos de los pueblos indígenas.⁶²

Sin embargo, pesar de los avances, quedan muchos retos para asegurar que los pueblos indígenas en la región puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Las desigualdades étnicas, generacionales y de género persisten. Asimismo, a pesar de los avances en acceso a la educación, aún no se garantiza la calidad y pertinencia cultural del proceso de enseñanza-aprendizaje para las niñas, niños y jóvenes indígenas (CEPAL, 2013, págs. 82-88).

En la región aún son escasos los análisis comprehensivos sobre el alcance de los programas sociales en la situación económica y social de los pueblos indí-

⁶² Algunas excepciones serían, por ejemplo, Colombia y Panamá (Robles, 2010).

genas y, cuando los hay, éstos muestran que las desigualdades persisten. Por ejemplo, en México, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2006 y 2012 muestran que, a pesar de algunas mejoras, la inequidad social persiste en lo relativo a las condiciones de vida, la situación de salud y el acceso a los servicios de salud entre la población indígena (9,4% de la población) y la no indígena (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).

Para atender las necesidades de la población indígena de la región se debieran diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones estructurales de vida de los pueblos indígenas; en particular orientadas a reducir las barreras de acceso a la protección social y a los servicios de salud. Es esencial que las políticas y programas de protección social tengan en cuenta la multiculturalidad de las sociedades de la región.

e) Personas con discapacidad

En la región son pocos los programas que han sido diseñados o reestructurados con el objetivo de superar las barreras específicas que las personas con discapacidad enfrentan para acceder a la protección social y de esta manera dar cumplimiento a las obligaciones internacionales relativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en particular, art. 28).

Dentro de los pocos programas dirigidos a las personas con discapacidad se destacan las pensiones no contributivas universales establecidas en el Uruguay (Programa de pensiones no contributivas), en Brasil (Beneficio de Prestación Continuada de Asistencia Social, BPC)⁶³ y en República Dominicana (Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado).⁶⁴

⁶³ El BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) fue establecido por la Constitución de 1988 y es regulado por la Ley Orgánica de Asistencia Social-Prestaciones de invalidez, la Ley 8742, del 12 de julio de 1993, por la Ley 12.435, del 6 de julio de 2011 y Ley 12.470, del 31 de agosto de 2011, que modifica invalidez y dispositivos por los Decretos 6214 del 26 de septiembre de 2007 y Decreto 6564, del 12 de septiembre de 2008.

⁶⁴ La Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado de República Dominicana fue establecida por ley en 2001, pero aún no ha sido implementada. Recién en 2013 se aprobó el reglamento del Régimen Subsidiado.

El BPC sobresale por su cobertura (a marzo del 2012 beneficiaba a 3,6 millones de personas en todo Brasil, de las cuales 1,9 millones eran personas con discapacidad y 1,7 millones personas mayores)⁶⁵ y porque en su reforma del 2012 amplió los criterios de evaluación para comprender barreras psicosociales que restringían el acceso de las personas con discapacidad a la prestación, en explícito cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ISSA, 2012).

Desgraciadamente, en los tres casos señalados, los montos que proporcionan estas pensiones no contributivas no alcancen siquiera el valor del salario mínimo y son suficientes para hacer frente a las necesidades económicas que enfrentan las personas con discapacidad (Alméras, 2013).

En general, la región debe seguir avanzando para dar cumplimiento a las normas y estándares internacionales relativos a las personas con discapacidad, y para ello se deben abandonar cualquier enfoque asistencialista, para dar lugar a sistemas integrales que promuevan la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad funcional. Para ello se necesitan seguir avanzando en apoyos para permanecer en el sistema de educación, mejoras de la infraestructura, acceso al trabajo y el crédito entre otros.

f) Especial énfasis en el territorio

El principio de igualdad y no discriminación también obliga a tener en cuenta de manera prioritaria los territorios más desventajados que permanecen invisibles al Estado. En América Latina, la alta concentración espacial de la población y de la actividad económica se acompaña de muy fuertes disparidades territoriales —que pueden ser medidas por las brechas en el PIB per cápita territorial (CEPAL, 2010). Esta situación de inequidad hace imperativo una respuesta adecuada por parte de las políticas públicas.

⁶⁵ <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc>.

Frente a esta situación, los planes nacionales de desarrollo de la región tienden a incluir explícitamente el objetivo de lograr una equidad territorial, como una forma de dar cumplimiento a este principio de igualdad. Por ejemplo, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 del Ecuador, establece que “la garantía de derechos (...) demanda la necesidad de generar políticas públicas que aseguren condiciones de equidad territorial”.⁶⁶

Por su enfoque de derechos, se destaca en Brasil, el programa Territorios de Ciudadanía (Programa Territórios da Cidadania).⁶⁷ Este programa busca reducir la desigualdad en los territorios más desventajados y su objetivo es “promover el desarrollo económico y universalizar los programas básicos de la ciudadanía a través de una estrategia de desarrollo territorial sostenible”.⁶⁸

El programa está enfocado en mejorar la calidad de vida de los brasileños que viven en las regiones que más lo necesitan, especialmente en el medio rural. Sigue tres ejes de acción: el apoyo de la actividad productiva, el goce de los derechos y fortalecimiento institucional y la infraestructura. De esta forma, busca lograr la inclusión social estimulando la generación de ingresos en la actividad rural como la participación ciudadana en la planificación del desarrollo territorial sostenible y el acceso a los servicios públicos esenciales: documentación civil, seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación y cultura, organización social e infraestructura (habitación, caminos de acceso, energía y saneamiento). Asimismo, como se ha indicado, el Plan Brasil sin Miseria busca dar prioridad a las familias, los territorios y el público más vulnerable en el acceso a políticas sociales. Por ejemplo, estableciendo unidades básicas de salud en las zonas con mayor concentración de pobreza.

⁶⁶ República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, 2009, pág. 33.

⁶⁷ Véase, <http://www.territoriosdacidadania.gov.br>

⁶⁸ Gobierno de Brasil, *Territorio de la ciudadanía. Integración de políticas públicas para reducir la desigualdad*, marzo de 2009.

IV. Participación

En las últimas décadas en la región ha habido una apertura a la participación ciudadana, que se ha expresado en el establecimiento, en varios países, de un marco normativo que consagra el derecho a la participación y define mecanismos concretos para llevarla a cabo a nivel constitucional, legal, de decretos, reglamentos y reglas de operación (Hevia, 2011).

Frente a un legado de clientelismo y corrupción en la política social de la región, las medidas de apertura a una mayor participación tienen un impacto potencial importante. Esta apertura a la participación es especialmente evidente en la expansión en los últimos 15 años de iniciativas de presupuestos participativos que se implementan en diferentes gobiernos locales o municipalidades en al menos 15 países de la región (UNIFEM, 2010). En relación a la protección social, se destaca que en varios países de la región se han establecen mecanismos precisos de participación en relación a la salud⁶⁹ o alimentación.⁷⁰

Asimismo, se han incorporado ciertos mecanismos de participación directos en diversos programas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, con distintos grados de éxito.

Brasil es quizás uno de los países de la región que más ha avanzado en materia de participación ciudadana en los programas sociales. Este avance está en línea con la Constitución y las leyes nacionales que establecen la participación deliberativa de la población. Así por ejemplo, el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), al igual que en el sector de la salud, establece

⁶⁹ Véase, por ejemplo, artículo 98 de la Constitución de Guatemala, que establece el derecho a la participación de las comunidades en programas de salud: “Las comunidades tienen el derecho y el deber de participar activamente en el planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud.” Asimismo, en Perú, el artículo 14 de la Ley General de Salud (Ley 26.842). En Brasil véase lo relativo a la participación en el Sistema Único de Salud (SUS), sección IV.3.A supra.

⁷⁰ Véase, por ejemplo, en el Perú: artículo 2 de la Ley 27.731, Ley que regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentario.

dos mecanismos de participación: las conferencias y los consejos gestores. Estos Consejos funcionan a nivel nacional, estatal y municipal y tienen una composición paritaria entre los miembros que pertenecen a la sociedad civil y al gobierno.

En México, destacan los comités de promoción comunitaria, que reúne a las beneficiarias del programa Oportunidades. Se trata de instancias que buscan “establecer un vínculo entre las familias beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y de la Coordinación Nacional, a efecto de canalizar sus peticiones y sugerencias, fortalecer las acciones de cada uno de los componentes que opera el Programa, fomentar el desarrollo comunitario, promover la contraloría social y transparencia del Programa” (Gobierno de México, 2010).

Sin embargo, estos comités han sido criticados por tratarse de un mecanismo con falta de autonomía, sin funciones o atribuciones que permitan hablar de él como un mecanismo de participación ciudadana, se trataría más bien de un mecanismo de participación obligatoria (Hevia, 2011).

A pesar de las críticas, dentro de los aspectos positivos se debe reconocer que en México, al igual que en Brasil, los avances en materia de participación en política social han estado acompañados de un marco normativo e institucional adecuado.

Particularmente relevante son la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la creación y operación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), así como la adopción de una variedad de leyes estatales y reglamentos municipales de transparencia y acceso a la información.

A pesar de los avances, la región aún enfrenta enormes obstáculos de naturaleza estructural a la participación efectiva de los grupos más desventajados y excluidos, debido a su nivel de ingresos, desigualdad de género, ubicación geográfica, discriminación étnica y racial. Mayores esfuerzos se necesitan

para poner en práctica la normativas constitucionales y legales relativas a la participación ciudadana, la descentralización político administrativa y la rendición de cuentas. Para ello es necesario que se institucionalice la participación ciudadana en todos los programas sociales, y de esta manera se dé una respuesta real a las demandas de la ciudadanía.

V. Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información

Un enfoque de derechos enfatiza la responsabilidad de las autoridades públicas ante los ciudadanos frente a su gestión y la necesidad de que se establezcan mecanismos asequibles para exigir estas responsabilidades. Para que se pueda hacer efectiva esta rendición de cuentas, es esencial que exista transparencia y acceso a la información.

La mayoría de los programas sociales de la región no cuentan con mecanismos de transparencia efectivos, lo que constituye un gran desafío desde un enfoque de derechos.⁷¹ Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que de acuerdo a los índices de percepción de corrupción, varios países de la región reciben muy bajas calificaciones, encontrándose entre los países en que se percibe un mayor nivel de corrupción de manera global.⁷²

Entre los avances, se puede observar la adopción de leyes de acceso a la información en varios países—entre ellos, Brasil (2011), Colombia (1985), Chile (2008), Ecuador (2004), Guatemala (2008), México (2002) y Perú (2002)— así como el establecimiento de “sistemas de atención ciudadana” donde se puede consultar información y presentar reclamos y denuncias (por ejemplo, en Argentina, Chile y México).

⁷¹ Programa Equidad Económica en América Latina (EELA) de Transparencia Internacional. Disponible en: http://www.transparency.org/whatwedo/activity/transparencia_y_rendicion_de_cuentas_en_programas_sociales_de_latinoamerica

⁷² Para dar un ejemplo, de los 176 países evaluados en el año 2012, México ocupó la posición 105, Honduras se ubicó en el puesto 133, Paraguay en el 150, Haití y Venezuela en el 165. Véase Índice de Percepción de la Corrupción 2012, Transparencia Internacional.

En lo que respecta a programas de protección social, el avance mayor se ha dado en los PTC, algunos de los cuales han incorporado mecanismos de acceso a la información flexibles e incluyentes que representan modelos a seguir. Por ejemplo, la incorporación de líneas telefónicas para llamadas gratuitas (por ejemplo, en el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador), así como la puesta en marcha de mecanismos de acceso de información que toman en cuenta las barreras de alfabetización, el bajo acceso a internet y los altos costos de transporte (por ejemplo, en Oportunidades). El resultado es que el acceso a la información por parte de algunos beneficiarios condiciones de desventaja ha mejorado.

Así como ha habido algunos avances en materia de transparencia y acceso a la información, en las últimas décadas, varios países de la región han establecido también mecanismos que permiten a los ciudadanos controlar a los funcionarios públicos encargados de la implementación de programas sociales, a través de la presentación de una queja o denuncia en caso de irregularidades o ser víctimas de abuso de poder.

En México, por ejemplo, existen tres canales de atención ciudadana: la Dirección General de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) del programa Oportunidades, y los sistemas de atención de denuncias de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Se destaca en este sentido el SAC, que recibe y maneja las quejas por parte de los ciudadanos y beneficiarios del programa Oportunidades. Entre 2003 y el 2009 el sistema recibió más de 780 mil demandas ciudadanas, entre solicitudes, quejas, sugerencias y denuncias (Hevia y Gruenberg, 2010). A pesar del potencial que tiene el sistema para investigar quejas y denuncias, en la práctica este se ve limitado puesto que en su mayoría recibe solicitudes de consulta. Por ejemplo, en los 6 años indicados la gran mayoría (el 83,2%) de las respuestas del SAC se refería a solicitudes y consultas (Hevia y Gruenberg, 2010).

La región necesita seguir avanzando para garantizar los derechos sociales de los titulares de programas sociales frente al clientelismo político y la corrupción. En este sentido, se ha sugerido que una estrategia persuasiva a través de la incorporación de medidas administrativas más flexibles, sanciones blandas y una gestión de la información y de la transparencia sería una opción viable (Gruenberg y Pereyra Iraola, 2009).

En general, el mayor avance en la región se ha dado en relación a los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de los PTC de mayor cobertura tales como Bolsa Família de Brasil y Oportunidades de México. Los esfuerzos que se han hecho en estos programas para establecer mecanismos de rendición de cuentas, de acceso a la información y de evaluación, que sean accesibles a los sectores más pobres de la población debieran ser lecciones para poner en práctica en todas las políticas y programas de protección social y en las políticas públicas de manera más general.

Al respecto, podemos enfatizar algunas de las recomendaciones que ha dado Hevia (2009) en relación al acceso de información en los programas de protección social, que incluye: mantener y mejorar los niveles de información a la población beneficiaria; facilitar las formas en que la ciudadanía pueda presentar una queja o denuncia ante las instancias pertinentes; fortalecer la resolución de quejas/denuncias que lleguen por vía telefónica a las diversas instancias, tomando en cuenta las limitaciones legales de las instancias de atención ciudadana, la resistencia institucional y la respuesta limitada de las contrapartes institucionales; vincular las instancias de capacitación con las de recepciones e investigación de quejas y denuncias y los órganos estatales e internos de control; revisar la legislación existente para limitar la posibilidad de los partidos y actores políticos a usar los programas sociales para propaganda política; transparentar los padrones de los programas sociales y resguardar mejor la información confidencial, para que estos no se puedan usar de manera ilícita para campañas electorales; y obligar la entrega de información a los beneficiarios sobre las recomendaciones de las evaluaciones externas de impacto, para mejorar la operación de los programas sociales.

F. La judicialización de los derechos sociales y su impacto en el diseño de las políticas de protección social

La consagración constitucional de los DESC, se ha traducido en el desarrollo de una creciente jurisprudencia por parte de algunos tribunales de la región.⁷³ Sobresalen aquellos países donde existe una protección constitucional de los DESC, como es el caso de las Constituciones de Argentina (art. 43), Estado Plurinacional de Bolivia (art. 19), Brasil (arts. 5, LXXI y 103), Colombia (art. 93) y República Bolivariana de Venezuela (art. 27).

Sin embargo, debemos reconocer que la exigibilidad judicial de estos derechos no ha sido igual en toda la región, debido a los diferentes contextos legales, sociales y culturales de los países (Tushnet, 2007, pág 9). Salvo por las excepciones recién mencionadas, en muchos países de la región parece que está arraigada la visión (ya superada) que los DESC constituyen meras declaraciones de intención y normas programáticas que no son exigibles por la vía judicial. Esto se traduce en que en algunos países estos derechos aún están excluidos de una protección constitucional (tutela constitucional) (Courtis, 2010).

Efectivamente, tradicionalmente se ha considerado que los DESC son de naturaleza jurídica distinta a los derechos civiles y políticos, considerándose que son vagos, de naturaleza inherentemente positiva y dependientes de recursos disponibles (Sepúlveda, 2005). Esta visión limitada de la naturaleza jurídica de los DESC, ha sido ampliamente debatida en la doctrina, y se puede considerar como un debate superado (Sepúlveda, 2001). Naturalmente, es posible argumentar que algunas obligaciones impuestas por los DESC requieren una mayor inversión pública que los derechos civiles y políticos, pero eso sería más un problema de grado que de fondo.

⁷³ Para un análisis en detalle de la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina, Brasil, Colombia, y República Bolivariana de Venezuela, véase, por ejemplo, Langford, Malcolm (ed.), *Teoría y jurisprudencia de los derechos sociales. Tendencias incipientes en el derecho internacional comparado*, Universidad de los Andes / Siglo del Hombre Editores, 2011.

Otros argumentos en contra de la exigibilidad judicial de los DESC dice relación con una eventual vulneración del principio de separación de poderes entre las distintas ramas del Estado, puesto que el poder judicial asumiría un rol de ejecutor de políticas públicas y asignaría recursos, cuando su rol debiera estar limitado a interpretar y aplicar la ley y no en “crear política pública”. Por convincente que pueda parecer este argumento, lo cierto es que a través de la revisión de un caso, no se les está pidiendo a los tribunales que hagan leyes o políticas públicas, sino revisar decisiones, acciones y omisiones a partir de un conjunto de criterios, en este caso los derechos humanos.

Finalmente, también se ha argumentado la falta de capacidad de los tribunales para decidir en casos relativos a los DESC. Frente a este argumento, debemos entender que las decisiones judiciales sobre estos derechos, buscan proteger derechos fundamentales estableciendo los procesos y criterios mediante los cuales se traslada la carga de la prueba a las autoridades estatales y las obligan a justificar su inacción o incumplimiento de los derechos, y usan su discrecionalidad a la hora de establecer remedios judiciales para encontrar formas apropiadas en función del contexto de hacer cumplir los deberes de los sujetos obligados.

A pesar de que el debate en contra de la exigibilidad judicial de los DESC, pareciera estar concluido, por varios motivos, entre ellos la naturaleza inherentemente conservadora de los tribunales y de los operadores jurídicos, este debate pareciera aun estar abierto en varios países de la región, donde a pesar de la importante evidencia de jurisprudencia comparada en materia de DESC, se mantienen en posiciones y argumentos tradicionales ya superados.

I. El caso de la Corte Constitucional de Colombia

Aunque queda fuera del alcance de este documento referirse en detalle a la protección y exigibilidad judicial de los DESC, es pertinente referirse de manera concreta a algunos casos, para entender de qué manera la protección judicial de los DESC puede tener una influencia significativa en las políticas y programas de protección social.

En la región, un caso emblemático de protección de DESC a través de la vía judicial se ha dado lugar en la Corte Constitucional de Colombia a través de la acción de tutela.⁷⁴ La acción constitucional de tutela, puede ser presentada por cualquier persona cuyos “derechos constitucionales fundamentales” estén amenazados o se violen por una acción u omisión de cualquier autoridad pública. La tutela procede sólo si no existe ningún otro recurso judicial disponible para la parte afectada, a menos que se use la acción como un medio temporal para evitar un daño irremediable (artículo 86, Constitución Colombiana).

La Corte Constitucional reconoce que las obligaciones relativas a los DESC son de naturaleza progresiva,⁷⁵ sin embargo con frecuencia responde a las acciones de tutela presentadas exigiendo un cumplimiento inmediato de estos derechos mediante una interpretación amplia del derecho a la vida, la dignidad y la seguridad. Así mismo, ha desarrollado el concepto de “mínimo vital para una vida digna”.

Ya en el año 1992, en una decisión histórica que da muestra de un activismo judicial garantista de los derechos, conociendo de una acción de tutela la Corte Constitucional ordenó al Estado Colombiano de proporcionar asistencia económica a un ciudadano de 63 años que vivía en indigencia, sin contacto con su familia, para someterse a una operación ocular que le permitiría recuperar la vista. En la sentencia la Corte reconoció que el ámbito y el contenido de los beneficios sociales se deberían determinar por la ley. Sin embargo, estableció que el Congreso no había cumplido con su deber de adoptar una ley que se ocupara de la situación de personas en las condiciones del demandante, y que ese vacío en el sistema de protección de la seguridad social justificaba la protección de la Corte. Por consiguiente, la Corte concedió la tutela y ordenó al Instituto de Seguros Sociales proporcionar el tratamiento.

⁷⁴ Para un análisis detallado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, véase Sepúlveda, Magdalena, “Select National Jurisdictions: Colombia”, En *Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law*, Langford, Malcolm (ed.), Cambridge University Press, 2008.

⁷⁵ Véase, por ejemplo, SU-111/97.

El razonamiento desarrollado por la Corte en este caso se ha aplicado en varias sentencias posteriores donde, al igual que en el caso señalado, se considera que en circunstancias excepcionales, el derecho a la seguridad es de aplicación inmediata. Para evaluar cuando este derecho será de aplicación inmediata se deben cumplir, según la Corte las siguientes condiciones: a) el individuo está en una situación de debilidad manifiesta debido a su situación económica, física o mental; b) no existe posibilidad para el individuo o su familia de tomar una acción que le permita remediar la situación; c) el Estado tiene la posibilidad de remediar o mitigar su condición; y d) la inacción o la omisión del Estado afecta la capacidad del individuo de gozar de las condiciones mínimas de una vida digna.⁷⁶

Si se cumplen todas estas condiciones, la Corte ordena al Estado cumplir inmediatamente con su deber de proporcionar asistencia social. Aplicando este razonamiento se ha obligado al Estado Colombiano, entre otras cosas, a proporcionar tratamiento médico,⁷⁷ a recibir gratuitamente a una mujer con una enfermedad mental en un sanatorio mental público,⁷⁸ y a proporcionar a un anciano acceso a un hogar de ancianos para vivir sus últimos días.⁷⁹

Con respecto al goce del derecho a la seguridad social en su componente contributivo, la Corte ha exigido que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, mediante la indexación de las mesadas de las que dependen sus beneficiarios.⁸⁰ Asimismo, ha supervisado la equidad de los procedimientos

⁷⁶ Véase Sentencia T-533/92. En palabras de la Corte: “Cuando una persona demuestra la circunstancia de debilidad manifiesta en que se encuentra, debido a su condición económica, física o mental, sin que ella misma o su familia puedan responder, excepcionalmente se genera para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en dicha situación. En tal evento, se opera una inversión en el orden de exigibilidad del principio de solidaridad social, que obliga al Estado a una prestación directa e inmediata en favor de la persona que se halla en circunstancias de debilidad manifiesta, sin perjuicio del derecho en cabeza de la autoridad estatal, cuando sea del caso, al reintegro posterior de su costo por parte del beneficiario y de su familia.”

⁷⁷ Sentencia T-533/92.

⁷⁸ Sentencia T-046/97.

⁷⁹ Sentencia T-1330/01.

⁸⁰ Sentencia T-457/09.

administrativos relativos a la provisión de beneficios sociales. En este sentido, la Corte ha indicado que todo programa social debería cumplir con los principios del debido proceso, es decir, con obligaciones como las siguientes: a) cuidar a las personas vulnerables o con discapacidades, entre las que están las personas ancianas y las personas con incapacidades físicas o mentales, con el fin de evitar la discriminación y la exclusión social; b) permitir la participación de los beneficiarios en audiencias y comités que decían sobre su situación; y c) proporcionar información oportuna, pertinente, correcta y completa sobre los procedimientos requeridos para obtener el subsidio relevante.⁸¹ Así, por ejemplo, la Corte concedió la protección de la tutela en el caso de un anciano que no había recibido un subsidio estatal porque había obtenido información errónea de la entidad administrativa encargada de los procedimientos necesarios para obtener el subsidio.⁸²

Aunque la acción de tutela no es el medio apropiado para conseguir recibir un beneficio impago de seguridad social (porque hay otros medios legales disponibles), la Corte ha declarado que si la falta de pago implica una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes, es posible exigir el cumplimiento de ese derecho mediante una tutela. Según este criterio, a pesar de que la orden de pago de los beneficios de maternidad, por ejemplo, no estaría protegida a través de una acción de tutela, en el evento de que el “mínimo vital” de la madre y su recién nacido dependen del pago de beneficios de maternidad, este derecho se convierte en un derecho fundamental que se puede exigir inmediatamente mediante una acción de tutela.⁸³

Se debe señalar que reclamar judicialmente el derecho a la seguridad social mediante un procedimiento de tutela no es posible para todas las personas. Esa protección se concede sólo en circunstancias excepcionales en las que

⁸¹ Véase, por ejemplo, Sentencias T-149/02 y T-499/95.

⁸² Sentencia T-149/02. La Corte ordenó a la autoridad relevante reexaminar el caso y proporcionar al hombre ayuda durante todo el procedimiento.

⁸³ Véanse las sentencias T-568/96, T-270/97, T-567/97, T-662/97, T-175/99, T-362/99, T-496/99, T-104/99, T-139/99, T-210/99, T-365/99, T-458/99, T-258/00, T-467/00, T-1168/00, T-6/01, T-1002/01, T-497/02, T-664/02 y T-707/02.

los individuos se encuentran en una situación de necesidad imperiosa, que requiere una protección judicial inmediata. Por consiguiente, no todos los adultos mayores, los desempleados, las madres pueden invocar efectivamente su derecho a la seguridad social mediante una acción de tutela, sino sólo aquellas personas cuyo “mínimo vital” dependa de esos beneficios.

Otro ámbito destacado de la judicialización de los DESC, pertinente de analizar brevemente, es la protección del derecho a la salud (artículo 49, Constitución Colombiana).⁸⁴ De manera general, la Corte considera que este derecho es de realización progresiva, y por ende no sujeto a la exigencia por vía judicial, excepto cuando existe un nexo con un derecho fundamental o cuando se trata del derecho a la salud de los niños/as, que según el propio texto constitucional es un derecho fundamental en sí mismo, de aplicación inmediata por los tribunales (artículo 44).

Algunas de las sentencias más polémicas y de mayor relevancia de la Corte Constitucional Colombiana se refieren a la protección del derecho a la salud de los niños/as a través de los llamados “tratamientos en el extranjero”. Estas sentencias se refieren a casos en los cuales la Corte ordena a los proveedores de servicios de salud, públicos o privados, que cubran los gastos de tratamientos administrados fuera de Colombia cuando no hay un tratamiento nacional disponible para la enfermedad.

En un caso histórico de 1995, una niña que padecía leucemia y necesitaba un trasplante complejo que no podía hacerse en Colombia, la Corte ordenó que el sistema de seguridad social pagara el tratamiento de salud de la niña en una clínica especializada de los Estados Unidos.⁸⁵

⁸⁴ Para un análisis en detalle de la protección de este derecho por la Corte Constitucional, véase Rodríguez Garavito, Cesar y Yamin, Alicia (eds.), *Justicia y salud: la Corte Constitucional y el derecho a la salud en Colombia*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2011.

⁸⁵ Sentencia T-165/95. Además del pago del tratamiento, la Corte ordenó también a la institución pública cubrir los pasajes de avión de la niña y de uno de sus padres, y darles 125.000 dólares como pago adelantado de los gastos.

Los criterios que ha elaborado la Corte para dar lugar a un el tratamiento en el extranjero son:

a) que existan circunstancias de extrema gravedad que afecten la vida del paciente; b) que el tratamiento médico requerido no se puede suministrar en Colombia; c) que exista un certificado médico que establezca que el tratamiento médico sería efectivo en las circunstancias concretas del paciente y que no es un tratamiento experimental; y d) que el paciente (o su familia) carezca de los medios para cubrir los costos, teniendo el Estado los recursos disponibles para hacerlo.⁸⁶

Estos casos indican que el derecho a los servicios de salud implica, al menos en el caso de los niños y niñas, el derecho a obtener cuidados de salud caros y especializados cuando la vida en general o una vida digna están en peligro. En estos casos, considera la Corte, que le corresponde al Estado asignar los recursos que permitan cubrir los costos.

En general, excepto en el caso de los niños, la exigibilidad judicial del derecho a la salud en las acciones de tutela depende de las circunstancias del caso. Por consiguiente, en el caso de un adulto, depende del juez decidir si su derecho a la salud es directamente exigible o no. En este sentido, son particularmente relevantes los casos en los que la Corte ordena la prestación de tratamientos médicos o el suministro de medicamentos que por ley están excluidos del catálogo de tratamientos y medicamentos disponibles en los planes obligatorios de salud. En esos casos,⁸⁷ la Corte ha determinado que el cumplimiento estricto con el plan obligatorio de salud implicaría la violación de los derechos fundamentales. Con ello, la Corte ha rectificado de hecho la ley y las normas de procedimiento de las instituciones prestadoras de cuidados de salud. Este tipo de protección otorgada por la Corte ha sido especialmente importante en los casos de VIH-SIDA.

⁸⁶ Sentencia SU-819/99.

⁸⁷ Véase, por ejemplo, sentencias SU-043/95 y SU-819/99.

Con respecto a las entidades privadas, en especial a los prestadores privados de servicios de salud, la Corte no sólo les ha ordenado que suministren medicamentos o presten tratamiento no incluidos en la ley, sino que también ha retenido el poder de supervisar el cumplimiento de la prestación de servicios, con el fin de evitar que las entidades violen los derechos de los individuos. Por ejemplo, la Corte ha expresado preocupación cuando un tratamiento médico se retrasa debido a las ineficiencias de las respuestas de los proveedores privados de servicios de salud. Según la Corte, el Estado tiene el deber de garantizar que los servicios médicos se proporcionan de manera eficiente y con continuidad, incluso cuando los servicios los prestan las entidades privadas.⁸⁸ Sin embargo, es importante destacar que cuando la Corte ordena a los prestadores privados de servicios de salud que cubran los costos de un tratamiento en el extranjero, o el pago de medicamentos o tratamientos no incluidos en el plan de salud obligatorio, dichos prestadores pueden solicitar el reembolso de los costos al Estado.⁸⁹

La jurisprudencia relativa al derecho a la salud, brevemente detallada en esta sección, llevó algunas consecuencias indeseadas, entre ellas una explosión de demandas, alentadas con frecuencia por las empresas aseguradoras que lograban utilidades al recobrar del Estado el costo de las medicinas y tratamientos ordenados por los jueces de tutela.⁹⁰ Como ha demostrado un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, entre 1999 y 2009 los tribunales colombianos decidieron 775.102 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, que representaron a lo largo del período 1999-2009 entre el 25% y

⁸⁸ Véase, por ejemplo, sentencias T-227/01, T-428/98, T-030/94, T-059/97, T-088/98, T-428/98, T-018/03 y T-658/03.

⁸⁹ Este tipo de gastos se cubre por un fondo especial de solidaridad, el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguros y Salud, establecido por la ley. Véase la Ley 100 (1993) y el Decreto Legislativo 1283 (1996).

⁹⁰ Para un análisis en detalle véase, Sepúlveda, Magdalena y Rodríguez Garavito, Cesar: "Colombia: la Corte Constitucional y su contribución a la justicia social", en *Teoría y jurisprudencia de los derechos sociales. Tendencias incipientes en el derecho internacional y comparado*, Malcolm Langford (editor), Universidad de los Andes, 2013.

el 40% de las acciones de tutela presentadas en todo el país.⁹¹ Al convertirse en la “válvula de escape” de las fallas del sistema de salud, un buen número de sentencias de tutela terminó teniendo efectos negativos sobre la equidad, la sostenibilidad financiera y la eficiencia del sistema (Procuraduría General de la Nación y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2008). Asimismo, la aproximación judicial convencional —esto es, las decisiones caso a caso— se mostró insuficiente frente a las fallas estructurales de las políticas públicas y diseño institucional que subyacían a las miles de tutelas que continuaban llegando a los despachos judiciales.

Para enfrentar estos dilemas, en el 2008 la Corte Constitucional dictó la trascendental sentencia T-760/08. En ella, acumuló 22 tutelas que ilustraban las falencias principales del sistema de salud, y dictó órdenes de carácter estructural al gobierno colombiano para enfrentarlas. En esta decisión, la Corte estableció que los cuidados médicos que estén excluidos del plan obligatorio de salud pueden ser exigidos inmediatamente por vía de tutela cuando: a) la falta de servicio médico amenace el mínimo vital del paciente; b) el servicio no sea reemplazable por otro contenido en el plan obligatorio de salud; c) el paciente no pueda pagar el tratamiento o el medicamento que precise y no pueda obtenerlo a través de otro sistema de aseguramiento de salud, como los planes de seguro provistos por el empleador, planes complementarios prepagados, etc.; y d) el servicio o el medicamento haya sido prescrito por el médico tratante.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la Corte dictó una serie de órdenes para que el poder ejecutivo mejorara la eficiencia, equidad y supervisión del sistema de salud. Entre dichas órdenes, destaca la que obliga al gobierno a actualizar periódicamente los beneficios incluidos en el plan obligatorio de salud, con base en criterios técnicos y con la “participación directa y efectiva de la comunidad médica y de los usuarios del sistema de salud”.

⁹¹ Véanse los tres informes publicados por Defensoría del Pueblo al respecto: La tutela y el derecho a la salud (periodo 2003-2005); La tutela y el derecho a la salud (periodo 2006-2008); y La tutela y el derecho a la salud (2009), Defensoría del Pueblo de Colombia.

II. Logros y desafíos de la judicialización

En sociedades como las latinoamericanas donde existen niveles muy elevados de desigualdad y exclusión social, la judicialización de los DESC es una herramienta fundamental para proteger a las personas contra las violaciones de los DESC, supervisar el diseño y la ejecución de las políticas públicas con el fin de asegurarse que los grupos vulnerables tienen la oportunidad de utilizar los recursos legales disponibles y pueden gozar de sus derechos. Permite además llenar los vacíos en la protección de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad cuando esos vacíos han sido descuidados por políticos o legisladores, o simplemente no se han atendido.

Sin embargo, la protección de los DESC por la vía judicial es posible sólo en aquellas jurisdicciones en que existe una garantía fuerte a los DESC, esto es, que no sólo se consagren en la Constitución, sino que además exista una norma constitucional (por ejemplo, la tutela constitucional) que permita su exigibilidad directa en los tribunales de justicia, como es el caso de Colombia y Brasil.

En el caso particular de Colombia, se ha argumentado que la protección de los DESC por la vía judicial no sólo ha modificado el equilibrio del poder social y político al conceder más poder a las personas débiles, vulnerables, marginadas y desorganizadas, sino que además esta protección ha sido una herramienta contra la violencia (Cepeda, 2004). Según esta opinión, la tutela ha permitido a los grupos tradicionalmente poco representados en el sistema político promover sus intereses mediante vías constitucionales, en vez de por la violencia (Cepeda, 2004).

También se ha argumentado que la protección de los DESC mediante la acción de tutela ha contribuido a lograr un cambio en la cultura legal, forzando a los tomadores de decisiones públicas a tomarse esos derechos en serio y a darles prioridad política (Arango, 2003). Asimismo, se ha argumentado que la protección de la tutela ha mejorado la relación entre el individuo y la administración pública, al obligar a esta última a cumplir con sus deberes de conformidad con el debido proceso (Uprimny, 2001).

En el caso de Brasil, se ha considerado que las decisiones en materia de DESC, en particular relativas al suministro gratuito de medicamentos, cuando han estado unidas a las estrategias bien coordinadas y eficientes de los procesos judiciales, han provocado cambios en el derecho y la adopción de políticas públicas que se consideran ejemplares (Piovesan, 2008).

Sin perjuicio de los beneficios, como se puede apreciar en el mismo caso colombiano, este tipo de sentencias son a menudo polémicas y es pertinente preguntarse si este tipo de decisiones son sostenibles, si efectivamente tienden a buscar una mayor equidad en las sociedades o si por el contrario el litigio en materia de DESC perpetúa los beneficios de las clases medias y altas, quienes tienen un mayor acceso a los sistemas judiciales.

En efecto, a primera vista, debido a la multitud de obstáculos económicos, físicos, sociales y culturales que enfrentan las personas que viven en situación de pobreza para acceder a la justicia,⁹² por lo general, los litigios en materia de DESC tienden a estar monopolizados por la clase media y alta. De tal manera que terminan favoreciendo a quienes ya son privilegiados. Sin embargo, un análisis más detallado y con perspectiva, muestra que el litigio individual también puede desencadenar procesos estructurales más igualitarios.

En este sentido, nuevamente es pertinente tomar como referente el litigio en salud en Colombia, puesto que se ha argumentado que este litigio ha dado lugar a un diagnóstico y reacción en el poder ejecutivo, legislativo y judicial que ha contribuido a una mayor igualdad, al tiempo que ha tenido una influencia simbólica positiva en el sentido de consolidar en la opinión pública la idea de los DESC como derechos exigibles (Uprimny, Rodrigo y Durán 2013).

En todo caso, se debe tener presente que los procesos judiciales no son la única forma de promover y proteger estos derechos fundamentales y no siempre

⁹² Para un análisis en detalle de los obstáculos en acceso a la justicia de las personas que viven en pobreza, véase el Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, documento A/67/278, del 9 de agosto de 2012.

son la estrategia más efectiva. Teniendo en cuenta las enormes desigualdades que existen en los países de la región, el alcance del litigio en tribunales es obviamente limitado: proteger de manera efectiva los DESC, mejorar las grandes brechas en materia de desigualdades sociales, facilitar la inclusión y la participación de la población en la vida económica y social, y estimular la mejora progresiva de las condiciones materiales de existencia de los sectores marginados de la sociedad requiere de un conjunto de reformas estructurales que evidentemente no pueden quedar limitadas a una estrategia judicial.

Por otra parte, el uso exitoso de los tribunales como estrategia para el cumplimiento de los DESC es un reto significativo. Se deben superar una serie de obstáculos que van desde la falta de normas adecuadas sobre legitimidad procesal a la falta de recursos financieros y jurídicos. Asimismo, para garantizar la legitimidad de ciertas demandas es necesario que la estrategia de litigio logre conectar entre sí a las comunidades demandantes, los movimientos sociales y los activistas con experiencia de litigio judicial, esto es también presenta un gran desafío.

Asimismo, el éxito de la utilización de los tribunales para la protección de los DESC, depende también de una serie de factores, incluida la capacitación de jueces y operadores jurídicos en la utilización de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos; el establecimiento de un marco normativo que permita a la sociedad civil presentar casos en representación de aquellos que de otra manera no podrían acceder al sistema judicial; una sociedad civil activa y preparada para ocuparse de casos en nombre de los grupos excluidos y desaventajados; y la voluntad de los tribunales de tomar decisiones que sirvan de guía a las políticas públicas y en la prestación de servicios.

Al mismo tiempo, es necesario también que los mecanismos no judiciales de promoción y protección de derechos humanos, tales como las instituciones nacionales de derechos humanos (por ejemplo, defensorías del pueblo y comisiones nacionales de derechos humanos), tengan competencia; estén dispuestas y capacitadas; y cuenten con los recursos financieros y humanos para lidiar con casos relativos a los DESC.

A pesar de los desafíos, algunos de los casos de protección judicial de los DESC de la región han demostrado que es posible desarrollar estrategias de litigio exitoso. Una de las lecciones aprendidas es que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto judicial puede en gran medida mejorar el sistema. La capacidad que tienen estas organizaciones de apoyar a las víctimas o iniciar causas en su nombre, puede reducir la carga económica y personal de los demandantes que emprenden acciones legales. Cuando existe la posibilidad de entablar litigios de interés público o de presentar escritos de *amicus curiae*, las organizaciones de la sociedad civil pueden desbloquear las vías de acceso a la justicia para las personas que viven en situación de pobreza. Esto ocurre en particular en las acciones interpuestas por causas de discriminación o malos tratos estructurales o sistémicos, que afectan a un gran número de personas que viven en pobreza.

Asimismo, a pesar de que en la mayoría de los sistemas jurídicos de la región los fallos judiciales afectan sólo a las partes del litigio o a quienes interponen una demanda, incluso cuando las causas tienen repercusiones más amplias —lo que favorece a las clases medias o altas que tienen los recursos para superar los obstáculos de acceso a la justicia y los impedimentos del litigio—, existen casos emblemáticos en que la protección judicial otorgada en un caso específico ha sido extendida para abordar soluciones jurídicas colectivas.

Esto sucede, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional Colombiana declara un “estado de cosas inconstitucional”. Este concepto no se contempla en la Constitución Colombiana y su desarrollo es una clara demostración de creatividad judicial. Cuando en los casos particulares del que tiene conocimiento la Corte, se reflejan: a) violaciones sistemáticas y generalizadas de varios derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas, y b) que las violaciones de estos derechos no se pueden atribuir únicamente a una autoridad estatal, sino que son producto de deficiencias estructurales, en estos casos determina que la situación constituye un “estado de cosas inconstitucional”, y por ende requiere de la adopción de remedios

judiciales que tengan por finalidad proteger no sólo a aquellos que presentan la acción de tutela, sino a todos los individuos en las mismas circunstancias.⁹³

Otra forma en que casos individuales han generado beneficios a los no litigantes que se encuentran en una situación similar, es a través de litigios de interés público. Al igual como sucede en los casos de declaración de estado de cosas inconstitucional en Colombia, los litigios de interés público pueden conducir a la concesión directa de prestaciones a personas que no han participado en el caso judicial específico. Asimismo, casos de alto perfil, pueden también influir en la formulación de políticas públicas. Estos casos pueden también ayudar a crear conciencia de la necesidad de respeto de las normas constitucionales e internacionales en materia de DESC.

Finalmente, es importante señalar que es un deber de los Estados establecer recursos judiciales accesibles para exigir el respeto de los DESC por parte de los habitantes. El derecho a la seguridad social (seguro social y asistencia social) así como el derecho a la salud y otros DESC están consagrados en tratados internacionales vinculantes para los países de la región, asimismo, están reconocidos en varias constituciones, por ende, los Estados deben garantizar que todas las personas, en especial quienes se encuentran en situación de marginalización, tengan acceso a mecanismos judiciales efectivos cuando dichos derechos sean vulnerados.

Aun existiendo un riesgo de que la judicialización de los DESC pueda dar lugar a resultados no esperados, una oposición frontal a la misma no se justifica. Negar la posibilidad de la población pueda exigir por vía judicial el cumplimiento de los DESC, que tribunales independientes y en cumplimiento de las garantías del debido proceso puedan fallar para garantizar la protección de los mismos, sería abiertamente contrario a una perspectiva de derechos y

⁹³ Sobre la doctrina y las sentencias sobre estados de cosas inconstitucionales, véase Rodríguez Garavito, C., “Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas inconstitucional”, en Rodríguez Garavito, C., (ed.), *Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento en Colombia*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009.

de las obligaciones asumidas por los Estados en sus constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Como se ha señalado, la crítica del uso de los tribunales como camino para el cambio social sólo es sostenible en el evento de que hubiera otras alternativas viables o si las demandas judiciales empeoraran la situación, en ausencia de otras alternativas. Por consiguiente, toda crítica a una decisión de acudir a los tribunales se debe pensar a partir de las estrategias más generales. Si una persona, una comunidad o un movimiento social tiene otras opciones reales disponibles —como la movilización activa, la reforma legal y de políticas públicas, la negociación, el activismo en los medios de comunicación, etcétera—, entonces debería ser objeto de escrutinio riguroso la decisión de acudir a los tribunales, especialmente si será la estrategia dominante en lugar de una estrategia complementaria (Langford, 2008).

G. Conclusiones y recomendaciones de política pública

Aunque tanto los defensores de los derechos humanos como los agentes de desarrollo reconocen que los derechos humanos desempeñan un papel esencial en la lucha contra la pobreza y en general están de acuerdo en el hecho de que existen sinergias entre los derechos humanos y los programas de desarrollo, aún existe un retraso considerable en lo que respecta a la construcción de estrategias que sirvan de puente entre los dos paradigmas.

En las últimas décadas los gobiernos de la región han ido incorporando un creciente discurso de derechos en sus estrategias de desarrollo, así como en sus políticas y programas de protección social. Por desgracia, a pesar de los logros, parece evidente que todavía estamos en las primeras etapas de la curva de aprendizaje en términos de poner en práctica el discurso de derechos.

Para continuar en este aprendizaje, este documento ha buscado, por un lado, avanzar en el desarrollo conceptual del enfoque de derechos en las políticas y programas de protección social y, por el otro, analizar cuál es el nivel de puesta en práctica de la retórica de derechos humanos en el diseño,

implementación y evaluación de políticas de protección social, a través del examen de algunos casos.

A pesar de que muchos de los casos concretos indicados en este documento, pueden servir de ejemplo respecto a un enfoque de derechos en las políticas y programas de protección social, lo cierto es que los progresos aun no son del todo auspiciosos. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, no sólo en relación a los ingresos monetarios sino también en las dimensiones de género, etnia, clase y ubicación territorial. Aunque de manera global los índices de la región han mejorado considerablemente, los grupos más desaventajados no han visto mejoras significativas en el disfrute de sus DESC tales como el acceso a la salud, educación y trabajo decente.

Asimismo, para amplios sectores de la población el empleo tiende a ser precario, las condiciones laborales distan de los estándares de trabajo decente y no garantizan el acceso a mecanismos de protección social. A pesar de la retórica de derechos, en la región el nivel real de disfrute de los mismos está muy lejos de alcanzar su plena realización.

A lo largo del documento, hemos visto que a pesar de que América Latina ha avanzado bastante en materia de protección social, todavía existen retos de enorme magnitud por delante. Cada país tendrá sus propias especificidades, pero más allá de las mismas, los países de la región tienen la imperiosa necesidad de reforzar su enfoque de derechos para satisfacer la presión de una ciudadanía cada vez más ávida de participar en la formulación e implementación de políticas y más exigente en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Si se hiciera un esfuerzo mayor para poner en práctica la adhesión a los derechos incorporada en muchos planes de desarrollo o bien la retórica de derechos de muchos gobiernos, se lograría muchos más avances para superar la pobreza y la exclusión social que persiste en muchos países de la región.

Una perspectiva basada en los derechos puede contribuir al desarrollo sostenible al menos de dos maneras. Primero, reduce los riesgos sociales y políticos a través de la mejora de la justicia social y un enfoque de inclusión y no discriminación. Segundo, se crean instituciones más fuertes y más equitativas, no sólo del Estado, sino también instituciones civiles y de la comunidad (Moser y Norton, 2001, pág. ix).

Por otra parte, la promoción y observancia de los derechos humanos se consideran como elementos centrales en los esfuerzos por fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde los derechos sociales y económicos no han avanzado tan rápidamente como los derechos civiles y políticos —una situación que plantea desafíos para las democracias de la región.

I. Dar el salto de la retórica a la práctica

Desarrollar una política pública centrada en los derechos no debe agotarse en la incorporación de un lenguaje de derechos en los textos que las recogen, sino que debe traducirse en medidas concretas tendientes al pleno ejercicio y goce de los mismos. En la práctica, la aplicación de un enfoque de derechos a la protección social supone no sólo resguardar los programas sociales de los ciclos políticos y las coyunturas electorales, sino que busca asegurar a todos los miembros de la sociedad el acceso a condiciones mínimas para una vida digna.

En este sentido, a pesar de los avances, las políticas y programas de protección social implementados en la región aún no han logrado asegurar que los grupos más desaventajados y vulnerables tengan acceso al disfrute de mínimos esenciales de DESC. Aún estamos frente a niveles inaceptables de pobreza y la desigualdad sigue siendo alarmante. De conformidad a las estadísticas disponibles compiladas por la CEPAL para 18 países de la región, en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe solo 15% (CEPAL, 2012b). En el año 2012, 28,8% de los habitantes de la

región vivían en situación de pobreza, lo que corresponde a 167 millones de personas, un millón de personas menos que en 2011. Sin embargo, el número de personas en extrema pobreza o indigencia se mantenía estable en 2012, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011 (CEPAL, 2012b).

Estas cifras muestran que es imperioso consolidar los logros y seguir avanzando. Es inaceptable que los sectores más desaventajados y marginados, así como otros grupos específicos tales como las mujeres y los pueblos indígenas se estén quedando atrás. Un enfoque de derechos debe promover intervenciones para reducir y eliminar las circunstancias injustas y evitables que privan a ciertos grupos de sus derechos.

Dar el salto de la retórica a la práctica, requiere sobre todo de voluntad política de los tomadores de decisiones públicas, en particular de los miembros del poder legislativo y de los ministerios claves, tales como de economía y finanzas y planificación y desarrollo. La implementación de un enfoque de derechos que vaya más allá de las palabras, requiere en muchos casos de reformas legales y administrativas, así como de leyes de presupuesto acorde a los objetivos propuestos. El objetivo de lograr políticas y programas de protección social que respeten las normas y principios de derechos humanos tanto en sus procesos de implementación como en su resultado, es una tarea a largo plazo que debe ser una política de Estado que trascienda los ciclos políticos.

En muchos casos se requiere que los servidores públicos cambien la forma en que tradicionalmente han diseñado, implementado y evaluado las políticas sociales. Para ello se debe poner especial énfasis en la capacitación, como herramienta esencial para que tomen conciencia de cómo su trabajo puede contribuir al logro de sociedades más inclusivas con pleno respeto de la dignidad y derechos de todos los habitantes. La sociedad civil también tiene un rol crucial en impulsar la puesta en práctica de un enfoque de derechos a través de la sensibilización de la opinión pública, elaboración de metodologías y herramientas de análisis, cabildeo a los responsables políticos, y mediante el seguimiento del impacto y la evaluación de las políticas públicas.

Es necesario también seguir avanzando en el desarrollo de un marco conceptual y metodológico sólido que guíe en la traducción técnica y política de los DESC en las políticas y programas de protección social. Aunque existe una diversidad de modelos en la región, de manera general se puede señalar que para dar el salto de la retórica a la práctica sería conveniente que los marcos normativos de los diversos países consagren de manera específica el derecho a la seguridad social (protección social) y que expliciten quienes son los responsables de su implementación (a quién se le puede legítimamente exigir su cumplimiento). Asimismo, es necesario que se institucionalicen y se refuercen los mecanismos de rendición de cuentas y reparación en caso de vulneración a los DESC. Sin dichos mecanismos estos derechos no pueden ser reclamados en la práctica.

Los países de la región debieran reforzar los diferentes canales de exigibilidad de los DESC: la vía judicial, cuasi-judicial y administrativa, todos los cuales han de funcionar de manera complementaria. Los mecanismos judiciales comprenden el sistema legal formal, incluidos, los tribunales y las Cortes Constitucionales. Los mecanismos casi judiciales de reparación incluyen las instituciones establecidas para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos, pero que se encuentran fuera del sistema judicial (por ejemplo, comisiones de derechos humanos y defensorías del pueblo). Las vías administrativas de reparación incluyen quejas y procesos internos de mediación a los ministerios e instituciones de prestación de servicios y estructuras de los comités establecidos alrededor de las instalaciones de servicios.

II. Avanzar en el establecimiento de sistemas de protección social

A pesar de las marcadas diferencias en cuanto a diseño, componentes y cobertura de los diferentes programas de protección social en la región, una característica común de las experiencias de muchos países pareciera ser la fragmentación. La fragmentación de los programas de protección social limita su potencial eficacia, la sinergia y el impacto sobre la pobreza, la desigualdad y la exclusión. De esta forma, es necesario que los países de la región avancen

con determinación a la construcción de “sistemas de protección social” que garanticen el disfrute de los DESC de toda la población.

Un criterio basado en los derechos humanos requiere que los responsables de la formulación de políticas aseguren que todas las personas estén protegidas de forma equitativa y no discriminatoria. Teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad de la región, el principio de igualdad y no discriminación requiere que se dé especial atención al pilar no contributivo de la protección social como vía de llegada a los sectores más desventajados —ya que no se logra mediante el pilar contributivo—.

Para ello se deben integrar las distintas iniciativas en sistemas de protección social que aseguren la coordinación de varios programas, así como de las instituciones del Estado que están a cargo de su diseño, financiación, implementación, regulación, seguimiento y evaluación, a fin de lograr efectos positivos en las condiciones de vida de la población (Cecchini y Martínez, 2011).

Para lograrlo, es necesario ir más allá de un diseño sistémico o de red, la sinergia de todos los programas depende en gran medida de los recursos humanos, que deben estar capacitados adecuadamente a todos los niveles y de la existencia de recursos financieros suficientes. Un modelo de sistema de protección social basado en derechos, debe fundarse en la búsqueda del acceso universal dando prioridad a los grupos más desventajados y excluidos.

III. Aprender de y consolidar las innovaciones de los programas de transferencia en efectivo en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas

Luego de cerca de tres lustros de implementación exitosa e innovadora de programas de transferencia en efectivo, se ha logrado aprender importantes lecciones que debieran utilizarse en el diseño de todas las políticas públicas. Sin perjuicio de que ciertos mecanismos innovadores relativos a la participación ciudadana, al acceso a la información, y a la rendición de cuentas debieran

seguir mejorándose, principalmente en lo relativo a asegurar que los grupos más desventajados puedan hacer un uso efectivo de los mismos, estos mecanismos debieran incluirse de manera sistemática en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas sociales de la región.

La calidad de la gestión que se espera en los programas de transferencia debiera ser el estándar que se debiera buscar en general en todos los programas sociales. Los sistemas de evaluación externa de impacto que se han puesto en marcha en los programas más emblemáticos, debieran también pensarse para otros programas sociales.

Paralelamente, se debe seguir consolidando el enfoque de derechos de estos programas, que deben estar establecidos como políticas de Estado permanentes, protegidas de las fluctuaciones políticas y con montos adecuados. Así mismo, se deben tomar las medidas para mejorar paulatinamente el cumplimiento con los principios de igualdad y no discriminación (incluyendo el enfoque de género), participación, transparencia y acceso a la información, y rendición de cuentas. Lo que se traducirá en una mayor legitimidad de alguno de los programas existentes.

IV. Realizar cambios estructurales para la igualdad

Un enfoque de derechos impone una lucha frontal contra la persistencia de la exclusión social y las grandes brechas de desigualdades en la región. De esta forma, los sistemas de protección social deben ampliar sus objetivos de manera de buscar un impacto directo sobre la desigualdad. Por ejemplo, se debe fortalecer los programas no contributivos, ampliando su cobertura y su financiación, puesto que continúan recibiendo limitados recursos fiscales y no alcanzan a sectores importantes de la población que quedan excluidos de los sistemas formales de protección social.

Sin perjuicio del rol fundamental de la protección social, ésta no contribuirá de manera efectiva a la reducción de la igualdad y a garantizar al menos niveles mínimos esenciales de DESC si no se inserta en una estrategia integral,

comprehensiva, que tenga por objeto reducir o eliminar las condiciones que causan o contribuyen a perpetuar la discriminación en contra de ciertos segmentos de la población en todos los ámbitos relevantes, tales como empleo, vivienda, alimentación, seguridad social, salud, la educación, cultura y participación en la vida pública.

Esto requiere tomar acción en muchos frentes. Desde un punto de vista normativo, impone la adopción de normas legales que aseguren el disfrute de los derechos y el acceso a los servicios sin discriminación de ningún tipo. Los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el acceso por aquellos que sufren de la discriminación estructural, como las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías, los jóvenes y los adultos mayores.

Desde la óptica de los derechos, el principio de la equidad requiere que se preste especial atención a los grupos sociales más desventajados y excluidos, a modo de tener en cuenta sus necesidades particulares y asegurar su inclusión. Esto requiere no sólo identificarlos sino que establecer estrategias precisas que busquen su inclusión. En este sentido, particularmente preocupante es la población de la región que aún no está cubierta por los sistemas contributivos ni por los sistemas no contributivos. En los países menos desarrollados de la región este grupo estaría representado por aquellos sectores que viven en condiciones claras de marginalización y que sistemáticamente quedan fuera del alcance de las políticas de transferencia asistenciales (Cecchini y Madariaga 2011).

La reducción de la desigualdad —requisito de un enfoque de derechos— no puede ser únicamente asumida por la protección social. Sin ser el objetivo de este documento, entrar a analizar en detalle las otras acciones que son necesarias, es importante señalar que la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos requiere un enfoque integral y políticas públicas que sean consecuentes en respetar, proteger y cumplir todo el espectro de DESC tales como el derecho a la salud, educación, derechos labores, etc. Esto significa, que se debe: i) mejorar la calidad, adecuación y accesibilidad de los

servicios públicos; ii) avanzar en la educación de calidad; y, iii) avanzar en los derechos laborales.

1. Mejorar la calidad, adecuación y accesibilidad de los servicios públicos

Se ha de asegurar que las instalaciones, los bienes y los servicios tales como salud, sanitarios, agua y transporte, del cual dependen mayoritariamente las personas y grupos más desventajados, sean de la máxima calidad posible, en particular supervisando la calidad de los proveedores de los mismos. Incluso cuando las instalaciones, bienes y servicios son proporcionados con la participación del sector privado o de entidades de la sociedad civil, los Gobiernos son responsables de garantizar la calidad, la asequibilidad y la cobertura, y tienen el deber de proteger a las personas contra los abusos cometidos por los proveedores de servicios privados.

2. Avanzar en la educación de calidad

Promover un cambio estructural para avanzar hacia sociedades más igualitarias requiere fortalecer la inversión en educación (CEPAL, 2012a). El derecho a la educación es un derecho en sí mismo, pero también en una herramienta para alcanzar el disfrute de otros derechos, tales como el derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado.

A pesar de los avances en la región, incluyendo el aumento de recursos a la educación, no se ha logrado reducir brechas en logros educativos entre distintos grupos sociales, ni tampoco se han propiciado mejoras claras en la calidad de la educación, medida en aprendizajes pertinentes a lo largo de todo el ciclo de educación formal (CEPAL, 2012a).

Las normas de derechos humanos, son explícitas en lo que se refiere a las obligaciones de los Estados en relación al derecho a la educación⁹⁴ que

⁹⁴ PIDESC, arts. 13 y 14; véase también CDESC, Observación general núm. 13.

comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles.

3. Avanzar en los derechos laborales

Para lograr efectos positivos sobre la pobreza y la desigualdad también es necesario una mayor protección, garantía y vigencia de los derechos laborales. La evidencia de la región muestra que los mercados de trabajo no han convertido en la puerta de entrada a la protección social, y que menos de la mitad de los ocupados (46%) están afiliados a la seguridad social (CEPAL, 2011).

Esto requiere que se avance en la protección normativa de estos derechos. Los estándares de derechos humanos exigen que los Estados aseguren unas condiciones laborales justas y favorables, en particular la seguridad y la higiene en el trabajo, la limitación razonable de las horas de trabajo y vacaciones anuales pagadas.⁹⁵ Que se asegure el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos y a entrar en negociaciones colectivas.⁹⁶ Que se garantice a los trabajadores acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca la cobertura más amplia posible (por ejemplo, la atención de la salud, indemnización por enfermedad, pensiones de vejez e indemnización por las lesiones relacionadas con el empleo).⁹⁷ Asimismo, prohíben cualquier forma de discriminación contra los trabajadores, por ejemplo, por motivos de sexo, raza, origen étnico o religión.⁹⁸ Establecen que la remuneración de los trabajadores debe ser justa, permitiendo a ellos y a sus familias una vida digna y que se asegure la remuneración igual por trabajo de igual valor sin discriminación de tipo alguno; en particular, que las mujeres puedan disfrutar de la misma remuneración que los hombres.⁹⁹ También se establece una

⁹⁵ PIDESC, art. 7.

⁹⁶ PIDESC, art. 8; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.

⁹⁷ PIDESC, art. 9; véase también CDESC, Observación general núm. 9, párrs. 12 a 21.

⁹⁸ Véanse, por ejemplo, CEDAW, art. 11; y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5.

⁹⁹ PIDESC, art. 7, y CEDAW, art. 11.

protección especial para las mujeres durante el embarazo y para las personas con discapacidad.¹⁰⁰

Para garantizar la aplicación de esas obligaciones, los Estados deben reglamentar los mercados laborales y establecer mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas de los agentes privados. Además, ayudará a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos un número mayor de vías de diálogo entre empleadores y trabajadores y la oportunidad de que los trabajadores participen en el diseño y la aplicación de las políticas de empleo.

Las obligaciones de no discriminación y de igualdad obligan a los Estados a garantizar que las políticas de creación del empleo beneficie a todos los sectores de la sociedad por igual. Las políticas que aumenten las posibilidades de empleo (por ejemplo, mediante los conocimientos especializados y la formación profesional que reflejan la demanda) de los grupos que enfrentan obstáculos especiales en su acceso al empleo, tales como las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes y las poblaciones indígenas, ayudarán a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Para eliminar los obstáculos al empleo de las mujeres, los Estados deberían asegurar la disponibilidad de servicios de atención (del Estado, de la comunidad y del mercado), la redistribución del trabajo remunerado y no remunerado desde una perspectiva de género y la eliminación de todas las formas de discriminación por motivos de género. Los Estados no solamente están obligados a elaborar leyes eficaces con ese fin, sino también a adoptar medidas para modificar las pautas de conducta socioculturales de los hombres y de las mujeres.¹⁰¹

Además de la promoción y protección de un marco normativo, es recomendable que, como ha señalado la CEPAL (2012a) los países de la región continúen la tendencia de fortalecimiento de los salarios mínimos en concordancia con el desarrollo de la economía.

¹⁰⁰ Véanse PIDESC, art. 10; CEDAW, art. 11 y CDPD, art. 27.

¹⁰¹ Véase la CEDAW, arts. 3 y 5.

Los países de la región deben asimismo dirigir sus esfuerzos a la generación de oportunidades para un trabajo sostenible, productivo y digno en que las personas puedan ejercer y realizar sus derechos humanos. Las políticas de empleo deben respetar el marco de derechos humanos, lo cual tiene amplias implicaciones: desde la protección de los derechos de los trabajadores hasta la adopción de políticas que garanticen un acceso equitativo al empleo por parte de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.

V. Avanzar en la equidad de género y en las políticas públicas de cuidado

Especialmente importante es que se reconozca que las políticas y programas de protección social no son neutrales al género y por lo tanto deben ser diseñados, implementados y evaluados teniendo en cuenta las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres, y garantizando que se aborden las necesidades específicas de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida (infancia, adolescencia, edad adulta y vejez).

Sin perjuicio de que la igualdad de género debe ser articulada como objetivo de todas las políticas sociales y se deben asegurar los recursos necesarios para lograrlo, en relación a los programas de protección social es importante destacar la necesidad de que se reconozca el papel de las mujeres como proveedoras de cuidado sin reforzar patrones de la discriminación y los estereotipos negativos.

El trabajo de cuidado debe asumirse como una responsabilidad social y colectiva. Se deben tomar medidas para promover el valor del trabajo de cuidado no remunerado y buscar su distribución más equitativa, por ejemplo, alentando a los hombres a participar más activamente en las tareas de cuidado de los miembros de la familia. El Estado debe jugar un rol más protagónico en la provisión de servicios de cuidado, desde guarderías y jardines infantiles hasta centros de atención y personal de apoyo domiciliario para adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden cuidarse a sí mismos. Muy pocos países en la región tienen hoy, en su política de protec-

ción social, una agenda clara con vistas a integrar estos servicios de modo más equilibrado entre los cuatro actores en juego en el mundo del cuidado, a saber: la familia, la comunidad, el Estado y el mercado (CEPAL, 2012a).

VI. Fomentar la armonización de las políticas fiscales con los derechos económicos, sociales y culturales

Para hacer efectivo el disfrute de los derechos, no basta sólo con establecer mecanismos de protección, también es necesario que existan recursos disponibles, que dichos recursos se asignen a políticas con enfoque de derechos y sean sostenibles. En particular, aumentar la progresividad de los sistemas tributarios y luchar contra la evasión fiscal son herramientas esenciales en la lucha frontal contra las grandes desigualdades de la región.

Responder a la pregunta sobre cuáles son los recursos disponibles en cada país, es un tema complejo, pero que necesariamente requiere analizar el modelo económico y social vigente y las políticas macroeconómicas (monetarias, cambiarias, fiscales y tributarias). La obligación de los Estados partes del PIDESC es que los Estados han de disponer del “máximo de los recursos que disponga”. Esto necesariamente nos lleva al tema de la disponibilidad de ingresos fiscales para asegurar gasto público adecuado y sostenible y la necesidad de aumentar la recaudación tributaria.

Bajos niveles de recaudación fiscal impactan desproporcionadamente a los sectores más pobres de la población y constituyen un obstáculo considerable en la capacidad del Estado para garantizar programas sociales y servicios públicos que permiten el disfrute de los DESC. En la última década, el nivel de la recaudación tributaria en la región como porcentaje del PIB ha mostrado una tendencia creciente (CEPAL, 2013b). Sin embargo, aún quedan importantes retos por superar, en especial respecto a la regresividad en la tributación y la dependencia de los impuestos directos.

Se hace por lo tanto imperioso fortalecer la base fiscal general con el fin de mantener niveles adecuados de gasto público social, lo que requiere que los

formuladores de políticas públicas hagan una adecuada planificación. Esto requiere, por ejemplo, mejorar la progresividad de los sistemas fiscales actuales con un impuesto sobre la renta con menos exenciones, que tenga capacidad redistributiva real y que proteja los ingresos de los hogares más pobres. Cualquier reforma tributaria ha de guiarse por el objetivo de favorecer a los más pobres.

Todo esto supone superar varios desafíos. Por ejemplo, el creciente aumento de los precios de las materias primas ha favorecido a muchos países latinoamericanos y algunos del Caribe, para los cuales los recursos no renovables han sido una fuente importante y creciente de ingresos fiscales. Sin embargo, el hecho de tener más ingresos fiscales provenientes de los recursos ha tendido a socavar los esfuerzos para recaudar impuestos generales en el resto de la economía, al mismo tiempo que estudios sugieren que hay un margen considerable para aumentar la recaudación de ingresos fiscales en el sector de los recursos (Corbacho y otros, 2013).

Asimismo, parece necesario mejorar la progresividad de los dos principales pilares de los sistemas tributarios de América Latina, es decir, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, y reducir la elevada evasión fiscal (CEPAL 2013b; Corbacho y otros, 2013). Estas medidas lograrían una mayor equidad, al buscar que todos los agentes económicos y ciudadanos contribuyan con su parte al esfuerzo colectivo.

Los principios de derechos humanos requieren que se haga un examen cuidadoso de la posibilidad de reequilibrar las contribuciones tributarias de las empresas y de los grupos de altos ingresos. La introducción de impuestos nuevos o más elevados no debería tener efectos perjudiciales en los que viven en la pobreza. El aumento de la eficiencia de la recaudación de impuestos exige que se vuelvan a examinar las moratorias fiscales, las exenciones y las prórrogas que benefician de forma desproporcionada a los sectores más acomodados de la sociedad.

Un criterio de derechos humanos requiere también que los Estados adopten medidas para eliminar la prevalencia de la evasión de impuestos, un problema

que reduce los recursos disponibles para las medidas destinadas a realizar los derechos humanos. También hay que considerar la posibilidad de modificar las prioridades de los gastos en sectores sociales (tales como la educación y la salud) en comparación con los gastos militares para garantizar una utilización al máximo de los recursos disponibles para la realización de los DESC. Como se examina a continuación, un criterio de derechos humanos requiere que los Estados debatan abiertamente las opciones fiscales, evitando decisiones tecnocráticas que se toman a puerta cerrada, y en lugar de ello permitiendo una mayor transparencia y participación.

VII. Superar las barreras de capacidad e institucionales

Para que los sistemas de protección social en la región consoliden un enfoque de derechos es necesario superar barreras o limitaciones institucionales. Esto requiere una estrategia a largo plazo que permita a los países de la región poder acrecentar sus capacidades institucionales, con continuidad institucional, asegurando sostenibilidad de recursos y sin estar limitados por intereses políticos partidistas de corto plazo.

Una de las barreras institucionales más preocupantes en la región es la falta de datos estadísticos confiables y desglosados. Esto es un gran obstáculo desde un enfoque de derechos, puesto que sin información adecuada no se pueden priorizar los derechos humanos de los más vulnerables y desfavorecidos, cuyas necesidades los Estados tienen que ser capaces de identificar y evaluar con más exactitud y eficiencia.

La falta de datos desglosados hace invisible a ciertos sectores de la población, como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, y población afro descendiente e impide el respeto de la prohibición de no discriminación. Asimismo, la falta de datos contribuye a que las políticas públicas no sean efectivas y no lleguen a quienes más lo necesitan. Los datos deben desagregarse por diversas dimensiones, tales como género, edad, situación geográfica, origen étnico y estado de salud.

Tomarse el enfoque de derechos en la protección social seriamente, también requiere el desarrollo de indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluar la efectividad de las políticas en el disfrute de los DESC de la población.

Desde un enfoque de derecho, es fundamental que los indicadores sean suficientemente desagregados para visibilizar a los grupos más desventajados de manera de poder hacer un seguimiento cabal de su situación.

A pesar de la complejidad que significa definir indicadores, desarrollar sistemas de medición y mecanismos de seguimiento, este desafío debe servir de estímulo para estrechar los vínculos entre políticas sociales y derechos (Pautassi, 2010).

Para que pueda existir una adhesión real al enfoque de derechos es esencial el fortalecimiento institucional de las oficinas y los sistemas nacionales de estadística, lo que garantiza la calidad y la credibilidad de las estadísticas oficiales, y permite avanzar en la incorporación del enfoque de género en la producción estadística.

También es necesario fortalecer las agencias encargadas de las políticas y programas de protección social, de modo que cuenten con el poder político, los recursos presupuestales efectivos y la capacidad técnica. Esto es importante sobre todo para garantizar que sus objetivos puedan ser aplicados de manera transversal. Esto requiere también que exista un número significativo de operadores de política pública altamente calificados para gestionar políticas con enfoque de derechos.

Asimismo, se debieran tomar medidas para asegurar que los funcionarios en los departamentos gubernamentales claves estén formados y tengan capacidad analítica para evaluar las repercusiones de sus decisiones sobre los derechos humanos. Además, los Estados deberían establecer mecanismos de coordinación para garantizar la comunicación y el intercambio de información entre los departamentos gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Finalmente, es conveniente examinar la introducción de evaluaciones de impacto de derechos humanos como una práctica que tiene un gran potencial para hacer explícitos los vínculos conceptuales entre impactos sociales, económicos, ambientales y de desarrollo de las políticas públicas (Banco Mundial, 2013). Estas evaluaciones pueden ser un gran aporte para reforzar las prácticas existentes con respecto a la participación e igualdad, asegurando así que estas preocupaciones se aplican de una manera más consistente y con pleno respeto de la normativa internacional de derechos humanos.

VIII. Avanzar en la protección del medio ambiente

El cambio climático y la degradación ambiental siguen amenazando las vidas y los medios de subsistencia de la población de la región, teniendo un impacto desproporcionado en los más pobres, que con mayor frecuencia dependen de los recursos naturales como medio fundamental de supervivencia.

Las actividades emprendidas por las poblaciones rurales, tales como la agricultura, la acuicultura y la pesca están sobre expuestas al cambio climático. Por ende, los Estados deberían adoptar políticas públicas que de manera explícita tuvieran en cuenta la sostenibilidad y el desarrollo de todas las comunidades tanto en las zonas rurales como urbanas.

De esta forma, los programas de protección social debieran ofrecer seguridad económica a las personas que tienen más probabilidades de verse afectadas por los impactos negativos del clima. Algunos programas innovadores que vinculan la protección social con objetivos de protección al medio ambiente, tales como el programa Bolsa Verde en Brasil, tienen un gran potencial en el respeto y garantía de los DESC de los sectores más desventajados.

IX. Asegurar la rendición de cuentas y acceso a mecanismos de reclamo incluyendo la vía judicial

Para consolidar un enfoque de derecho es esencial que existan sólidos mecanismos de reclamo y reparación. Un factor clave es mejorar el acceso a los

mecanismos judiciales por parte de los sectores más pobres de la población. Para ello, al primer paso es superar la tradicional supuesta dicotomía entre los derechos civiles y políticos, de un lado y los DESC por otro, que ve a los segundos como derechos “programáticos”, meros objetivos políticos o declaraciones de buena voluntad. Siguiendo el ejemplo de varios países de la región, se deben consagrar estos derechos a nivel constitucional y establecer los mecanismos para que sean exigibles por la vía judicial.

Superada una posible barrera normativa, es preciso promover y capacitar a los operadores jurídicos para poder presentar y resolver casos relativos a la exigibilidad de estos derechos en general y a las violaciones del derecho a la seguridad social en particular.

Asimismo, es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para poder realizar litigio de interés público. Esto significa desde el establecimiento de reglas normativas que permitan el acceso a la justicia de estas organizaciones en representación de sectores desventajados, como el garantizar su independencia y actuar.

Es necesario también fortalecer el acceso a asistencia legal gratuita de calidad, para permitir que los sectores más desventajados de la población tengan acceso a los tribunales para exigir sus derechos.

X. Respetar las libertades y derechos esenciales para la participación social

Un enfoque de derechos requiere de la participación activa de múltiples actores sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de protección social. Una participación real y efectiva, requiere de un marco normativo que garantice y haga efectivo un amplio abanico de derechos tales como la libertad de expresión,¹⁰² la libertad de reunión,¹⁰³ la libertad

¹⁰² Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19.

¹⁰³ *Ibidem*, art. 21.

de asociación,¹⁰⁴ el derecho a buscar, recibir y difundir información¹⁰⁵ y el derecho a la educación, incluido el derecho a la educación en la esfera de los derechos humanos.¹⁰⁶

Todos esos derechos son requisitos previos y necesarios para la participación: a fin de participar de manera efectiva, todos los miembros de la población deben poder organizarse, reunirse, expresarse sin intimidación ni censura, conocer los hechos y argumentos pertinentes, ser conscientes de sus derechos, y tener las competencias y la capacidad necesarias.

En lo que respecta al derecho a la información, los Estados han de hacer todo lo posible para asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información que pueda ser de interés público, entre otros medios, poniendo dicha información a disposición de la opinión pública e instituyendo los procedimientos necesarios que permitan el acceso rápido, efectivo, práctico y fácil a la información. Respecto de las solicitudes de información, no deberían percibirse derechos que llegaran a constituir un obstáculo no razonable para acceder a la información, y debe existir un sistema de recurso para los casos en que se deniegue el suministro de información (Comité de Derechos Humanos, 2011).

Asimismo, los Estados deben velar por que los grupos que corren mayor riesgo de caer en la pobreza, como los que están expuestos a discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otra condición, no sólo estén debidamente representados en todos los procesos de adopción de decisiones que los afecten sino que también tengan poder y apoyo para expresar sus opiniones.

¹⁰⁴ *Ibidem*, art. 22; CEDAW, art. 7(c); y CDN, art. 15.

¹⁰⁵ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19.

¹⁰⁶ PIDESC, art. 13.1; CDN, art. 29.1; y CDPD, art. 24(c).

Los Estados deben asegurar que los pueblos indígenas, que son particularmente vulnerables a la pobreza en la región, gocen del derecho al consentimiento libre, previo e informado a través de sus propias instituciones representativas respecto de todas las decisiones que conciernan al uso de sus tierras, territorios y recursos por agentes estatales y no estatales.

Los Estados deben también proteger activamente a las personas, las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, los grupos y otras organizaciones no gubernamentales que apoyan y defienden los derechos de quienes viven en la pobreza. El principio de igualdad y de no discriminación requiere acciones afirmativas para lograr que todos tengan las mismas oportunidades de participación. Para ello es preciso identificar los obstáculos que impiden la participación de los grupos vulnerables y desfavorecidos y poner los medios para eliminarlos con miras a lograr una igualdad sustantiva.

H. Bibliografía

- Alméras, Diane, *Mapeo de los programas de pensión y de apoyo al cuidado para las personas con discapacidad en la región*, CEPAL, 2013. Disponible en: «<http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/2267/756303/DianeAlmeras-EGM2013-Panel5.pdf>».
- Arango, Rodolfo, “La jurisdicción social de la tutela”, en Molina Betancour, Carlos Mario: (ed.), *Corte Constitucional 10 años: Balance y perspectivas*, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 2003.
- Armijo, Marianela, “Planes Nacionales de Desarrollo en América Latina: Indicadores para el Desarrollo”, contribución al taller *Hacia un Panorama del Sector Público en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, 2010.
- Attanasio, Orazio P.; Di Maro, Vincenzo y Vera-Hernández, Marcos, *El impacto de un programa de cuidado infantil sobre resultados en nutrición. Evidencia en Colombia*, Instituto de Estudios Fiscales, 2010. Disponible en: «<http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/centrodoc/186555f3a8dd894c84ba1ad811713586.pdf>».

- Banco Mundial, *Human Rights Impact Assessments: A Review of the Literature, Differences with other forms of Assessments and Relevance for Development*, febrero, 2013.
- Banco Mundial, *Realizing Rights through Social Guarantees an Analysis of New Approaches to Social Policy in Latin America and South Africa*, Report No. 40047, 2007.
- Barrientos, Armando y Hulme, David, *Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*, Brooks World Poverty Institute, Working paper No. 30, 2008.
- Barrientos, Armando y Niño-Zarazúa, Miguel, *The effects of non-contributory social transfers in developing countries: A Compendium*, Manchester. Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, 2010.
- Barrientos, Armando, *Conditions in antipoverty programmes*, 19 Journal of Poverty and Social Justice 1, 2011.
- Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, *Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos*, Libros de la CEPAL No. 111, Santiago, 2011.
- Cecchini, Simone y Madariaga, Aldo, *Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*, Cuadernos de la CERPAL No. 95, Santiago, 2011.
- Cecchini, Simone, *Do CCT Programmes Work in Low-income Countries?*, One Pager 90, International Policy Centre for Inclusive Growth, 2009.
- CEPAL, *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*, Santiago, 2010.
- CEPAL, *Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo*, Santiago, 2012a. CEPAL: Panorama Social de América Latina 2012, Santiago, 2012b.
- CEPAL, *Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres*, Informe Anual 2012, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Santiago, 2012c.
- CEPAL, *Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y sociales en el marco de los derechos humanos*, Santiago, 2013.

- CEPAL, *Panorama fiscal de América Latina y el Caribe. Reformas tributarias y renovación del pacto fiscal*, Santiago, 2013b.
- Cepeda, M. J., *Judicial Activism in a Violent Context: The Origin, Role and Impact of the Colombian Constitutional Court*, Washington University Global Studies Law Review, volumen 3, 2004.
- Chopra, Deepta; Wanjiku, Alexandra, Kelbert y Iyer Padmini, *A Feminist Political Economy Analysis of Public Policies Related to Care: A Thematic Review*, Institute of Development Studies, Reino Unido, 2013.
- Comité de Derechos Humanos, *Observación General No. 34 sobre Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión*, Documento CCPR/C/GC/34, 12 Septiembre 2011.
- Corbacho A., Fretes Cibils V, Lora E. (editores): *Recaudar no basta: los impuestos como instrumento de desarrollo*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2013.
- Courtis, Christian, “Las políticas sociales, programas sociales, derechos sociales. Ideas para una construcción garantista”, en Abramovich, Victor y Pautassi, Laura (compiladores), *La Medición de Derechos en las Políticas Sociales*, Editores del Puesto, 2010.
- Cueto, Santiago; Guerrero, Gabriela y Leon, Juan, *Promoting early childhood development through a public programme, Wawa Wasi in Peru*, Young lives working paper 51, 2009. Disponible en: «<http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:53921573-62b5-4b7a-b457-1d36566321e8>».
- De Roux, Carlos Vicente y Ramírez J., Juan Carlos (Editores), *Derechos económicos, sociales y culturales, economía y democracia*, CEPAL – SERIE Estudios y perspectivas – Oficina de la CEPAL en Bogotá, 2004.
- De Souza, Renilson Rehem, *El sistema público de salud brasileño*, Ministerio de la Salud de Brasil, Brasilia, 2012.
- Department for International Development, United Kingdom (DFID), HelpAge International, Hope & Homes for Children, Institute of Development Studies, International Labour Organization, Overseas Development Institute, Save the Children UK, UNDP, UNICEF and the World Bank, *Advancing Child-Sensitive Social Protection*, June 2009.

- Disponible en: «www.unicef.org/socialpolicy».[Consultado el 31 de enero de 2024].
- Fiszbein, Ariel, *Entrevista con CIPPEC*, 30 Agosto 2013, disponible en: «<http://cippec.org/priorizarlaequidad/entrevista-a-ariel-fiszbein/>».
- Galasso, Emanuela y Ravallion, Martin, *Social Protection in a Crisis: Argentina's Plan Jefes y Jefas*, World Bank Policy Research, Working Paper No. 3165, 2003. Disponible en: «http://www-ds.worldbank.org/external/default/WDSCContentServer/TW3P/IB/2003/12/08/000012009_20031208112939/Rendered/PDF/wps3165.pdf».
- Galasso, Emanuela, “Aliviando la extrema pobreza en Chile: efectos a corto plazo de Chile Solidario”, en *Estudios de Economía*, volumen 38, No. 1, Junio 2011 pp. 101-127.
- Gasparini, Leonardo y Cruces, Guillermo, *Las asignaciones universales por hijo. Impacto, discusión y alternativas*, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), 2010.
- Gobierno de Brasil, *Territorio de la ciudadanía. Integración de políticas públicas para reducir la desigualdad*, marzo 2009, Disponible en: «<http://www.territoriosdacidadania.gov.br> ».
- Gobierno de México, *Programa de Desarrollo Humano Oportunidades*, 2010. Disponible en: «http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/atencion_ciudadana_p».
- Gruenberg Christian y Pereyra Iraola, Victoria, “Sistemas de rendición de cuentas. De la teoría promisorio a la práctica concreta: los casos de México y Argentina”, en Gómez-Álvarez, David (coord.): *Candados y Contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina*, Guadalajara, México, 2009.
- Hevia, Felipe y Gruenberg, Christian, *Continuidades y reformas en el sistema de atención ciudadana del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades*, Mexican Rural Development Research Report, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010.
- Hevia, Felipe, “Contraloría social y control ciudadano en los programas sociales”. En Gómez Álvarez, David (coord.) *Candados y contrapesos*:

la protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América, Guadalajara, México, ITESO, 2009.

Hevia, Felipe, *Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza. El caso de Progres/Oportunidades de México*, Regional Integration and Social Cohesion, volumen 5, 2011.

Instituto Nacional de Salud Pública, *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales*, Cuernavaca, Morelos, México, 2012. Disponible en: «<https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/descargas.php>».

International Social Security Association (ISSA), *Evaluation model based on the International Classification of Functioning, Disability and Health for persons with disabilities to access benefits A case of the National Social Security Institute*, ISSA, 2012.

Kidd Stephen y Calder Rebecca: *Conditional Cash Transfer Programmes: their relevance for Nepal*, DFID, Londres, 2011.

Langford, Malcolm (ed.), *Teoría y jurisprudencia de los derechos sociales. Tendencias incipientes en el derecho internacional comparado*, Universidad de los Andes y Siglo del Hombre Editores, 2011.

Langford, Malcolm, *Litigating Economic, Social and Cultural Rights*, Cambridge University Press, 2008.

Martinez Franzoni, Juliana y Voorend, Koen, *Blacks, Whites, or Grays? Conditional Transfers and Gender Equality in Latin America*, Social Politics, volumen 19, número 3, 2012.

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Perú, *aportes del programa nacional wawa wasi a la estrategia nacional cuna más 2011-2016*, Lima, Diciembre 2011. Disponible en: «<http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2013/08/documento-wawa-wasi.pdf>».

Missoni Eduardo y Solimano, Giorgio, *Towards Universal Health Coverage: the Chilean experience*, World Health Report (2010) Background Paper, 4 World Health Organization, 2010.

Mkandawir, Thandika, *Targeting and Universalism in Poverty Reduction, Social Policy and Development Programme Paper Number 23*, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Ginebra, 2005.

- Moser, Caroline y Norton, Andy, *To Claim our Rights: livelihood security, human rights and sustainable development*, Overseas Development Institute, 2001.
- Naranjo Bonilla, Mariana, *Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe*, Ecuador, CEPAL 2013.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), *Can Low-income countries afford basic social security?*, Social Security Policy Briefings, Paper 3, Ginebra, Suiza, 2003.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), *La aplicación del Convenio núm. 169 por tribunales Nacionales e Internacionales en América Latina*, Ginebra, Suiza, 2009.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), *La seguridad social y la primacía del Derecho*, referencia ILC100-III(1B), Ginebra, Suiza, 2011b.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), *Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet, Convocado por la OIT con la colaboración de la OMS*, Ginebra, Suiza, 2011.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), *Seguridad social para todos. Establecimiento de pisos de protección social y de sistemas integrales de seguridad social*, Ginebra, Suiza, 2012.
- Organización Panamericana de la Salud, *Salud en las Américas 2012*, Volúmenes de Países: Brasil, 2012.
- Pautassi, Laura, Pilar Arcidiácono y Mora Straschnoy, *Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de la Argentina: entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos*, CEPAL; 2013.
- Pautassi, Laura, “Seguridad y protección social. Lecciones de la experiencia Argentina”, en Bercovich, Luciana y Maurino, Gustavo (coord.): *Los Derechos Sociales en la Gran Buenos Aires. Algunas aproximaciones desde la teoría, las instituciones y la acción*. Buenos Aires, Eudeba, 2013, pp. 79-102.
- Pautassi, Laura, “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición”, en Abramovich, Victor y Pau-

- tassi, Laura (compiladores): *La Medición de Derechos en las Políticas Sociales*, Editores del Puesto, 2010.
- Piovesan, Flavia, “Select National Jurisdictions: Brazil”, en Langford, M.; *Litigating Economic, Social and Cultural Rights*, Cambridge University Press, 2008.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*, PNUD, 2004.
- República de Colombia, Procuraduría General de la Nación y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, *El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos y el sistema de inspección, vigilancia y control del Estado Colombiano en materia de quejas en salud*, Bogotá, Colombia, 2008.
- República Oriental del Uruguay, *Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Bases para su implementación*, borrador, diciembre 2008.
- Robles Claudia y Mirosevic, Vlado, *Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe*, Brasil, CEPAL-Colección Documentos de proyectos, 2013.
- Robles, Claudia, *Pueblos indígenas y programas de transferencias con corresponsabilidad. Avances y desafíos desde un enfoque étnico*, serie Políticas Sociales, No. 156, Santiago, CEPAL, 2010.
- Roca, Emilia, “Extension of the Universal Family Allowance: The Universal Child Allowance”, en *Sharing Innovative Experiences, Successful Social Protection Floor Experiences*, vol. 18, 2011.
- Román, Oscar y Muñoz, Félix, “Una mirada crítica en torno al plan AUGE. Algunos aspectos generales y valóricos”, *Revista Médica de Chile*, Santiago, 2008.
- Ruel, Marie T.; Quisumbing, Agnes R.; Hallman, Kelly, de la Brière, Bénédicte y Coj de Salazar, Nora, *The Guatemala Community Day Care Program. An Example of Effective Urban Programming*, Research Report No. 144, International Food Policy Research Institute, Washington DC., 2006. Disponible en: «<http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/abstract/144/rr144toc.pdf>».

- Sepúlveda, Magdalena, *The nature of obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Intersentia-Hart, 2001.
- Sepúlveda, Magdalena, “La supuesta dicotomía entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”, en: *Protección Internacional de Derechos Humanos. Nuevos Desafíos*, Courtis, C.; Hauser, D. y Rodríguez Garavito, C. (eds.): Editorial Porrúa, México, 2005.
- Sepúlveda, Magdalena, “Select National Jurisdictions: Colombia”, en Langford, M.; *Litigating Economic, Social and Cultural Rights*, Cambridge University Press, 2008.
- Sepúlveda, Magdalena, *Informe de la Relatora Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos al 23vo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Documento A/HRC/23/36*, de 11 marzo 2013a.
- Sepúlveda, Magdalena, *Informe de la Relatora Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos al Sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Documento A/68/293* de 9 de agosto 2013b.
- Sepúlveda, Magdalena y Rodríguez, Garavito, Cesar, “Colombia: la Corte Constitucional y su contribución a la justicia social”, en Langford, Malcolm (ed.), *Teoría y jurisprudencia de los derechos sociales. Tendencias incipientes en el derecho internacional comparado*, Universidad de los Andes y Siglo del Hombre Editores, 2011.
- Tabbush, Constanza, “Gender, Citizenship and New Approaches to Poverty Relief: Conditional Cash Transfer Programmes in Argentina”, en Razavi, Shahra (ed.): *The Gendered Impacts of Liberalization Towards “Embedded Liberalism”?*, Routledge/UNRISD Research in Gender and Development, 2009.
- Tushnet, M., *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton University Press, Princeton, 2007.

- UNIFEM, *Work on Gender-Responsive Budgeting: Overview*. UNIFEM, New York, 2010. Disponible en: «<http://ella.practicalaction.org/node/1156#sthash.dvVv5NlJ.dpuf>».
- Uprimny, Rodrigo y Durán, Juanita, *Justiciabilidad del derecho a la salud en Colombia y equidad*. Ponencia presentada en el taller “Equidad en salud y judicialización del derecho a la salud en Colombia: balance de dos décadas, y perspectivas ante la reforma en marcha” Bogotá, Colombia, 2013. Disponible en: «<http://dds.cepal.org/proteccionsocial/pacto-social/actividades-2013-07-taller-judicializacion-salud-colombia>».
- Uprimny, Rodrigo, “Las transformaciones de la administración de justicia en Colombia”, en Sousa Santos, Boaventura de y García, Mauricio, *El caleidoscopio de la justicia en Colombia*, Siglo del Hombre, 2001.
- Yanes, Pablo (2011), “La pensión ciudadana de adultos mayores en la Ciudad de México: Institucionalización de la universalidad y la no condicionalidad”, en Rico, María Nieves y Valera Maldonado, Carlos (editores), *Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas*, CEPAL, Serie seminarios y conferencias No. 61, Santiago de Chile.



Inteligencia jurídica en expansión

Trabajamos para
mejorar el día a día
del **operador jurídico**

Adéntrese en el universo
de **soluciones jurídicas**

 +52 1 55 65502317

 atencion.tolmex@tirantonline.com.mx

prime.tirant.com/mx/

